

النظام القانوني

للتحول الى القطاع الخاص

الخصخصة

دراسة مقارنة

الدكتور

مهند إبراهيم علي فتدي الجبوري



بسم الله الرحمن الرحيم

النظام القانوني للتحويل
إلى القطاع الخاص

النظام القانوني للتحويل إلى القطاع الخاص "الخصخصة"

دراسة مقارنة

إعداد

مهند إبراهيم علي فندي الجبوري

الطبعة الأولى

2008م



محفوظات جميع الحقوق

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2007 / 4 / 916)

339,52

الجبوري، مهند إبراهيم
النظام القانوني للتحويل إلى القطاع الخاص (الخصخصة) / مهند إبراهيم الجبوري /
- عمان : دار الحامد ، 2007 .
(ص .)
ر. أ. : (2007 / 4 / 916)
الوصفات : / الخصخصة // الإقتصاد المالي // السياسة المالية /

❖ أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية .

* رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر 1009 / 4 / 2007

* (ردمك) ISBN 978-9957-32-324-2



دار الحامد للنشر والتوزيع

شفا بدران - شارع العرب مقابل جامعة العلوم التطبيقية

هاتف: 00962- 5231081 فاكس : 00962- 5235594

ص.ب . (366) الرمز البريدي : (11941) عمان - الأردن

Site : www.daralhamed.net

E-mail : info@daralhamed.net

E-mail : daralhamed@yahoo.com

E-mail : dar_alhamed@hotmail.com

لا يجوز نشر أو اقتباس أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي وجه، أو بأي طريقة أكانت إلكترونية، أم ميكانيكية، أم بالتصوير، أم التسجيل، أم بخلاف ذلك، دون الحصول على إذن المؤلف الخطي، وبخلاف ذلك يتعرض الفاعل للملاحقة القانونية.

بسم الله الرحمن الرحيم

ولله ملك السماوات والأرض وإلى
الله المصير

صدق الله العظيم

سورة النور

الآية (42)

المحتويات

الصفحة	الموضوع
11	المقدمة
	الفصل الأول
17	المفهوم القانوني للتحويل إلى القطاع الخاص
18	المبحث الأول: ماهية التحويل إلى القطاع الخاص
18	المطلب الأول: تعريف التحويل إلى القطاع الخاص
24	المطلب الثاني: مزايا التحويل إلى القطاع الخاص وعيوبه
24	المقصد الأول: مزايا التحويل إلى القطاع الخاص
26	المقصد الثاني: عيوب التحويل إلى القطاع الخاص
34	المطلب الثالث: التمييز بين المفهوم القانوني والمفهوم الاقتصادي للتحويل إلى القطاع الخاص
41	المبحث الثاني: الأساس القانوني للتحويل إلى القطاع الخاص
41	المطلب الأول: الأموال العامة التي يصح تحويلها إلى القطاع الخاص
47	المطلب الثاني: القيود الدستورية على عملية التحويل إلى القطاع الخاص
53	المبحث الثالث: شروط التحويل إلى القطاع الخاص
53	المطلب الأول: إعادة الهيكلة القانونية للمشروعات العامة
67	المطلب الثاني: الهيئات القائمة على عمليات التحويل إلى القطاع الخاص
78	المطلب الثالث: تقييم أسهم الشركات العامة أو أصولها
	الفصل الثاني
91	أساليب التحويل إلى القطاع الخاص
93	المبحث الأول: التحويل إلى القطاع الخاص عن طريق العرض العام للأسهم

93	المطلب الأول: إجراءات العرض العام للأسهم
104	المطلب الثاني: الوفاء بقيمة الأسهم
104	المقصد الأول: استبدال أسهم الشركات العامة بأوراق مالية أخرى
107	المقصد الثاني: بيع الأسهم بالتقسيط أو بتمن مؤجل
110	المبحث الثاني: التحويل إلى القطاع الخاص عن طريق البيع لمستثمر رئيس
111	المطلب الأول: البيع عن طريق التعاقد المباشر أو تقديم العطاءات
111	المقصد الأول: الطرح الخاص للأسهم
117	المقصد الثاني: بيع أصول المشروعات العامة
120	المطلب الثاني: البيع عن طريق المزايدة العلنية
121	المقصد الأول: بيع العقار في المزايدة العلنية
126	المقصد الثاني: بيع الأموال المنقولة في المزايدة العلنية
133	المبحث الثالث: التحويل إلى القطاع الخاص عن طريق البيع للعاملين
134	المطلب الأول: أساليب البيع للعاملين
134	المقصد الأول: البيع المباشر للعاملين
139	المقصد الثاني: تملك العاملين للأسهم بشكل غير مباشر
139	أولاً. شراء الشركة لأسهمها بقصد توزيعها على العاملين
142	ثانياً. شراء اتحادات العاملين للأسهم
144	المطلب الثاني: المزايا المقررة للعاملين عند شراء الأسهم
145	المقصد الأول: تملك العاملين للأسهم بسعر مخفض أو مجاناً
147	المقصد الثاني: تقسيط قيمة الأسهم المباعة للعاملين
150	المبحث الرابع: التحويل إلى القطاع الخاص عن طريق دمج الشركات أو زيادة رأسمالها
151	المطلب الأول: التحويل إلى القطاع الخاص عن طريق الدمج
159	المطلب الثاني: التحويل إلى القطاع الخاص عن طريق زيادة رأس المال

	الفصل الثالث
171	آثار التحويل إلى القطاع الخاص
172	المبحث الأول: أثر التحويل إلى القطاع الخاص في الشركة العامة
173	المطلب الأول: انقضاء الشخصية المعنوية للشركة العامة
179	المطلب الثاني: تغير النظام القانوني الذي تخضع له الشركة العامة
185	المطلب الثالث: تأسيس الشركة الناجمة عن التحويل
186	المقصد الأول: تحديد الشكل القانوني للشركة الناجمة عن التحويل
189	المقصد الثاني: مستلزمات تأسيس الشركة الناجمة عن التحويل
191	المقصد الثالث: إجراءات تأسيس الشركة الناجمة عن التحويل
194	المبحث الثاني: خلافة الشركة الناجمة عن التحويل للشركة العامة
195	المطلب الأول: المقصود بالمشروع الاقتصادي ومدى اعتداد المشرع به
199	المطلب الثاني: الأساس القانوني لخلافة الشركة الناجمة عن التحويل للشركة العامة
206	المطلب الثالث: انتقال عقود الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحويل
207	المقصد الأول: أثر التحويل إلى القطاع الخاص في عقد الإيجار
212	المقصد الثاني: أثر التحويل إلى القطاع الخاص في عقد الترخيص التجاري
218	المبحث الثالث: الرقابة اللاحقة على عمليات التحويل إلى القطاع الخاص
219	المطلب الأول: حق الدولة في إنشاء السهم الخاص
219	المقصد الأول: الحقوق التي يخولها السهم الخاص
225	المقصد الثاني: الطبيعة القانونية للسهم الخاص
229	المطلب الثاني: تشكيل مجموعة المساهمين الثابتة
241	الخاتمة
251	المراجع

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نقدم لموضوع كتابنا مدخل تعريفى بموضوع الكتاب، حيث تتبنى غالبية الدول في الوقت الحاضر برامج للتحويل إلى القطاع الخاص أو ما شاعت تسميته (بالخصخصة). وتختلف الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها من وراء تطبيق هذه العملية، بحسب فلسفة الدولة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية، فقد يكون الهدف من التحويل إلى القطاع الخاص دعم دور القطاع الخاص في ممارسة النشاط الاقتصادي وتعزيزه إلى جانب القطاع الاشتراكي وقد يكون هذا الهدف هو التحويل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي.

ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من عملية التحويل إلى القطاع الخاص أصدرت العديد من الدول تشريعات خاصة تنظم هذه العملية، عن طريق تحديد شروط التحويل وأساليبه، فضلا عن تحديد آثاره القانونية. وتعنى هذه التشريعات بشكل خاص، بتنظيم عملية التحويل إلى القطاع الخاص بوصفها وسيلة لتحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، كلاً أو جزءاً على وفق الأساليب والقواعد المحددة قانوناً، وذلك عن طريق عرض أسهم الشركات العامة للبيع للجمهور، بشروط واحدة أو عن طريق البيع لمستثمر رئيس أو البيع للعاملين، فضلاً عن إمكانية تحويل الشركات العامة عن طريق دمجها بشركات خاصة أو مختلطة، أو بزيادة رأسمالها بأموال يقدمها القطاع الخاص.

وتسعى هذه التشريعات من خلال تنظيم عملية التحويل إلى القطاع الخاص إلى تحقيق الفوائد المرجوة منه، كتوسيع قاعدة الملكية أو تطوير المشروعات العامة عن طرق بيعها لمستثمر رئيس يمتلك المعرفة الفنية والتكنولوجيا، أو يمتلك الخبرة الإدارية، كما تسعى هذه التشريعات إلى تجنب السلبيات التي قد تترتب على عملية التحويل إلى القطاع الخاص، وذلك بوضع القواعد التي تحول دون أن تؤدي هذه

العملية إلى خلق الاحتكارات أو إلى زيادة نسبة البطالة، فضلا عن وضع القواعد التي تكفل استمرار المشروعات العامة بعد تحويلها إلى القطاع الخاص.

أما في العراق فيعد ما ورد في التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي، أول بادرة تشير إلى تبني فكرة التحول إلى القطاع الخاص إذ ورد فيه انه (في ميدان الصناعة أنشأت الدولة مصانع كان يمكن أن يتولاها القطاع الخاص بكفاءة افضل ويوفر على الدولة الكثير من الجهود والأموال)، وبالرغم من ذلك فإن الواقع العملي يشير إلى أن عمليات التحول إلى القطاع الخاص في العراق لم تبدأ بشكل فعلي إلا ابتداء من عام 1987. إذ عمدت الدولة في هذا العام إلى بيع العديد من المنشآت السياحية، والمصانع، وذلك بالاستناد إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بهذا الشأن، وقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.

ثم اصدر المشرع العراقي قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والذي نظم عملية تحول الشركات العامة في المواد (35-38).

ويحظى موضوع التحول إلى القطاع الخاص بأهمية كبيرة، وذلك لارتباطه باقتصاد الدولة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

ويعد التحول إلى القطاع الخاص، من ابرز التغيرات التي اتسمت بها اقتصاديات العالم المتقدم والعالم النامي خلال العقدين الأخيرين، ووفقا لإحصاءات البنك الدولي للأعمار والتنمية، بلغ عدد الدول التي بدأت في تطبيق برامج التحول إلى القطاع الخاص حتى أوائل التسعينات، أكثر من مائة دولة⁽¹⁾.

وقد برزت أهمية هذا الموضوع في العراق في الآونة الأخيرة بشكل واضح، وذلك بسبب توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي، فظهرت العديد من الدراسات الاقتصادية التي تدعو إلى تبني هذه السياسة الاقتصادية، ولعل أهم هذه الدراسات تلك التي عرضت على مجلس الوزراء في جلسته الثانية

(1) د. منير إبراهيم هندي، التجربة المصرية في الخصخصة، بحث مقدم إلى ندوة التحول إلى القطاع الخاص، تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 1996، ص 139.

والعشرين لعام (2000)، والتي تتعلق بتنشيط القطاع الصناعي الخاص، إذ تركزت المناقشة في هذه الجلسة على فكرتين رئيسيتين تضمنتها هذه الدراسة، تتمثل الأولى بقيام القطاع الصناعي الخاص، بإنشاء مشاريع صناعية بمشاركة الدولة أو من دونها لدعم مشاريع أخرى مملوكة للدولة، أما الثانية فتتمثل بإنشاء الدولة لمشاريع صناعية يديرها موظفو الدولة، تتولى دعم المشاريع العامة أو الخاصة القائمة على أن تعمل هذه المشاريع على وفق قواعد العمل في القطاع الخاص، وتتمتع بالامتيازات الممنوحة له، وتتحول بموجب آلية محددة بعد مدة من الزمن إلى القطاع الخاص.

ويقينا أن تحديد قواعد وإجراءات التحول إلى القطاع الخاص وآثاره القانونية من شأنه أن يبين للقائمين على هذه العملية الأساليب أو الوسائل القانونية التي يمكن اتباعها في تنفيذ عملية التحول إلى القطاع الخاص، على نحو ينسجم مع الأهداف المراد تحقيقها من خلال تطبيق هذه السياسة الاقتصادية. ومن أجل ذلك كله، ارتأينا أن نبث في هذا الموضوع لا سيما وأنه لم يحظ بأي اهتمام من قبل الفقهاء والباحثين في مجال القانون في العراق.

وللتحول إلى القطاع الخاص جوانب قانونية وأخرى اقتصادية وإدارية واجتماعية وتنصب دراستنا في هذا البحث على الجوانب القانونية لهذه العملية، ودون أن نفصل بين هذا الموضوع وغايته الاقتصادية بوصفه وسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية.

وستقتصر دراستنا هذه على البحث في التحول إلى القطاع الخاص مفهومه (الضيق) الذي يتناول أساليب تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، دون أن نبث في الأساليب الأخرى التي تدعم أو تعزز دور القطاع الخاص في ممارسة النشاط الاقتصادي التي تدخل ضمن المفهوم الواسع للتحول إلى القطاع الخاص والذي تتبناه الدراسات الاقتصادية الحديثة.

واعتمدنا في هذا البحث على المنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين التشريع العراقي من جهة والتشريع الفرنسي والمغربي والمصري من جهة أخرى، غير أن هذه المقارنة لم تكن مكتملة في جميع جوانب البحث، وذلك لأن كلا من المشرع الفرنسي والمغربي قد أصدر تشريعا خاصا بعملية التحول إلى القطاع الخاص، في

حين أجاز كل من المشرع العراقي والمصري هذه العملية دون أن يخضعها لتشريع واحدٍ مستقل. فضلا عما تقدم، ارتأينا الإشارة إلى موقف بعض القوانين المقارنة الأخرى، وذلك لما لهذه القوانين من خصوصية في معالجة بعض جوانب البحث ولإفادة قدر الإمكان من تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بموضوع البحث.

ويهدف هذا الكتاب إلى تقييم تجربة العراق في التحول إلى القطاع الخاص من الوجهة القانونية، والتوصل إلى تحديد المرتكزات الأساسية للنظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص عن طريق البحث في الشروط القانونية التي يلزم توافرها لنجاح هذه العملية، فضلا عن البحث في الأساليب التي يمكن اتباعها في عملية التحول وتحديد الآثار القانونية التي تنجم عن تطبيق هذه الأساليب، وعلى نحوٍ يضمن الحفاظ على حقوق الدولة واستمرار المشروعات العامة بعد تحويلها إلى القطاع الخاص من أجل دعمها وتطويرها.

الفصل الأول
المفهوم القانوني للتحويل إلى القطاع
الخاص

الفصل الأول

المفهوم القانوني للتحويل إلى القطاع الخاص

يعد التحويل إلى القطاع الخاص، من ضمن السياسات الاقتصادية الحديثة التي تنتهجها الدولة من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، ولا شك في أن تبني مثل هذه السياسة الاقتصادية يستلزم وجود تنظيم قانوني لهذه العملية، يبين أبعادها ووسائل تحقيقها.

ولبيان المفهوم القانوني للتحويل إلى القطاع الخاص، لابد من البحث في ماهية التحويل إلى القطاع الخاص، بوصفه سياسة اقتصادية ذات إطار قانوني، ولابد أيضا من البحث في الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه العملية من أجل تحديد مدى اتفاق هذه السياسة مع القوانين الوضعية التي تعكس فلسفة الدولة الاقتصادية والسياسية.

وفضلا عن ذلك، فإن للتحويل إلى القطاع الخاص شروط قانونية ينبغي توافرها وذلك لكي تتحقق الأهداف المرجوة من هذه العملية، لذلك ارتأينا تقسيم هذا الفصل على ثلاثة مباحث وكما يأتي:

المبحث الأول: ماهية التحويل إلى القطاع الخاص.

المبحث الثاني: الأساس القانوني للتحويل إلى القطاع الخاص.

المبحث الثالث: شروط التحويل إلى القطاع الخاص.

المبحث الأول ماهية التحول إلى القطاع الخاص

إن بيان المقصود بالتحول إلى القطاع الخاص، يتطلب منا ابتداء تعريفه من أجل تحديد معناه وتمييزه مما قد يشته به من أنظمة أخرى. كما يتطلب بيان مزايا التحول إلى القطاع الخاص وعيوبه أيضاً، وذلك من خلال عرض حجج وآراء المؤيدين والمعارضين لهذه العملية، فضلاً عن بحث موقف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة، بشأن معالجة الآثار السلبية التي قد تنجم عن التحول إلى القطاع الخاص. كذلك يجب أن نميز بين المفهوم القانوني للتحول إلى القطاع الخاص وبين مفهومه الاقتصادي. ومن أجل ذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وكما يأتي:

المطلب الأول: تعريف التحول إلى القطاع الخاص.

المطلب الثاني: مزايا التحول إلى القطاع الخاص وعيوبه.

المطلب الثالث: التمييز بين المفهوم القانوني والمفهوم الاقتصادي للتحول إلى القطاع الخاص.

المطلب الأول تعريف التحول إلى القطاع الخاص

يستخدم الباحثون عدة مصطلحات للدلالة على عملية التحول إلى القطاع الخاص "Privatization"⁽¹⁾ كالتخصيص والتخصية والاستخصاص والخصوصية وكذلك

(¹) إن كلمة Privatization في اللغة الإنكليزية، هي اسم مشتق من الصفة Privat ومعناها "خاص" لذلك نلاحظ أن معظم الترجمات العربية لهذا الاصطلاح مشتقة من كلمة خاص.

الخصخصة⁽¹⁾، ولعل هذا الأخير هو أكثر الاصطلاحات شيوعاً في الاستخدام⁽²⁾. كذلك، استخدمت كلمات وتعابير أخرى للدلالة على هذه العملية إذ يستخدم البعض⁽³⁾ كلمة "الاهلنة" للدلالة على هذه العملية. كما أن بعض الدول استخدمت مصطلحات أخرى للدلالة على هذه العملية فعلى سبيل المثال استخدمت تونس تعبير "خروج الدولة من الاقتصاد" و"التفويت" واستخدمت شيلي وسيرلانكا تعبير "الرأسمالية الشعبية" واستخدمت كوستريكا وجاميكا تعبير "الديمقراطية الاقتصادية"⁽⁴⁾. وبسبب تعدد هذه التعابير والمصطلحات نعتقد مع البعض⁽⁵⁾ أن تعبير "التحول إلى القطاع الخاص" جدير بالتأييد، وذلك تجنباً للخلاف في استعمال تعابير غير متفق عليها

(¹) انظر في استخدام هذه المصطلحات: عاطف الدغمي، استراتيجية الخصخصة في البلدان النامية، مجلة المهندس الأردني، العدد (67) السنة (34)، آب - 1999، ص78، كذلك، غرفة تجارة وصناعة البحرين، التخصيص في دولة البحرين الواقع الحالي والآفاق المستقبلية، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة التوجهات المستقبلية للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي، المنامة، البحرين، 1995، ص2.

(²) ولعل من المناسب أن نذكر في هذا المجال، ان مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية اقر استعمال كلمة "خصخصة" دون غيرها من الكلمات، انظر: محمد محمود الإمام، محددات الأداء الاقتصادي لكل من القطاعين العام والخاص في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية والصندوق العربي للإعانة الاقتصادي والاجتماعي، بيروت، 1990، ص103.

(³) عبد المنعم السيد علي، تجربة العراق مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة، بحث مقدم إلى ندوة القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية والصندوق العربي للإعانة الاقتصادي والاجتماعي، بيروت، 1990، ص349.

(⁴) إدريس بن علي، التجربة المغربية في الخصخصة، بحث مقدم إلى ندوة التحول إلى القطاع الخاص، تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إدارة البحوث والدراسات، القاهرة، 1996، ص45.

(⁵) د. ربيع صادق دحلان، الإتجاهات المعاصرة في إدارة المشروعات العامة، التحول إلى القطاع الخاص، دار البلاد للطباعة والنشر - جدة، ط1، 1988، كذلك د. محمد أمين عودة، مفاهيم

أما عن تعريف التحول إلى القطاع الخاص اصطلاحاً فإنه يثير صعوبات جمة مردها تطور المفهوم الاقتصادي لهذه العملية، من حيث تعدد أشكالها أو أساليبها فإذا كان التحول إلى القطاع الخاص عند نشأته يعني نقل ملكية المشروعات

العامة إلى القطاع الخاص، فإن هذا المفهوم تطور في الوقت الحاضر، وبات يشمل فضلاً عن نقل الملكية نقل إدارة المشروعات العامة إلى القطاع الخاص عن طريق عقود الإيجار وعقود الإدارة، فضلاً عن اعتبار إدارة المشروعات العامة على وفق مبادئ وأساليب القطاع الخاص، من قبل الدولة نفسها من ضمن أساليب التحول إلى القطاع الخاص⁽¹⁾.

وعلى أية حال فلقد عرف⁽²⁾ التحول إلى القطاع الخاص بأنه "تقليص لدور الدولة في الاقتصاد"، ومن الواضح إن هذا التعريف يركز على حقيقة إن التحول إلى القطاع الخاص هو وسيلة لدعم القطاع الخاص وتقليص دور القطاع الاشتراكي (العام)⁽³⁾.

ويختلف مدى هذا الأثر باختلاف الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه من التحول إلى القطاع الخاص، وفيما إذا كان هذا الهدف يتمثل بالقضاء على القطاع الاشتراكي أو تشجيع القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين القطاع الاشتراكي.

و صور وأشكال التحول إلى القطاع الخاص، بحث مقدم إلى ندوة التوجهات المستقبلية للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، 1995.

(¹) وارن ريدل، خبرات عالمية في تطبيق برامج الخصخصة، بحث مقدم إلى ندوة التوجهات المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، 1995، ص 6.

(²) عاطف الدغمي، المرجع السابق، ص 78.

(³) طبقاً لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (373) الصادر في 1977/3/28، حل مصطلح (القطاع الاشتراكي) محل مصطلح (القطاع العام) على أن يدخل ضمن مفهوم القطاع الاشتراكي، القطاع التعاوني وجميع النشاطات التي تتولى الدولة تمويلها وإدارتها، الوقائع العراقية، العدد (2580) في 1977/4/4.

غير أن ما يلاحظ على هذا التعريف، انه لم يبين وسائل أو صور التحول إلى القطاع الخاص، الأمر الذي حددته تعاريف أخرى، فلقد عرف⁽¹⁾ أيضا بأنه " إدارة المنشأة على أساس تجاري من خلال نقل ملكيتها كليا أو جزئيا للقطاع الخاص، أو بتأجير خدمات إدارة محترفة تضطلع بمهمة تسير المنشأة على هذا الطريق"، كما عرف⁽²⁾ بأنه "نقل ملكية أو إدارة المؤسسة العامة إلى القطاع الخاص، سواء اتخذ ذلك شكل البيع المباشر أو التمليك أو المبادلة بالديون أو من خلال عقود الإدارة أو التأجير".

ويلاحظ على التعريف الأول أنه، قد بين ان الهدف من التحول إلى القطاع الخاص هو " إدارة المنشأة على أساس تجاري " وانه لا يهدف إلى مجرد نقل ملكية المشروعات العامة أو إدارتها إلى القطاع الخاص، كذلك فلقد بينت هذه التعاريف أساليب التحول إلى القطاع الخاص، من حيث انه قد يكون عن طريق نقل الملكية، وهو بهذا المفهوم يكون على النقيض من مفهوم "التأميم" الذي يعني نقل الملكية الخاصة إلى القطاع العام⁽³⁾، أو عن طريق نقل إدارة المشروعات العامة إلى القطاع الخاص.

كذلك فلقد عرف⁽⁴⁾ التحول إلى القطاع الخاص بأنه "مجموعة من القوانين والأنظمة والإجراءات التي تتولى نقل ملكية أو إدارة بعض أصول وحدات القطاع

(¹) د. منير إبراهيم هندي، أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة - خلاصة الخبرات العالمية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية - إدارة البحوث والدراسات، القاهرة، 1995، ص153

(²) غسان القلعاوي، القطاع العام إلى أين؟، دار المكتبي، دمشق، ط1، 1995، ص107، كذلك محمد صبري بن آونج، الخصخصة، تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، الأردن، ط1، 2000، ص24.

(³) المحامي، علاء خليفة، التخاصية - نظرة شاملة، مجلة المهندس الأردني، العدد 67، السنة 34، آب، 1999، ص70.

(⁴) عبد الحسين وداي العطية، الخصخصة "Privatization" في البلدان النامية: إيجابيتها وسلبيتها، مجلة دراسات، المجلد 45، العدد (1)، كانون الثاني - 1998، ص79.

العام إلى القطاع الخاص، أفرادا وشركات كما عرف⁽¹⁾ أيضا بأنه " قيام الدولة بتحويل ثلاثة أنواع من الحقوق للقطاع الخاص، وهي حق الملكية، وحق ممارسة النشاط وحق التطوير، واستنادا إلى شكل التحويل المتبع يكتسب القطاع الخاص أيا من هذه الحقوق أو جميعها "

ويلاحظ على هذين التعريفين، أن الأول منهما يجسد الجانب القانوني للتحويل إلى القطاع الخاص، من حيث انه يجب ان يتم وفقا للشروط والأوضاع القانونية، أما التعريف الثاني، فلقد ركز على الحقوق التي تنتقل إلى القطاع الخاص جراء عملية التحويل ودون تعداد لأشكال التحويل وأساليبه. فوفقا لهذا التعريف يمكن للقطاع الخاص أن يمتلك الأموال التي كانت مملوكة ملكية عامة، أو أن يكون له الحق في إدارة هذه الأموال بموجب عقود الإيجار أو الإدارة مثلا، كما ويمكن للقطاع الخاص ان يقوم بتطوير بعض المشروعات كما هو عليه الحال مثلا في عقود الامتياز المسماة (B.O.T) أي بناء تشغيل نقل ملكية، فبموجب هذه العقود ينتقل حق تشغيل أو استغلال وتطوير المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، ثم تؤول ملكية هذه المشاريع مرة أخرى إلى الدولة⁽²⁾.

ويتضح من خلال التعاريف المتقدمة، إن تعريف التحويل إلى القطاع الخاص يجب أن يشتمل على العناصر الأساسية الآتية:

1. أن تكون هناك قوانين تسمح بتبني مثل هذه السياسة الاقتصادية، وتبين كذلك أساليب هذا التحويل وآثاره، ويظهر ذلك بشكل خاص في الدول الاشتراكية التي تضع بعض القيود على الملكية الخاصة، والتي يكون القطاع الاشتراكي فيها هو القائد والموجه للاقتصاد.
2. أن ينصب التحويل إلى القطاع الخاص على النشاطات الاقتصادية للدولة، ومن ثم فإن قيام القطاع الخاص ببعض المهام غير الاقتصادية والتي تقوم

(¹) (UNCTAD) United nation conference on trade and development comparative Experiences with privatization-policy Insights and lessons learned, united nation, New York and Geneva , 1995, P. 63.

(²) (UNCTAD), OP. Cit., P. 64.

- بها الدولة عادة، لا يعد في حقيقة الأمر من قبيل عمليات التحويل إلى القطاع الخاص.
3. إن التحويل إلى القطاع الخاص، إنما يتحقق من خلال نقل ملكية أو إدارة المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، والتي يكون لها قدر من الأهمية الاقتصادية، إذ لا يعد مجرد نقل ملكية بعض الأموال العامة التي ليس لها قيمة اقتصادية كبيرة "كالسيارات" مثلاً أو مجرد استئجار الأفراد أو الشركات لبعض الأموال العامة، من قبيل عمليات التحويل إلى القطاع الخاص. ذلك إن هذه العملية هي بالأساس عملية اقتصادية يستلزم لتحقيقها توافر أدوات قانونية واقتصادية فعالة، وتتمثل هذه الأدوات بالمشروعات العامة بشكل أساسي.
4. أن يتم التحويل إلى القطاع الخاص بالوسائل التي يحددها القانون، إذ أنه قد يتم عن طريق وسائل تؤدي إلى نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص، أو دمج المشروعات العامة بأخرى خاصة أو زيادة رأسمالها بأموال يقدمها القطاع الخاص، وهذه الوسائل تمثل المفهوم التقليدي للتحويل إلى القطاع الخاص. كذلك قد يتم التحويل طبقاً للمفهوم الاقتصادي الحديث لهذه العملية عن طريق وسائل لا تؤدي إلى انتقال الملكية كعقود الإيجار وعقود الإدارة، أو السماح للقطاع الخاص بالقيام بنشاطات اقتصادية كانت حكراً على القطاع الاشتراكي. بيد أن الأساليب التقليدية للتحويل إلى القطاع الخاص، تعد أكثر الأساليب فاعلية، وهي التي تتناولها التشريعات الخاصة بالتحويل إلى القطاع الخاص بالتنظيم دون الوسائل الأخرى التي يمكن تطبيقها وفقاً للقواعد العامة الواردة في القوانين الأخرى، لذلك فإن تعريف التحويل إلى القطاع الخاص، والذي سنتبناه في دراستنا هذه، يتناول الأساليب الأولى دون الثانية، ومن ثم يمكن أن نعرف التحويل إلى القطاع الخاص بأنه "تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص كلاً أو جزءاً، عن طريق بيع أسهمها أو أصولها أو دمجها بشركات خاصة أو مختلطة، أو زيادة رأسمالها بأموال مقدمة من القطاع الخاص".

المطلب الثاني مزايا التحول إلى القطاع الخاص وعيوبه

يورد الداعون للتحول إلى القطاع الخاص، والمنادون بضرورة اللجوء إليه العديد من الحجج والمسوغات، والتي تنطلق في معظمها من الافتراض بأن القطاع الخاص بطبيعته أكفأ من الدولة لمؤسسات الإنتاج والخدمات ويتعلق البعض الآخر منها بتجربة القطاع العام في ممارسة النشاط الاقتصادي وما اعتراها من سلبيات وما شابها من قصور. ومن جهة أخرى، هناك من يعارض فكرة التحول إلى القطاع الخاص، وينادي بضرورة استمرار القطاع العام في أداء دوره التنموي في الاقتصاد. ويقدم هؤلاء بدورهم العديد من الحجج التي تؤيد مواقفهم وتدعم وجهات نظرهم. وفيما يأتي، نستعرض حجج ومسوغات كل من المؤيدين والمعارضين للتحول إلى القطاع الخاص، وذلك في المقصدين الآتيين.

المقصد الأول: مزايا التحول إلى القطاع الخاص

تتلخص حجج المؤيدين لسياسة التحول إلى القطاع الخاص، في انه يمكن أن يرتب النتائج الآتية:
1. تخفيض الديون الخارجية للبلد، إذ يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال مبادلة هذه الديون بأسهم المشروعات العامة، التي يتم نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وقد اتبع هذا الأسلوب في العديد من الدول، ولا سيما في أمريكا اللاتينية⁽¹⁾.

(¹) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوا (1995)، الجزء الثاني، المخصصة في منطقة الاسكوا، الأمم المتحدة، نيويورك، 1997 ص4.

2. تركيز الدولة على وظائفها الأساسية، التي لا يمكن أن توكل إلى القطاع الخاص، وأداء هذه الوظائف بفاعلية وكفاءة أكبر، وذلك نتيجة انسحابها من بعض الأنشطة الاقتصادية وتحويلها إلى القطاع الخاص⁽¹⁾.
3. توسيع قاعدة الملكية وتنويعها، وذلك بان يتاح لصغار المستثمرين والموظفين أو العاملين في المشروعات العامة التي يتم نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، فرصة المشاركة في ملكية أسهم هذه المشروعات⁽²⁾، وهذه الميزة تفترض منح التسهيلات والدعم المالي للعاملين وصغار المستثمرين، كما وتفترض ان يتم نقل ملكية المشروعات العامة عن طريق بيع الأسهم وليس عن طريق بيع الأصول.
4. تقليل الأعباء الملقاة على عاتق الميزانية العامة، ولا يمكن التخلص من هذه الأعباء، إلا من خلال تخلص الدولة من بعض الأنشطة العامة، وجعل القطاع الخاص يقوم بها، فتحويل بعض المشروعات العامة ولا سيما تلك التي تعمل بخسارة، يؤدي إلى تخفيض عجز الميزانية، فضلا عن العائدات التي تتحصل من ثمن بيع هذه المؤسسات، التي تفضي- إلى زيادة التدفق النقدي الداخل إلى خزانة الدولة⁽³⁾.
5. المساعدة في إعادة توزيع العاملين في المشروعات بحسب حاجتها الحقيقية لليد العاملة، وهما يسمح بإعادة التوازن بين إنتاجية العامل ومستوى الأجور⁽⁴⁾.

(¹) د. احمد صقر عاشور، سياسة خصخصة المشروعات العامة - ركائزها ومقومات نجاحها، ندوة التحول إلى القطاع الخاص، تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إدارة البحوث والدراسات، القاهرة، 1995، ص13.

(²) د. احمد صقر عاشور، المرجع السابق، ص13.

(³) Ronald Laskiue, Les Privatisations Enjeux stardegiques et opprtunites boursieres, Les Editions d' organisation, Paris, 1993, P. 10.

(⁴) Econmic and social commission for western Asia "ESCWA" ,Role of financial markets in privatization in the ESCWA region, united nation , New York , 1997, P. 8.

6. تفعيل دور المنافسة الحرة بين المشاريع المتماثلة، وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف نتيجة زيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع والخدمات⁽¹⁾.
7. تطوير الأسواق المالية المحلية، ذلك لان نقل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص غالباً ما يتم من خلال بيع الأسهم عن طريق الأسواق المالية، مما يؤدي إلى تنشيطها⁽²⁾.

المقصد الثاني: عيوب التحول إلى القطاع الخاص

بالرغم من مزايا التحول إلى القطاع الخاص المذكورة آنفاً، فإن هناك من يعارض تطبيق هذه السياسة ويوجه إليها النقد، بسبب السلبيات التي تنجم عنها، والتي تتمثل بما يأتي:

1. فتح المجال أمام القطاع الخاص الدولي للحركة كيفما يشاء، مما يجعل السيطرة الأجنبية على المشروعات العامة التي يتم تحويلها غالبية على السيطرة الوطنية. فالهدف من التحول إلى القطاع الخاص، وفقاً لهذا الرأي هو تقليص مساحة القطاع العام في إدارة الشؤون الاقتصادية وتفكيك وحداته ثم تصفيته لفسح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والشركات غير الوطنية ولاسيما الشركات المتعددة الجنسية لممارسة دورها المرسوم دون تدخل من الدولة، وذلك على أساس إن التحول إلى القطاع الخاص هو التمهيد والخطوة الضرورية لتطبيق العولمة الاقتصادية⁽³⁾.

⁽¹⁾ عاطف الدغمي، المرجع السابق، ص79. كذلك د. محمود حسين الراوي، الآثار الاقتصادية للخصخصة في ظل العولمة مع إشارة إلى تجربة الأردن، بحث مقدم إلى المؤتمر الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء الأهلية " العولمة وأبعادها الاقتصادية " 8-10 آب 2000، تحرير د. فليح حسن خلف، ط1، 2001، ص507.

⁽²⁾ عبد الحسين وداي العطية، المرجع السابق، ص80.

⁽³⁾ د. حميد الجميلي، حلقة نقاشية، استشراف مستقبل الاقتصاد العربي في ظل المتغيرات الدولية، بيت الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، تموز 1997، ص32.

2. أن نقل ملكية المشروعات العامة أو إدارتها إلى القطاع الخاص قد يؤدي إلى زيادة البطالة بسبب الاستغناء عن العمالة الزائدة في المشروعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص⁽¹⁾.
3. إن الدافع وراء التحول إلى القطاع الخاص، قد لا يكون دافعا ذاتيا بسبب الحاجة إليه، وإنما بسبب هيمنة المؤسسات التمويلية الدولية كوكالة المعونة الدولية (SAIDU) وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للأعمار والتنمية، إذ تفرض هاتان المؤسساتان شروطا ضمن برامج (التكييف والتصحيح الهيكلي) التي يدعمانها وهذه الشروط تتعلق بتحسين مناخ الاستثمارات العامة وتحسين أداء المشروعات العامة، وتقليص دور الدولة من خلال تخفيض حجم القطاع العام (أي التحول إلى القطاع الخاص).
- وتكون موافقة الدولة على هذه البرامج التي يفرضها الصندوق والبنك الدوليان، من خلال التوقيع على ما يسمى بخطاب النوايا (Letter of Intent) وتوقيع الدولة على هذا الخطاب يمكنها من الحصول على قروض ومنح من الدول المانحة وسوق راس المال العالمي⁽²⁾، وهذا الاتفاق المعقود بين الدول والمؤسسات التمويلية الدولية، ما هو من الناحية القانونية إلا وعد بالتعاقد ويكون ملزما لطرفيه.
4. بيع الأسهم المملوكة للدولة في بعض المشروعات العامة بأسعار متدنية في أسواق الأوراق المالية، ذلك أن الأسواق المالية في الدول النامية يسهل التأثير فيها باتجاه الانخفاض قبل إتمام عملية بيع الأسهم المملوكة للدولة⁽³⁾.

⁽¹⁾ د. إبراهيم محمد الحمود، الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة، دراسة تحليلية نقدية مقارنة، مجلة الحقوق، السنة الثانية والعشرون، العدد الثاني، 1998، ص 39. كذلك:

- A Ysıt Tansel, Worker Displaced due to Privatization in Turkey, Working Paper-Series, No. 9719, P. 4.

⁽²⁾ الضو نعيم احمد، الاقتصاد القطري ومنهج الخصخصة، ندوة توجهات وآفاق الخصخصة في قطر، الدوحة 7/6 نيسان، 1996، غرفة تجارة وصناعة قطر، ط 2، 1997-1998، ص 283.

⁽³⁾ احمد النمري، الخصخصة مالها وما عليها، مجلة المهندس الأردني، العدد (67)، السنة (34)، آب 1999، ص 77.

5. مطالبة المالكين وأصحاب الشركات التي يتم نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص بحقوقهم في هذه الأموال، التي سبق للحكومات أن قامت بتأميمها، فضلا عن مطالبتهم بالتعويض عن المكاسب التي كان يمكن تحقيقها خلال المدة ما بين التأميم والتحول إلى القطاع الخاص⁽¹⁾.

والحقيقة أن تحقيق المزايا المرجوة من التحول إلى القطاع الخاص وتجنب السلبيات التي قد تنجم عنه، يرتبط إلى حد كبير بالهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه من وراء تطبيق سياسة التحول إلى القطاع الخاص، إذ يجب أن يكون الهدف من هذه السياسة الاقتصادية هو تشجيع القطاع الخاص ودعمه وتنسيق التعاون بينه وبين القطاع الاشتراكي العام بحيث لا يؤدي إلى القضاء على وحدات القطاع الاشتراكي بشكل نهائي⁽²⁾.

وبهذا الصدد يلاحظ البعض⁽³⁾ إن هناك ثلاثة اتجاهات في تحديد الغاية من التحول إلى القطاع الخاص، وهي:

1. توسيع قاعدة الملكية الخاصة، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه بحيث يكون له دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية.
2. التخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع العام، وذلك من خلال تحويلها إلى القطاع الخاص، لكي تحقق أرباحا أكبر، وتزيد قدراتها الاقتصادية بشكل عام وقد طبقت بريطانيا وأستراليا هذا المفهوم.

(¹) د. ميرغني عبد العال حمور، الخصخصة، المفاهيم والتجارب والدروس، ندوة توجهات وآفاق الخصخصة بدولة قطر، الدوحة 7/6 نيسان 1996، غرفة صناعة وتجارة قطر، ط2، 1997-1998، ص83، حيث يشير إلى أن هذه المشكلة واجهت بولندا أبان عمليات التحول إلى القطاع الخاص التي جرت فيها.

(²) علاء خليفة، المرجع السابق، ص70.

(³) د. احمد ماهر، دليل المدير في الخصخصة، مركز التنمية الإدارية، كلية التجارة - جامعة الإسكندرية، بدون تاريخ نشر، ص22-23. كذلك د. محمود حسين الوادي، المرجع السابق، ص506.

3. التلخص من الاقتصاد الاشتراكي، وذلك بوصف الاشتراكية فلسفة سياسية واقتصادية تنتهجها الدولة، ويتم ذلك من خلال التحول إلى اقتصاد السوق وتبني سياسة التحرر الاقتصادي "Liberalization"، وقد أتت دول أوروبا الشرقية هذا المفهوم. كما ويؤكد مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة على هذا المفهوم للتحول إلى القطاع الخاص⁽¹⁾.

ونعتقد إن التحول إلى القطاع الخاص في العراق، يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص ودعمه إلى جانب القطاع الاشتراكي ودون أن يكون الهدف هو التحول إلى اقتصاد السوق أو التحرر الاقتصادي وهذا ما ينسجم مع فلسفة الدولة الاشتراكية ونصوص الدستور العراقي⁽²⁾، كما إنه ينسجم مع ما قرره قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 الذي جعل دور القطاعين المختلط والخاص مكملًا لنشاط القطاع الاشتراكي⁽³⁾، كما ويمكن أن يكون الهدف من عملية التحول هو التخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع الاشتراكي، إذ ان المادة (14) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 تنص على انه " إذا بلغت خسارة الشركة نسبة (50%) من رأسمالها الاسمي فعلى الوزارة إعداد تقويم اقتصادي لها يقدم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الشركة أو تصفيتها".

ونرى إن الكثير من سلبيات التحول إلى القطاع الخاص يمكن تلافيها من خلال وضع القيود أو الضوابط القانونية التي من شأنها إن تحد من هذه الآثار السلبية إلى حد كبير.

(¹) UNCTAD, Op. Cit., P. 43.

إذ يشير هذا التقرير إلى ضرورة تحقيق التحرر الاقتصادي من خلال تعديل التشريعات ورفع القيود عن الاستثمارات الأجنبية وتحرير الأسعار وتعديل القوانين المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاستيراد والتصدير وحماية المنافسة وكذلك وضع قواعد قانونية تنظم عمليات صرف العملات الأجنبية وغير ذلك.

(²) وسنبين موقف الدستور العراقي عند بحثنا لأساس التحول إلى القطاع الخاص.

(³) الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.

فإذا كان من الممكن ان يؤدي التحول إلى القطاع الخاص إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص الدولي، وبالذات الشركات الأجنبية المتعددة الجنسية فإنه يمكن تلافي ذلك من خلال وضع أسس قانونية واضحة تحدد نوعية المشروعات التي سيتم تحويلها إلى القطاع الخاص بحيث تستبعد المشاريع الاستراتيجية، كما وتحدد أيضا نوعية المشروعات التي يسمح فيها بدخول مستثمرين أجانب، وتلك التي ستكون قاصرة على الوطنيين ونسبة الملكية المسموح فيها لكل فئة منها في كل نوع من أنواع المشروعات، ذلك لان المستثمر الأجنبي قد يكون هو المستثمر المثالي في بعض المشروعات التي تتطلب المعرفة الفنية والتكنولوجية فضلا عن القدرة المالية التي تضمن تشغيل المشروع بكفاءة وفاعلية⁽¹⁾. وبالرغم من ذلك فإن قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997، قصر حق العضوية في الشركات العراقية على العراقي فقط، كما انه نص على أن يعامل مواطنو الأقطار العربية المقيمون في أقطار الوطن العربي معاملة العراقي فيما يخص اكتساب العضوية في الشركات العراقية المساهمة والمحدودة⁽²⁾.

غير إن قرار مجلس قيادة الثورة رقم (23) الصادر في 1994/3/7، قد نص على انه:
" 1. يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي أو استثمار أمواله في الشركات داخل العراق، وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار من أي وجه كان⁽³⁾."
وإذا كان من شأن هذا الحكم أن يمنع السيطرة الأجنبية على الشركات العراقية فإنه ومن جهة أخرى قد يفوت على هذه الشركات فرصة التطور من خلال البيع لشريك استراتيجي هو "أجنبي" على الأغلب ويمتلك المعرفة الفنية والتكنولوجية.

(¹) د. منير إبراهيم هندي، خصخصة المشروعات العامة، المرجع السابق، ص 12.

(²) المادة (12) من قانون الشركات العراقي.

(³) الوقائع العراقية العدد (3501) في 1994/3/14.

وحرصا من المشرع الفرنسي على الحد من السيطرة الأجنبية على الشركات العامة التي يتم نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، فقد حدد نسبة الأسهم التي تؤول إلى الأجانب من الأشخاص الطبيعية والمعنوية بمناسبة " التحويل إلى القطاع الخاص" بما لا يزيد على (20%) من رأسمال الشركة ويجوز لوزير الاقتصاد تخفيض هذه النسبة إذا اقتضى الأمر غير أن هذا الحكم قد الغي فيما بعد من قبل المشرع الفرنسي⁽¹⁾. كما نصت المادة (6) من قانون التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص المغربي رقم (3989) الصادر في 1990/4/18 على تخويل الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل " إن يحدد إذا اقتضت ذلك حماية المصالح الوطنية المبلغ الأقصى للأسهم والحصص التي يمكن أن يشتريها أشخاص طبيعية أجانب أو أشخاص معنوية أجنبية أو خاضعة لرقابة أجنبية الضوابط التي من شأنها أن تحول دون انتقال مساهمات أو حصص فيما بعد إلى أيدي أجنبية"⁽²⁾.

وفضلا عن ذلك فإنه إذا كان ما يؤخذ على التحويل إلى القطاع الخاص انه قد يؤدي إلى تركيز الثروة في يد عدد قليل من الرأسماليين فإنه من الممكن تجنب هذه النتيجة أيضا من خلال التحويل إلى القطاع الخاص عن طريق بيع المشاريع العامة كأسهم وليس كأصول ووضع حد أعلى لعدد الأسهم التي يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يملكها بحيث لا يصار إلى بيع الشركات العامة كأصول إلا في حالات خاصة، ومنها عدم إمكانية البيع عن طريق أسواق الأوراق المالية، وذلك بسبب الخسائر التي قد تصاب بها هذه الشركات أو المشروعات قبل عملية البيع، أو أن يكون

⁽¹⁾ انظر المادة (10-1) والتي ألغيت بموجب القانون المرقم 96-314 والمؤرخ في 96/4/12، وانظر:

Alice pezard, L' experience Francaise en matiere de privatisations.

محاضرة أقيمت على طلبة الدراسات العليا في كلية القانون - جامعة الموصل، 1999، ص4. (غير منشورة) ويلاحظ أن القانون المصري لا يتضمن مثل هذا الحكم.

⁽²⁾ وانظر نص هذا القانون في الموسوعة المغربية في التشريع والقضاء، الدار العربية للموسوعات، المجلد 23، بدون تاريخ نشر - ص مؤسسات، تشريع - ن - 46.

القصد من بيع الشركة العامة كأصول هو لاختيار المشتري الذي تتوافر فيه الإمكانيات المادية والخبرة الفنية والإدارية⁽¹⁾.

وقد راعى المشرع العراقي هذه الاعتبارات فقد أشارت المادة (36) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997⁽²⁾ إلى إن تحول الشركة العامة يتم عن طريق بيع أسهمها، كما إن المادة (32) من قانون الشركات العراقي بينت الحد الأعلى ملكية الأسهم في الشركات المساهمة الخاصة بما لا يتجاوز (20%) من رأسمالها وخولت الجهة القطاعية المختصة وضع الحد الأعلى لمساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي من غير القطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة المختلطة على أن لا يتجاوز (10%) من رأسمالها. وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي إلى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه هذا الشخص أكثرية راس المال لغرض احتساب النسبة المذكورة⁽³⁾.

كذلك فإن ما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (151) لسنة 1989⁽⁴⁾ من شأنه أن يعمل على تحقيق الهدف من عملية التحول إلى القطاع الخاص في توسيع قاعدة الملكية، وإن يحول دون تركيز الثروة في يد عدد قليل من المستثمرين ولاسيما إذا انصب البيع على أصول المشروع وليس على أسهمه، وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986، فقد جاء في هذا القرار أنه:

"أولا: يمنع بيع المعامل أو المشاريع المملوكة للدولة أو القطاع الاشتراكي التي تباع بالمزايدة العلنية أو بغيرها إلى القطاع الخاص سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا سبق له أن اشترى أو تملك مشروعا أو معملا من أية جهة كانت إلا إذا كان المشروع أو المعمل الجديد مكتملا من الناحية الإنتاجية للمشروع السابق".

أما المشرع الفرنسي، فلقد حرص على توزيع رأسمال الشركات العامة التي يتم بيعها بطريقة تضمن حصول الفرنسيين وصغار المستثمرين بشكل خاص على عدد

(1) د. منير إبراهيم هندي، خصخصة المشروعات العامة، المرجع السابق، ص 78-79.

(2) الوقائع العراقية، العدد (3685) في 1997/9/1.

(3) المادة (33- ثانيا) من قانون الشركات العراقي.

(4) الوقائع العراقية العدد (3247) في 1989/3/27.

من الأسهم بالأولية على غيرهم، فأوجب تلبية جميع طلبات شراء الأسهم الصادرة من الأفراد الفرنسيين أو المقيمين في فرنسا " أشخاص طبيعية " بحيث يتم الاستجابة إلى جميع طلباتهم وبصورة كلية، وفي حالة عدم إمكانية تحقيق ذلك يصار إلى تخفيض عدد الأسهم التي تتضمنها هذه الطلبات بمرسوم يصدر من مجلس الدولة⁽¹⁾. كذلك حول المشرع الفرنسي وزير الاقتصاد أن يقرر الحد الأعلى لعدد أسهم الشركات العامة والتي يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يشتريها بما لا يتجاوز (5%) من الأسهم التي يتم بيعها إذا ما تم البيع في سوق الأوراق المالية⁽²⁾.

كذلك أولى المشرع المغربي عناية بهذا الأمر إذا أجاز للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، أن يقرر أنه لا يجوز لشخص طبيعي أو معنوي شراء عدد من الأسهم أو الحصص يتعدى نسبة مئوية معينة⁽³⁾.

وفضلا عما تقدم يلاحظ أن بعض الدول وبالذات دول أوروبا الشرقية قد اتبعت نهجا خاصا في عمليات التحويل إلى القطاع الخاص وهو أسلوب التحويل الشعبي "Mass privatization" والذي يسمى أيضا " بخصخصة السندات " "Voucher or coupon privatization" ويهدف هذا النهج بشكل أساسي إلى تحقيق الهدف المتمثل بتوسيع قاعدة الملكية الخاصة وهو يستند أساسا إلى توزيع سندات أو شهادات مجانية أو بقيمة اسمية محددة على جميع الأفراد البالغين سن الرشد، وقد تؤخذ بعض المسائل الأخرى بنظر الاعتبار عند توزيع هذه السندات كعدد سنوات العمل مثلا وتكون هذه السندات قابلة للاستبدال بشكل مباشر أو غير مباشر بأسهم الشركات العامة التي يجري نقل

(¹) المادة (13) من قانون التحويل إلى القطاع الخاص الفرنسي رقم 912-86، الصادر في 1986/8/6 المعدلة، وكانت هذه المادة تقضي قبل تعديلها بالقانون رقم 923 الصادر عام 1993 بتلبية جميع طلبات شراء الأسهم الصادرة من الأفراد الفرنسيين والمقيمين في فرنسا بما لا يتجاوز (10) أسهم.

(²) المادة (9) من قانون لخصخصة الفرنسي وانظر: Christian baillon, Droit des Entreprises publiques Encyclopedie delmas pour la vie des affaires, Delmas-paris, 1^{re} edition, 1992, P. 212.

(³) المادة (6) من قانون التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص المغربي، أما القانون المصري فيلاحظ أنه لم يضع حدا أعلى ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام التي يتم بيعها.

ملكيته إلى القطاع الخاص⁽¹⁾، وبذلك يتم توسيع قاعدة الملكية بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من الأفراد.

أما ما يتعلق بمشكلة البطالة التي قد تنتج جراء نقل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، فالحقيقة أن هذه المخاوف في محلها بيد أنه قد يكون الأمر على العكس من ذلك إذ قد يؤدي بيع المشروعات العامة إلى زيادة حجم العمالة فيها، فضلا عن أن تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص قد يكون من خلال زيادة رأسمالها بواسطة القطاع الخاص، مما يؤدي إلى توسيع استثماراتها ومن ثم زيادة عدد العاملين فيها⁽²⁾.

المطلب الثالث

التمييز بين المفهوم القانوني والمفهوم الاقتصادي
للتحول إلى القطاع الخاص

اتضح لنا مما سبق أن التحول إلى القطاع الخاص يعني نقل ملكية المشروعات العامة كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص، ويرتبط هذا المفهوم للتحويل إلى القطاع الخاص بنشأته، إذ لم يكن يقصد به إلا نقل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص⁽³⁾، غير أن مصطلح التحول إلى القطاع الخاص أصبح يعني في الدراسات

(¹) UNCTAD , op. Cit, P. 94-95.

(²) فعلى سبيل المثال ازداد عدد العاملين في شركة جاكوار (Jaguar) البريطانية بمعدل (2000) عامل بعد بيعها للقطاع الخاص كذلك ازداد حجم العمال في شركة هافيلاند (Haviland) الكندية للطائرات بعد بيعها لشركة بوينج. انظر: د. منير إبراهيم هندي، خصخصة المشروعات العامة، المرجع السابق، ص13.

(³) وما يدل على ذلك أن التحول إلى القطاع الخاص قد عرف في أول الأمر في بريطانيا وهي أول دولة عرفت هذا النظام بمصطلح (إلغاء التأميم) Denationalization، انظر: د. ميرغي عبد العال، المرجع السابق، ص66. كذلك:

- Oxford dictionary of law, Fourth ed., Oxford University press, Grate Britain, 1998, P.355.

الاقتصادية الحديثة أكثر من ذلك بحيث أصبح وسيلة اقتصادية تعبر عن فلسفة جديدة لدور الدولة في الاقتصاد، وعنصراً رئيسياً من مجموعة سياسات متكاملة للإصلاح الاقتصادي وتمثل هذه السياسات بتقليص دور الدولة في الإنتاج المباشر للسلع والخدمات وتخفيف أعباء الموازنة العامة وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتحرير التجارة وتشجيع المنافسة وتوفير بيئة اقتصادية تمكن القطاع الخاص من أن ينمو ويتوسع دوره، والتحول إلى القطاع الخاص يمثل إحدى وسائل تقليص حجم القطاع العام⁽¹⁾. والتحول إلى القطاع الخاص لا يعد غاية بحد ذاته وإنما هو إحدى الوسائل التي قد تنتهجها الدولة في عملية الإصلاح الاقتصادي، فلم يعد مفهوم التحول إلى القطاع الخاص قاصراً على نقل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، بل أصبح يشمل كل الوسائل التي من شأنها أن تقلص دور الدولة في الاقتصاد وتعمل على دعم القطاع الخاص لذلك فإن الدراسات الاقتصادية الحديثة⁽²⁾ تشير إلى أن صور التحول إلى القطاع الخاص باتت تختلف من دولة إلى أخرى تبعاً لاختلاف نظرة كل دولة إلى هذه العملية وما تتوقعه من نتائج اقتصادية منها، وهذه الصور والأشكال يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية على النحو الآتي⁽³⁾:

أولاً، التحول الصريح إلى القطاع الخاص " الخصخصة الصريحة "

Proper privatization وتشمل هذه المجموعة بيع المشروعات العامة كلياً أو جزئياً وتصفية المشروعات العامة، كما وتشمل حالة تخفيض مساهمة الدولة في رأسمال المشروعات العامة عن طريق زيادة رأسمال هذه المشروعات بأموال يقدمها القطاع

(1) د. أحمد صقر عاشور، المرجع السابق، ص5.

(2) انظر مثلاً: د. محسن أحمد الخضيرى، الخصخصة، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، 1993، ص74، كذلك، محمد صبري بن اوانج، المرجع السابق، ص92، كذلك علي حسين علي، الخصخصة مفاهيم ومحاذاير، مجلة التجارة والصناعة، ايلول - 1995، ص32-33.

(3) انظر في هذه الأساليب، علي حسين علي ن المرجع السابق، ص33، كذلك فريدة علي ابو الفتاح، الخصخصة في الدول المتقدمة والنامية، دروس مستفادة، مجلة التجارة والصناعة، العدد الثالث والثلاثون، 1997، ص34.

الخاص، أو إدماج هذه المشروعات بالشركات الخاصة وهذه الأساليب تعد أكثر أساليب التحول إلى القطاع الخاص فاعلية وأثرا، وهي التي تمثل المفهوم القانوني للتحول إلى القطاع الخاص والذي عالجت التشريعات المقارنة - ولاسيما التشريع الفرنسي -⁽¹⁾ ونظمت أحكامه وسنفردها لهذه الأساليب فضلا خاصا لكونها تمثل محورا لدراستنا القانونية هذه.

ثانيا. التحول الجزئي إلى القطاع الخاص "خصخصة جزئية" Partial privatization وتتميز أساليب هذه المجموعة بأنها لا تؤدي إلى نقل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص بل أنها تقتصر على نقل إدارة هذه المشروعات للقطاع الخاص، ولذلك تسمى أيضا بتحويل الإدارة إلى القطاع الخاص "خصخصة الإدارة" وأهم هذه الأساليب تتمثل بما يسمى عقود الإدارة "Management contract" وتأجير المشروعات العامة وعقود الامتياز والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات العامة "Contracting out" ويدخل ضمن إطار هذه المجموعة أيضا أسلوب آخر، يتمثل بالسماح للقطاع الخاص بممارسة أنشطة اقتصادية كانت حكرًا على القطاع العام.

ثالثا. التحول الضمني إلى القطاع الخاص "الخصخصة الضمنية" Implicit privatization وهي تعني إدارة المشروعات العامة وفقا للأسس التي يعمل بها القطاع الخاص ووفقا "لقوى السوق وآلياته" إذ تبقى الدولة محتفظة بملكية وإدارة المشروعات العامة، وتعمل من جهة أخرى على إزالة وتبسيط القوانين التي تنظم إدارة هذه المشروعات العامة، وتخفيف أو إلغاء بعض صور الرقابة الحكومية عليها وإلغاء الدعم الحكومي لهذه المشروعات، وتحديد أسعار المنتجات أو الخدمات التي

(1) التشريعات التي نظمت عملية التحول إلى القطاع الخاص في فرنسا هي، القانون رقم (793-86) الصادر في 1986/7/2، والذي خول الحكومة الفرنسية القيام بعمليات التحول إلى القطاع الخاص، وكذلك القانون المرقم (86-912) في 1986/8/6 والذي يتعلق بأساليب التحول إلى الخاص، وقد عدل هذا القانون الأخير بالقانون المرقم (93-923) في 1993/7/19. وكذلك القانون رقم (96-314) في 1996/4/12. وأنظر:

Code des Societes, Litec, 1999, P. 1049.

تقدمها تلك المشروعات وفقا لتكلفة الإنتاج وهذه الإجراءات تندرج تحت مفهوم ما يسمى (بتتجير) المشروعات العامة "Commercialization".

ويبدو واضحا أن مفهوم التحول إلى القطاع الخاص أصبح أشمل وأوسع بكثير من المفهوم التقليدي له - نقل ملكية المشروعات العامة إلى القطاع الخاص -، وإنه بات يمثل نظرية اقتصادية متكاملة تهدف بشكل أساسي إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص على حساب تقليص دور الدولة في الاقتصاد ولعل السبب الذي دفع الاقتصاديين لإعطاء هذا المفهوم الواسع للتحول إلى القطاع الخاص يكمن في رغبتهم في تجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عند نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص، وإيجاد البدائل التي من شأنها أن تحقق نفس الآثار الاقتصادية الناجمة عن نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص⁽¹⁾.

ومهما يكن من أمر فإن التشريعات المقارنة والخاصة بعمليات التحول إلى القطاع الخاص لا تعنى في حقيقة الأمر إلا بالمفهوم التقليدي للتحول إلى القطاع الخاص "التحول الصريح"⁽²⁾، مع تأكيدنا على أن الأساليب الأخرى - التي أشرنا إليها - للتحول إلى القطاع الخاص لا تخلو من الجوانب القانونية، وذلك على أساس أن القانون يمثل بالضرورة الإطار التنظيمي لأية سياسة اقتصادية، فضلا عن أن هذه الأساليب التي يقول بها الاقتصاديون لم تأت في حقيقة الأمر بما هو جديد في ميدان القانون وهي مفاهيم قانونية معروفة لدى المختصين بالقانون والجديد يتمثل ببعض التفاصيل والتي قد تكون غير معروفة سابقا فإذا ما أمعنا النظر في أساليب ما يسمى بالتحول الجزئي للقطاع الخاص، لتبين إنها لا تخرج في حقيقتها عن كونها عقودا

(1) د. ميرغني عبد العال، المرجع السابق، ص 14.

(2) إذ لم ينظم قانون التحول إلى القطاع الخاص الفرنسي لسنة 1986 إلا الأساليب الناقلة للملكية، كذلك هو الحال بالنسبة إلى قانون تحويل المنشآت من القطاع العام إلى القطاع الخاص المغربي لسنة 1990، كذلك هو الحال في القانون التونسي الصادر في الأول من شهر شباط، 1999. وانظر بشأنه د. محمد ميدون، التجربة التونسية في الخصخصة، ندوة التحول إلى القطاع الخاص، تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إدارة البحوث والدراسات، القاهرة، 1996، ص 109.

تبرمها الإدارة مع القطاع الخاص، تمنحه بموجبها حق ممارسة بعض النشاطات والأعمال التي تمارسها، وهذه العقود هي ما تعرف بالعقود الإدارية⁽¹⁾، وبرزت هذه العقود التي يعدها الاقتصاديون من قبيل وسائل التحول إلى القطاع الخاص، عقد الإيجار، وعقد الإدارة وعقد الامتياز.

ويعرف عقد الإدارة بأنه اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص بمقتضاه ينتقل حق إدارة المشروع العام من الشخص العام إلى القطاع الخاص، مع احتفاظ الشخص العام بملكية موجودات المشروع العام⁽²⁾، ويختلف عقد الإدارة عن عقد الإيجار في أن في عقد الإدارة يقتضي أن تتولى الإدارة دفع أجرة إدارة المشروع العام إلى الفرد أو الشركة من القطاع الخاص، ودون أن يكون لهذا الأخير بالضرورة الحق في الأرباح جراء إدارته للمشروع العام بالرغم من أن هذا الأجر قد يربط بالأرباح أو بجودة الأداء، أما في عقد الإيجار فمن المعروف أن الفرد أو الشركة من القطاع الخاص هو الذي يدفع أجرة المشروع العام للإدارة نظير انتفاعه بهذا المشروع، كذلك فإن الشخص العام في عقد الإدارة هو الذي يستمر في وضع الشروط اللازمة للاستثمار في المشروع العام بجميع التفاصيل ولا يكون المدير من القطاع الخاص مسؤولاً عنها بأي شكل من الأشكال، في حين أن تحديد شروط الاستثمار في المشروع العام يقع على عاتق المستأجر للمشروع العام ويتحمل مسؤوليته كقاعدة عامة⁽³⁾. وكما أشرنا سابقاً تكون سائر الأحكام الأخرى لهذه العقود خاضعة لأحكام العقود الإدارية المعروفة في القانون الإداري.

أما عن عقد الامتياز فهو أيضاً من العقود المعروفة في ميدان القانون الإداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص (فرداً أو شركة) بمهمة إشباع حاجة جماعية عن طريق إنشاء وتسيير مرفق عام على نفقته

(¹) صهيب موسى جفال المومني، الجوانب القانونية للتخاصية في التشريع الأردني - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا - الجامعة الأردنية، 1997، ص 90.

(²) UNCTAD, Op. Cit., P. 73.

(³) المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

الخاصة وعلى مسؤوليته لقاء منحه حق تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين تحت إشراف الشخص العام ورقابته⁽¹⁾، وتشير الدراسات الاقتصادية إلى استخدام عقد الامتياز كأسلوب لتحويل الإدارة إلى القطاع الخاص، غير إنها في بعض الأحيان تعده أسلوباً مستحدثاً للتعاقد بين الإدارة والقطاع الخاص، وتحت تسميات جديدة لعل أهمها أسلوب إنشاء تشغيل نقل ملكية (BOT)⁽²⁾ وموجب هذا الأسلوب يتولى القطاع الخاص بناء المشروع على نفقته لقاء حقه في تشغيل هذا المشروع مدة من الزمن بحسب الاتفاق ثم يعيد المشروع إلى الدولة فيصبح جزءاً من ملكيتها. كذلك هناك أسلوب آخر هو أسلوب (بناء - تشغيل - تملك) (Boo)⁽³⁾ ووفقاً لهذا الأسلوب يتولى القطاع الخاص أيضاً بناء المشروع وتشغيله وتملكه مقابل مبلغ مالي يدفعه للدولة. والأسلوب الأول لا يخرج في حقيقته عن كونه عقد امتياز موجه تمهين الحكومة للقطاع الخاص حق إنشاء وتشغيل مشروع معين لإشباع حاجة عامة ملحة (كالماء والكهرباء)⁽⁴⁾، فإن لم تكن الخدمة التي يقدمها المشروع ذات طبيعة عامة ملحة، لما لجأت الإدارة إلى التعاقد مع القطاع الخاص بشأنه تاركة تقديم الخدمة أو السلعة متى كانت كمالية للقطاع الخاص ابتداءً، ولا يختلف الأسلوب الثاني عن الأسلوب الأول إلا من حيث أنه يسمح للقطاع الخاص بتملك المشروع الذي أقامه على نفقته بموجب شروط معينة أهمها استمراره في تقديم الخدمة وبالشروط المتفق عليها، وليس هناك ما يمنع من تكييف هذا العقد أيضاً على أساس أنه عقد امتياز⁽⁵⁾.

(¹) د. علي الخطار، عقد امتياز المرافق العامة وتطبيقاته في الأردن، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد السابع، العدد الخامس، 1992، ص 17.

(²) Build-operation-transfer

- علاء خليفة، المرجع السابق، ص 72.

(³) Build - operation - owned.

(⁴) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تقويم خصخصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية في دول مختارة أعضاء في الاسكوا، الأمم المتحدة، نيويورك، 1999، ص 14-15.

(⁵) صهيب موسى جفال المومني، المرجع السابق، ص 113-114، كذلك:

- UNCTAD, Op. Cit., P. 74.

وفضلا عما تقدم، فإن مفهوم التحول الضمني إلى القطاع الخاص، والذي يتمثل بشكل أساسي بقيام الدولة بإدارة المشروعات العامة وفقا للأسس التي يعمل بها القطاع الخاص، ليس مفهوما جديدا أو مستحدثا " إذ عرفتھا میادین الإدارة منذ مطلع هذا القرن متمثلة في المؤسسة العامة، كأداة إدارية تم ابتداعها وتصحيحها لتعمل بعقلية وروح القطاع الخاص دون أن تفرط في أهدافها العامة وفي مسؤولياتها تجاه الصالح العام"⁽¹⁾.

وتأسيسا على ما تقدم نستطيع أن نستنتج، أن المفهوم القانوني للتحويل إلى القطاع الخاص يختلف عن مفهومه الاقتصادي، فالتشريعات التي أصدرتها الدول المختلفة لتنظيم عملية التحويل إلى القطاع الخاص لم تنظم في حقيقة الأمر إلا الأساليب الناقلة للملكية تاركة الأساليب الأخرى للقواعد العامة الموجودة في قوانينها، على أساس أنها لا تمثل في حقيقتها مفهوما قانونيا مستحدثا أو جديدا، ومن ثم لا يستلزم اتباع الأساليب غير الناقلة للملكية تنظيما قانونيا مستقلا، على العكس من الأساليب الناقلة للملكية والتي باتت تمثل نظاما قانونيا مستقلا بذاته عن القواعد العامة للقانون.

(¹) د. مرغني عبدالعال حمود، مؤسسات القطاع العام في مفترق الطرق بين إمكانيات التطور واحتمالات الخصخصة (دراسة نظرية)، بحث مقدم إلى ندوة التوجهات المستقبلية للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي، المنامة - البحرين، 28/27 آذار 1995، اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وغرفة صناعة وتجارة البحرين، ص13.

المبحث الثاني الأساس القانوني للتحويل إلى القطاع الخاص

يعد التحويل إلى القطاع الخاص نظاماً قانونياً تقرره الدولة بما لها من سلطة في تنظيم اقتصادها فالتحويل إلى القطاع الخاص لا يعني مجرد التصرف بأموال الدولة بالبيع أو نحوه للقطاع الخاص، إذ لا بد من مراعاة الأهداف الاقتصادية المراد تحقيقها من خلال هذه العملية ذلك أن لها فضلاً عن الجانب القانوني جوانب أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية التي ترتبط بدورها بفلسفة الدولة وفيما إذا كانت اشتراكية أو رأسمالية فلا بد من أن تراعي الدولة عند تبنيها لهذا النهج الاقتصادي القوانين النافذة فقد تفرض هذه القوانين قيوداً تحد من حرية الدولة في تبني هذا النهج الاقتصادي منها ما يتعلق بطبيعة الأموال العامة التي يحق للدولة تحويلها إلى القطاع الخاص ومنها ما يتعلق بالنصوص الدستورية التي تقرر فلسفة الدولة السياسية والاقتصادية.

وعلى هذا الأساس ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وكما يأتي:
المطلب الأول: الأموال العامة التي يصح تحويلها إلى القطاع الخاص.
المطلب الثاني: القيود الدستورية على عملية التحويل إلى القطاع الخاص.

المطلب الأول الأموال العامة التي يصح تحويلها إلى القطاع الخاص

تقسم أموال الدولة إلى نوعين: أموال الدولة العامة وأموال الدولة الخاصة، ويقصد بأموال الدولة العامة الدومين العام، الأموال التي تعود للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم⁽¹⁾، وهذه الأموال تخضع لنظام

(¹) المادة (71) من القانون المدني العراقي والمادة (87) من القانون المدني المصري، كذلك يقر القضاء المصري بمعيار تخصيص المال للمنفعة العامة بمقتضى القانون أو بالفعل لتمييز أموال الدولة العامة عن أموالها الخاصة، الطعن رقم (1426) لسنة 56 ق، جلسة 1989/4/9، كذلك الطعن رقم (1625) سنة 55 ق، جلسة 1991/3/24، حسن الفكاهي، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، الإصدار المدني - ملحق (8)، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص 812-816.

قانوني يختلف عن ذلك الذي تخضع له الأموال الخاصة المملوكة للأفراد إذ أن هذه الأخيرة تخضع لأحكام القانون الخاص في حين تخضع الأولى لأحكام القانون العام⁽¹⁾.

وقد اختلف الفقه في تصنيف أموال الدولة العامة إذ يذهب البعض إلى تقسيمها استنادا إلى موقع المال في الإقليم "بري وبحري وجوي" في حين يقسمها البعض الآخر على أساس الشخص العام الذي يملكها "محافظة أو بلدية.... الخ" ويقسمها البعض كذلك وفقا للأغراض التي أعدت لها فتكون هناك أموال عامة "حربية وأخرى دينية ومباني الحكومة ومقراتها..". أما التقسيم الأخير فهو يستند إلى طبيعة الأموال "منقولة أو عقارية"⁽²⁾.

وعادة ما يولي المشرع عناية خاصة لحماية أموال الدولة العامة، وذلك لما لها من أهمية، فبعض الدول نصت على هذه الحماية صراحة في دساتيرها⁽³⁾.

أما أموال الدولة الخاصة، فهي الأموال التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة ملكية خاصة، والتي لا تخصص للمنفعة العامة، وتخضع لأحكام القانون الخاص في استغلالها وفي التصرف فيها، والغرض من هذه الأموال هو

(1) د. علي محمد بدير، د. عصام البرزنجي، د. مهدي السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، بغداد، 1999، ص384.

(2) انظر في عرض هذه الآراء، د. رفيق عبد السلام، الحماية الجنائية للمال العام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1994، ص132.

(3) وقد نص الدستور العراقي الموقت لسنة 1970، على هذه الحماية في المادة (15) منه والتي جاء فيها (لأموال العامة ولممتلكات القطاع الاشتراكي حرمة خاصة، على الدولة وجميع أفراد الشعب صيانتها والسهر على أمنها وحمايتها، وكل تخريب فيها او عدوان عليها يعتبر تخريبا في كيان المجتمع وعدوان عليه).

الانتفاع بها وهما تنتج من غلات وثمار فيكون للدولة و الأشخاص المعنوية العامة، حق الانتفاع بها بشكل مباشر أو غير مباشر^(١).

وهناك أمثلة كثيرة لهذه الأموال، فهي تتمثل بجميع الأموال التي تستغلها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، ودون أن يكون الغرض من ذلك هو تحقيق المنفعة العامة فقط، بل لتحقيق الأرباح أيضا بل إن أموال الدولة العامة ذاتها قد تتحول إلى أموال خاصة عند انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وعلى ذلك تنص المادة (72) من القانون المدني العراقي، إذ جاء فيها انه " تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ".

وبالرغم من صراحة النص المتقدم، يرى جانب من الفقه⁽²⁾ أن تطور دور الدولة في الاقتصاد وما لحقه من تغير في المفاهيم القانونية أدى إلى هدم التفرقة بين أموال الدولة العامة وبين أموالها الخاصة، وان هذا الأمر قد تجسد في إصدار المشرع العراقي لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986، الذي لم تميز مادته الأولى التي تحدد نطاق سريانه، بين أموال الدولة العامة وبين أموالها الخاصة، فقد جاء في هذه المادة أنه " أولا: تسري أحكام هذا القانون على أموال الدولة منقولة كانت أو غير منقولة عند بيعها أو إيجارها إلا إذا وجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك. ثانيا: "يشمل تعبير (أموال الدولة)، أموال القطاع الاشتراكي أيضا أينما ورد في هذا القانون ".

ونعتقد أن عدم تمييز النص المتقدم أموال الدولة العامة من أموالها الخاصة لا يعني أن المشرع العراقي قد أجاز التصرف بأموال الدولة العامة بل انه يعني سريان قانون بيع وإيجار أموال الدولة على جميع عمليات بيع وإيجار أموال الدولة الخاصة إلا إذا وجد نص يقضي بخلاف ذلك، إذ تتسم نصوص قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بالسمة الإجرائية، فالغرض منها هو تحديد إجراءات بيع وإيجار

(١) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن - حق الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967، ص93.

(٢) د. ماهر صالح عللاوي الجبوري، القانون الإداري، مطبوعات جامعة الموصل، 1989، ص239-240. كذلك، فوزي حسين سلمان الجبوري، المرجع السابق، ص174.

أموال الدولة ولم يرد في هذا القانون قاعدة موضوعية لتمييز أموال الدولة العامة من أموالها الخاصة، ومن ثم يبقى التمييز بينهما خاضعا بحسب الأصل، لنصوص القانون المدني المشار إليها.

وتأسيسا على ما تقدم، نرى أن الأموال التي يصح تحويلها إلى القطاع الخاص هي أموال الدولة الخاصة دون أموالها العامة، وما يهمنا ضمن هذا السياق هي أموال الدولة الخاصة التي تتمثل بوحدات اقتصادية "مشروعات عامة"، ذلك أن التصرف ببعض الأصول الصغيرة التي تملكها الدولة "كالسيارات" مثلا لا يعد من قبيل التحول إلى القطاع الخاص كما أشرنا إلى ذلك سابقا.

وتشمل فكرة المشروعات العامة Entreprises Publiques، المؤسسات العامة الصناعية والتجارية⁽¹⁾ فضلا عن شركات الدولة وهذه المشروعات بالرغم من تباين نظمها القانونية تجمعها مجموعة من الخصائص المشتركة، بقدر يسمح بضمها معا تحت تسمية واحدة، وبعض هذه المشروعات العامة نتج عن التأمين وبعضها الآخر أنشأته الدولة مباشرة.

وتخضع المشروعات العامة كمبدأ عام لأحكام القانون الخاص، وتعد أموالها كقاعدة عامة من أموال الدولة الخاصة، ويكون للمشروع على أمواله كافة الحقوق التي تتمتع بها الشركة الخاصة على أموالها كما ويتمتع المشروع العام ببعض امتيازات السلطة العامة، كنزع الملكية والإعفاء من الخضوع لنظام الإفلاس، وتتولى الإدارة تعيين مديري المشروعات العامة، وتفرض عليها نوعا من الرقابة الإدارية والمالية، كما تحتفظ أحيانا بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة ببعض شؤون المشروع الجوهرية⁽²⁾.

(¹) أن جميع المؤسسات العامة، سواء كانت إدارية أم صناعية أم تجارية أم مهنية، هي أشخاص مرفقية، لا تختلف من حيث تكوينها ولكنها تختلف من حيث النظام القانوني الذي تتبعه، د. محمد علي آل ياسين، القانون الإداري، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ نشر، ص168.

(²) د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص445-446. ولعل من المناسب أن نذكر ما أورده الدكتور محسن شفيق من أن "هناك جدلا

وتشمل المشروعات العامة في فرنسا، المؤسسات العامة الصناعية والتجارية (EPIC)⁽¹⁾ والشركات العامة. وقد عرفت محكمة النقض الفرنسية المشروع العام بأنه "المشروع الذي يمتلك فيه الأشخاص المعنوية العامة أكثر من نصف رأس المال"⁽²⁾، كما وأكد مجلس الدولة الفرنسي على أن الشركة التابعة للقطاع العام هي الشركة التي تمتلك فيها الدولة أكثر من نصف رأس المال، وسواء كان ذلك بصورة منفصلة أم مجتمعة أي سواء أكانت هذه الملكية تعود لشخص معنوي عام واحد أم لعدة أشخاص⁽³⁾.

وتقسم الشركات العامة إلى قسمين⁽⁴⁾ الأول، يسمى الشركات الوطنية national La societe وهي شركة مساهمة تكون الدولة المساهم الوحيد فيها وهي تمثل الشكل المهيمن على المشروعات العامة في فرنسا، بسبب احتفاظ المشروعات التي أمتتها الدولة بالشكل السابق على التأميم "شكل شركة مساهمة"، كما حدث بالنسبة إلى كثير من عمليات التأميم التي جرت في فرنسا بين عامي 1945-1946 وكذلك كل عمليات التأميم التي جرت فيها عام 1982⁽⁵⁾. أما النوع الثاني فهو الشركات

فقهيا حول طبيعة شخصية المشروع العام، أي حول إذا ما كان من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص ويمكن أن يقال بوجه عام، أن فقهاء القانون الإداري يميلون إلى اعتباره شخصا عاما أيا كان الشكل الذي يفرغ فيه، ولو اتخذ شكل شركة المساهمة، وذلك لأنه يستكمل على أية حال مقومات المؤسسة العامة التي تتمثل على وجه الخصوص في قيامه على مرفق عام يؤدي خدمات عامة وخضوعه لرقابة الدولة، أما فقهاء القانون التجاري فيعتبرونه شخصا خاصا استنادا إلى الشكل التجاري الذي يفرغ فيه وأسلوب الإدارة الخاصة الذي يتبع في تسييره والاستقلال المالي الذي يتمتع به" د. محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967-1968، ص 318-319.

⁽¹⁾ L'établissement public industriel et commercial

⁽²⁾ cass 1 civ. 3 mai 1988.

⁽³⁾ CE 24 nov. 1978, AJDA, 20 mars, 1979, P. 44.

⁽⁴⁾ Jean-philippe colson, Droit public Economique, L.G.D.J., Paris, 1997, P.243-256.

⁽⁵⁾ وقد تضمنت عمليات التأميم التي جرت في فرنسا عام 1982، خمسة مجمعات صناعية، وتسعة وثلاثين مصفا وشركتين مالبيتين، أنظر:

Jean-philippe colson, Op. Cit., P. 243-256.

المختلطة (S.E.M) وهي شركات مساهمة تكون أسهمها مملوكة لمساهمين من القطاع العام والقطاع الخاص معا. وقد يمتلك القطاع العام أغلبية رأسمال هذه الشركة، وقد تكون مساهمته اقل من ذلك. ويرى جانب من الفقه في فرنسا ان الشركة التي يمتلك فيها القطاع العام اقل من (10%) من راس المال لا تعد من الشركات المختلطة⁽¹⁾.

وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام صراحة على اعتبار الشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون من أشخاص القانون الخاص، وهذه الشركات تشرف بدورها على الشركات التابعة والتي يجب أن تملك فيها الشركة القابضة ما لا يقل عن (51%) من رأس المال⁽²⁾.

أما بخصوص موقف المشرع العراقي فنلاحظ أن المشروعات العامة التي يصح تحويلها إلى القطاع الخاص، تتمثل بشكل رئيسي، بالشركات العامة ويقصد بالشركة العامة " الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس اقتصادية"⁽³⁾ ووفقا للمادة (40) من قانون الشركات العامة العراقي تحولت جميع الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والممولة ذاتيا، والتي تمارس نشاطا اقتصاديا إلى شركات عامة تخضع لقانون الشركات العامة المشار إليه⁽⁴⁾ فضلا عن ذلك، تعد الشركات المختلطة من ضمن المشروعات العامة أيضا والشركة المختلطة عبارة عن شركة مساهمة أو محدودة تتكون باتفاق شخص أو أكثر من القطاع الاشتراكي مع شخص أو أكثر من غير القطاع المذكور برأسمال مختلط لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي فيه عن (25%)، ويجوز استثناء تكوين شركة مختلطة من شخصين أو أكثر من القطاع

⁽¹⁾ المرجع نفسه، ص 257.

⁽²⁾ المادة (16) من قانون شركات قطاع الأعمال المصري (23) لسنة 1992.

⁽³⁾ المادة الأولى من قانون الشركات العامة العراقي (22) لسنة 1997.

⁽⁴⁾ لمزيد من التفصيل في التعريف بالشركة العامة انظر: د. لطيف جبر كوماني و د. علي كاظم الرفيعي، القانون التجاري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ص 408.

المختلط⁽¹⁾ وطبقا للمادة (64/ ثانيا) من قانون الشركات العراقي لا يجوز للمساهم من القطاع الاشتراكي نقل ملكية أسهمه في الشركة المختلطة إلى شخص من غير هذا القطاع، إذا أدى ذلك إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عن (25%) من رأس المال. ويا حبذا لو أن المشرع العراقي يعدل هذا الحكم ذلك انه أجاز تحويل الشركات العامة إلى شركات مختلطة أو خاصة، لذلك يكون من باب أولى إجازة تحويل الشركات المختلطة إلى شركات خاصة عن طريق بيع الأسهم التي يملكها القطاع الاشتراكي فيها، طالما أن ذلك يتفق مع سياسة الدولة الاقتصادية ويحقق المصلحة العامة.

المطلب الثاني

القيود الدستورية على عملية التحويل إلى القطاع الخاص

إن حق الدولة في تبني سياسة التحويل إلى القطاع الخاص ليس مطلقا، فلا بد لها من مراعاة النصوص الدستورية التي تحدد فلسفة الدولة السياسية والاقتصادية. والحقيقة، إن التعارض بين التحويل إلى القطاع الخاص والدستور يتوقف على الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه من وراء تطبيق مثل هذه السياسة الاقتصادية من جهة، وعلى طبيعة الفلسفة السياسية والاقتصادية التي تتبناها " اشتراكية أو رأسمالية " من جهة أخرى. وقد سبقت الإشارة، إلى إن الهدف من التحويل إلى القطاع الخاص يختلف من دولة إلى أخرى، فبعضها يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية الخاصة ودعم القطاع الخاص، وبعضها الآخر يهدف إلى القضاء على الوحدات الخاسرة في القطاع العام في حين أن دول أخرى قد تذهب إلى أبعد من ذلك إذ تهدف من عملية التحويل إلى القطاع الخاص إلى القضاء على القطاع العام والتحويل من النظام الاشتراكي إلى النظام

(¹) المادة (7) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997.

الرأسمالي⁽¹⁾ والتعارض ما بين التحول إلى القطاع الخاص والدستور، سيظهر فيما لو كان الدستور يقرر ان الدولة ذات نهج اشتراكي وذلك عندما يعطي الأولوية للملكية العامة ويفضلها على الملكية الخاصة، بحيث يكون للدولة الدور الرئيس في ممارسة النشاط الاقتصادي عن طريق مشروعاتها العامة، فالدستور في هذه الحالة يتعارض مع التحول إلى القطاع الخاص فيما إذا كانت الدولة تهدف من وراء هذه العملية إلى القضاء على القطاع العام والتحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، الأمر الذي قد يستلزم تعديل الدستور بما يتفق مع الأوضاع الجديدة التي تنشأ جراء التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي⁽²⁾ كما ان هذا التحول يتطلب تعديل الكثير من القوانين الأخرى أو إصدار قوانين جديدة. ذلك أن وظيفة القانون تختلف باختلاف مذهب الدولة أو فلسفتها الاقتصادية، إذ أن تبني الدول الاشتراكية والتي تستند قوانينها على المذهب الجماعي (Collectivism) لمبادئ الدول الرأسمالية التي تستند قوانينها إلى المذهب الفردي (individualism) يتطلب حتما تغيير وظيفة القانون في هذه الدول، وذلك لاختلاف المذهبين في نظرتهم إلى كل من القانون العام والقانون الخاص من حيث الأشخاص أو الحقوق أو الأموال⁽³⁾ لذلك يجب أن تتم عمليات التحول إلى القطاع الخاص ضمن إطار المشروعية "Legality" أي أن يراعى فيها القواعد القانونية ولا سيما الدستورية منها ويرى البعض⁽⁴⁾ أن توافر المشروعية يعد ضروريا لإنجاح عمليات التحول إلى القطاع الخاص، إذ أن فكرة المشروعية (Legitimacy) تختلف عن فكرة الشرعية التي تعنى بالجانب القانوني فقط، ذلك ان المشروعية تستلزم فضلا عن توافر الإطار القانوني السليم لهذه العملية، توافر القبول الاجتماعي، وهو أمر يجاوز

(1) د. احمد ماهر، المرجع السابق، ص 22-23.

(2) UNCTAD, Op. Cit., P. 42.

(3) صدقي حسين سليمان، الجانب القانوني للخصخصة، بحث مقدم الى ندوة توجهات وآفاق الخصخصة بدولة قطر، الدوحة، 7/6 نيسان / 1996، غرفة تجارة وصناعة قطر، الطبعة الثانية، 1996 - 1997، ص 325.

(4) د. حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد - طظ ياعاشور، دار الشروق - القاهرة، الطبعة الأولى، 1998، ص 24-25.

مجرد التحقق من وجود الإطار القانوني السليم الى ضرورة خلق الشعور العام بان هذه العمليات تتم مراعاة للمصلحة العامة وفي إطار من العدالة والأنصاف، دون محاباة أو تمييز لأي طرف على حساب الطرف الآخر.

وتأسيسا على ما تقدم يلاحظ⁽¹⁾ أن المشرع الفرنسي قد راعى في التشريعات الخاصة بالتحويل إلى القطاع الخاص، نصين دستوريين، يتمثل الأول منهما بالفقرة التاسعة من ديباجة الدستور الفرنسي لسنة 1958، والتي تنص على أن " كل مال وكل مشروع يتمتع بخصائص المرفق العام الوطني، أو يكون نشاطه محل احتكار فعلي ينبغي أن يكون مملوكا للجماعة"، أما الثاني، فيتمثل بنص المادة (34) من الدستور الفرنسي التي تنص على أن " للمشرع وحده سلطة وضع القواعد الخاصة بتأميم المشروعات وكذلك القواعد الخاصة بتحويل المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص" وقد اقر المجلس الدستوري الفرنسي، بالقيود الواردة في هذين النصين لدى تصديده للبحث في مشروعية عمليات التحويل إلى القطاع الخاص والتي جرت في فرنسا، وذلك في قراره المرقم (86-207) الصادر في 25-26/6/1986، فقد جاء في هذا القرار انه: " لا يفترض ان تتم كل عملية تحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بموجب تشريع خاص، بل أن على المشرع أن يضع القواعد والإجراءات التي تطبق على جميع هذه العمليات، بيد انه لا يمكن للهيئات التي أناط بها المشرع مهمة تحويل المشروعات العامة، تحويل المشروعات التي تدير مرفق عام وطني، أو تلك التي يكون نشاطها محل احتكار فعلي". وقد حدد المجلس الدستوري مفهوم الاحتكار الفعلي في هذا القرار ذاته، وذلك على أساس النظر إلى "السوق الذي تمارس فيه الشركات الأخرى نشاطها والمنافسة التي يوجهها المشروع من قبل هذه الشركات"⁽²⁾ لذلك لم يعتبر مجلس الدولة الفرنسي نشاط مؤسسة الائتمان المحلي

(¹) Jean-paul voluet, privatisation et societe privatisee, Rep societes dalloz avril 1999, P. 5.

(²) decis – cons. Const , n81-132 du 16 janu. 1986, jo 17 jaanu

الفرنسي (ancerCredit Locul De f)، مرفقا عاما وطنيا أو محل احتكار فعلي، لأنه يواجه منافسة من قبل الشركات المصرفية الأخرى في السوق⁽¹⁾.

كذلك أقرت محكمة النقض الفرنسية بهذه القيود الدستورية، فقد جاء في قرار لها أنه "استنادا إلى أحكام المادة 34 من الدستور للمشرع وحده سلطة تحديد القواعد المتعلقة بتحويل المشروعات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ولا تستطيع الحكومة أن تحول المشروعات العامة إلى القطاع الخاص بمراسيم أو قرارات دون أن يخولها المشرع ذلك"⁽²⁾.

أما فيما يتعلق بالدستور المصري لسنة 1971، فيلاحظ أن اعتبار التحويل إلى القطاع الخاص وسيلة للتحويل إلى نظام السوق لا يتفق مع الدستور القائم والذي وضع في ظل النظام الاشتراكي⁽³⁾ فقد جاء في المادة الأولى منه أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي" كما نصت المادة (30) منه على أنه "الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية".

وبالرغم مما تقدم، يلاحظ أن عمليات التحويل إلى القطاع الخاص مستمرة في مصر منذ أن بدأت في عام 1991، وهي تهدف كما يبدو إلى تحقيق ما يسمى بالتحول الاقتصادي والتحول نحو نظام السوق⁽⁴⁾ وقد أقرت المحكمة الدستورية المصرية في قرارها الصادر في 1997/2/1 بحق الدول في تنفيذ برامج "الخصخصة" عن طريق تطبيق قانون شركات قطاع الأعمال العام، وقد جاء في هذا القرار، الذي رفض الطعن بعدم دستورية قانون شركات قطاع الأعمال العام بحجة تعارضه مع نص المادة (30) من الدستور المصري "بان النصوص الدستورية لا يجوز تفسيرها باعتبارها حلا نهائيا

(¹) CE -30 JUIN 1995, PREC., CONCL. Bonicht, petites affiches, 14 fevr., 1996, P. 13

(²) Cass 1r civ. 3 mai, 1988, cts Renault c/ED, Jcp 1989, 1121203.

(³) سعاد الشراوي، القانون الإداري وتحرير الاقتصاد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص372.

(⁴) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الأمم المتحدة، تقييم برامج الخصخصة في منطقة الاسكوا، الأمم المتحدة - نيويورك، 1999، ص57.

ودائماً لأوضاع اقتصادية جاوز الزمن حقائقها، فلا يكون تبنيتها والإصرار عليها، ثم فرضها بآلية عمياء إلا حرثاً في البحر بل يتعين فهمها على ضوء قيم أعلى غايتها تحرير الوطن والمواطن سياسياً واقتصادياً⁽¹⁾.
أما عن موقف الدستور العراقي لسنة 1970، من عمليات التحول إلى القطاع الخاص، فمن المعروف أن جمهورية العراق ذات نهج اشتراكي وقد قرر الدستور العراقي ذلك في أكثر من مادة من مواده فلقد نصت مادته الأولى على أن "العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة، هدفه الأساس تحقيق الدولة العربية الواحدة وإقامة النظام الاشتراكي"، كما جاء في مادته الثانية عشر انه "تتولى الدولة تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني بهدف إقامة النظام الاشتراكي على أسس علمية وثورية...". كما ورد في المادة الثالثة عشر منه انه "الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج الأساسية ملك الشعب تستثمرها السلطة المركزية في جمهورية العراق استثماراً مباشراً وفقاً لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني".
فهذه النصوص تشير إلى أن الدستور العراقي يقرر صراحة أن نظام الدولة هو النظام الاشتراكي، كما ويقرر ملكية الشعب من خلال الدولة لوسائل الإنتاج الأساسية والثروات الطبيعية، ومن ثم فإن هذه النصوص تضع قيوداً على حرية الدولة في تبني سياسة التحول إلى القطاع الخاص، فلا يجوز ان يكون الهدف من التحول إلى القطاع الخاص في العراق، هو التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، كما ولا يجوز تحويل وسائل الإنتاج الأساسية والثروات الطبيعية إلى القطاع الخاص، ذلك أن المادة (13) من الدستور العراقي والمشار إليها، نصت صراحة على أن استثمار هذه الثروات يتم من قبل الدولة بشكل مباشر.
لذلك يلاحظ من الناحية العملية، أن عمليات التحول إلى القطاع الخاص في العراق لم تتناول وسائل الإنتاج الأساسية والثروات الطبيعية، لأنها تعد مملوكة للشعب

(¹) قرار المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية رقم (7) لسنة (16) قضائية - دستورية، الصادر في 1997/2/1 (غير منشور).

- كما ذكرنا، وإنما شملت بعض المعامل الصغيرة نسبياً والتي لا تعد من قبيل وسائل الإنتاج الأساسية، فضلاً عن بعض المنشآت السياحية كالفنادق والمدن السياحية. والمقصود بهذه العمليات هو دعم القطاع الخاص إلى جانب القطاع الاشتراكي وتحسين التنسيق بينهما⁽¹⁾.

(1) فقد تم تحويل المنشآت السياحية التابعة للمؤسسة العامة للسياحة / الملغاة، إلى شركات مساهمة مختلطة، بناء على أمر السيد رئيس الجمهورية، المبلغ بكتاب ديوان الرئاسة (42999) في 1988/11/17، إذ أمر سيادته ببيع أسهم تلك الشركات للقطاع الخاص وجعل الحد الأعلى لنسبة مساهمة القطاع الاشتراكي في هذه الشركات هي (49%)، والباقي (51%) للقطاع الخاص، على أن لا يشترك القطاع الاشتراكي في إدارتها. وانظر: عباس مرزوك العبيدي، التصريف بالأسهم والحصص في الشركة بيعة أو هبة - دراسة قانونية وعملية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون - جامعة بغداد، 1997، ص144.

المبحث الثالث شروط التحول إلى القطاع الخاص

تسعى الدول التي تطبق برامج التحول إلى القطاع الخاص إلى توفير الشروط التي من شأنها أن تسهل هذه العملية وتضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها. ولعل أبرز هذه الشروط هو وجود هيئة أو جهة تتولى إعداد برامج التحول إلى القطاع الخاص والإشراف على تنفيذها، كذلك يعد تقييم المشروعات العامة التي يراد تحويلها إلى القطاع الخاص من الشروط الضرورية لعملية التحول، لذلك عمدت التشريعات المقارنة إلى تحديد الجهات التي تتولى عملية التقييم فضلا عن تحديد الضوابط التي ينبغي مراعاتها في عملية التقييم. غير أنه وقبل هذا وذاك يلاحظ أن بعض التشريعات المقارنة قد عمدت إلى تنظيم عملية إعادة هيكلة مشروعاتها العامة على نحو يسهل إجراءات التحول إلى حد كبير. ولما تقدم ارتأينا تقسيم هذا المبحث على ثلاثة مطالب وعلى النحو الآتي:

المطلب الأول: إعادة الهيكلة القانونية للمشروعات العامة.

المطلب الثاني: الهيئات القائمة على عملية التحول إلى القطاع الخاص.

المطلب الثالث: تقييم اسهم الشركات العامة أو أصولها.

المطلب الأول إعادة الهيكلة القانونية للمشروعات العامة⁽¹⁾

يؤثر الشكل التنظيمي للمشروعات العامة في الخطوات الضرورية اللازمة لتحويلها إلى القطاع الخاص، فإذا كانت هذه المشروعات العامة تخضع لأحكام القانون

(¹) وفضلا عن إعادة الهيكلة القانونية Legal restructuring هناك إعادة الهيكلة المالية وإعادة الهيكلة الإدارية وبشأنها انظر: د. احمد ماهر، المرجع السابق، ص 245-261.

الخاص، وتأخذ شكل الشركات الخاصة ولا سيما شكل الشركة المساهمة فإنه سيكون من السهل تحويلها إلى القطاع الخاص ذلك أن لهذه المشروعات العامة خصائص المشروعات التجارية الخاصة، ومن ثم لا تحتاج عملية تحويلها إلى القطاع الخاص إلى إحداث تغيرات في هيكلها فهي تخضع لذات النظام القانوني الذي تخضع له الشركات الخاصة من حيث إدارتها وتقسيم رأسمالها إلى أسهم وغير ذلك إذ يكفي لتحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص أن تقوم الدولة بنقل ملكية أسهمها إلى القطاع الخاص. أما إذا كانت هذه المشروعات العامة تخضع لأحكام القانون العام في علاقاتها القانونية ولا تتخذ شكل الشركات الخاصة فإن تحويلها إلى القطاع الخاص يستلزم تغيير هيكلها القانوني على نحو يكون فيه متفقاً مع النظام القانوني الذي يخضع له النشاط الخاص⁽¹⁾.

وعملية إعادة الهيكلة القانونية للمشروعات العامة التي نشأت بموجب قواعد القانون العام تتم من خلال ما يسمى بالتجديد "Commercialization" وكذلك التشريك "tionalCorporatiz" ويقصد بالتجديد استخدام وسائل القطاع الخاص وأهدافه في نشاط المشروعات العامة وإدارتها⁽²⁾، أما التشريك فيذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أنه يعني اتخاذ المشروعات العامة شكل الشركات الخاصة فضلاً عن خضوعها لأحكام القانون الخاص وخاصة القانون التجاري⁽³⁾.

(¹) د. محمود صبح، الخصخصة ماذا؟ متى؟ لماذا؟ كيف؟.. المشكلات والحلول، البيان للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1999، ص56: كذلك

UNCTAD, Op. Cit., P. 51-52

(²) وهذا ما حدث في دولة برونو، فقد تم إخضاع المؤسسات العامة فيها لأحكام القانون التجاري الذي يحكم النشاط التجاري للقطاع الخاص، وذلك لإخضاعها لمجموعة قواعد أكثر كفاءة وللتأكيد على ضرورة أن تعمل كما لو كانت خاصة، وانظر: ماري شولي، جون نيليس، تعريب: د. سعاد نائل برنوطي، إصلاح المشروعات العامة - دروس من التجربة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 1995، ص24.

(³) UNCTAD, Op. Cit., P. 70-71.

- كذلك أنظر:

- Fu Fengxing, Corporation reform in China, united nation, department of economic and social affairs, privatization of public sector activities, UN, New York, 1999, P. 94.

ويتم التجيز عموماً من خلال وقف الإعانات المالية التي قد تقدمها الحكومة للمشروعات العامة بأي شكل كان، وتعرض هذه المشروعات لظروف السوق أي المنافسة وتقيدها بميزانية محددة، أما التشريك فيستلزم تحويل المشروعات العامة إلى شركات تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة والتي تبقى مالكة لجميع الأسهم في هذه الشركات⁽¹⁾.

وهذه المرحلة هي مرحلة وسطى بين قرار التحول إلى القطاع الخاص والتحول النهائي إذ أن تحويل المشروعات العامة إلى شركات خاصة وبشكل خاص إلى شركات مساهمة لا يعني أن العملية انتهت ذلك أن هذه الشركات ما زالت مملوكة للدولة بالكامل.

فالمقصود بهذه العملية ليس تأسيس هذه الشركة فحسب وإنما نقل ملكية أسهمها إلى القطاع الخاص في مرحلة لاحقة. وهذه العملية تستلزم تقييم المشروعات العامة لبيان مقدار رأسمال الشركة التي ستنتج عن عملية التحول كما وتستلزم أيضاً حلول هذه الشركة محل المشروعات العامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات⁽²⁾.

وفيما يتعلق بموقف المشرع الفرنسي- من عملية إعادة الهيكلة فلقد سبقت الإشارة إلى أن المشروعات العامة وفقاً للتشريع الفرنسي قد تتخذ شكل مؤسسات عامة صناعية أو تجارية أو شكل شركات مساهمة تملك الدولة أسهمها بالكامل أو بالاشتراك مع الأفراد أو الشركات الخاصة (شركات مختلطة).

ولأن الشكل المهيمن على المشروعات العامة في فرنسا هو شكل الشركة المساهمة التي تملك الدولة أسهمها بالكامل بسبب احتفاظ هذه المشروعات بشكلها السابق على التأميم فلقد اقتصر عمليات إعادة هيكلة المشروعات العامة في فرنسا على المؤسسات العامة الصناعية والتجارية والتي يراد تحويلها إلى القطاع الخاص.

(¹) UNCTAD, Op. Cit., P. 72.

(²) صهيب موسى جفال المومني، المرجع السابق، ص 14.

لذلك فلقد اصدر المشرع الفرنسي العديد من القوانين الخاصة بإعادة هيكلة هذه المؤسسات ومن الأمثلة على ذلك تحويل مؤسسة التبوغ والكبريت (SETA) إلى شركة مساهمة تملك الدولة رأسمالها بالكامل بموجب القانون الصادر في 1980/7/2 كذلك تحويل مؤسسة التجمع الصناعي لتسليم الأراضي (Gita) إلى شركة مساهمة بالقانون الصادر في 1989/12/23 وتحويل مؤسسة (رينو) الصناعية إلى شركة مساهمة أيضا بالقانون الصادر في 1990/7/24⁽¹⁾.

ويشير جانب من الفقه الفرنسي⁽²⁾ إلى أن عملية إعادة هيكلة المشروعات العامة قد أدت إلى تجاوز مرحلة المؤسسات العامة الصناعية والتجارية في فرنسا وان لهذه العملية مزايا عديدة لا تقتصر على التمهيد لتحويل المشروعات العامة التي تتخذ شكل المؤسسة إلى القطاع الخاص إذ أن تقسيم رأسمال المشروعات العامة إلى اسهم عن طريق اتخاذ هذه الشركات شكل الشركة المساهمة يسمح للمشروع بان يكيف قدراته المالية بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية المحيطة به إذ يمكنه مثلا أن يزيد من رأسماله عن طريق طرح اسهم جديدة للاكتتاب العام كما أن هذا الأمر يسهل على هذه المشروعات الاشتراك مع مشروعات أخرى لتأسيس شركات مشتركة بينها.

كذلك أولت العديد من التشريعات المقارنة اهتماما بهذه العملية كما هو عليه الحال بالنسبة إلى التشريع الأردني والمصري، وفيما يتعلق بالتشريع المصري فلقد كان التشريع المنظم لشركات القطاع العام هو القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، ومن اجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية جديدة وتبسيط تحول الشركات العامة إلى القطاع الخاص، صدر قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بيد أن هذا القانون لم يقرر إلغاء قانون هيئات القطاع العام وشركاته لسنة 1983، مما أدى إلى ازدواج النظام القانوني للشركات العامة في مصر وتضييق نطاق تطبيق القانون رقم 97 لسنة 1983، إذ اقتصر تطبيقه على الشركات العامة التي لا تخضع لأحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 وهي الشركات المقرر

(¹) Jean-philippe colson, Op. Cit., P. 254.

(²) المرجع نفسه، ص 263.

لها أنظمة خاصة⁽¹⁾. ومن أجل تسهيل إجراءات تحويل الشركات العامة إلى القطاع الخاص تمت إعادة هيكلة وحدات القطاع العام المصري بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه فقد نصت المادة الثانية من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذه القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر" وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويكون رأس مالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة⁽²⁾ والشركة القابضة هي شركة تمتلك مجموعة شركات تابعة، وتقوم باستثمار أموالها من خلال هذه الشركات التابعة ويكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها⁽³⁾.

أما الشركة التابعة فهي الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل، وتتخذ الشركة التابعة شكل الشركة المساهمة ويقسم رأس مالها إلى أسهم اسمية متساوية القيمة⁽⁴⁾.

(¹) وقد أكدت المادة (9) من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 ذلك " إذ جعلت لرئيسي- الجمهورية السلطة بعد - موافقة مجلس الوزراء - لتحويل الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضة أو شركات تابعة تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ويرى البعض أن تحويل رئيس الجمهورية هذه السلطة يخالف أحكام الدستور المصري. رضا عبد الحميد السيد، شرح قانون شركات قطاع الأعمال العام، القاهرة، 1993، ص 16-17.

(²) المادة (1) من قانون شركات قطاع الأعمال المصري.

(³) المادة (1) و (2) من قانون شركات قطاع الأعمال المصري. لمزيد من التفصيل في دور الشركات القابضة في عمليات التحويل إلى القطاع الخاص، ماري شري، جون نبليس، المرجع السابق، ص 61.

(⁴) المواد (16 و 18) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري.

- وعلى أي حال يلاحظ أن قانون شركات القطاع الأعمال العام المصري لسنة 1991 قد تضمن العديد من الأحكام التي من شأنها التقريب بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة الخاصة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981 ولعل أهم أوجه التقارب تتمثل فيما يأتي⁽¹⁾:
1. تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن الشركات الخاصة "المساهمة والمحدودة والتوصية" على الشركات القابضة والتابعة، فيما لم يرد بشأنه نص في القانون رقم (203) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية⁽²⁾.
 2. المساواة في المعاملة من حيث المزايا والحقوق والالتزامات بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة الخاصة، فلا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام من أية مزايا أو تحميلها أية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين الشركات المساهمة الخاصة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1983⁽³⁾.
 3. خضوع العاملين في شركات قطاع الأعمال العام لقانون العمل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون قطاع الأعمال العام أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له⁽⁴⁾.
 4. جواز تداول اسهم الشركات التابعة طبقاً للأحكام القانونية الخاصة بتداول اسهم الشركات المساهمة الخاصة ويختلف هذا الحكم عن الوضع القائم في

(¹) د. حسام الدين عبد الغني الصغير، بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام للعاملين في إطار البرنامج الحكومي لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص - برنامج الخصخصة، دار الفكر العربي ودار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص12 وما بعدها.

(²) المادة (1) من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، والمادة (1) من مواد إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(³) المادة (7) من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري.

(⁴) المادة (48) من قانون شركات قطاع الأعمال العام لسنة 1991 المصري وكانت علاقات العمل في القطاع العام تخضع لقانون العاملين في القطاع العام رقم 48 لسنة 1978 المصري.

ظل العمل بالقانون رقم (97) لسنة 1983 إذ لم تجز المادة (27) من هذا القانون التصرف في أسهم شركات القطاع العام المملوكة لهيئة القطاع العام سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الأشخاص العامة وبنوك وشركات القطاع العام⁽¹⁾.

وفضلاً عما تقدم قرر المشرع المصري في المادة الخامسة من قانون إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام أن يتم تقييم صافي أصول كل شركة من الشركات القابضة والشركات التابعة التي حلت في تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 محل هيئات القطاع العام وشركاته التي كانت خاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وفقاً للقواعد التي تقرها الجمعية العامة لكل شركة من هذه الشركات، كما وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال، كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته المملوكة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسال مسؤولية كاملة عنها⁽²⁾. وتعد هذه الأحكام القانونية من مستلزمات عملية إعادة الهيكلة القانونية التي أشرنا إليها. وفيما يتعلق بالتشريع الأردني فلقد عالج المشرع الأردني عملية إعادة هيكلة المشروعات العامة في المادة (8) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة (1997)، فقد نصت هذه المادة على أنه "على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون:

أ. يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير⁽³⁾ ووزير المالية والوزير المختص تحويل مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة إلى شركة مساهمة عامة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها

⁽¹⁾ المادة (20) من قانون شركات قطاع الأعمال المصري: وانظر د. محمود سالم، قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 - دوره في برنامج الإصلاح الاقتصادي ودور المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام في تصحيح مسيرة شركات قطاع الأعمال العام، مطبعة الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية، القاهرة، 1997، ص 52.

⁽²⁾ المادة (2) من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال المصري.

⁽³⁾ المقصود بالوزير هو وزير الصناعة والتجارة، المادة (2) من هذا القانون.

باستثناء المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها، فيتوجب تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بموجب أحكام هذه المادة.

ب. يحدد رأس مال تلك الشركة بإعادة تقدير موجودات المؤسسة أو السلطة أو الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام القانون على أن يكون من بين أعضاء لجنة إعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر هذه الموجودات اسهما نقدية في رأس مال الشركة.

ج. يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمنا أسلوب بيع وتداول أسهمها وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقا لأحكام هذا القانون.

د. لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون.

هـ. تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها.

و. تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعا في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.

ومن هذا النص يتضح لنا أن المشرع الأردني قد جاء بأحكام تفصيلية بخصوص إعادة هيكلة المشروعات العامة فحدد الجهة المختصة باتخاذ هذا القرار كما حدد شكل الشركة الناجمة عن هذا التحول بالشركة المساهمة العامة والتي يتكون رأسمالها من موجودات المشروعات العامة التي يتم تقييمها وفقا لأحكام القانون،

ويكون راس المال مملوكا بالكامل للدولة بحيث تستطيع الدولة تحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص عن طريق بيع أسهمها، وتعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمشروعات العامة التي تنقضي جراء إعادة الهيكلة من خلال ما يسمى بالتشريك⁽¹⁾.

ويتبين لنا من خلال ما تقدم، أن المشرع المصري قد عمد إلى إعادة هيكلة جميع الشركات العامة من خلال إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الذي يسري على جميع الشركات العامة باستثناء الشركات المقرر لها أنظمة خاصة، أما المشرع الأردني فلم يجعل عملية إعادة الهيكلة القانونية شاملة لجميع المشروعات العامة، وإنما قصرها على المشروعات العامة التي يراد تحويلها إلى القطاع الخاص فقط.

أما عن موقف المشرع العراقي من عملية إعادة الهيكلة القانونية للمشروعات العامة قبل تحويلها إلى القطاع الخاص فإن منطق البحث الدقيق يقتضي أن نبين الأحكام القانونية الخاصة بهذه العملية وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بهذا الشأن ثم نبين بعد ذلك موقف قانون الشركات العامة من هذه العملية.

وفيما يتعلق بقرارات مجلس الثورة الخاصة بعملية التحويل إلى القطاع الخاص فلقد اصدر مجلس قيادة الثورة العديد من القرارات التي تجيز تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص لعل أهمها هو قرار مجلس قيادة الثورة رقم (273) الصادر في 1989/4/23 الملغي⁽²⁾ والذي أجاز بقرار من رئيس الجمهورية نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قيمته التقديرية على مليون دينار إلى القطاع المختلط أو

(¹) ومن الأمثلة على ذلك، قرار مجلس الوزراء الأردني الصادر بتاريخ 1996/10/7 بتحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة يقدر رأسمالها بمائتين وخمسين مليون دينار أردني. وانظر: د. هاني الطهراوي، القانون الإداري - الكتاب الأول "ماهية القانون الإداري- التنظيم الإداري - النشاط الإداري"، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 1998، ص292.

(²) الوقائع العراقية، العدد (3254) في 1989/5/8، وقد نصت الفقرة (ثالثا) من هذا القرار على انه "ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة خمس سنوات فقط".

القطاع الخاص بقيمته التقديرية، وتتخذ الجهة التي تنتقل إليها ملكية المشروع شكل شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983. كما واصلت مجلس قيادة الثورة القرار رقم (140) لسنة 1993 الملغى⁽¹⁾ ووفقاً لهذا القرار يخول وزير الصناعة والمعادن صلاحية تحويل المعامل التابعة للوزارة إلى شركة (مساهمة عامة) بعد الحصول على موافقة ديوان الرئاسة، ويتم ذلك من خلال تقدير موجودات هذه المعامل وفقاً للمعايير المعتمدة في وزارة الصناعة والمعادن⁽²⁾ ومن ثم تتولى وزارة الصناعة والمعادن إعداد عقد للشركة تقدمه إلى مسجل الشركات الذي يتولى تسجيل الشركة وإصدار شهادة تأسيسها ونشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية والنشرة وفي صحيفة يومية واحدة وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها⁽³⁾ وموجب هذا القرار تحتفظ الوزارة بنسبة (25%) من أسهم الشركة وتطرح ما لا يتجاوز 75% من أسهم الشركة للبيع بالمزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة⁽⁴⁾.

وفضلاً عما تقدم فقد أجاز قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) الصادر في 1995/9/20⁽⁵⁾، تحويل المنشآت والشركات والمعامل إلى شركات مساهمة خاصة أو مختلطة. وهذه القرارات لم تشر إلى عملية إعادة هيكلة المشروعات العامة قبل تحويلها إلى القطاع الخاص، بل إنها تتحول مباشرة إلى شركة من شركات القطاع الخاص أو المختلط. وذلك على الرغم من أن قرار مجلس قيادة الثورة رقم 100 لسنة

(¹) الوقائع العراقية، العدد (3477) في 1993/9/27، وقد غيى هذا القرار بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (67) الصادر في 8/6/1996 المنشور في الوقائع العراقية، العدد (3726) في 1996/6/15.

(²) الفقرة (1/أ) من هذا القرار.

(³) الفقرة (1/أ) من هذا القرار.

(⁴) الفقرة (1/ب) من هذا القرار.

(⁵) الوقائع العراقية، العدد (3583) في 1995/10/2، وقد نصت الفقرة تاسعاً من هذا القرار على أن يعمل به ثلاث سنوات، غير أن قرار مجلس قيادة الثورة رقم (12) الصادر في 1999/2/7 جدد العمل بهذا القرار، الوقائع العراقية، العدد (3761) في 1999/2/15.

1995 المشار إليه، قد نص على تحويل المنشآت أو الشركات أو المعامل التابعة للقطاع الاشتراكي إلى شركات مساهمة تكتسب الشخصية المعنوية قبل طرح أسهمها للجمهور للاكتتاب العام فلقد نصت الفقرة (ثالثا/2/ب) من هذا القرار على انه "بعد تنزيل مساهمة القطاع الاشتراكي في رأسمال الشركة المساهمة المختلطة تطرح اسهم الشركة المختلطة أو الخاصة لمدة سنتين يوميا من تاريخ تسجيل الشركة إلى الفئات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذا القرار حصرا ببيان تصدر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي تعود لها المنشأة أو الشركة أو المعمل ينشر في صحيفتين يوميتين في الأقل وفي النشرة الخاصة بالشركات التي يصدرها مسجل الشركات " فهذا النص يشير إلى أن الجهة التي تتولى تأسيس الشركة المساهمة الخاصة أو المختلطة، هي الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة والتي يعود لها المعمل أو المنشأة أو الشركة دون أن يكون المقصود منه إعادة هيكلة المنشأة أو المعمل أو الشركة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص على النحو الذي أشرنا إليه بالنسبة إلى القوانين المقارنة، ذلك أن المقصود بإعادة الهيكلة القانونية للمشروعات العامة هو تحويلها إلى شركات مساهمة تملك الدولة رأسمالها بالكامل، الأمر الذي يسمح للدولة ببيع هذه الأسهم للقطاع الخاص وفقا للطريقة التي تراها مناسبة أو لبيعها على شكل دفعات للحيلولة دون بيع الأسهم بسعر منخفض فيما إذ بيعت دفعة واحدة لعدم قدرة السوق المالية على استيعابها أو لكي يتسنى للدولة تحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص عن طريق زيادة رأسمالها بأموال يقدمها القطاع الخاص أو دمجها بشركات خاصة الأمر الذي لا يمكن تصوره - على الأغلب - فيما لو كانت المشروعات العامة تخضع لنظام قانوني يختلف عن ذلك الذي تخضع له الشركات الخاصة.

وهذه المزاي لا يمكن أن تتحقق وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه ذلك أن الفقرة (2/ج) من هذا القرار تنص صراحة على أن طرح الأسهم للجمهور إنما يتم عن طريق (الاكتتاب العام) وفقا لأحكام قانون الشركات العراقي⁽¹⁾. وهذا يعني أن

(1) وتنص الفقرة (2/ج) من هذا القرار على انه "إذا ظهر بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) أعلاه أن عدد الراغبين في شراء اسهم الشركة قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فتقسم الأسهم

عملية التحول وفقا لأحكام هذا القرار، إنما تتم عن طريق تأسيس شركة جديدة، ذلك أن طرح الأسهم للاكتتاب العام لا يكون إلا عند تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها، كما أن طرح الأسهم للاكتتاب العام يقتضي- أن يكون بقيمتها الاسمية وهي دينار واحد فقط⁽¹⁾.

أما فيما يتعلق بقانون الشركات العامة سنة 1997 فيلاحظ ابتداء أن هذا القانون لم يعتمد إلى إعادة هيكلة جميع المشروعات العامة التي تحولت إلى شركات عامة وفقا للمفهوم الذي أوردناه والذي اخذ به المشرع المصري في قانون شركات قطاع الأعمال العام لسنة 1991 فبالرغم من أن المادة (40) من قانون الشركات العامة العراقي قد قضت بتحول جميع الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع الاشتراكي الممولة ذاتيا والتي تمارس نشاطا اقتصاديا إلى شركات عامة، فإن هذه الشركات العامة لا تخضع لذات الأحكام التي تخضع لها الشركات المساهمة الخاصة أو المختلطة سواء في تأسيسها أو إدارتها أو انقضاءها⁽²⁾، ولعل ابرز اوجه الاختلاف فيما بين الشركة العامة والشركة المساهمة الخاصة أو المختلطة والذي قد يكون عائقا أمام عملية التحول هو أن رأسمال الشركات العامة لا يقسم إلى اسهم قابلة للتداول، بل يتكون من حصة واحدة أو عدة حصص إذا اشترك في تأسيسها شخصان أو أكثر من الأشخاص المعنوية العامة الممولة ذاتيا⁽³⁾، ومن ثم لا يمكن تحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص بمجرد نقل ملكية أسهمها طالما أن رأسمالها لا يقسم إلى اسهم ابتداء عند

بينهم قسمة غرماء، ويجري التوزيع إلى اقرب سهم صحيح، أما إذا كان الاكتتاب اقل من الأسهم المطروحة، فيطرح المتبقي منها إلى عموم المواطنين وفق أحكام قانون الشركات ذي الرقم 36 لسنة 1983".

(¹) المادة (30) من قانون الشركات العراقي.

(²) نظم المشرع العراقي أحكام تأسيس الشركات العامة في المواد (7-3) من قانون الشركات العامة، وتضمنت المواد (19-27) من هذا القانون الأحكام القانونية الخاصة بإدارة هذه الشركة ومجلس إدارتها والمدير المفوض، غير أن هذا القانون لم يعالج هذا القانون من صور الانقضاء سوى الدمج في المواد (31-34) وكذلك التحول في الماد (35-38) والأحكام التي تضمنتها هذه المواد تختلف في مجملها عن الأحكام التي تخضع لها الشركات الخاصة.

(³) المادة (9/ثالثا) من قانون الشركات العامة العراقي.

تأسيسها، كما ولا يمكن أيضا تحويلها إلى القطاع الخاص عن طريق زيادة رأسمالها بأموال مقدمة من القطاع الخاص من خلال الاكتتاب العام.

ومما تقدم، يتضح لنا أن المشرع العراقي لم يعتمد على إعادة هيكلة المشروعات العامة بحيث يسهل تحويلها إلى شركات خاصة أو مختلطة من خلال تنظيمه لهذه المشروعات في قانون الشركات العامة. غير أنه ومن جهة أخرى أجاز في قانون الشركات العامة تحول الشركات العامة إلى شركات مساهمة بموافقة مجلس الوزراء، وذلك من خلال إعداد الوزارة المعنية دراسة بالمسوغات الاقتصادية والفنية للتحول وأسلوب تقييم قيمة اسهم راس المال وطريقة بيعها وترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها⁽¹⁾ وبعد موافقة مجلس الوزراء على التحول تقوم الوزارة بإعداد (عقد جديد للشركة)⁽²⁾ تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء إلى المسجل "كما تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ آخر نشر لقرار التحول"⁽³⁾.

ومن الواضح لنا، أن هذه الأحكام التي نص عليها قانون الشركات العامة لا تقتضي- أن تتم إعادة هيكلة الشركات العامة التي يراد تحويلها إلى شركات مساهمة قبل بيع أسهمها للقطاع الخاص، ومن ثم فإن عملية التحول تكون بشكل مباشر أي أن الشركة العامة تتحول إلى شركة مساهمة خاصة أو مختلطة دون المرور بمرحلة وسطى تكون فيها اسهم هذه الشركة مملوكة للوزارة المعنية بالكامل.

ولكل ما تقدم نقترح على المشرع العراقي أن ينظم في قانون الشركات العامة عملية إعادة هيكلة الشركات العامة قبل تحويلها إلى شركات مساهمة بحيث يتم تحويل

(¹) المادة (36) من قانون الشركات العامة العراقي.

(²) أن عبارة (عقد جديد للشركة) الواردة في المادة (37) من قانون الشركات العامة العراقي توحى بأن الشركة العامة تنشأ ابتداء بموجب عقد، وأن تحويلها يستلزم إعداد عقد جديد. في حين أن المادة (4) من هذا القانون تنص صراحة على أنه "تقوم الوزارة بإعداد عقد أو بيان خاص بتأسيس الشركة"، وفي تقديرنا أن الغالب هو أن هذه الشركة تتأسس بموجب بيان وإنها لا تتأسس بموجب عقد إلا إذا اشترك في تأسيسها أكثر من شخص من الأشخاص المعنوية العامة.

(³) المادة (37/أولا - ثانيا - ثالثا) من قانون الشركات العامة العراقي.

الشركات العامة إلى شركات مساهمة تعمل وفقا للأسس التجارية وتخضع لقانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997، وتكون جميع اسهم هذه الشركة مملوكة للوزارة المعنية على أن يدير هذه الشركة مدير ومجلس إدارة يعينهم الوزير المختص ليتولوا إدارة الشركة لحين تحويلها إلى القطاع الخاص وعلى أن تحل هذه الشركة محل الشركة العامة في جميع حقوقها والتزاماتها ابتداء من تاريخ اكتساب الشركة الجديدة للشخصية المعنوية، ثم تتولى الوزارة تحويل هذه الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مختلطة بالطريقة التي تراها مناسبة سواء عن طريق بيع أسهمها للقطاع الخاص أو عن طريق دمجها بشركة خاصة، أو عن طريق زيادة رأسمالها بأموال مقدمة من القطاع الخاص.

إذ أن من شأن هذا الحكم أن يسهل عملية تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة خاصة أو مختلطة فهو يسمح للوزارة أن تختار الأسلوب والوقت المناسبين لتحويل الشركة العامة فمن حيث الأسلوب يمكن إعادة هيكلة الشركة العامة على النحو السالف الذكر، من تحويل الشركة العامة إلى شركة مساهمة خاصة، أو مختلطة ليس من خلال بيع اسهم هذه الشركات العامة فقط، بل من خلال دمجها بشركة خاصة أو من خلال زيادة رأسمالها عن طريق اكتتاب الجمهور باسمهم هذه الشركة أو تحويل ديون هذه الشركات إلى اسهم، وهذه الأساليب لا يمكن اتباعها ما لم يكن رأسمال الشركة العامة مقسما إلى اسهم. وتظهر أهمية تطبيق مثل هذه الأساليب على الشركات المتعثرة التي قد لا يقبل الجمهور على شراء أسهمها عند ما يراد تحويلها إلى القطاع الخاص.

أما من حيث الوقت فإن الواقع يشير إلى أن سوق بغداد للأوراق المالية قد لا تستوعب بيع أعداد كبيرة من اسهم الشركات العامة في وقت قصير الأمر الذي قد يؤثر في أسعار هذه الأسهم باتجاه الانخفاض. ويمكن تجنب مثل هذه النتيجة إذا ما تمت عملية التحول من خلال تحويل الشركة العامة إلى شركة مساهمة تمتلك الوزارة

المعنية أسهمها بالكامل بحيث تستطيع بيع اسهم هذه الشركات على شكل دفعات ودون أن يؤثر ذلك في سعر البيع⁽¹⁾.

المطلب الثاني الهيئات القائمة على عمليات التحويل إلى القطاع الخاص

أن عمليات التحويل إلى القطاع الخاص لا تعد غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق بعض الإصلاحات الاقتصادية لذا فقد حرصت معظم الدول التي طبقت برامج التحويل إلى القطاع الخاص على أن تتولى "لجان أو هيئات" إدارة وتنسيق هذه البرامج، وفي الغالب تشترك في هذه الهيئات أطراف لها علاقة مباشرة بالمشروعات العامة التي يراد تحويلها إلى القطاع الخاص، وخاصة "الوزراء المعنيين" ذلك انهم يأخذون على عاتقهم نجاح أو فشل برامج التحويل إلى القطاع الخاص من الناحيتين السياسية والاقتصادية⁽²⁾.
وتأسيسا على ما تقدم خول المشرع الفرنسي وزير الاقتصاد الصلاحيات اللازمة لإدارة وتنفيذ عمليات التحويل إلى القطاع الخاص، فقد خول المشرع الفرنسي

(¹) ويشير الواقع العملي إلى انه قد تم بيع اسهم بعض الشركات السياحية المساهمة المختلطة والتي تم تحويلها إلى القطاع الخاص بناء على أمر السيد رئيس الجمهورية المبلغ إلى دائرة تسجيل الشركات بكتاب ديوان الرئاسة 42999 في 1988/11/27 في مكتب تداول الأسهم التابع للمصرف الصناعي بدلا من سوق بغداد للأوراق المالية، إذ أن الوزارة طلبت بيع أسهمها في هذه الشركات والتي تمتلكها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 630 في 1989/10/5 الذي قضى- بأيلولة كافة اسهم الشركات السياحية التي لم يكتب بها إلى وزارة المالية، وقد بررت الوزارة طلبها هذا، بان البيع يتم في المصرف الصناعي بصورة يومية أما في سوق بغداد فانه يتم بصورة محددة بجلسات أسبوعية.
د. عباس مرزوك فليح العبيدي، المرجع السابق، ص144.

(²) Metin R. Ercan, Efficency of Institutions and the privatization process: the Turkish privatization administration in critical perspective, Escaw, proceedings expert grope meeting on the institutional aspects of privatization in the Escaw region, Beirut, 1-3 Dec., 1997, U. N., New York, 1999, P. 42.

وزير الاقتصاد سلطة الموافقة على إنشاء سهم خاص iquefaction speci تملكه الدولة في الشركات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص والذي من شأنه أن يمكن الدولة من المحافظة على استمرار هذه الشركات وحماية المصالح الوطنية، كما خول المشرع الفرنسي وزير الاقتصاد سلطة الموافقة على عمليات البيع خارج سوق الأوراق المالية وتحديد سعر البيع النهائي غير أن سلطة وزير الاقتصاد في هاتين الحالتين مقيدة بموافقة لجنة المشاركات والتحويلات "Commission des participations et des transferts de paiement" (1) إذ لا يجوز للوزير أن يوافق على البيع خارج سوق الأوراق المالية إلا بموافقة هذه اللجنة كما لا يجوز له الموافقة على البيع بسعر أقل من السعر الذي حددته هذه اللجنة (2).

وتتكون لجنة المشاركات والتحويلات من (7) أعضاء من ضمنهم الرئيس ويتم اختيارهم بحسب خبرتهم في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية، وفي حالة حصول شاغر في عضوية هذه اللجنة، يعين بديل له لمدة تمتد حتى نهاية مدة تعيين سلفه.

ومن أجل ضمان حياد أعضاء هذه اللجنة حضر المشرع الفرنسي عليهم مزاولة أي عمل بموجب توكيل من أحد أعضاء مجلس إدارة أو مجلس الرقابة الشركات التي يراد تحويلها إلى القطاع الخاص، كما وحظر عليهم ممارسة أي نشاط له علاقة بهذه الشركة، ويلتزم أعضاء هذه اللجنة وابتداء من تاريخ تعيينهم بإعلام رئيس اللجنة بالنشاطات المهنية التي يقومون بها أو أي عمل قد يقومون به بموجب وكالة طوال فترة عضويتهم في اللجنة كما ويلتزمون أيضا بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم في هذه اللجنة، ويمكن عزل العضو الذي يخل بهذه الالتزامات بموجب قرار يصدر من اللجنة نفسها بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات بين الأعضاء يعد رأي رئيس اللجنة حاسما للخلاف. كذلك فلقد حظر

(1) وهذه اللجنة كانت تسمى بلجنة الخصخصة "Commission de la privatisation" قبل تعديل القانون الفرنسي عام 1993.
(2) لم يخصص المشرع الفرنسي نصا يبين اختصاصات وزير الاقتصاد في عمليات التحويل إلى القطاع الخاص، بل يبين هذه الاختصاصات في نصوص متفرقة.

المشرع الفرنسي على أعضاء هذه اللجنة أن يشغلوا خلال الخمس سنوات التالية لانتهاؤ عملهم في اللجنة عضوية مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في الشركات التي كانت الدولة تساهم في رأسمالها قبل تحويلها إلى القطاع الخاص⁽¹⁾.

وعلى أية حال، يلاحظ أن المشرع الفرنسي قد حدد الشركات العامة التي يراد تحويلها إلى القطاع الخاص من خلال (ملحق) بالقانون وخول وزير الاقتصاد سلطة تحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص بموجب مرسوم يصدر عنه⁽²⁾.

أما عن الجهات المختصة بالإشراف على تنفيذ عمليات التحويل إلى القطاع الخاص في مصر، فلقد حدد دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية وإعادة الهيكلة وحوافز العاملين والإدارة لسنة 1996 هذه الجهات على النحو الآتي:

1. مجلس الوزراء.
2. اللجنة الوزارية المختصة بشركات قطاع الأعمال العام.
3. وزير قطاع الأعمال العام.
4. المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام.
5. الشركات القابضة.
6. الشركات التابعة⁽³⁾.

وقد حدد هذا الدليل صلاحيات أو اختصاصات كل من هذه الجهات إذ يتولى مجلس الوزراء اعتماد البرنامج السنوي للتحويل إلى القطاع الخاص، فضلا عن بيان القواعد والسياسات العامة لهذا لبرنامج، أما اللجنة الوزارية فتكون برئاسة رئيس

(¹) المادة (3) من قانون "الخصخصة الفرنسي" الصادر في 1986/8/2 المعدل. وانظر:

PENE(D.):Laprivatisation en france AJDE, No. 5, 20 Mai.,1987, P. 5.

(²) ولقد تضمن القانون الصادر في 1996/8/6 (65) شركة في حين تضمن القانون الصادر في 1993/7/19 (21) شركة يراد تحويلها إلى القطاع الخاص.

(³) انظر في التنظيم المنفذ للبرنامج في مصر، ص 16-19 من هذا الدليل.

مجلس الوزراء وتتألف من (22) عضواً من ضمنهم (18) وزيراً من ذوي الشأن⁽¹⁾ وتتولى دراسة البرنامج السنوي للتحويل إلى القطاع الخاص المقدم من قبل وزير قطاع الأعمال العام ومكوناته وضوابط وقواعد تنفيذه واعتماده للعرض على مجلس الوزراء ويتولى وزير قطاع الأعمال العام بمعونة المكتب الفني، وضع برنامج التحويل إلى القطاع الخاص وتحديد أولويات المنشآت التي تعرض للبيع، وكذلك تسهيل عملية البيع على أن يعتمد البرنامج من اللجنة الوزارية المشار إليها كما يقع ضمن اختصاصه متابعة تنفيذ البرنامج وتقييم نتائجه ويرفع بذلك تقريراً إلى اللجنة الوزارية. أما المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام الذي أنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام رقم (7411) لسنة 1991 فهو يقوم بمهمة الأمانة الفنية في مجال تنفيذ القانون رقم (23) لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، إذ يتولى المكتب الفني معاونة الشركات القابضة في إعداد برنامج البيع لجزء من محفظة استثماراتها سنوياً وعرض ذلك على وزير قطاع الأعمال العام، ومتابعة تنفيذ برامج التحويل إلى القطاع الخاص في الشركة التابعة وتلقي التقارير الدورية (شهرية وربيع سنوية وسنوية) عن تنفيذ البرامج التي توافق عليها مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وعرض المؤشرات الرئيسية التي يتم التوصل إليها من هذه التقارير على وزير قطاع الأعمال العام، فضلاً عن اشتراكه مع هيئة سوق المال في مراجعة السعر العادل لأسهم الشركات التي ستطرح لأول مرة، وذلك قبل الموافقة عليها من مجلس إدارة الشركة القابضة⁽²⁾.

أما عن دور الشركات القابضة والشركات التابعة فالشركات القابضة تقوم بتنفيذ البرنامج المتفق عليه، وذلك تحت إشراف وزير قطاع الأعمال العام، ولها أن تستعين بما تحتاج إليه من خبراء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أما الشركات التابعة فيحق لإدارة هذه الشركات أن تباع أو تؤجر أي أصل من أصولها أو أي خط من خطوط إنتاجها

(¹) نقلاً عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تقييم برامج الخصخصة في منطقة الاسكوا، المرجع السابق، ص 58.

(²) د. منير إبراهيم هندي، المرجع السابق، ص 147-148.

الذي لا تستطيع استغلاله اقتصاديا وذلك تنفيذا لقرارات مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، ومما تجدر ملاحظته أن بيع الأسهم التي تملكها الشركات القابضة في الشركات التابعة يدخل في الأصل ضمن اختصاصات مجلس إدارة الشركة القابضة⁽¹⁾، غير أنه إذا ترتب على بيع كل أو بعض الأسهم انخفاض نسبة مساهمة الشركة القابضة أو الأشخاص المعنوية العامة وبنوك القطاع العام في رأسمال الشركة التابعة عن 51% فإن الاختصاص بالتصرف في الأسهم ينعقد للجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة⁽²⁾، ذلك أن البيع في هذه الحالة يؤدي إلى تحول الشركة التابعة إلى شركة مساهمة خاصة⁽³⁾.

(¹) ويتألف مجلس إدارة الشركة القابضة وفقا للمادة (3) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري، من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي:

1. رئيس متفرغ للإدارة، 2. عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوي الخبرة في النواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال، 3. ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد. ويعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة ويصدر قرار تشكيل مجلس الإدارة من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(²) ووفقا للمادة (9) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري تتكون الجمعية العامة للشركة القابضة من:

1. الوزير المختص (وهو وزير قطاع الأعمال العام) رئيسا.
2. أعضاء من ذوي الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة لا يقل عددهم عن اثني عشر- ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للمادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المصري لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائها على الأقل مما فيهم رئيس الجمعية، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، أما قرارات الجمعية العامة غير العادية فلا تصدر إلا بأغلبية ثلثي عدد أصوات الحاضرين. كما تنص المادة (29) من هذه اللائحة انه " مع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام خاصة بهذه اللائحة تسري في شأن إجراءات وشروط وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية المواد من 200 إلى 231 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليها".

(³) إذ أن انخفاض نسبة مساهمة الشركات القابضة عن 51% من رأسمال الشركة التابعة، يؤدي إلى تحولها إلى شركة خاصة، وفقا لما ورد في المادة (16) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري، وانظر: د. محمود سالم، المرجع السابق، ص 50.

أما عن موقف المشرع المغربي فقد اسند تنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمامها أو مواكبتها إلى وزير تساعده لجنة وزارية تكون تحت رئاسته ويطلق عليها اسم (لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص) وتتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يعينون (بظهير شريف) ويراعى في اختيارهم ما يتمتعون به من كفاءة في الميادين الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولهذه اللجنة أن تستعين بصورة مؤقتة أو مستديمة بخبراء مستشارين تختارهم من بين الشخصيات أو الهيئات التي ترى فائدة في الاستعانة بخبراتها⁽¹⁾.

وقد حدد المشرع المغربي صلاحيات الوزير المختص بهذه العمليات في المرسوم المرقم (290403) الصادر في 1990/10/16⁽²⁾، إذ يتولى الوزير المختص بعمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وفقا لهذا المرسوم رئاسة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتوجيه الدعوة لاجتماعاتها وتحديد جدول أعمالها، كما يتولى إعداد برنامج عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتحديد الجدول الزمني لإنجازها كذلك للوزير أن يطلب من مديري الشركات والمنشآت المراد تحويلها إلى القطاع الخاص اطلاعه على جميع الوثائق والدراسات والبيانات والمعلومات والمقترحات المفيدة للقيام بعمليات التحويل، وللوزير أيضا أن يعمل على إجراء تقييم أولي للمساهمات والمنشآت المراد تحويلها إلى القطاع الخاص بواسطة خبراء يختارهم مباشرة، فضلا عن ذلك خول هذا المرسوم الوزير المختص بإصدار قرار يقضي- بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يشتري عند تحويل مساهمات من القطاع العام إلى القطاع الخاص عددا من الأسهم أو الحصص يتعدى نسبة مئوية معينة، وللوزير أيضا أن يصدر قرارا يحدد المبلغ الأقصى- للأسهم أو الحصص التي يجوز أن يشتريها عند تحويل مساهمات من القطاع العام إلى القطاع الخاص أشخاص طبيعيين أجانب أو أشخاص معنوية أجنبية أو خاضعة لمراقبة أجنبية، كذلك فإن للوزير بعد موافقة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع

⁽¹⁾ المادة الثانية من قانون التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص المغربي لسنة 1990.

⁽²⁾ انظر نص هذا المرسوم في الموسوعة المغربية في التشريع والقضاء، المرجع السابق، ص مؤسسات - تشريع - ن 75-76.

الخاص بتقديم اقتراحات للوزير الأول تهدف إلى بيع بعض المساهمات أو المنشآت العامة مباشرة لبعض الأشخاص وله أيضا أن يقدم اقتراحات للوزير الأول في شأن العمليات الرامية إلى إنجاز التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بقصد اتخاذ قرار بشأنها.

وفضلا عما تقدم، حدد المشرع المغربي كيفية عمل لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بالمرسوم المرقم (290578) الصادر في 1990/10/16⁽¹⁾، فوفقا لهذا المرسوم تجتمع لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بدعوة من رئيسها (الوزير المختص) والذي يتولى تحديد جدول أعمالها، وتصدر لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها الرئيس وثلاثة من أعضائها على الأقل وإذا شغل مقعد أحد أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص لأي سبب من الأسباب وجب تعيين من يحل محله وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون المغربي المشار إليها.

أما عن موقف المشرع العراقي فيلاحظ أنه ليس هناك جهة معينة بالذات تتولى الإعداد والتنفيذ لعمليات التحويل إلى القطاع الخاص، ففيما يتعلق بتحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة، وفقا لقانون الشركات العامة العراقي لسنة 1997، تختص الوزارة ذات العلاقة ومجلس الوزراء بتنفيذ عملية التحويل⁽²⁾، فوفقا للمادة (36) من قانون الشركات العامة العراقي "تعد الوزارة دراسة بالمسوغات الاقتصادية والفنية للتحويل، وأسلوب تقييم قيمة اسهم رأس المال وطريقة بيعها وترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وهذا يعني أن المبادرة في اختيار الشركات

⁽¹⁾ انظر نص المرسوم في الموسوعة المغربية للتشريع والقضاء، المرجع السابق، ص 79.

⁽²⁾ وطبقا لقرار مجلس قيادة رقم 140 لسنة 1993 (الملغي)، يصدر قرار تحويل المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، من قبل وزير الصناعة والمعادن بعد موافقة ديوان الرئاسة على ذلك (الفقرة 1) من هذا القرار.

العامة المراد تحويلها إلى شركات مساهمة تكون من قبل الوزارة المعنية، وإن الوزير المختص هو الذي يتخذ قرار التحول في أول الأمر، ثم يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للموافقة عليه⁽¹⁾. ووفقاً للمادة الأولى من قانون الشركات العامة العراقي يقصد بتعبير الوزير الوارد في هذا القانون، الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، كما يقصد بتعبير الوزارة، الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويمكن تحديد الوزارة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي تتولى الإعداد لعملية التحول على النحو السالف الذكر بالوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة والتي تقوم بتقديم طلب إلى مجلس الوزراء لتأسيس الشركة العامة، والتي تقوم بإعداد عقد أو بيان خاص بتأسيس الشركة⁽²⁾. وهذا المعيار كفيل بتحديد الوزارة أو الجهة التي تتولى الإعداد لتحول الشركة العامة في حالة اشتراك شخصين أو أكثر من الأشخاص المعنوية العامة الممولة ذاتياً في تأسيس شركة عامة، إذا كانت هذه الأشخاص المعنوية العامة تتبع وزارات مختلفة⁽³⁾، ففي مثل هذه الحالة، تكون الوزارة المختصة هي الوزارة التي تقدم طلب تأسيس الشركة إلى مجلس الوزراء والتي تتولى إعداد عقد هذه الشركة بعد موافقة مجلس الوزراء كما ذكرنا.

أما إذا كان التحول إلى القطاع الخاص يتم من خلال بيع الموجودات ودون تحويلها إلى شركات فإن الجهة المختصة باتخاذ قرار البيع، تتمثل بالوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله، وتحدد في القرار أنواع وأوصاف الأموال التي يراد بيعها⁽⁴⁾ ويتم بيع هذه الموجودات من قبل لجان تشكل

(1) وقد أكدت المادة (35) من قانون الشركات العامة على ذلك بنصها على أنه "يجوز تحول الشركة العامة إلى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء"، ولعل من المناسب أن نذكر أن العديد من الدول كبلغاريا وغانا والبرتغال وماليزيا قد جعلت سلطة الموافقة على عمليات التحول إلى القطاع الخاص لمجلس الوزراء أيضاً انظر:

UNCTAD, op. Cit., p. 54.

(2) المادتان 3 و 4 من قانون الشركات العامة العراقي.

(3) وقد أجازت المادة (9/9) من قانون الشركات العامة العراقي اشتراك أكثر من شخص معنوي عام في تأسيس الشركة العامة.

(4) المادة الثانية من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي.

بقرار من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله⁽¹⁾.
وهما أن تعبير أموال الدولة الوارد في قانون بيع وإيجار أموال الدولة يشمل أموال القطاع الاشتراكي⁽²⁾،
فإن بيع الأسهم المملوكة للقطاع الاشتراكي في الشركات المختلطة يكون أيضا بقرار من الوزير المختص أو الرئيس
الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله، على أن لا يؤدي ذلك إلى تخفيض نسبة مساهمة القطاع
الاشتراكي عن 25% من رأسمال الشركة لتعارض ذلك مع أحكام قانون الشركات العراقي⁽³⁾.
ويتضح لنا من خلال ما تقدم، أن عمليات التحويل إلى القطاع الخاص لا تخضع في العراق لجهة معينة،
من حيث اتخاذ القرار الخاص بالتحويل وبيان شروطه وقواعده فقرار التحويل قد يصدره وزير الصناعة
والمعادن أو وزير النقل والمواصلات أو مدير الهيئة العامة للسياسة، بحسب الأحوال، كما ويتضح لنا إن تحويل
الشركات العامة إلى شركات مساهمة يستلزم موافقة مجلس الوزراء على عملية التحويل، في حين أن التحويل إلى
القطاع الخاص عن طريق بيع الموجودات كـ بعض المعامل الصغيرة أو الفنادق⁽⁴⁾ وفقا لقانون بيع وإيجار أموال
الدولة لا يستلزم موافقة مجلس الوزراء على عملية البيع⁽⁵⁾.

(¹) المادة السادسة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي.

(²) المادة الأولى / ثانيا من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي.

(³) المادة 64 / ثانيا من قانون الشركات العراقي.

(⁴) فعلى سبيل المثال أعلنت شركة رمضان مبارك العامة للمقاولات الإنشائية عن مزيدة علنية لبيع معمل طابوق التأميم ومعمل
طابوق 7 نيسان، العائدين لها وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، انظر: جريدة بابل، 18 نيسان، 2000، العدد (22702).

(⁵) ويرى البعض أن قرار بيع المشروع الصادر من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله وفقا
لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، وكذلك قرارات مجلس الوزراء بتصفية الشركات العامة أو تحويلها وفقا لأحكام قانون
الشركات العامة العراقي يمكن أن تكون محلا للطعن أمام القضاء الإداري، فوزي حسين سلمان الجبوري، المرجع السابق،
ص174.

وعلى العكس من ذلك، فقد تبين لنا أن القوانين المقارنة قد جعلت وزيرا معيناً يهيمن على عملية التحويل إلى القطاع الخاص، من حيث التنفيذ والإعداد وبيان قواعد التحويل وشروطه كما أن هذه القوانين قد نصت على تشكيل لجان خاصة لمساعدة الوزير المختص في هذه الأمور.

وتأسيساً على ما تقدم يبدو لنا أنه من الضروري أن تناط مهمة الإشراف على عمليات التحويل إلى القطاع الخاص إلى وزير معين (كوزير المالية) مثلاً بحيث يتولى هذا الوزير الإعداد لعمليات التحويل إلى القطاع الخاص من حيث اختيار المعامل أو الشركات العامة لغرض تحويلها إلى القطاع الخاص وتحديد شروط البيع وقواعده واتخاذ القرار الخاص بتحديد السعر النهائي للبيع، فضلاً عن سلطته في مطالبة مديري الشركات العامة أو من يقوم مقامهم باطلاعهم على الوثائق الضرورية لعملية التحويل إلى القطاع الخاص، كما نقترح تشكيل لجنة تتولى مساعدة الوزير المختص في هذه المهام، على أن تضم هذه اللجنة عدداً من الخبراء (سبعة مثلاً) في الأمور الاقتصادية والمالية والقانونية ويتألف هذه اللجنة الوزير المختص وتتولى هذه اللجنة الإشراف على عمليات التحويل إلى القطاع الخاص فتقوم بإعداد البرامج واختيار الشركات العامة التي يراد تحويلها إلى القطاع الخاص وتقديم تقارير دورية عن عمليات التحويل إلى القطاع الخاص للوزير المختص وتقديم التوصيات بشأن إجراء البيع خارج سوق الأوراق المالية ومراجعة عملية تقييم الشركات العامة وغير ذلك ويمكن الاسترشاد بالأحكام القانونية التي أقرتها القوانين المقارنة والتي أشرنا إليها في تحديد مهام والية عمل الوزير المختص واللجنة التي تساعد في هذا المجال.

وفضلاً عما تقدم، يجب - حسب تقديرنا - أن تتم المصادقة على جميع عمليات التحويل إلى القطاع الخاص سواء تمت عن طريق بيع الموجودات وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة أو عن طريق تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة وفقاً لقانون الشركات العامة من قبل مجلس الوزراء فلا مسوغ للتمييز بين الحالتين خاصة وأن المقصود بالموجودات التي تباع وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة الموجودات ذات القيمة المرتفعة والتي يمكن أن تشكل وحدة اقتصادية مستقلة كمعامل الطابوق أو

الفنادق وغيرها. إذ أن البيع في هذه الحالة جزءا من السياسة الاقتصادية للدولة وتوحيد الإجراءات من شأنه أن يضمن سلامة تطبيق مثل هذه السياسة الاقتصادية. وأخيرا نشير إلى أنه قد يكون عدم وجود جهات خاصة تقوم بالإشراف على تنفيذ عمليات التحويل إلى القطاع الخاص في العراق من ضمن الأسباب التي أدت إلى الاختيار غير الدقيق لبعض المشروعات العامة التي جرى تحويلها إلى القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى نزاع ملكية هذه المشروعات وإعادةتها إلى القطاع الاشتراكي مجددا والأمثلة على ذلك كثيرة منها معمل النشا والدكسترين في قضاء الهاشمية⁽¹⁾ ومدينة الحبانية الساحلية⁽²⁾ وكذلك المعامل التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص (شركات مساهمة عامة) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 140 لسنة 1993، وهي شركة طابوق القادسية وشركة سميت المثنى وشركة نسيج الديوانية وشركة نسيج الناصرية⁽³⁾.

ولا يخفى ما يؤدي إليه هذا الأمر من اثر سلبي يتمثل بتبديد الكثير من الجهود والأموال التي بذلت في سبيل تحويل هذه المشروعات العامة إلى القطاع الخاص ثم إعادةتها مجددا إلى القطاع الاشتراكي، وكذلك ما تؤدي اليه هذه العملية من خلق شعور لدى الجمهور بعدم الاطمئنان في استثمار أموالهم في المشروعات العامة التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص مما قد يشكل عائقا أمام عمليات التحويل إلى القطاع الخاص في العراق.

(¹) قرار مجلس قيادة الثورة رقم (208) الصادر في 11/30 / 1994، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 3541.

(²) قرار مجلس قيادة الثورة رقم (83) الصادر في 15/6/1998، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 3727.

(³) قرار مجلس قيادة الثورة رقم (67) الصادر في 8/6/1998 المشار إليه سابقا وقد ألغى هذا القرار قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (140) لسنة 1993 وألغى جميع الشركات المؤسسة بموجب، ونقل جميع حقوقها والتزاماتها إلى وزارة الصناعة والمعادن (الفقرة ثلثا من هذا القرار).

المطلب الثالث تقييم أسهم الشركات العامة أو أصولها

أن تقييم أسهم الشركات العامة أو أصولها، يعد من مستلزمات عملية التحول إلى القطاع الخاص، ويقصد بالتقييم في هذا المجال، تحليل دقيق وتفصيلي للموجودات أو لحقوق الشركة العامة والتزاماتها، بقصد التوصل إلى السعر العادل والمعقول، لغرض تحويلها إلى القطاع الخاص⁽¹⁾. وعملية التقييم بهذا الوصف تعد ضرورة لا غنى عنها وأيا كان الأسلوب الفني المتبع في نقل ملكية هذه الأصول أو الأسهم للقطاع الخاص⁽²⁾. ويؤدي التقييم الدقيق لهذه الأصول أو الأسهم إلى تجنب النقد الذي قد يوجه إلى الدولة أو موظفيها فيما يتعلق بتحديد سعر البيع، وخاصة البيع لشخص واحد والذي يسمى "بالشريك الاستراتيجي"⁽³⁾، كما انه يضمن للأفراد من القطاع الخاص والذين قد يقدمون على استثمار أموالهم في تملك أصول أو أسهم الشركات العامة التي تحول إلى القطاع الخاص إمكانية تحقيق الأرباح من خلال هذا الاستثمار وعملية تقييم

(¹) وينبغي عدم الخلط بين تقييم المشروعات العامة لغرض إعادة هيكلتها وتحديد حقوق والتزامات الشركة المساهمة التي تكون أسهمها مملوكة للدولة بالكامل -كما أسلفنا- وعملية التقييم في هذه المرحلة والتي يراد منها تحديد السعر الذي سيتم به نقل ملكية هذه الأسهم أو الأصول للقطاع الخاص.

(²) UNCTD, Op. Cit., P. 102-103

كذلك: د. آدم مهدي احمد، الخصخصة في البلدان العربية، نماذج الخصخصة، بحث مقدم إلى المؤتمر العشرون لاتحاد المحامين العرب، 20-24 آذار 2001، بيروت - لبنان، ص7.

(³) فعلى سبيل المثال: أثارت عملية بيع 75% من أسهم شركة الأهرام للمشروبات المصرية لمستثمر أمريكي من اصل مصري، تعقيدات كثيرة، أدت إلى إجراء السلطات المصرية لتحقيقات موسعة وذلك لقيام هذا الشخص ببيع (62.5%) من أسهم هذه الشركة في بورصة لندن بسعر (105) جنيه مصري للسهم الواحد رغم شراءه قبل أيام بسعر 68.5 جنيه مصري من الشركة القابضة مما يعني تحقيقه ربحا مقداره (20) مليون دولار أمريكي، مجلة البورصة المصرية، العدد الثالث عشر، الاثنين -14- أغسطس، 1997، ص3.

أصول أو أسهم الشركات العامة بقصد تحويلها إلى القطاع الخاص، لا تخلو في الحقيقة من الصعوبة والتعقيد ذلك أن هذه الشركات غالبا ما تكون قد أنشأت وفقا لظروف اقتصادية قد تحول دون تحويلها إلى القطاع الخاص، ولعل ابرز هذه الصعوبات تتمثل بأن هذه الشركات قد أنشئت لأغراض غير تجارية "تحقيق المنفعة العامة" ومن ثم تكون كلفة إنشائها غير متناسبة مع الأرباح التي يمكن أن تحققها، الأمر الذي يؤثر في سعر البيع باتجاه الانخفاض⁽¹⁾. ويجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار عند أجرا عملية التقييم، الغرض من هذا التقييم أي فيما إذا كان تقييم الشركة العامة سوف يستتبع انقضائها وتصفيها أو انه لا يؤدي إلى ذلك بحيث تبقى هذه الشركة العامة قائمة كوحدة اقتصادية مستمرة، كما في حالة اندماج الشركة العامة بشركة خاصة، أو حالة بيع أسهم الشركات العامة وهذه الحالة تمثل الأسلوب الأكثر شيوعا في عمليات التحول إلى القطاع الخاص⁽²⁾.

وعلى هذا الأساس أولت التشريعات المختلفة عناية خاصة بعملية تقييم أصول أو أسهم الشركات العامة التي يراد تحويلها إلى القطاع الخاص. فقد أولى المشرع الفرنسي عناية كبيرة بهذه العملية، من حيث تحديد الجهة المختصة بعملية التقييم وإجراءات التقييم وتتم عملية التقييم من خلال قيام مكاتب خبرة متخصصة بمراجعة حسابات الشركة والتأكد من سلامة مركزها المالي، ولهذه المكاتب أن تستعين بمراقب حسابات الشركة Le commissaire aux comptes في عملها، ثم تقدم تقريرا بنتيجة عملها إلى لجنة المشاركات والتحويلات، كذلك تتولى البنوك الاستشارية Les banques conseil جمع المعلومات المالية والاقتصادية والتسويقية وتحليلها ثم تعد تقريرا يتضمن المعلومات والدراسات اللازمة للتقييم. وتقدم هذه التقارير إلى لجنة المشاركات والتحويلات وتضمنه توصياتها وطريقة البيع التي تقترحها⁽³⁾، وقد خول المشرع الفرنسي- لهذه اللجنة الاطلاع على كافة المستندات والبيانات اللازمة لإجراء عملية

(¹) UNCTAD, Op. Cit., P. 102.

(²) د. احمد ماهر، المرجع السابق، ص 108.

(³) P. Pochet, Reflexion sur le regime juridique des privatisation , R.T.D.C., 41 (3) Juill-sepy., 1988 , p. 376.

التقييم إذ يمكن للجنة أن تطلب من مراقب حسابات الشركة المعنية أية معلومات حول نشاط الشركة أو وضعها المالي، ولا يعد مراقب الحسابات في هذه الحالة مخلا بالتزامه بالمحافظة على الأسرار المهنية⁽¹⁾.

وقد حدد المشرع الفرنسي القواعد الأساسية التي يمكن أن تسترشد بها هذه اللجنة في عملية التقييم، وذلك بان تتم عملية التقييم بطريقة موضوعية ووفقا للأسس المتبعة في عملية النقل الكلي أو الجزئي لأصول الشركة على أن تراعى اللجنة في عملية التقييم قيمة أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية وقيمة موجوداتها والأرباح المتحققة ووجود فروع للشركة والعوائد التي يمكن أن تحققها مستقبلا. وتزاوّل اللجنة عملها على وجه الاستقلال فهي ليست لجنة إدارية تابعة للوزير، ومن ثم لا يعد القرار الصادر منها بشأن عملية التقييم وتحديد السعر النهائي للبيع قرارا إداريا مما يعني عدم جواز الطعن في هذا القرار طعنا إداريا⁽²⁾.

وقد حرص المشرع الفرنسي على أن تمارس هذه اللجنة عملها ضمن إطار مبدأ (الشفافية) Le principe de latransparence وذلك من خلال الإعلان عن ضوابط وإجراءات التقييم وتحديد السعر النهائي، كما انه حرص على حياد هذه اللجنة واستقلالها فبين الضوابط المتبعة في اختيار أعضائها وكذلك حدد الالتزامات التي تقع عليهم على النحو الذي لا يجوز أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركات محل عملية التقييم كما أسلفنا.

وتنتهي عملية التقييم وفقا للقانون الفرنسي بقيام لجنة المشاركات والتحويلات بتقديم تقرير عن نتيجة عملها إلى الوزير المختص - وزير الاقتصاد - والذي يتولى بناء على هذا التقرير تحديد سعر البيع النهائي، بيد أن سلطته في هذا المجال ليست مطلقة، فلا يجوز له أن يحدد سعر اقل من السعر الذي حددته اللجنة في تقريرها⁽³⁾.

(¹) المادة (1/3) من قانون 1986/8/6 الفرنسي المعدلة.

(²) المادة (3) من قانون 1986/8/6 الفرنسي المعدلة.

(³) المادة (20) من قانون 1986/8/6 الفرنسي المعدلة.

أما عن موقف المشرع المصري، فلم يتضمن قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري أية أحكام خاصة بتقييم أسهم أو أصول الشركات التي يراد تحويلها إلى القطاع الخاص غير أن الإرشادات الصادرة عن المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام⁽¹⁾، تؤكد على ضرورة تقييم الأصول والخصوم والتوصل إلى صافي حقوق الملاك لأن ذلك يعد من الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى مشاركة كبيرة من قبل الأفراد من خلال إقبالهم على شراء الأسهم والأصول المطروحة للبيع⁽²⁾، ووفقا لهذه الإرشادات تتمتع الشركات القابضة بالحرية الكاملة في البحث عن الخبرات التي تحتاجها لتنفيذ برامج طرح استثمارها للبيع، وكذلك التعاقد معها وتقوم بتمويل نفقات هذه الخبرات من مواردها الذاتية، فإذا تعذر هذا التمويل يمكنها أن تطلب من المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام توفير التمويل اللازم للمساعدة الفنية، ويتم التعاقد مباشرة بين الشركة القابضة والخبراء وتلتزم الشركة في صياغة وتنفيذ العقود التي تبرمها مع الخبراء بالقواعد التي يضعها المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام في حالة استخدامها للأموال المقدمة من المكتب الفني. وتتولى الشركة القابضة وضع الإطار التفصيلي للأعمال والمهام والدراسات التي سيقوم بها الخبراء، ويمكنها إذا أرادت الاستعانة في ذلك بالمكتب الفني أو بأية خبرة تراها لازمة لإعداد هذا الإطار ويتم توقيع عقد الخبرة بين الشركة القابضة والخبير أو الخبراء وترسل نسخة من مشروع العقد في حالة تمويله من المكتب الفني قبل توقيعه إلى هذا المكتب لمراجعته وتخصيص التمويل المطلوب.

ويعد الخبراء تقريرا شاملا للأوضاع المالية والفنية والعمالية والتسويقية للشركة المطلوب طرح ممتلكاتها أو أسهمها للبيع، ويراجع هذا التقييم بواسطة أجهزة الشركة (مجلس الإدارة والجمعية العامة) للأخذ به أو تعديله، ثم يعرض على الجهاز المركزي للحسابات بوصفه الجهة المسؤولة عن الرقابة على أموال الدولة. ويعتمد بعد ذلك من

(¹) وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن هذه الإرشادات ليست لها قوة الإلزام لافتقارها لسند تشريعي.

(²) دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج الحكومة (المصرية)، المرجع السابق، ص 67.

الجمعية العامة للشركة القابضة ثم يعرض على اللجنة الوزارية المختصة، كما يتضمن التقرير الذي يعده الخبير أو الخبراء برنامجا مقترحا يحدد الوسائل المناسبة للبيع والجدول الزمني للملائم لطرح الاستثمارات في السوق⁽¹⁾.

أما في حالة بيع الأصول وخطوط الإنتاج الرئيسية (كالفنادق ومحلات البيع بالتجزئة) فيجب الالتزام بأحكام المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المصري، والتي تقضي- بتشكيل لجنة التقييم المنصوص عليها في المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام كذلك فإنه ووفقا للمادة (26) من اللائحة التنفيذية المشار إليها لا يجوز للشركة القابضة التصرف بالبيع في اصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقا لما يأتي:

1. أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط.
2. أن لا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام وهي لجنة تختص أساسا في التحقق من تقييم الحصص العينية التي تدخل في تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها وتشكل هذه اللجنة بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية أربعة على الأكثر من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبة والقانونية والفنية، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب الأحوال وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للحسابات.

(¹) دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج الحكومة (المصرية)، ص26-27 ويشار إلى أن طرق التقييم (المحاسبية) المتبعة في مصر هي: طريقة التقييم من خلال القيمة الدفترية والقيمة الدفترية المعدلة والقيمة الاستبدالية والقيمة المالية لصافي قيمة التدفقات النقدية في المستقبل وأخيرا التقييم باستخدام أسلوب القيمة المتدفقة لتوزيعات الأسهم، وفي تفصيل ذلك، انظر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تقييم برامج الخصخصة في منطقة الاسكوا، المرجع السابق، ص60-61.

وفيما يتعلق بموقف القانون المغربي فقد خولت المادة الخامسة من قانون التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص المغربي، الحكومة المغربية أن تحدد قواعد تقييم الممتلكات التي ستحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وطرق تحديد الثمن الذي ستعرض به للبيع، وتركيب وصلاحيات الهيئة المكلفة بالتقييم. وعلى هذا الأساس أصدرت الحكومة المغربية المرسوم المرقم (290402) في 16/10/1990⁽¹⁾. ووفقا لهذا المرسوم تتألف هيئة التقييم من سبعة أعضاء يكون بضمنهم رئيس و (خليفة رئيس) يعينون وفق الإجراءات المقررة لتعيين أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويشترط لصحة مداوات هيئة التقييم أن يحضرها خمسة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الذين تتألف منهم⁽²⁾ ويلتزم أعضاء هيئة التقييم بكتمان السر المهني فيما يتعلق بجميع القضايا التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بالأعمال المسندة إليهم ولا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التقييم خلال مزاولة مهامه وطوال مدة خمس سنوات تبتدئ من انتهائه من مزاولتها أن يمتلك أسهما أو حصصا في شركة أو منشأة كانت محل تحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو عنصرا من أصولها أو في شركة تكون قد تملك أسهما أو حصصا في تلك الشركة أو المنشأة أو عنصرا من أصولها، أو في شركة تكون فرعا أو أصلا للشركة المملوكة لذلك. ويمتد هذا الحظر إلى أزواج أعضاء هيئة التقييم وفروعهم الذين يعولونهم⁽³⁾.

وقد حدد المشرع المغربي الضوابط التي يجب أن تراعى في عملية التقييم، وذلك بان يباشر التقييم وفق المناهج الموضوعية المتبعة بوجه عام عندما يتعلق الأمر بالتصرف في جميع أو قسم من المنشأة وتراعى في ذلك بوجه خاص بحسب

(¹) انظر نص هذا المرسوم في الموسوعة المغربية في التشريع والقضاء، المرجع السابق، ص مؤسسات - تشريع - ن - ص 62.

(²) المادة (2) من هذا المرسوم.

(³) المواد (4-6-7) من هذا المرسوم.

الخصوصية التي تتسم بها كل حالة قيمة الأصول والأرباح المتحققة وقيمة الأسهم في سوق الأوراق المالية ووجود شركات وليدة والآفاق المستقبلية⁽¹⁾.

وتتولى هيئة التقييم تحديد السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشأة للبيع وذلك بعد الاطلاع على تقرير التقييم المحال إليها من قبل الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ويمكن للهيئة في سبيل ذلك أن تأمر بإجراء أية خبرة ترى من المفيد القيام بها وإن تطلب اطلاعها على جميع الوثائق والمستندات والدراسات التي من شأنها أن تساعد على إنجاز المهمة المنوطة بها، ويبلغ السعر الذي تعرض به المساهمة أو المنشأة للبيع إلى الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل داخل أجل لا يتعدى شهرين من التاريخ الذي أحيل فيه إلى هيئة التقييم تقرير التقييم المشار إليه⁽²⁾.

ومن الواضح أن هناك تقارب كبير بين موقف القانون المغربي وموقف القانون الفرنسي، فيما يتعلق بضوابط وإجراءات التقييم وكيفية تعيين أعضاء لجنة التقييم وضمان حيادهم واستقلالهم مع الأخذ بنظر الاعتبار أن القانون المغربي قد عين لجنة خاصة لعملية التقييم، في حين أن المشرع الفرنسي أناط هذه المهمة بلجنة المشاركات والتحويلات والتي تساعد وزير الاقتصاد في تنفيذ عمليات التحويل إلى القطاع الخاص، والتي تقابلها لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص في القانون المغربي.

أما عن قواعد وإجراءات تقييم الأسهم أو الأصول في التشريع العراقي فينبغي التمييز بين حالتين الأولى حالة تقييم الأصول التي تباع وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة فوفقا لهذا القانون يتم بيع أموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله⁽³⁾، وتشكل لجنة تقييم الأموال غير المنقولة من ثلاثة موظفين ذوي خبرة لا تقل درجة

⁽¹⁾ المادة (1) من هذا المرسوم.

⁽²⁾ المادة (3) من نفس المرسوم.

⁽³⁾ المادة (6) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي.

أي منهم عن مدير أو رئيس ملاحظين وبضم إليهم موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف مالي من وزارة المالية وتتولى هذه اللجنة إجراء الكشف على المال غير المنقول وتقييم قيمته وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له في دائرة التسجيل العقاري وبقيم العقارات المجاورة أو ببدلات بيعها ولها أن تستعين بمن ترى من الخبراء، وتتخذ قرارها بتقييم قيمة المال غير المنقول (بالاتفاق أو الأكثرية)⁽¹⁾.

وتنظم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المشار إليها ويوقع من قبل أعضاء اللجنة والخبراء أن وجدوا، ولا يعد هذا التقييم قطعيا إلا بتصديقه من قبل الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله⁽²⁾ ووفقا للمادة الخامسة والعشرين من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، تسري هذه الأحكام على تشكيل لجنة تقييم الأموال المنقولة أيضا.

ومن أجل ضمان حياد أعضاء اللجنة المذكورة منعت المادة الرابعة من هذا القانون أعضاء لجنتي التقييم والبيع من شراء هذه الأموال بطريق المزايادة العلنية⁽³⁾.

أما الحالة الثانية فهي حالة تقييم الشركات العامة لغرض تحويلها إلى شركات مساهمة، وبهذا الصدد نلاحظ أن قانون الشركات العامة العراقي لم ينظم قواعد وإجراءات التقييم، وترك للوزارة المعنية أن تختار الأسلوب الملائم للتقييم فقد نصت المادة (36) من قانون الشركات العامة العراقي على انه (تعد الوزارة دراسة بالمسوغات الاقتصادية والفنية للتحويل وأسلوب تقييم قيمة أسهم راس المال وطريقة بيعها).

(¹) المادة (2/7) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي ومن الواضح أن ما قرره المشرع العراقي من أن قرار لجنة التقييم يصدر بالأكثرية أو الأكثرية ويوجب الصواب ذلك انه يكون ممكنا بالطبع أن يصدر القرار بالاتفاق ما دام انه يمكن أن يصدر بالأكثرية لذا كان الأجدر أن تقرر هذه المادة أن قرار اللجنة يصدر بالأكثرية.

(²) المادة (3/7) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي.

(³) تجيز المادة (21) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي، بيع الأموال غير المنقولة دون مزايادة علنية، غير أن البيع في هذه الحالة لا يعد من قبيل التحويل إلى القطاع الخاص الأمر الذي سنفصل أحكامه في موضعه المناسب.

ولنا على هذا النص الملاحظات الآتية:

1. ترك النص المتقدم حرية تحديد قواعد وإجراءات تقييم أسهم راس المال وطريقة البيع للوزارة المعنية، وهذا يعني أن الوزارة غير ملزمة باتباع الإجراءات الخاصة بالتقييم التي نص عليها قانون بيع وإيجار أموال الدولة المشار إليها فيما تقدم وان قواعد وإجراءات التقييم قد تختلف من حالة إلى أخرى بحسب ما ترتئيه الوزارة المعنية.
2. لم يحدد النص الجهة التي تتولى عملية التقييم ومن ثم تكون الوزارة بالخيار في أن تنيط مهمة التقييم إلى لجنة تشكل وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة أو أن تلجأ إلى جهة أخرى (كالخبراء من القطاع الخاص) أو أية لجنة لا تخضع في تشكيلها لقانون بيع وإيجار أموال الدولة.
3. لم يحدد النص الضوابط التي تجري بموجبها عملية التقييم وفيما إذا كانت عملية التقييم تنصب على حقوق الشركة والتزاماتها أم إنها تنصب على موجودات الشركة فقط ؟ والحقيقة أن عملية التقييم يجب أن تشمل حقوق الشركة والتزاماتها طالما أن للشركة العامة ذمة مالية مستقلة فقد تكون دائنة وقد تكون مدينة، كما أن لها احتياطيا نقديا بمعنى أن التقييم يجب أن ينصب على الذمة المالية للشركة وليس على موجوداتها فقط، كذلك يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار المنظور المستقبلي للشركة (أي الأرباح التي يمكن أن تحققها الشركة الناجمة عن التحول). فجميع هذه العناصر يمكن أن تحدد قيمة أسهم الشركة الناجمة عن التحول.

وينبغي أن نؤكد أخيرا على أن عملية التقييم وفقا لقانون الشركات العامة العراقي تختلف عما نصت عليه بعض القوانين المقارنة، كالقانون المصري والأردني، فوفقا للقانون المصري يتم تقييم جميع الشركات العامة لغرض تحويلها إلى شركات قطاع الأعمال العام والتي يكون رأسمالها مكونا من أسهم، ثم يصار إلى تقييم أسهم هذه الشركات قبل بيعها للقطاع الخاص، كذلك الحال بالنسبة إلى المشرع الأردني، إذ انه قضى- بتقييم (المشروعات العامة) لغرض تحويلها إلى شركات مساهمة تكون

أسمها مملوكة للدولة بالكامل ثم يصار إلى تقييم هذه الأسهم مجددا لغرض نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، أما في العراق فإن عملية التقييم تتم على مرحلة واحدة إذ لم ينظم المشرع العراقي عملية إعادة هيكلة الشركات العامة قبل بيعها بل يصار إلى تقييمها وبيعها على مرحلة واحدة.

وعلى أية حال نرى انه من الضروري أن تناط مهمة تقييم قيمة الشركات العامة، باللجنة التي سبق وان اقترحتنا تشكيلها لغرض مساعدة الوزير المختص في الإعداد والتنفيذ لعمليات التحويل إلى القطاع الخاص، بحيث تختص هذه اللجنة بإجراء التقييم سواء تم البيع على شكل أصول أو على شكل أسهم على أن تتم عملية التقييم أول الأمر من قبل خبراء يتم التعاقد معهم بواسطة هذه اللجنة، ثم يصار بعد ذلك إلى مراجعة هذا التقييم من اللجنة نفسها، بحيث يخول أعضاء اللجنة الاطلاع على جميع الوثائق أو المستندات اللازمة لعملية التقييم، ويجب أن يحظر على أعضاء هذه اللجنة أن يملكوا الأسهم أو الأصول التي كانت محلا للتقييم كما ويجب أن يشمل هذا الحظر أزواج أعضاء هذه اللجنة وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك بقصد ضمان حيادهم، كما ويجب أن يحظر على هؤلاء أن يشغلوا منصب المدير المفوض أو عضوية مجلس الإدارة في أي من الشركات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص.

هذا ويمكن أن يحدد سقف زمني تنتهي فيه اللجنة من عملها (شهرين مثلا) ثم ترفع بعد ذلك تقريراً يتضمن كافة المعلومات عند عملية التقييم وسعر البيع الذي تقترحه إلى الوزير المختص والذي يتخذ قرار البيع على أن لا يكون السعر اقل من السعر الوارد في تقرير اللجنة المشار إليها.

وتمة ملاحظة أخيرة نوردتها في هذا المجال وتتمثل بضرورة إخضاع عمليات التحويل إلى القطاع الخاص لقانون واحد ذلك أن تنظيم عملية التحويل إلى القطاع الخاص في قانون الشركات العامة وقانون بيع وإيجار أموال الدولة وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1995 يشكل مأخذاً على المشرع العراقي وينبغي تلافيه إذ انه قد يحول دون تحقيق النتائج المرجوة من عملية التحويل إلى القطاع الخاص، بسبب تعدد الجهات المشرفة على هذه العملية وتباين مستلزمات وإجراءات التحويل في هذه القوانين والقرارات الأمر الذي قد يؤدي إلى الإرباك في تنفيذ عمليات التحويل.

فعلى الرغم من أن نطاق تطبيق قانون بيع وإيجار أموال الدولة على عمليات التحويل يقتصر- على حالة التحويل إلى القطاع الخاص التي تتم عن طريق بيع الأصول فإن تحويل الشركات العامة إلى شركات خاصة أو مختلطة يمكن أن يخضع لقانون الشركات العامة أو لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1995 إذ أن نطاق تطبيق هذا القرار يشمل حالة تحويل (المنشآت والشركات والمعامل) إلى شركات مساهمة مختلطة أو خاصة وفقاً للفقرة (ثانياً/2) من هذا القرار.

ولكل ما تقدم ندعو المشرع العراقي إلى إصدار قانون خاص بعمليات التحويل إلى القطاع الخاص يضم جميع الأحكام القانونية الخاصة بهذه العملية من حيث تنظيم عمليات إعادة هيكلة المشروعات العامة وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على عملية التحويل وإجراءات تقييم الشركات العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص وأساليب هذا التحويل وآثاره القانونية.

الفصل الثاني
أساليب التحول إلى
القطاع الخاص

الفصل الثاني

أساليب التحويل إلى القطاع الخاص

تستند عملية التحويل إلى القطاع الخاص بمفهومها القانوني إلى فكرة رئيسة مؤداها تخفيض نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي في رأسمال الشركة العامة أو إنهاؤها بشكل كلي. وتتحقق هذه النتيجة من خلال نقل ملكية أسهم أو أصول هذه الشركة والمملوكة للقطاع الاشتراكي إلى القطاع الخاص بشكل جزئي أو كلي. ويمكن أن يتحقق ذلك بعدة أساليب إذ يمكن إجراء عملية التحويل إلى القطاع الخاص من خلال العرض العام للأسهم أي بيع أسهم الشركات العامة للجمهور كما ويمكن أن يتم من خلال بيع أسهم الشركات العامة أو أصولها لمستثمر واحد أو عدة مستثمرين وكذلك عن طريق بيع أسهم الشركات العامة للعاملين فيها. وفضلا عن هذه الأساليب هناك أساليب أخرى من شأنها أن تخفض من نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي في رأسمال الشركة العامة دون الحاجة إلى بيع الأسهم أو الأصول المملوكة له في هذه الشركات. وذلك عن طريق دمج الشركات العامة بشركات خاصة أو عن طريق زيادة رأسمال الشركة العامة بأموال مملوكة للقطاع الخاص⁽¹⁾.

ومما لا ريب فيه أن اختيار الأسلوب الملائم للتحويل من شأنه أن يؤثر إلى حد كبير في مدى نجاح الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لعمليات

(1) وقد سبقت الإشارة إلى أن دراستنا ستقتصر على البحث في أساليب التحويل إلى القطاع الخاص بمفهومه القانوني أو التقليدي دون التطرق إلى الأساليب الأخرى للتحويل بمفهومه الاقتصادي الحديث المتمثلة بنقل إدارة المشروعات العامة إلى القطاع الخاص عن طريق عقود الإيجار أو الامتياز وغيرها وكذلك إدارة المشروعات العامة من قبل الدولة على وفق الأسس التي يعمل بها القطاع الخاص باعتبار أن هذه الأساليب يمكن تطبيقها بالرجوع إلى القواعد العامة للقانون ولا سيما القانون الإداري.

التحول إلى القطاع الخاص⁽¹⁾. ولغرض الإحاطة بالأحكام القانونية الخاصة بهذه الأساليب ارتأينا تقسيم هذا الفصل على أربعة مباحث وحسب التفصيل الآتي:

المبحث الأول. التحول إلى القطاع الخاص عن طريق العرض العام للأسهم.

المبحث الثاني. التحول إلى القطاع الخاص عن طريق البيع لمستثمر رئيس.

المبحث الثالث. التحول إلى القطاع الخاص عن طريق البيع للعاملين.

المبحث الرابع. التحول إلى القطاع الخاص عن طريق دمج الشركات أو زيادة رأسمالها.

(¹) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوا، المرجع السابق، ص5.

المبحث الأول التحول إلى القطاع الخاص عن طريق العرض العام للأسهم

يقصد بالعرض العام للأسهم (O.P.V)⁽¹⁾ (طرح كل أو جزء من أسهم الشركة العامة للبيع للجمهور في سوق الأوراق المالية)⁽²⁾.
وبعد هذا الأسلوب من أكثر أساليب التحول إلى القطاع الخاص شيوعاً وذلك بسبب ما يترتب عليه من مزايا إذ أن من شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية من خلال تمكين أكبر عدد ممكن من الأشخاص من شراء الأسهم المباعة، كما أن هذا الأسلوب يعد من أكثر الأساليب ملائمة للشركات الكبيرة التي يصعب بيعها لشخص واحد أو عدة أشخاص أي أن هذا الأسلوب يكاد يكون الأسلوب الوحيد لتحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة فضلاً عن أن لهذا الأسلوب أثراً كبيراً في تنشيط سوق الأوراق المالية في الدولة، لأنه يؤدي إلى زيادة تداول الأسهم في السوق⁽³⁾.
وسنن في هذا المبحث إجراءات العرض العام للأسهم في المطلب الأول والوفاء بقيمة الأسهم في المطلب الثاني.

المطلب الأول إجراءات العرض العام للأسهم

يتطلب استخدام هذا الأسلوب للتحول بالضرورة أن يتخذ المشروع المراد تحويله إلى القطاع الخاص شكل شركة يقسم رأسمالها إلى أسهم وان كان على خلاف

(¹) L'offre publique de vent.

(²) د. منير إبراهيم هندي، خصخصة المشروعات العامة، المرجع السابق، ص 46.

UNCTAD , op. Cit., p. 87

(³) كذلك

Economic commission For Europe (ECE), privatization and changing ownership in the steel Industry, united nations, New York; and Geneva, 1996, p. 5.

ذلك فلا بد من إعادة هيكلة المشروع المراد تحويله بحيث يتخذ شكل شركة مساهمة يقسم رأسمالها إلى أسهم مملوكة للدولة بالكامل⁽¹⁾.
وبيع أسهم الشركة العامة عن طريق العرض العام للأسهم قد ينصب على كافة أسهم الشركة إذا كانت مملوكة للدولة بالكامل، وقد يقتصر على جزء من أسهمها⁽²⁾.
ويشير البعض⁽³⁾ إلى أنه لا يمكن استخدام هذا الأسلوب للتحويل في الدول التي لا يوجد فيها سوق منظمة للأوراق المالية وأنه يجب أن تتوافر في الشركة المراد تحويلها شروط التسجيل في سوق الأوراق المالية والتي تتمثل بشكل عام بتحقيق الشركة لقدر معين من الأرباح خلال السنتين أو الثلاثة السابقة على طلب التسجيل وان لا تقل قيمة أصولها عن قدر معين، كما قد يشترط أن تكون قد وزعت أرباحاً في عدد من السنوات السابقة على التسجيل أو مرور حد أدنى من السنوات على إنشائها.
ونعتقد أنه ليس من الضروري أن يتوافر في الشركة العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص شروط التسجيل في سوق الأوراق المالية حتى يمكن بيع أسهمها في هذه السوق. فبإمكان المشرع أن يستثني بيع هذه الأسهم من الأحكام التي تتضمنها قوانين سوق الأوراق المالية، ذلك أن اشتراط توافر شروط التسجيل في السوق بالنسبة إلى الشركة العامة المراد تحويلها قد يؤدي إلى عرقلة عملية التحويل وإطالة أمدها ولاسيما إذا كان المشروع المراد تحويله لا يتخذ شكل الشركة المساهمة الأمر الذي قد يستلزم إعادة هيكليته، ومن ثم الانتظار لمدة سنتين أو ثلاثة⁽⁴⁾ لحين توافر شروط التسجيل في السوق قبل أن يصار إلى بيع أسهمه.

(¹) صهيب موسى جفال المومني، المرجع السابق، ص 46.

(²) د. محمود الصبح، المرجع السابق، ص 35.

(³) د. منير إبراهيم هندي، خصخصة المشروعات العامة، المرجع السابق، ص 54.

(⁴) فعلى سبيل المثال اشترطت المادة الثامنة من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم 24 لسنة 1991 أن تكون الشركة المساهمة قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين، لكي تقبل أسهمها في السوق - إذا كان رأسمالها اقل من (500) دينار.

وقد انتهج المشرع العراقي هذا النهج في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (140) لسنة 1993 الملغي والذي خول وزير الصناعة والمعادن صلاحية تحويل المعامل التابعة للوزارة إلى شركة مساهمة بعد موافقة ديوان الرئاسة فقد أجاز هذا القرار طرح أسهم هذه المعامل وفقا للشروط المنصوص عليها فيه، في سوق بغداد للأوراق المالية على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986، استثناء من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم (24) لسنة 1991⁽¹⁾.

وفضلا عن ذلك يلاحظ أن السعر الذي تطرح به الأسهم للبيع قد يكون محددا كما وقد يكون غير محدد وذلك عند عرض الأسهم بسعر أولي قابل للتغير بحسب العرض أو الطلب في السوق⁽²⁾.

وقد جرى العمل في فرنسا على أن يتم البيع في العرض العام للأسهم بسعر محدد يتم تحديده من قبل لجنة المشاركات والتحويلات ويصدر به قرار من وزير الاقتصاد⁽³⁾. وعلى العكس من ذلك قرر المشرع المغربي وجوب عرض أسهم الشركة في السوق المالية بسعر أولي على أن يكون هذا السعر مساويا للسعر المحدد للعرض من قبل هيئة التقييم⁽⁴⁾.

ووفقا للتشريع الفرنسي، تتم عملية العرض العام للأسهم من خلال قيام الدولة بإعلان شروط العرض للمستثمرين وذلك عن طريق إعلان سعر الأسهم في جدول البورصة الرسمي ببورصة الأوراق المالية ثم يصار إلى إعادة الإعلان بالصحف وعن طريق الوسطاء الماليين العاملين في البورصة، ويتضمن هذا الإعلان عدد الأسهم المعروضة والسعر المحدد للسهم ومدة العرض وخلال فترة العرض يتلقى الوسطاء العاملون في البورصة أوامر الشراء من المستثمرين ثم يتولى الوسطاء

(¹) انظر المادة (1/ب) من هذا القرار.

(²) UNCTAD., Op. Cit., p. 89.

(³) Lysiane cartelier, privatisation et construction Europeenne, Etudes de droit des communautes Europeenne: Entre concurrence et interet general, Edition A. Pedone, Paris, 1995, P. 160.

(⁴) المادة (13) من المرسوم المغربي رقم (290402) الصادر في 16/10/1990، الموسوعة المغربية للتشريع والقضاء، المرجع السابق، ص مؤسسات -تسريع -ن-61.

تحويل أوامر الشراء إلى بورصة الأوراق المالية وفي حالة عدم تلبية جميع أوامر الشراء فيجب الإعلان عن نسبة التخفيض والأساس الذي قامت عليه⁽¹⁾.
ومن الجدير بالذكر أن أوامر الشراء المستخدمة في الأسواق المالية نوعان الأولى اسمية والثانية عادية⁽²⁾.

ويستخدم في فرنسا أسلوب الأوامر الاسمية لشراء أسهم الشركات العامة في حالة العرض العام للأسهم إذ أن من شأن ذلك أن يحقق الأهداف التي توخاها المشرع الفرنسي والمتمثلة بإعطاء الأشخاص الطبيعية من الجنسية الفرنسية أو من المقيمين فيها أو من رعايا دول الاتحاد الأوروبي حق الأولوية في شراء أسهم الشركات العامة عند عرضها للبيع إذ يجب وفقا للمادة (13) من القانون الفرنسي الصادر في 1986 / 8 / 6 أن تلبى جميع أوامر الشراء المقدمة من هؤلاء الأشخاص بصورة كلية وعند عدم كفاية الأسهم المعروضة لتلبية جميع أوامر الشراء يجري تخفيضها بموجب شروط يتم تحديدها بمرسوم. ومن أجل ذلك يتم تصنيف أوامر الشراء إلى ثلاث فئات وهي (أ و ب و ج) بحيث يستطيع كل شخص من الأشخاص المشار إليهم أن يصدر أمرا واحدا للشراء من فئة (أ)، وهذه الفئة من أوامر الشراء لها أولوية في التنفيذ علما أن للقاصرين أيضا أن يصدروا مثل هذه الأوامر للشراء من خلال ممثلهم القانوني، ويستطيع أبا من هؤلاء أن يصدر أيضا أمرا بالشراء من الفئة (ب) وهذه الفئة ليست لها أولوية في التنفيذ لأنها مخصصة بالأساس لأشخاص ليس لهم حق الأولوية في الشراء، أما أوامر الشراء من الفئة (ج) فهي مخصصة للمؤسسات الاستثمارية أي أن أوامر الشراء من الفئة (ج) يمكن أن تصدر من قبل الأشخاص المعنوية الفرنسية أو الأشخاص المعنوية التي تحمل جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي بشرط أن لا تكون هذه الأخيرة خاضعة لرقابة أو سيطرة دولة ليست من دول الاتحاد الأوروبي، وفقا

(1) د. احمد محمد محرز، النظام القانوني لتحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص "الخصخصة"، القاهرة، 1995، ص 89-90.
(2) ويقصد بأوامر البورصة "التوكيل الذي يعطي إلى وسيط البورصة لبيع أو شراء أوراق مالية معينة"، انظر: حسن النجفي، سوق الأوراق المالية -البورصة، مكتبة الخلفاء، بغداد، 1992، ص 55.

للتحديد الوارد في المادة (1-355) من قانون الشركات التجارية الفرنسي لسنة 1966⁽¹⁾.
وفضلا عما تقدم، تشير التجارب الدولية إلى انه في العرض العام للأسهم بسعر محدد يمكن اللجوء إلى مصرف أو شركة استثمار بتعهد بتصرف كل الإصدار أو حد أدنى منه، وقد يدفع مقدما قيمة الكمية التي تعهد ببيعها أو جزء منها، ودور المصرف يقتصر في هذه الحالة على بذل العناية اللازمة لتصرف الأسهم دون الالتزام بتصرف حد أدنى منه، أي أن التزام المصرف ببيع الأسهم هو التزام ببذل وعناية وليس التزاما بتحقيق غاية وذلك في مقابل عمولة يتلقاها عن عمليات البيع، وإذا ما تبقى جزء من الأسهم لم يتم التصرف فيه فيرد إلى الدولة⁽²⁾. وقد نص المشرع المغربي صراحة على هذا الحكم إذ يجب وفقا للمادة (14) من المرسوم المغربي المرقم (290402) الصادر في 1990 / 10 / 16 بيع الأسهم للجمهور بسعر محدد، والذي يجب أن لا يقل عن السعر المحدد من قبل هيئة التقويم، أن يتم البيع في المؤسسات المالية والمصرفية. وفي المؤسسات البريدية ومصالح الخزينة العامة والمعنية في قائمة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحول ووزير المالية. ونعتقد أن التزام المصرف في هذه الحالة يعد ماثلا لالتزامه بإجراء الاكتتاب عند تأسيس الشركات المساهمة، فالمصرف في هذه الحالة ليس إلا وسيطا يتقاضى عمولة عند بيعه لأسهم الشركات العامة⁽³⁾.
ونلاحظ أن المشرع العراقي قد اخذ بأسلوب مماثل تقريبا فقد أجاز المشرع العراقي للمصرف الصناعي أن يزيد من نسبة مساهمته في الشركات المختلطة الجديدة لبلوغ النسبة التي يشترطها القانون لتأسيس الشركات ومن ثم بيع الأسهم تدريجيا إلى

(¹) Jean - Paul valuet, Op., Cit., P. 30.

(²) د. منير إبراهيم هندي، خصخصة المشروعات العامة، المرجع السابق، ص 49.

(³) وبخصوص دور المصرف في عملية الاكتتاب، انظر: د. باسم محمد صالح و د. عدنان احمد ولي، القانون التجاري - الشركات التجارية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1989 ص 35.

الراغبين في شرائها من المواطنين⁽¹⁾. وحيث أن تحول الشركة العامة هو انقضاء لهذه الشركة وتأسيس لشركة جديدة، نرى إمكانية تطبيق هذا الحكم عند تحويل الشركات العامة، وعلى النحو الذي يستطيع فيه المصرف الصناعي من الاكتتاب بأسهم الشركة العامة عند تحويلها ثم يتولى بيعها بعد ذلك للمواطنين مع ملاحظة أن المصرف الصناعي في هذه الحالة لا يعد وكيلا عن الدولة في بيع الأسهم وإنما يعد مالكا للأسهم التي يبيعها وهذا الحكم يقارب ما نصت عليه المادة (39) من قانون الشركات المصري لسنة 1981 والتي تجيز للمصرف أن يضمن الاكتتاب بأن يعتمد إلى شراء الأسهم التي لا يكتتب بها الجمهور، وله بعد ذلك أن ي طرحها للجمهور مرة ثانية⁽²⁾.

أما عن مدى إمكانية تطبيق أسلوب العرض العام للأسهم في العراق، فنلاحظ ابتداء أن قانون الشركات العراقي وقرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بموضوع التحول لم تنص صراحة على إمكانية استخدام هذا الأسلوب في التحول، ويشير الواقع العملي إلى أن هذا الأسلوب لم يطبق في العراق بالنسبة لعمليات التحول التي جرت فيه، والسبب في ذلك يعود إلى أن المشروعات العامة في العراق لا تتخذ شكل شركة مساهمة تكون أسهمها مملوكة للدولة، أي أن رأسمالها لا يقسم إلى أسهم أساسا ومن ثم لا يتصور أن يرد البيع على الأسهم إلا إذا تمت عملية إعادة هيكلة المشروعات العامة وتحويلها إلى شركات مساهمة تكون أسهمها مملوكة للدولة بالكامل إذ يمكن في هذه الحالة أن يصار إلى بيع هذه الأسهم للجمهور عن طريق العرض العام، ذلك أن هذا الأسلوب يستلزم أن تكون الشركة العامة شركة مساهمة بحيث يمكن بيع أسهمها في سوق الأوراق المالية أو المؤسسات المصرفية أو المالية.

ولكل ما تقدم، نلاحظ أن الأسلوب البديل للعرض العام للأسهم الذي جرى تطبيقه في العراق والذي ينسجم مع أحكام التشريع العراقي هو أسلوب الاكتتاب العام

(¹) قرار مجلس قيادة الثورة رقم (836) في 1984/7/31، الوقائع العراقية، العدد (3005) في 1984 / 8/6.

(²) د. باسم محمد صالح و د. عدنان احمد ولي، المرجع السابق، ص 135.

لان تحويل الشركة العامة وفقا للتشريع العراقي ما هو إلا تأسيس لشركة خاصة أو مختلطة وانقضاء لشركة عامة فرأسمال الشركة الناجمة عن التحويل يتكون من موجودات ⁽¹⁾ الشركة العامة محل التحويل، أي انه يتكون من حصة عينية واحدة يجري تقديرها وفقا لإجراءات خاصة، ثم تقوم الدولة بطرح أسهم للاكتتاب العام تعادل القيمة المقدرة لهذه الموجودات ويجري الاكتتاب برأسمال الشركة الناجمة عن التحويل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات.

وبالرغم من ذلك نلاحظ أن قانون الشركات العامة لم يقرر هذه الأحكام صراحة بل انه وعلى العكس من ذلك يخول الوزارة المعنية تحديد أسلوب تقويم قيمة راس المال وطريقة بيعها ⁽²⁾. وهذا الأمر قد يعني انه يمكن اتباع أي أسلوب تراه الوزارة مناسبا في عملية البيع ومن هذه الأساليب بالطبع أسلوب العرض العام للأسهم.

غير أننا نرى أن هذا الحكم لا ينسجم مع الأحكام القانونية الأخرى التي تضمنها قانون الشركات العامة نفسه بخصوص تحويل الشركات العامة. إذ كيف يمكن للوزارة أن تحدد أسلوب تقييم أسهم راس المال وطريقة بيعها، في حين أن رأسمال الشركة العامة لا يقسم إلى أسهم أساسا ؟

فضلا عن ذلك تشير المادة (37) من قانون الشركات العامة العراقي صراحة إلى الأحكام التي أشرنا إليها بخصوص انقضاء الشركة العامة جراء التحويل وتأسيس شركة جديدة يتكون رأسمالها من موجودات الشركة العامة ويجري الاكتتاب به من قبل الجمهور والعاملين، فقد نصت هذه المادة على انه " أولا. بعد موافقة مجلس الوزراء على التحويل تقوم الوزارة بإعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء إلى المسجل. ثانيا. تقوم الوزارة بنشر قرار التحويل في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل. ثالثا. تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ابتداء من

⁽¹⁾ ويقصد بموجودات الشركة مجموع قيم الأموال والحقوق التي تعود إلى الشركة في وقت معين وتكون متطابقة مع راس المال الاسمي في بداية حياة الشركة، إلا أنها تختلف بعد ذلك فقد تكون أكثر من راس المال أو أقل، د. خالد الشاوي، شرح قانون الشركات التجارية العراقي، الطبعة الأولى، بغداد، 1968، ص 248.

⁽²⁾ المادة (36) من قانون الشركات العامة العراقي.

تاريخ آخر نشر. رابعا. لمجلس الوزراء عند تحول الشركة إلى شركة مساهمة أن يحدد نسبة معينة من رأس المال الاسمي للشركة تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين".

فهذا النص يحدد إجراءات تأسيس الشركة المساهمة الناجمة عن التحول بحيث تتولى الوزارة القيام بهذه الإجراءات، وهذا يعني انقضاء الشخصية المعنوية السابقة واكتساب شخصية معنوية جديدة جراء التحول⁽¹⁾. كما أن الفقرة الرابعة من هذه المادة تشير صراحة إلى إمكانية تخصيص نسبة من رأسمال الشركة الاسمي للعاملين "للاكتتاب" بها كمساهمين. ومن الواضح أن عملية الاكتتاب التي يشير إليها النص المذكور لا يمكن تصورها، فيما لو تم نقل ملكية الأسهم بغير الاكتتاب العام، كما لو تم عن طريق بيع الأسهم بالعرض العام للأسهم أو غير ذلك من الأساليب.

ويتبين لنا مما تقدم أن ثمة تعارضا بين المادة (36) من قانون الشركات العامة العراقي والمادة (37) منه، فالمادة (36) تجيز بيع الأسهم بأي طريقة مناسبة في حين أن المادة (37) تستلزم إجراء اكتتاب عام بأسهم الشركة الناجمة عن التحول.

ولإزالة هذا التعارض نؤكد على ما سبق وأن اقترحناه على المشرع العراقي من ضرورة تنظيم عملية إعادة هيكلة الشركة العامة قبل تحويلها إلى القطاع الخاص إذ أن من شأن ذلك أن يمكن الوزارة من اتباع أي أسلوب تراه مناسباً لبيع أسهم الشركة العامة ولعل أهم هذه الأساليب هو العرض العام للأسهم بوصفه من الوسائل التي تعمل على تحقيق أهداف المشرع في عملية التحول، وبشكل خاص ما يتعلق بتوسيع قاعدة الملكية والسماح لأكثر عدد ممكن من الأشخاص من الاشتراك في ملكية أسهم الشركات الناجمة عن التحول. ويمكن للمشرع العراقي أن يستعين في تنظيم إجراءات العرض العام للأسهم بالأحكام التي جاءت بها التشريعات المقارنة السالفة الذكر بحيث يمكن عرض أسهم

(1) د. إبراهيم طه الفياض، الشركات العامة، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والتطور في المجتمع العراقي، المعقود في كلية الحداثة الجامعة، الموصل، 24-25 آذار - 2001، ص4. (غير منشور).

الشركات العامة في سوق بغداد للأوراق المالية بسعر محدد أو بسعر أولي، على أن يكون هذا السعر مساويا للسعر المحدد من قبل الجهة التي تتولى عملية التقييم وعلى أن تكون أوامر الشراء اسمية بحيث تمكن المشرع العراقي من إعطاء أولوية لبعض الفئات في شراء أسهم الشركات العامة إذ أن ذلك يتوافق مع ما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1995 الذي يجيز (تحويل المنشآت والشركات والمعامل إلى شركات مساهمة خاصة أو مختلطة) والذي يعطي الأولوية لفئات معينة للاكتتاب بأسهم الشركة الناجمة عن التحويل، فهذا القرار يشير صراحة إلى أن عملية التحويل تتم من خلال الإكتتاب بأسهم الشركة الناجمة عن التحويل، وهذا يعني انه لا يجوز اتباع أسلوب العرض العام للأسهم وغير ذلك من الأساليب في عملية التحويل، فطبقا لهذا القرار يتم تقدير موجودات الشركة أو المعمل أو المنشأة وتعد هذه القيمة المقدرة رأسمالا للشركة المساهمة المختلطة أو الخاصة والذي يقسم إلى أسهم قيمة السهم دينار واحد⁽¹⁾. وبعد تنزيل مساهمة القطاع الاشتراكي في رأسمال الشركة المساهمة المختلطة تطرح أسهم الشركة لمدة ستين يوما من تاريخ تسجيل الشركات إلى الفئات الآتية حصرا:

1. حاملو وسام الثورة والرافدين والقادسية وأم المعارك حسب درجته.
2. أبطال القادسية وأم المعارك.
3. حاملو سيف القادسية وأم المعارك.
4. حاملو الأنواط من أصدقاء السيد الرئيس صدام حسين.

وتطرح الأسهم إلى هذه الفئات ببيان تصدره الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي تعود لها "المنشأة أو الشركة أو المعمل". وينشر هذا البيان في صحيفتين يوميتين في الأقل وفي النشرة الخاصة بالشركات التي يصدرها المسجل⁽²⁾.

⁽¹⁾ الفقرة (ثالثا 2/أ) من هذا القرار.

⁽²⁾ الفقرة (ثالثا 2/ب) من هذا القرار.

ونعتقد أن هذا البيان يجب أن يشتمل على المعلومات التي يتضمنها بيان الاكتتاب وفقاً لقانون الشركات العراقي وهي ⁽¹⁾.

1. نص عقد الشركة.
2. عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم والمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم، علماً أنه يجب وفق لأحكام هذا القرار أن تسدد قيمة الأسهم نقداً ولا يجوز تقسيطها ⁽²⁾.
3. الحدان الأدنى والأعلى لعدد الأسهم التي يجوز الاكتتاب بها.
4. مكان الاكتتاب ومدته.
5. نفقات تأسيس الشركة.
6. العقود والاتفاقات التي الرّم بها المؤسسون لمصلحة الشركة، وهي في هذه الحالة تشمل العقود والاتفاقات الخاصة بالشركة أو المعمل قبل عملية التحول.
7. التقرير الخاص بتقدير الموجودات الخاصة بالمنشأة أو الشركة أو المعمل ذلك أن قانون الشركات يوجب أن يتضمن بيان الاكتتاب تقرير اللجنة الخاصة بتقدير الحصص العينية عند وجود مثل هذه الحصص.
8. أية معلومات أخرى يضيفها المؤسسون.

وإذا ظهر بعد انتهاء مدة الاكتتاب - (60) يوماً - أن عدد الراغبين في شراء أسهم الشركة قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فتقسم الأسهم بينهم قسمة غرماء، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح. أما إذا كان الاكتتاب أقل من الأسهم المطروحة فيطرح المتبقي منها إلى عموم المواطنين على وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ المادة (39/ثالثاً) من قانون الشركات العراقي.

⁽²⁾ الفقرة (سابعاً) من هذا القرار.

⁽³⁾ لمزيد من التفصيل عن إجراءات الاكتتاب العام، انظر د. عباس مرزوك فليح العبيدي، الاكتتاب برأسمال الشركة المساهمة، دراسة قانونية وعملية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998.

وهذا يعني أن عملية الاكتتاب وفقا لهذا القرار تتم على مرحلتين في المرحلة الأولى تعرض الأسهم للاكتتاب (خاص) إذ تعرض للاكتتاب لمدة (60) يوما على الفئات المذكورة في القرار حصرا. وإذا بقي عدد من الأسهم غير المكتتبين بها فيصار إلى عرضها على الجمهور في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن قانون الشركات العراقي اشترط أن يبلغ الاكتتاب (75%) من رأسمال الشركة الاسمي، حتى يعد اكتتابا ناجحا وبعبكسه يجب على المؤسسين أن يخفضوا رأس المال بحيث يبلغ الاكتتاب (75%) من رأس المال الاسمي على أن يقتزن هذا الإجراء بموافقة الجهة القطاعية المختصة، أو أن يقرروا الرجوع عن تأسيس الشركة⁽¹⁾.

ويبدو لنا أن للوزارة المعنية أن لا تلتزم بهذا الحكم في عملية الاكتتاب التي تجري بمناسبة عملية التحول إلى القطاع الخاص، وذلك لانتفاء العلة من هذا الحكم في هذه الحالة فإذا كانت العلة من فشل الاكتتاب الذي لم يبلغ (75%) من رأسمال الشركة الاسمي هي تقدير المشرع عدم كفاية رأسمال الشركة لتحقيق أهدافها الاقتصادية بسبب انخفاض نسبة الأسهم المكتتب بها فإن هذه العلة منتفية في حالة التحول لأن أسهم الشركة العامة مملوكة بالأساس للوزارة المعنية ومن ثم ستبقى الأسهم غير المكتتب بها من قبل الجمهور مملوكة لهذه الوزارة بحسب الأصل ولا خشية عندئذ من عدم كفاية رأس المال المكتتب به لإنجاح المشروع الذي تأسست من أجله الشركة.

وخلاصة القول أن كلا من قانون الشركات العامة العراقي وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1995 لا يجيزان بيع أسهم الشركات العامة عند تحويلها للقطاع الخاص سواء كان البيع عن طريق العرض العام للأسهم أم غير ذلك من الأساليب فعملية التحول تتم عن طريق الاكتتاب العام وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون الشركات العراقي.

(¹) المادة (43/أولا) من قانون الشركات العراقي.

المطلب الثاني الوفاء بقيمة الأسهم

يلتزم المشتري بدفع ثمن الأسهم التي اشتراها نقدا والأصل أن يكون الثمن حالا غير انه قد يكون مؤجلا أو مقسما إلى أقساط دورية تدفع في مواعيد محددة⁽¹⁾.
وقد أولى المشرع الفرنسي عناية خاصة لموضوع الوفاء بقيمة الأسهم فحدد الأساليب التي من شأنها أن تيسر الوفاء بقيمتها من أجل تشجيع الأفراد على تملك هذه الأسهم لتوسيع قاعدة الملكية. وتتمثل هذه الأساليب باستبدال اسهم الشركات العامة بأوراق مالية أخرى وتأجيل أو تقسيط الوفاء بثمن الأسهم. وسنتناول هذه الأساليب كلا في مقصد مستقل وعلى النحو الآتي:

المقصد الأول: استبدال اسهم الشركات العامة بأوراق مالية أخرى

أجاز المشرع الفرنسي استبدال اسهم الشركات العامة المملوكة للدولة بأنواع خاصة من سندات القرض⁽²⁾. التي تصدرها الشركات العامة، وتتمثل هذه السندات بشهادات الاستثمار Certificats investment⁽³⁾، وصكوك المساهمة titres participatifs⁽¹⁾ والشهادات البترولية Certificats petroliers⁽²⁾.

⁽¹⁾ انظر المادة (574) من القانون المدني العراقي.

⁽²⁾ وتجدر الإشارة إلى أن المادة الخامسة من قانون التحويل إلى القطاع الخاص الفرنسي كانت تجيز استبدال سندات القرض التي سبق وأن أصدرتها الدولة بالأسهم عند تحويل الشركة العامة إلى القطاع الخاص وذلك ضمن حدود (50%) من قيمة الأسهم التي تملكها الشخص بمناسبة عملية التحويل ويراعى في احتساب معدل تبادل سندات القرض بالأسهم متوسط أسعار هذه السندات في البورصة خلال العشرين جلسة السابقة على طرح الأسهم للبيع في البورصة ويحدد معدل التبادل بقرار يصدر من وزير الاقتصاد. غير أن هذا الحكم الذي تضمنته المادة الخامسة من قانون التحويل الفرنسي الصادر في 1986/8/6 الغي بموجب المادة (23) من القانون المرقم 93-923 في 1993/7/19.

⁽³⁾ أجازت المادة (1/283) من قانون الشركات التجارية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 83-1 في 1983/1/3، للشركة أن تصدر شهادات استثمار، وهي مطابقة لنص المادة (282) من قانون

فقد أجاز المشرع الفرنسي، بالقانون الصادر في 1983/1/3 المعدل لقانون الشركات التجارية الفرنسي- لسنة 1996، تمويل الشركات المؤمنة عن طريق طرح هذه الأوراق المالية للجمهور، من أجل تخفيض الأعباء المالية للدولة، الناجمة عند ملكيتها لهذه الشركات المملوكة للدولة بالكامل.

وهذه الأوراق، تشكل جزءاً من رأسمال الشركة، غير أنها لا تخول حاملها حق التصويت، كحامل السهم، بمقابل أن لحاملها حق الحصول على الأرباح بالأولوية على المساهمين، ويعد حملة هذه الأوراق المالية، كما يرى البعض⁽³⁾، بمثابة حملة سندات القرض، يكون لهم الحق في الفائدة عن صكوكهم، أيًا كان المركز المالي للشركة. في حين يرى البعض الآخر بحق⁽⁴⁾ أن هذه الأوراق المالية تعد بمثابة أسهم، غير أنها لا تخول أصحابها حق التصويت، ذلك أنها تعد جزءاً من رأسمال الشركة. فالأسهم التي لا تخول أصحابها حق التصويت، معروفة في التشريعات الأنكلوسكسونية، كالقانون الإنكليزي والأمريكي، وتسمى بالأسهم الخالية من حق التصويت Non voting Share ويتم استبدال هذه الأوراق بأسهم الشركات العامة، عن طريق ما يسمى بالعرض العام

الشركات المساهمة المغربي رقم (17/95) الصادر في 1996/8/30، وقد جاء في هذه المادة أنه "يمكن للجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة أن تقرر، بناء على تقرير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وبناء على تقرير مراقبي الحسابات، إنشاء شهادات استثمار تمثل الحقوق المالية وشهادات حق في التصويت تمثل الحقوق الأخرى المرتبطة بالأسهم الصادرة بمناسبة الزيادة في رأس المال أو تجزئ الأسهم الموجودة على ألا تتجاوز نسبة هذه الشهادات رأسمال الشركة".
(¹) أنظر بخصوص هذه الصكوك الفقرة 6.7 من المادة (283) من قانون الشركات التجارية الفرنسي المعدلة بالقانون رقم (83-1) الصادر في 1983/1/3.

(²) وهذه الشهادات تمثل نوعاً خاصاً من شهادات الاستثمار تصدرها الشركات البترولية في فرنسا، د. أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن - الجزء السادس. شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة، دار نشر المعرفة، الرباط، 1992، ص136.

(³) د. أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص91-92.

(⁴) د. أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص136.

للتبادل (O.P.E) L' offre Publique de change ⁽¹⁾ ويحتسب معدل تبادل هذه السندات بالأسهم وفقا لمعايير التقييم المشار إليها آنفا، على أن يراعى في عملية التقييم فقدان المزايا المرتبطة بهذه الأوراق المالية، المتمثلة بحق الأولوية في الحصول على أرباح الشركة، كما يجب أن تراعى في عملية التقييم فقدان الحق في التصويت الذي يمكن منحه لبعض حملة هذه الأوراق. فقد أجاز المشرع الفرنسي منح شهادات حق التصويت لحملة شهادات الاستثمار والشهادات البتولية، ويمكن تحويلها بعد ذلك إلى أسهم عادية ⁽²⁾.

وقد أخذ المشرع المغربي بأسلوب مماثل للتحويل إلى القطاع الخاص، فبناء على اقتراح من الوزير المكلف بعمليات التحويل إلى القطاع الخاص، قرر وزير المالية والاستثمارات الخارجية إصدار سندات قرض تسمى "سندات الخوصصة" وذلك بمقتضى قرار وزاري رقم (3025-95) الصادر في 2 / كانون الثاني / 1996، وسندات الخوصصة عبارة عن قيم منقولة تمثل سندات قرض مصدرة من قبل الخزينة، تخول حائزها إمكانية استبدالها بأسهم الشركات العامة ⁽³⁾.

ومن شأن إصدار هذه السندات أن يمكن السلطات من إيجاد أحسن تقدير للطلب على أسهم الشركات العامة، المراد تحويلها إلى القطاع الخاص، من خلال تقدير الطلب الذي يمكن أن يصدر عن حائزي هذه السندات، وتجميع هذه الطلبات ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Christian Baillon, Op. Cit., P. 218.

⁽²⁾ المادة (6) من قانون التحويل الفرنسي الصادر في 1986/8/6.

⁽³⁾ محمد العليج، حصيلة وآفاق عملية الخوصصة في المغرب (1989-1996)، بحث مقدم إلى ندوة الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية، المعقودة في المركز الوطني للدراسات والتحليل الخاصة بالتخطيط - الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1999، ص303.

⁽⁴⁾ المرجع نفسه، ص303.

ولم نجد في التشريعات العراقية ⁽¹⁾ ما يتيح استخدام هذا الأسلوب في التحول إلى القطاع الخاص ولأهمية هذا الأسلوب وما يترتب عليه من مزايا تتمثل بالتيسير على الأفراد في وفاء قيمة الأسهم وإمكانية تقدير الطلب على اسهم الشركات العامة، قبل تحويلها إلى القطاع الخاص نقترح على المشرع العراقي أن يجيز للشركة العامة إصدار سندات قرض تخول أصحابها الحق في استبدالها باسهم الشركات العامة عند تحويلها إلى القطاع الخاص.

المقصد الثاني: بيع الأسهم بالتقسيط أو بضمن مؤجل

بغية تمكين الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من تملك اسهم الشركات العامة لتوسيع قاعدة الملكية أجاز المشرع الفرنسي تأجيل الوفاء بقيمة الأسهم أو تقسيطها، فقد نصت المادة الرابعة المعدلة من القانون الفرنسي الصادر في 1986/8/6 على جواز تأجيل الوفاء بضمن الأسهم التي يتم التنازل عنها من قبل الحكومة وفقا للشروط التي يحددها قرار البيع الصادر من وزير الاقتصاد، ويجب أن لا يتجاوز الأجل الممنوح للمشتري ثلاث سنوات من تاريخ البيع إذا ما تمت عمليات البيع وفقا لإجراءات سوق الأوراق المالية وإذا عجز المشتري عن أداء الثمن في الوقت المحدد فإن الدولة تسترد ملكية هذه الأسهم، وتتولى بيعها في سوق الأوراق المالية وتحفظ بالمبالغ المستحقة لها فضلا عن الفوائد التأخيرية ونفقات البيع، ويرد المتبقي لحامل هذه الأسهم.

وقد فصل المرسوم الفرنسي- رقم 97-177 الصادر في 1997/2/26 في الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة المشار إليها.

(¹) كذلك لم ينظم المشرع المصري هذا الأسلوب للتحويل والسبب في ذلك هو أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري رقم (203) لسنة 1991 قد أجاز بيع اسهم (الشركات التابعة) للقطاع الخاص، غير انه ليس بقانون للتحويل إلى القطاع الخاص بالمعنى الدقيق إذ لم يتضمن هذا القانون أية إشارة إلى أساليب التحويل إلى القطاع الخاص.

فوفقاً لهذا المرسوم، يكون حامل السهم الذي لم تسدد قيمته بالكامل متمتعاً بكافة الحقوق المتعلقة بهذا السهم طالما أنه مسجل باسمه لدى الشخص المعنوي الذي أصدره. وتكون هذه الأسهم قابلة للتداول وفقاً لأحكام القانون دون قيد أو شرط وذلك حتى حلول موعد دفع القسط الأخير من ثمنها، وإذا كانت هذه الأسهم صادرة من شركة يجوز تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية فإن هذه الأسهم تسعر على وفق (خط خاص) يختلف عن الخط الخاص بأسعار الأسهم المسددة قيمتها بالكامل ومع ذلك لا يمكن التصرف بهذه الأسهم خلال الشهر الذي يستحق فيه الثمن أو جزء منه، وفي حالة عجز الحامل عن الدفع في ميعاد الاستحقاق تطبق أحكام المادة (4) المشار إليها وتسجل الأسهم في سجلات الشركة باسم الدولة ودون الحاجة إلى أعذار الحامل للوفاء بالثمن المستحق. ووفقاً لهذا المرسوم تباع هذه الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استردادها من قبل الدولة ويكون للحامل الذي عجز عن أداء قيمة أسهمه حق الأولوية في شرائها عند بيعها من قبل الدولة في سوق الأوراق المالية.

ومما تقدم يتضح لنا أن المشرع الفرنسي قد جاء بإحكام تفصيلية خاصة ببيع الأسهم بالتقسيط فأجاز تقسيط ثمن الأسهم، وفي الوقت ذاته أجاز للحامل أن يتصرف بهذه الأسهم قبل سداد قيمتها بالكامل الأمر الذي يشكل حافزاً كبيراً للأفراد لشراء أسهم الشركات العامة عند تحويلها إلى القطاع الخاص ومن ثم يحقق هدف المشرع في توسيع قاعدة الملكية من خلال هذه العملية. وخلافاً لموقف المشرع الفرنسي- لم يعالج المشرع العراقي أساليب بيع الأسهم⁽¹⁾ فاستعاض عنها بالقواعد العامة للاكتتاب الواردة في قانون الشركات العراقي على النحو المشار إليه فيما تقدم. وقد يبدو لأول وهلة أن قانون الشركات العراقي أجاز

(¹) كذلك لم ينظم كلا من المشرع المغربي والمصري إجراءات بيع أسهم الشركات التجارية العامة بالتقسيط.

تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها في المرحلة التأسيسية للشركة، وان هذا يعني جواز تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها عند تحويل الشركات العامة إلى القطاع الخاص.

ومع ذلك فإن الأمر لا يخلو من الصعوبة لا سيما فيما يتعلق بتطبيق نص المادة (48/أولا) من قانون الشركات العراقي والتي تنص على انه "في الشركة المساهمة يجب على المؤسسين تسديد ما لا يقل عن (25%) من قيمة الأسهم التي يكتتبون بها عند التأسيس وتكون النسبة ذاتها واجبة التسديد من الجمهور عند اكتتابه باسهم الشركة في مرحلة التأسيس".

فهذا النص واضح في دلالة على عدم جواز تقسيط قيمة الأسهم للجمهور إلا إذا تم تقسيطها بالنسبة للمؤسسين أيضا وضمن نفس الشروط. ولما كانت الوزارة المعنية تعد مؤسسا للشركة الناجمة عن التحويل ومالكة لأسهم هذه الشركة بالكامل لذلك فإن قيمة الأسهم التي ستحتفظ بها تعد مدفوعة بالكامل لأنها مملوكة لها بالأساس، ومن ثم لا يجوز تقسيط قيمة الأسهم الأخرى التي تطرح للجمهور للاكتتاب بها، طالما ان قيمة اسهم المؤسسين مدفوعة بالكامل وهذا الحكم يشمل أيضا، حالة عدم احتفاظ الوزارة بأية نسبة من رأس مال الشركة الناجمة عن التحويل.

لذلك نقترح على المشرع العراقي ان ينظم الإجراءات التي تكفل تقسيط قيمة اسهم الشركات العامة عند بيعها للجمهور عند تحويلها إلى القطاع الخاص. وذلك لتمكين الأفراد من ذوي الدخل المحدود من تملك اسهم الشركات العامة عند تحويلها إلى القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.

المبحث الثاني التحول إلى القطاع الخاص عن طريق البيع لمستثمر رئيس

يتحقق هذا الأسلوب عن طريق بيع موجودات الشركة العامة أو بيع جميع أسهمها أو جزء كبير من هذه الأسهم إلى مستثمر واحد أو عدة مستثمرين وقد يتم البيع عن طريق التعاقد المباشر أو عن طريق تقديم العطاءات أو المزاد العلني⁽¹⁾.

ويتبع هذا الأسلوب بشكل خاص عندما يكون حجم الشركة العامة المراد بيعها صغيراً ولا يتناسب مع النفقات التي تستلزمها عملية العرض العام للأسهم أو عندما تكون هذه الشركة بحاجة إلى تكنولوجيا حديثة أو بحاجة إلى دخول الأسواق العالمية فيتم البيع لمستثمر رئيس وهو أجنبي في الغالب قادر على تحقيق هذه الأهداف. أو قد تكون الشركة العامة تعاني من العجز المالي أو الضعف الإداري بحيث لا يمكن معالجة هذه المشاكل المالية والإدارية إلا إذا تم البيع لمستثمر رئيس ذي كفاءة مالية أو خبرة إدارية عالية. فضلاً عن أن هذا الأسلوب يناسب المشروعات العامة التي لا يقسم رأسمالها إلى أسهم إذ يمكن بيع موجوداتها إلى مستثمر واحد أو عدة مستثمرين⁽²⁾.

غير أن ما يؤخذ على هذه الطريقة أنها قد تؤدي إلى تركيز الملكية كما أنها قد تؤدي إلى السيطرة الأجنبية في حالة كون المستثمر الرئيس من الأجانب⁽³⁾.

ومن أجل تحقيق المزايا المترتبة على اتباع هذا الأسلوب في التحول وتجنب سلبياته فقد حرصت التشريعات على تنظيم أحكامه من خلال التعاقد المباشر أو تقديم العطاءات في حين أولى المشرع العراقي عناية خاصة بأسلوب البيع عن طريق المزاد العلني، وسنتناول هذه الأساليب في مطلبين يخصص الأول للبيع عن طريق التعاقد المباشر أو تقديم العطاءات، أما الثاني فيخصص للبيع عن طريق المزاد العلني.

(1) UNCTAD., op. Cit., p. 90.

(2) UNCTAD., op. Cit., p. 90.

(3) ESCAW, op. cit., p. 22.

المطلب الأول

البيع عن طريق التعاقد المباشر أو تقديم العطاءات

سبقت الإشارة إلى أن البيع قد ينصب على أصول الشركة كما انه قد ينصب على جميع أسهمها أو جزء كبير من هذه الأسهم وهو ما يسمى بأسلوب (الطرح الخاص للأسهم)⁽¹⁾ وسنتناول إجراءات بيع الأسهم في المقصد الأول، ثم نبحت في إجراءات بيع الأصول في المقصد الثاني وكما يأتي:

المقصد الأول: الطرح الخاص للأسهم

الأصل في التشريع الفرنسي أن تتم عمليات التحول إلى القطاع الخاص وفقا لإجراءات سوق الأوراق المالية غير ان لوزير الاقتصاد وموافقة لجنة المشاركات والتحويلات أن يقرر البيع خارج سوق الأوراق المالية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية⁽²⁾.

ويجوز أن يتم التعاقد عن طريق تقديم عطاءات أو عن طريق التفاوض المباشر وعند التعاقد عن طريق تقديم عطاءات يتم تضمين شروط العملية في (كراسة الشروط) ثم يصار إلى نشر هذه الشروط ويكون للمستثمرين تقديم عطاءاتهم خلال (15) يوما من تاريخ النشر ويجب أن تتضمن هذه العطاءات الشروط المالية للشراء المقدمة من قبل كل مستثمر. أما إذا كان البيع عن طريق التفاوض المباشر فيجب إعداد تقرير يتضمن اسم المشتري وشروط العقد ويقدم إلى وزير الاقتصاد ويتولى وزير الاقتصاد إصدار قرار البيع وذلك بعد موافقة لجنة المشاركات والتحويلات⁽³⁾. وقد يكون البيع في هذه الحالة ضمن ما يسمى باتفاقية التعاون الصناعي

(¹) د. محمود الصبح، المرجع السابق، ص36.

(²) المادة (الرابعة) من قانون التحول الفرنسي الصادر في 1986/8/6 ومن الشركات التي تم بيعها وفقا لهذه المادة شركة (C.C.F.) - (B.T.P.) Banque du butimentetdes travaux وشركة Credit commirecial de France Banque du baillon et des travaux puplics.

.puplics

انظر: Christain baillon , op. cit., p. 217-218.

(³) Jean-paul valuet , op. cit., p. 11-12.

أو التجاري أو المالي. Cooperation industrielle , commerciale ou financiere فقد تتضمن هذه الاتفاقية تحويل جزء من رأسمال الشركة إلى الطرف الآخر من هذه الاتفاقية والذي يكون من القطاع الخاص، وفي هذه الحالة يجب أيضا ان يوافق وزير الاقتصاد ولجنة المشاركات والتحويلات على شروط الاتفاقية وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتضمن النشر أهداف الاتفاق ومعلومات عن المساهمين الجدد وتعد هذه الاتفاقية نافذة بعد (15) يوما من تاريخ آخر نشر⁽¹⁾.

وفضلا عن ذلك فقد يتم البيع خارج سوق الأوراق المالية عن طريق البيع لما يسمى (مجموعة المساهمين الثابتة) (Groaped action inestables G.A.S.) وهذه العملية لم ينظمها المشرع الفرنسي بشكل مباشر، غير أن تشكيل مثل هذه المجموعة يدخل ضمن الإطار العام لقانون التحويل إلى القطاع الخاص الفرنسي الذي يجيز البيع خارج سوق الأوراق المالية، إذ يكون الوزير الاقتصاد ولجنة المشاركات والتحويلات سلطة تنظيم شروط هذه العملية وذلك استنادا إلى نص المادة (4-2) المعدلة من القانون الصادر في 1986/8/6 والمرسوم الفرنسي رقم 93-1041 في 1993/9/3.

وتنظم العلاقة القانونية بين أعضاء هذه المجموعة عن طريق كراسة الشروط التي تستخدم في عملية بيع الأسهم بحيث يلتزم الأعضاء في هذه المجموعة بعدم نقل ملكية أسهمهم في الشركة التي تم بيع أسهمها خلال فترة معينة (شرط عدم التصرف) وهذه المدة قد تكون عدة أسابيع أو سنة أو سنتين، لا يجوز التصرف خلالها بنسبة معينة من اسهم هؤلاء المساهمين، كما يلتزم هؤلاء المساهمون بعدم التخلي عن هذه النسبة من الأسهم بعد انتهاء مدة الحظر إلا لمستثمرين آخرين يعينهم وزير الاقتصاد وهذا ما يعرف بشرط الأفضلية أو الشفعة (Claus de preemption) وهو يعطي حق الأولوية في شراء الأسهم التي تم بيعها بالتراضي إلى مجموعة من الأشخاص⁽²⁾.

⁽¹⁾ انظر في ذلك المرسوم الفرنسي رقم 93-1-41 في 1993/9/3، كذلك المرسوم 98-315 في 1998/4/47. وانظر: Alic pezard , op. ciy o. 4.

⁽²⁾ Y. D Jehane, pasoyaux durs aux groupes dezationnaircs stables , Banque , n 543, dec. 1993, p. 7.

أما عن موقف المشرع المغربي فلقد أجاز أيضا البيع خارج سوق الأوراق المالية عن طريق تقديم العطاءات أو عن طريق التفاوض المباشر⁽¹⁾. وما نلاحظه على موقف المشرع المغربي انه حدد الأهداف التي ينبغي مراعاتها عند اتباع هذه الأساليب في البيع والتي تتمثل بما يأتي⁽²⁾:

1. تمكين فئات اجتماعية جديدة من امتلاك المنشآت ومناهضة الاحتكار.
2. تطوير ودعم الاقتصاد الوطني
3. المحافظة على تشغيل العمال في المشروعات محل التحول.

وعلى هذا الأساس نصت المادة (10) من المرسوم المغربي رقم (290402) الصادر في 16/10/1990 على انه "رغبة في تحقيق تطوير وتعزيز الاقتصاد (الجهوي) فان امتلاك مساهمات عامة في بعض الشركات المعنية بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبعد استطلاع هيئة التقويم يخصص بالأسبقية للفئات التالية:

1. الأشخاص الطبيعيون المقيمون أو المولودون أو المزاولون نشاطا اقتصاديا في العمالة أو الإقليم الذي يوجد به مركز نشاط الشركة المراد تحويل المساهمات العامة فيها إلى القطاع الخاص.
2. الأشخاص الطبيعيون ذوي الجنسية المغربية المقيمين بالخارج أو المولودين في العمالة أو الإقليم.
3. الشركات الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الجهوي التي يوجد مقرها الرئيس في العمالة أو الإقليم ويكون أكثر من نصف رأسمالها مملوكا لأشخاص طبيعيين من المشار إليهم في البندين (1 و2) أعلاه.

ولبلوغ الغاية المنصوص عليها أعلاه، توجه دعوة لتقديم عروض لشراء المساهمات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مقصورة على الأشخاص

⁽¹⁾ المادة (14) من قانون التحول المغربي لسنة 1990.

⁽²⁾ المادة (2/5) من القانون المغربي المشار إليه.

الطبيعيين والمعنويين المنتمين إلى الفئات الوارد بينها فيما سبق. وإذا لم تفض الدعوة لتقديم عروض الشراء الموجهة إلى هذه الفئات إلى أي نتيجة عند انصرام شهرين من تاريخ نشر الإعلان المتعلق بها فان المساهمات المعنية تباع وفق الشروط العامة المنصوص عليها في هذا المرسوم".

وقد حدد المشرع المغربي إجراءات البيع عن طريق تقديم العروض (العطاءات) إذ ينبغي أولاً على الوزير المختص، أن يقوم بنشر إعلان في الجريدة الرسمية وفي الصحف يتضمن بوجه خاص تحديد نسبة المساهمات أو المنشآت المراد بيعها والأشخاص الذين يملكونها وسعر العرض الأدنى والذي يجب أن يكون مساوياً للسعر المحدد من قبل هيئة التقويم والأجل المحدد لتقديم العروض وشروط البيع الخاصة⁽¹⁾. ويجب تقديم عروض الشراء خلال المدة المحددة بالإعلان وبعد ذلك تتولى لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص فتح الظروف ويقبل العرض الذي يتضمن أعلى سعر مقدم للشراء ويعتبر البيع ناجزاً من تاريخ صدور مرسوم بذلك، وذلك خلال شهرين من تاريخ فتح الظروف⁽²⁾.

وفي حالة تخلف الشخص الذي قبل عرضه المقدم للشراء يصار إلى بيع المساهمات أو المنشآت باتباع واحد أو أكثر من طرق التحويل الواردة في القانون المغربي⁽³⁾.

أما عن إجراءات البيع المباشر في القانون المغربي فيتم تحديد المساهمات أو المنشآت محل البيع المباشر بمرسوم يصدر من الوزير المختص وتوافق عليه لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ويتضمن هذا المرسوم النسبة المئوية للمساهمات أو المنشآت المراد تحويلها إلى القطاع الخاص والأشخاص الذين يملكونها والشركة المعنية ومقرها الرئيسي وغرضها والنشاط الذي تقوم به⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ المادة (15) من المرسوم المغربي المشار إليه أعلاه.

⁽²⁾ المادة (16) من المرسوم المغربي المشار إليه أعلاه.

⁽³⁾ المادة (17) من المرسوم المغربي المشار إليه.

⁽⁴⁾ المادة (18) من المرسوم المغربي المشار إليه.

ويتولى الوزير المختص إحالة اقتراح البيع المباشر على لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص لإستحصل موافقتها على البيع، ويتضمن تقرير الوزير الاقتراحات التي قدمها من يرغب بالشراء والأسباب التي تجعل هذه الاقتراحات تتيح تحقيق واحد أو أكثر من أهداف البيع التي أشرنا إليها فيما تقدم. وعندما توافق اللجنة على الاقتراح يتولى الوزير المختص إبرام عقد البيع الذي يكون معلقا على صدور المرسوم الخاص بالبيع ويصبح العقد نافذا فور تبلغ المشتري بالمرسوم المشار إليه ويجب أن تنشر موافقة لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص على اقتراح البيع المباشر مع المرسوم المشار إليه⁽¹⁾.

ويتضح لنا مما تقدم إن كلا من المشرع الفرنسي والمغربي قد جعل البيع خارج سوق الأوراق المالية استثناء من الأصل العام وهو بيع الأسهم عن طريق العرض العام للأسهم في سوق الأوراق المالية. وان الغاية من إجازة البيع خارج سوق الأوراق المالية هو تحقيق أهداف اقتصادية معينة كتمكين فئة معينة من تملك اسهم الشركة العامة لضمان استمرار الشركة في تحقيق أهدافها بعد عملية التحويل. كما ويلاحظ ان كلا من المشرع الفرنسي والمغربي قد راعى في تنظيمه لعملية التحويل عن طريق تقديم العطاءات أو التفاوض المباشر ان تكون الأحكام القانونية الخاصة بهذا الأسلوب مفصلة بحيث لا تدع مجالا للشك في مدى سلامة إجراءات البيع وبشكل خاص تحديد سعر البيع⁽²⁾.

وفيما يتعلق بمدى إمكانية تطبيق هذا الأسلوب في مصر يشير دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج الحكومة المصرية لسنة 1996 إلى إمكانية البيع لمستثمر رئيس من خلال دعوة المستثمرين للتقدم بعطاءاتهم. كما وبين هذا الدليل شروط وإجراءات التعاقد عن طريق تقديم العطاءات⁽³⁾.

⁽¹⁾ المادة (19) من المرسوم المغربي المشار إليه.

⁽²⁾ ومن أجل ضمان تحديد السعر العادل للبيع إلزم المشرع السنغالي والأرجنتيني الحكومة باتباع أسلوب العطاءات وتجنب استخدام أسلوب التفاوض المباشر عند البيع لمستثمر رئيس. وانظر: د. منير إبراهيم هندي، خصخصة المشروعات العامة، المرجع السابق، ص 57.

⁽³⁾ دليل الإجراءات والإرشادات العامة برنامج الحكومة المصرية، المرجع السابق، ص 23-25.

والحقيقة ان استخدام هذا الأسلوب في مصر- لا يتعارض مع قانون الشركات المصري لسنة 1982 والذي لم يضع حداً أعلى لملكية الأسهم في الشركات المساهمة المصرية⁽¹⁾.
أما عن مدى إمكانية استخدام هذا الأسلوب في العراق فيبدو انه يصعب الأخذ بهذا الأسلوب للتحويل إلى القطاع الخاص في العراق لان المشرع العراقي قد وضع حداً أعلى لمساهمة الشخص في الشركات المساهمة، فلا يجوز ان تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي والمعنوي من غير القطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة الخاصة على (20%) من رأسمالها، وللجهة القطاعية المختصة أن تحدد الحد الأعلى لمساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي من غير القطاع الاشتراكي في الشركة المختلطة على ان لا يتجاوز (10%) من رأسمالها⁽²⁾.
وهذا يعني انه لا يمكن لشخص واحد أن يمتلك غالبية رأسمال الشركة العامة عند تحويلها إلى القطاع الخاص. ومع ذلك يمكن لعدة أشخاص أن يملكوا غالبية رأسمال الشركة العامة عند تحويلها غير أن تملك اسهم الشركة لا يكون من خلال التعاقد المباشر مع الوزارة المعنية أو عن طريق تقديم العطاءات وإنما عن طريق الاكتتاب العام، وهذا ما يجعل هذا الأسلوب عديم الفائدة في العراق، إذ يصعب فرض الشروط على المكتتبين لمنعهم من التصرف بأسهمهم أو لضمان تنفيذ استراتيجية معينة لنشاط الشركة بعد التحويل لان الاكتتاب العام يتم أساساً وفقاً للقواعد العامة الواردة في قانون الشركات العراقي. وهذا ما يؤكد بالتالي مدى أهمية تنظيم عملية التحويل على نحو يكون فيه للوزارة المعنية الحق في بيع أسهمها بالطريقة المناسبة، فيمكنها ان تبيع هذه الأسهم عن طريق تقديم العطاءات أو التعاقد المباشر الأمر الذي يمكنها بالتالي من فرض الشروط المناسبة على المشتريين، وبما حذاً لو أن المشرع

(¹) ولاحظ، أن الواقع العملي في مصر يشير إلى انه ابتداءً من عام 1997 تم اتباع طريقة البيع لمستثمر رئيسي- بدلاً من طريقة العرض العام للأسهم، انظر: تصريح وزير قطاع الأعمال العام المصري (مختار خطاب)، جريدة الأهرام الاقتصادي، السنة 125 - العدد 41565، 2000/9/24، ص25.
(²) المادة (32/أولاً) من قانون الشركات العراقي.

العراقي ينظم أساليب بيع أسهم الشركات العامة ويجعل من أسلوب العرض العام الأساس في عملية التحويل مع إمكانية التعاقد عن طريق تقديم العطاءات في الحالات الاستثنائية التي يقدر المشرع أهميتها.

المقصد الثاني: بيع أصول المشروعات العامة

سبقت الإشارة إلى أن عملية البيع لمستثمر رئيس لا تقتصر على حالة بيع الأسهم بل تشمل أيضا حالة بيع الأصول لهذا المستثمر.

ولم ينظم المشرع الفرنسي إجراءات بيع أصول الشركة العامة ضمن أساليب التحويل إلى القطاع الخاص، غير أن القضاء الفرنسي يذهب إلى وصف عملية بيع أصول الشركة العامة بأنها من قبيل عمليات التحويل إلى القطاع الخاص، فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الفرنسية أن تحويل أية شركة من القطاع العام إلى القطاع الخاص لا يأتي عن طريق التنازل عن غالبية أسهم رأس المال، وإنما عن طريق التنازل عن موجودات الشركة محل التحويل أيضا⁽¹⁾. ومما تجدر ملاحظته في هذا المجال أن الموجودات محل التنازل يجب أن تكون في هذه الحالة -وفقا لهذا القرار- "محلا لاستغلال اقتصادي مستقل وممثلة لجزء أساسي من نشاط الشركة العامة محل التحويل"⁽²⁾. كما أن التنازل عن الموجودات لا يعد من قبيل عمليات التحويل إلى القطاع الخاص، إذا كان هذا التنازل قد تم لمصلحة شركة أخرى من القطاع العام، وعلى هذا الأساس قرر مجلس الدولة الفرنسي عدم اعتبار تحويل وسائل الاستغلال لشركة عامة أو أحد فروعها أو إلى شركة عامة أخرى من قبيل عمليات التحويل إلى القطاع الخاص⁽³⁾.

ويتضح مما تقدم أن القضاء الفرنسي يشترط لكي يعد التنازل عن موجودات الشركة من قبيل عمليات التحويل إلى القطاع الخاص أن تكون هذه الموجودات محلا

⁽¹⁾ Cass.1er civ. 3mai 1988.

⁽²⁾ Jen paul valuet , op. cit., p.8

⁽³⁾ CE 6 mars , 1991 , RF. Adm. publ. 1991 , P. 839.

لاستغلال اقتصادي مستقل على الرغم من عدم تمتعها بالشخصية المعنوية كالفنادق مثلا. وعلى هذا الأساس يعد بيع موجودات الشركة العامة من أساليب التحول إلى القطاع الخاص في فرنسا، وينبغي أن يراعى فيه جميع الشروط والإجراءات التي قررها المشرع الفرنسي. بخصوص عمليات التحول إلى القطاع الخاص كضرورة التعاقد عن طريق العطاءات أو مباشرة وضرورة تحديد السعر بما ينسجم مع قرار وزير الاقتصاد ولجنة المشاركات والتحويلات وغير ذلك.

أما عن موقف المشرع المغربي فقد أجاز صراحة (بيع المنشآت) بوصفها وسيلة من وسائل التحول إلى القطاع الخاص⁽¹⁾، ويتم بيع هذه المنشآت أما عن طريق تقديم العطاءات أو عن طريق التفاوض المباشر، وعلى النحو الذي أشرنا إليه فيما تقدم.

وقد أجاز المشرع المصري أيضا أن تنصب عملية البيع على أصول الشركة العامة غير انه خول الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة بيع الأصول في حالتين استثنائيتين فقط، أشارت إليهما المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المصري، فقد نصت هذه المادة على انه "لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في اصل من خطوط الإنتاج الرئيسة إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقا لما يأتي:

1. أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلًا اقتصاديًا أو أن يؤدي الاستمرار في تشغيلها إلى تحميل الشركة خسارة مؤكدة.
2. إلا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون وهذه اللجنة التي يشير إليها النص المتقدم هي اللجنة المختصة بتقدير الحصص العينية.

(¹) انظر المواد (15-19) من المرسوم المغربي رقم 290402 الصادر في 16/10/1990 والمشار إليه فيما تقدم.

ويتضح لنا من هذا النص أن المشرع المصري لا يجيز بيع أصول الشركات العامة التي يصح أن تكون محلا لاستغلال اقتصادي مستقل إلا في الحالتين الاستثنائيتين الواردتين في النص المتقدم.

وقد أشار دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج الحكومة المصرية إلى أن البيع في هذه الحالة يمكن أن يتم في مزاد عام أو عن طريق التقدم بعروض للشراء بأسلوب الظروف المغلقة⁽¹⁾.

أما عن موقف المشرع العراقي من عملية بيع الأصول فنلاحظ أنه قد جرى العمل في العراق على اتباع هذا الأسلوب للتحويل. غير أن ما يميز موقف المشرع العراقي في هذا المجال أن عملية البيع هذه تتم عن طريق المزايدة العلنية وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ولأهمية هذا الأسلوب في العراق سنخصص له مطلباً مستقلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن بيع الأصول قد يكون جزءاً من إجراءات تصفية الشركة العامة ففي بعض الحالات الخاصة قد تفضل الدولة بيع الشركة العامة كأصول بدلا من بيع أسهمها بوصفها مشروعاً مستمراً⁽²⁾.

ومن هذه الحالات الحالة التي يكون فيها ثمن بيع الأصول أكبر من ثمن بيع الأسهم أو عندما لا يكون هناك إقبال من الجمهور على شراء أسهم الشركة العامة أو عند تعرض الشركة للخسارة أو عجزها عن استثمار هذه الأصول استثماراً مجزياً⁽³⁾.

وقد قررت المادة (14) من قانون الشركات العامة العراقي إحدى هذه الحالات وهي حالة خسارة الشركة لنسبة كبيرة من رأسمالها الاسمي فوفقاً لهذه المادة إذا بلغت خسارة الشركة (50%) من رأسمالها الاسمي فعلى الوزارة إعداد تقويم اقتصادي لها يقدم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الشركة أو تصفيتها.

(1) دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج الحكومة المصرية، المرجع السابق، ص24.

(2) ومما ينبغي ملاحظته أن الدولة غير ملزمة ببيع أصول الشركة العامة بعد تصفيتها، إذ يمكنها أن تستمر باستغلال بعض الأصول، كما يمكنها أن تؤولها إلى القطاع الخاص أيضاً. انظر:

UNCTAD, Op.Cit., p. 99.

(3) المصدر نفسه، الصفحة نفسها، كذلك د. محمود الصبح، المرجع السابق، ص37-38.

المطلب الثاني البيع عن طريق المزايدة العلنية

الأصل أن لا يقدم المتعاقدان على التعاقد، إلا بعد مرحلة يتفاوضان فيها على شروط العقد ومن ثم يعلنان عن موافقتهم النهائية على التعاقد. غير أن هناك عقوداً تبرم دون سابق مفاوضة ومن هذه العقود، العقود التي تتم عن طريق المزايدة العلنية وفي هذا النوع من العقود يعد العطاء الذي يبدأ به المكلّف بالمزاد (المنادي) مجرد دعوة إلى التعاقد، أما الإيجاب فهو العطاء الذي يتقدم به أحد المشتركين في المزايدة أما القبول فلا يتم إلا برسو المزايدة على الشخص الأخير. ولما كان الإيجاب هو العطاء الذي يتقدم به أحد المشتركين بالمزايدة فإنه يسقط بعطاء أزيد منه ولو وقع باطلاً أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد⁽¹⁾. والبيع بالمزاد العلني يستخدم وسيلة للتحويل إلى القطاع الخاص في نقل ملكية المشروعات العامة الصغيرة أو المتوسطة الحجم التي لا يستلزم تحويلها إلى القطاع الخاص إدخال تكنولوجيا حديثة أو تحسينات إضافية خاصة ولهذا الأسلوب في التحويل مزاياه الخاصة فلأنه يقوم بالأساس على تقديم عطاءات تنافسية بشكل علني تتوافر فيه صفة الشفافية⁽²⁾. إلى حد كبير، كما أن إجراءات البيع بالمزاد العلني تكون سريعة وغير معقدة بالمقارنة مع الأساليب الأخرى للتحويل. أما عن الانتقادات التي وجهت لهذا الأسلوب فتتمثل بأنه لا يصلح وسيلة لتحويل المشروعات العامة الكبيرة إلى القطاع الخاص، كذلك لا يمكن وفقاً لهذا

(¹) د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني - الجزء الأول - مصادر الالتزام، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الرابعة، 1974، ص 89-90.

(²) ويقصد بالشفافية " وضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضوعيتها ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وبما يتناسب مع روح العصر، فضلاً عن تبسيط الإجراءات ونشر المعلومات والإفصاح عنها وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة للجميع ". أنظر د. موسى اللويزي، التنمية الإدارية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الطبعة الأولى، 2000، ص 148.

الأسلوب فرض شروط البيع بنفس الحرية التي يمكن من خلالها فرض هذه الشروط عند اتباع الأساليب الأخرى للتحويل وذلك لان البيع في هذه الحالة لا تسبقه مرحلة تفاوض فيما بين المتعاقدين وأخيرا هناك خشية من عدم اشتراك عدد كاف من المزايدين في المزاد الأمر الذي قد يؤثر في سعر البيع باتجاه الانخفاض⁽¹⁾.

وإذا كان هذا الأسلوب للتحويل إلى القطاع الخاص قد استخدم في عدد كبير من دول أوروبا الشرقية والوسطى⁽²⁾ فان كلا من المشرع الفرنسي والمغربي قد اغفل معالجته ضمن أساليب التحويل إلى القطاع الخاص. في حين تبني المشرع العراقي هذا الأسلوب في عمليات التحويل إلى القطاع الخاص التي جرت في العراق ابتداء من عام 1988 وذلك وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986. وقد فرق هذا القانون بين إجراءات بيع الأموال المنقولة وإجراءات بيع الأموال غير المنقولة لذلك سنخصص لكل منهما مقصدا مستقلا وكما يأتي:

المقصد الأول: بيع العقار في المزايمة العلنية

سبق وان أشرنا إلى أن التحويل إلى القطاع الخاص، قد يتحقق عن طريق بيع الأصول وانه لا يقتصر على حالة بيع الأسهم. لذلك يمكن بيع المعامل الصغيرة أو الفنادق إلى القطاع الخاص عن طريق المزايمة العلنية أيضا ووفقا للمادة الثامنة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم 32 لسنة 1986 تتولى لجنة البيع إجراءات بيع هذه الأموال بعد ورود موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله على البيع وورود تقرير لجنة التقدير ومصادقة الوزير

(1) UNCTAD, Op. Cit., P. 91.

(2) وتعد عمليات التحويل إلى القطاع الخاص - عن طريق البيع بالمزاد العلني التي جرت في جمهورية جيكونسولوفاكيا السابقة من أبرز الأمثلة على مدى فاعلية هذا الأسلوب وسرعته فوفقا لقانون التحويل ذي النطاق المحدود Small-scale-privatization الصادر في تشرين الثاني 1990 تمت جميع إجراءات التحويل من شباط 1991 لغاية النصف الأول من عام 1993 وبلغت حصيلة عمليات البيع ما يزيد على (1.6) بليون دولار أمريكي. انظر: UNCTAD, Op. Cit., P. 91.

- أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله على هذا التقدير وعلى النحو الآتي:
1. تنظم لجنة بيع الأموال غير المنقولة قائمة مزايده في ضوء أوصاف العقار المثبتة من قبل لجنة التقدير وتبقى هذه القائمة لدى الدائرة المعنية المكلفة بالبيع لاطلاع المواطنين عليها خلال مدة المزايدة.
 2. عند تعدد العقارات المراد بيعها تنظم قائمة مزايده لكل منها على حدة.
 3. يعلن عن بيع العقار بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق نسخة من الإعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه وأخرى على مدخله وللجنة فضلا عن ذلك نشر- الإعلان، وإذاعته بوسائل الإعلان الأخرى إذا ما قدرت أن المصلحة تدعو إلى ذلك.
 4. يجب أن يتضمن الإعلان جميع أوصاف العقار المثبتة في المحضر والمنظم من قبل لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه.
 5. تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر- الإعلان في الصحيفة وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم في ذلك على أن يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن (20%) من القيمة المقدرة للعقار ويجوز للدائرة أن تستوفي نسبة أعلى وهو ما يفضلها البعض للتأكد من جدية المشترك في المزايدة⁽¹⁾.
- أما من يشترك في المزايدة عند إجرائها ولم يكن قد دفع التأمينات فتستوفي منه هذه التأمينات عند رسو المزايدة عليه⁽²⁾.

(¹) د. عصمت عبد المجيد بكر، أحكام بيع وإيجار أموال الدولة - دراسة في ضوء القانون رقم 32 لسنة 1986، مطبعة الخيرات، بغداد، 2000، ص 34.

(²) المادة (10/خامسا) من التعليمات المالية الصادرة من وزارة المالية رقم (5) لسنة 1986.

ومن الواضح ان هذا الحكم يحول دون تحقيق الغاية التي توخاها المشرع وهي ضمان جدية المشترك في المزايدة عندما اشترط عليه دفع نسبة (20%) من القيمة المقدرة للعقار قبل الاشتراك في المزايدة. أما عن مكان إجراء المزايدة العلنية لبيع العقار فالمزايدة لا تجري إلا ضمن الوحدة الإدارية التي يقع فيها العقار وفي اليوم المحدد للمزايدة ينادي للاشتراك في المزايدة على أن يتضمن النداء وصفا كاملا للعقار المراد بيعه وتجري المزايدة علنا ولا تفتح بأقل من (70%) من القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع الإحالة على المزايد الأخير ويعد العرض الذي لا يزداد عليه خلال خمسة دقائق نهاية للمزايدة.

6. يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير خلال خمسة أيام من تاريخ الإحالة على أن لا يقل عن (15%) من البديل الأخير وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر ثم تجري بعدها الإحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير⁽¹⁾.

ووفقا للمادة العاشرة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، إذ لم يبلغ بدل البيع القيمة المقدرة له من قبل لجنة التقدير تمديد المزايدة لمدة (15) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة وإذا لم يبلغ بدل البيع بنتيجة المزايدة الثانية (80%) من القيمة المقدرة يعاد تقديره من قبل لجنة تقدير أخرى تشكل وفق أحكام المادة (7) التي أشرنا إليها ويعلن عن إجراء مزايدة جديدة. أما إذا لم يحصل راغب في الشراء بموجب التقدير الجديد فيعرض الأمر على الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة لتقرير ما تراه مناسبا⁽²⁾.

وعلى أية حال إذا تمت الإحالة فتعاد التأمينات إلى الأشخاص الذين (يكفون يدهم) عند مراجعتهم ومطالبتهم باستعادتها ويبلغ صاحب الضم ما قبل الأخير

⁽¹⁾ المادة التاسعة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.

⁽²⁾ المادة (11) من التعليمات رقم (5) الصادرة من وزارة المالية.

بضرورة التريث في سحب تأميناته لحين انتهاء المدة القانونية البالغة ثلاثين يوما والتي بانتهائها يعد المشتري ناكلا إذا لم يدفع بدل البيع⁽¹⁾.

ولا تعد الإحالة عند البيع قطعية إلا بتصديق الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله، غير أن قانون بيع وإيجار أموال الدولة لم ينص على مدة محددة للتصديق على قرار الإحالة⁽²⁾ ومن ثم نرى أنه من الضروري أن يقرر المشرع مدة محددة يجب فيها على الجهات المذكورة المصادقة على قرار الإحالة وذلك لتجنب تعقيد إجراءات البيع أو إطالتها.

وطبقا للمادة الثانية عشرة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة يلتزم المشتري بدفع بدل بيع العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية وللوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله الموافقة على دفع الثمن مقسما على الوجه الآتي:

1. نصف بدل البيع وكامل المصاريف خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية.
2. بقية بدل البيع بأقساط لا تتجاوز خمسة أقساط ولا يمتد أجل آخر قسط إلى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الإحالة القطعية.

وإذا تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط في موعده فللوزير أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه وفي هذه الحالة تفرض الفائدة على القسط المستحق وإذا تكرر ذلك فللوزير أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة إلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة وعند تعذر ذلك يباع العقار وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة وتستوفي الأقساط الباقية من ثمنه⁽³⁾.

⁽¹⁾ المادة 12/أولا من التعليمات أعلاه.

⁽²⁾ المادة (11) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

⁽³⁾ المادة الرابعة عشرة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

ويذهب مجلس شوري الدولة في أحد قراراته إلى " إن سعر الفائدة المصرفي المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، يكون وفقا لسعر الفائدة التأخرية الذي تستوفيه المصارف الاختصاصية على قروضها والذي يحدده البنك المركزي وحسب طبيعة العقار الموصوف في إعلان البيع بالمزايدة العلنية ⁽¹⁾ .

ولاشك عندنا في أن هذه الأحكام التي تجيز للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تقسيط الثمن من شأنها أن تيسر على الأشخاص من القطاع الخاص، عند شرائهم للمشروعات العامة أو جزء منها مبناسبة عملية التحول إلى القطاع الخاص.

ومهما يكن من أمر يسجل العقار المباع باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري ⁽²⁾ بعد تسديده الثمن والمصاريف كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية إذ تتولى الدائرة المختصة والتي تولت عملية البيع إشعار مديرية التسجيل العقاري لتسجيل العقار المباع باسم المشتري.

كما يتم تسجيل العقار باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري في حالة قيام المشتري بتسديد نصف البدل وكامل المصاريف وتنظيم دفع بقية البدل على النحو السالف الذكر على أن توضع إشارة الحجز على سجله العقاري ويكون لهذه الشارة حكم الرهن التأميني.

⁽¹⁾ القرار المرقم 1993/62 في 1993/12/29 نقلا عن د. عصمت عبد المجيد، المرجع السابق، ص58: ولعل من المناسب ان نذكر ان سعر الفائدة التأخرية التي تفرضها المصارف على قروضها عند التأخير في تسديدها هي (16%) للمصرف التجاري و(14%) للمصرف الزراعي و (7-9%) للمصرف الصناعي و (12%) للمصرف العقاري وذلك حسب تحديد البنك المركزي الذي خولته المادة (2/49) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976، تحديد الحدود العليا والدنيا لأسعار الفائدة التي تتقاضاها المصارف. انظر: د. عصمت عبدالمجيد، المرجع السابق، ص57.

⁽²⁾ المادة الخامسة عشرة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة والمادة السابعة عشرة من التعليمات رقم (5) الصادرة عن وزارة المالية.

ووفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (858) الصادر في 1987/7/19⁽¹⁾ يجوز نقل ملكية العقارات التي تم تملكها وفقاً لأحكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة ذات العلاقة بشرط تسديد بدل شراء تلك العقارات قبل إجراء التصرف فيها.

وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني العراقي فقد جاء في قرار محكمة التمييز انه " إذا كان المدعي عند شرائه معمل الكتل الكونكريتية ودفعه الثمن إلى المدعي عليه ولم تكن قاطعة البلوك بحوزة المدعي عليه وإنها لدى جهة أخرى واطلع المدعي على ذلك وراجع المحافظة لتسلمها منها فليس له بعدئذ المطالبة باجر المثل عن الإضرار التي لحقت به جراء عدم وجود القاطعة طالما انه ارتضى لنفسه تسلم المبيع بهذا الشكل بل كان عليه طلب الفسخ أو اخذ المبيع بكل الثمن استناداً إلى حكم المادة (543 - مدني)⁽²⁾.

المقصد الثاني: بيع الأموال المنقولة في المزايدة العلنية

مما لا شك فيه أن الأسهم تعد من الأموال المنقولة التي يمكن التصرف فيها وفقاً لأحكام خاصة تتضمنها عادة قوانين الشركات. كما ويمكن بيع هذه الأسهم عن طريق المزايدة العلنية في حالات خاصة⁽³⁾ ومنها حالة بيع أسهم الشركات العامة عن طريق المزايدة العلنية للجمهور وذلك وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة. فقد نظم هذا القانون إجراءات

(¹) الوقائع العراقية، العدد (3178) في 1987/11/3.

(²) قرار محكمة التمييز المرقم 232 / موسعة أولى / 86-1987، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع، 1987، ص 24-25.

(³) تجيز المادة (48/أولاً) من قانون الشركات العراقي والمادة (2/32) من قانون الشركات المصري والمادة (2/75) من قانون الشركات التجارية الفرنسي للمساهمة أن يدفع 25% من قيمة الأسهم عند الاكتساب، ويتم تسديد الباقي على أقساط خلال أربع سنوات وفقاً للتشريع العراقي، وخلال خمس سنوات وفقاً للتشريعين الفرنسي والمصري، وإذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها، يكون للشركة بعد إذاره أن تعرض أسهمه للبيع في المزايدة العلنية.

بيع الأموال المنقولة وهي لا تختلف في مجملها عن إجراءات بيع الأموال غير المنقولة المشار إليها فيما تقدم إلا في بعض الأحكام المتعلقة بطبيعة الأموال المنقولة محل البيع إذ تتولى إجراءات البيع لجنة البيع المشكلة وفقا للمادة الثامنة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة والتي تقوم بالإجراءات الآتية:

1. تنظيم قائمة المزاييد في ضوء أوصاف الأموال المراد بيعها التي تثبتها لجنة التقدير كما ويتم الإعلان عن وضع الأموال في المزاييدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد على أن لا تقل المدة بين تاريخ نشر الإعلان والتاريخ المعين لإجراء المزاييدة عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوما وتعلق نسخة من الإعلان في الدائرة التي تتولى بيعها وأخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة فضلا عن ذلك أن تقرر نشر الإعلان بوسائل الإعلان الأخرى إذا رأت أن المصلحة تدعو إلى ذلك. ويجب ان يتضمن إعلان البيع أوصاف الأموال المراد بيعها ويوم المزاييدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري فيه⁽¹⁾.

2. تعد قائمة المزاييدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم في الاشتراك بالمزاييدة على أن يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن (20%) من القيمة المقدرة للأموال ومع ذلك يجوز لمن لم يقيد أسمه في قائمة المزاييدة أن يشترك في المزاييدة على أن تستوفي منه هذه التأمينات عند رسو المزاييدة عليه⁽²⁾.

3. ينادى في اليوم المعين للبيع في الزمان والمكان المحددين للاشتراك في المزاييدة على أن يتضمن النداء وصفا كاملا للأموال المراد بيعها وتجري المزاييدة علنا ثم تقرر لجنة البيع الإحالة على المزاييد الأخير ويعد العرض الذي لا يزداد عليه خلال دقيقة واحدة إلى خمسة دقائق نهاية للمزاييدة وللجنة البيع تحديد هذه المدة حسب نوع المال المعروض للبيع⁽³⁾.

(¹) المادة (السادسة والعشرون / أولا وثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي.

(²) د. عصمت عبد المجيد، المرجع السابق، ص 70.

(³) المادة (السادسة والعشرون / رابعا وخامسا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

4. يجوز الضم "كسر القرار" على بدل المزايدة الأخير خلال خمسة أيام من تاريخ الإحالة على أن لا يقل عن (15%) من البديل الأخير وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة سبعة أيام من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة ثم تجري بعدها الإحالة ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير⁽¹⁾.
5. إذا لم يبلغ بدل بيع الأموال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة لها من لجنة التقدير تمديد المزايدة (15) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة وتباع الأموال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه إذا لم تكن من الأموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية أما إذا رأت لجنة البيع أن السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لا يحقق المصلحة العامة فتمدد المزايدة خمسة عشر يوما أخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة وتباع الأموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه⁽²⁾.
- ونعتقد أن هذا الحكم لا ينسجم مع غاية المشرع في البيع بسعر عادل فإذا كانت دواعي المصلحة العامة هي التي دفعت المشرع إلى تخويل لجنة البيع الحق في عدم إتمام إجراءات البيع في المزايدة الثانية عندما تقدر أن السعر الذي رست عليه هذه المزايدة لا يحقق المصلحة العامة فإن السعر الذي ستباع به هذه الأموال في المزايدة الثالثة قد لا يحقق المصلحة العامة أيضا لذا نرى أنه من الضروري في هذه الحالة أن يقرر المشرع تخويل لجنة البيع. تقديم توصية إلى الوزير المختص لبيع تلك الأموال بأسلوب آخر غير المزايدة العلنية. وبشكل خاص في حالة بيع أسهم الشركات العامة.
6. لا تعد الإحالة قطعية إلا بتصديق الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله⁽³⁾.
7. في حالة نكول المزايد الأخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع الثمن وكامل المصاريف خلال سبعة أيام من تاريخ الإحالة القطعية يعرض المبيع على

⁽¹⁾ المادة (السادسة والعشرون / سادسا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

⁽²⁾ المادة (السابعة والعشرون) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

⁽³⁾ المادة (الثامنة والعشرون) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

المزايد الأخير الذي كَفَّ يده قبله وبالبديل الذي كان قد عرضه فإذا وافق على أخذه يضمن الناكِل بقرار من لجنة البيع الفرق بين البدلين من تأميناته وان لم تكف فمِن أمواله الأخرى ويستوفي ذلك وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977. أما إذا رفض المزايد قبل الناكِل اخذ المبيع بالبديل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا لمدة (15) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة ويضمن الناكِل بقرار من لجنة البيع الفرق بين البدلين من تأميناته وان لم تكف فمِن أمواله الأخرى ويستوفي ذلك وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المشار إليه⁽¹⁾. ويجري تسليم المال المبيع بعد دفع البديل واعتبار البيع قطعيا ويلتزم المشتري بنقله خلال (7) أيام من هذا التاريخ.

وتطبيقا لهذه الأحكام تم بيع أسهم المنشآت السياحية التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة مختلطة بناء على الأمر الصادر من السيد رئيس الجمهورية عن طريق المزايدة العلنية⁽²⁾.

والملاحظ على عمليات بيع هذه الأسهم أنها قد تمت في أغلبها قبل إنشاء سوق بغداد للأوراق المالية في مكتب تداول الأسهم العائد للمصرف الصناعي غير أنه وبعد إنشاء سوق بغداد للأوراق المالية جرى بيع الأسهم في هذه السوق غير ان وزارة المالية طلبت من سوق بغداد استثناء أسهمها في الشركات السياحية من البيع داخل السوق، وقد استندت الوزارة في طلبها إلى المسوغات الآتية:

1. إن بيع الأسهم في المصرف الصناعي يكون بشكل يومي في حين ان البيع في سوق بغداد محدود بجلسات أسبوعية الأمر الذي قد يؤخر عملية البيع.

2. انخفاض عمولة المصرف الصناعي بالمقارنة مع عمولة سوق بغداد للأوراق المالية وهي (1.8%) من القيمة الاسمية للأسهم يتقاضاها المصرف من المشتري دون الوزارة، في حين أن العمولة في سوق بغداد هي (2%) تتحملها الوزارة مناصفة مع المشتري ومن دون تحديد لحدها

(¹) المادة (التاسعة والعشرون) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

(²) عباس مرزوك فليح العبيدي، التصرف بالحصص والأسهم، المرجع السابق، ص144.

الأعلى الأمر الذي قد يحمل الوزارة مبالغ كبيرة تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني⁽¹⁾.

وقد جرى العمل على أن من يرسو عليه المزاد لا يسدد ثمن الأسهم كاملاً وإنما يسدد النصف ويقسط الباقي على قسطين سنويين يلتزم المساهم بتسديدها إلى وزارة المالية ويؤشر ذلك في سجلات الشركة ويجب على المساهم الحصول على موافقة الوزارة إذا ما قرر بيع أسهمه.

وفضلاً عما تقدم خول قرار مجلس قيادة الثورة رقم (140) لسنة 1993 (الملغي) وزير الصناعة والمعادن صلاحية تحويل المعامل التابعة للوزارة إلى شركات (مساهمة عامة) بعد حصول موافقة ديوان الرئاسة على ذلك بحيث تحتفظ الوزارة من خلال المنشأة العامة التي كان يرتبط بها المعمل بنسبة لا تقل عن (25%) من الأسهم، وتطرح الأسهم المتبقية التي لا تتجاوز (75%) من أسهم الشركة للبيع بالمزايدة العلنية إلى العراقيين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين في سوق بغداد للأوراق المالية على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 استثناء من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم (24) لسنة 1991.

وتطبيقاً لهذا القرار تم تحويل معمل أسمنت المثنى ومعمل طابوق القادسية ومعمل نسيج الناصرية ومعمل نسيج الديوانية إلى شركات مساهمة وعلى النحو المشار إليه أعلاه.

وقد تم بيع هذه الأسهم في سوق بغداد للأوراق المالية على شكل "حزم" لا تقل عن (5) آلاف سهم ولا تتجاوز (250) ألف سهم، وقيمة السهم الاسمية هي دينار واحد. ويدفع المشتري ثمن الأسهم بالكامل عند الإحالة بموجب صك⁽²⁾.

(¹) كتاب وزارة المالية ذو الرقم 29812 في 1992/8/4 المعنون إلى سوق بغداد للأوراق المالية. وبناء على المبررات الواردة في هذا الكتاب وافق مجلس إدارة السوق على استثناء هذه الأسهم من البيع داخل قاعة تداول الأوراق المالية، انظر: عباس مرزوك فليح العبيدي، المرجع السابق، ص145.

(²) ملف شركة أسمنت المثنى وملف شركة طابوق القادسية وملف شركة نسيج الناصرية وملف شركة نسيج الديوانية في سوق بغداد للأوراق المالية.

وقد حدد مبلغ التأمينات الواجب دفعه للاشتراك في المزايدة بـ (25) ألف دينار يتم دفعها عن طريق صك مصدق لأمر سوق بغداد للأوراق المالية باعتبار أن السوق هو الدائرة المختصة بالبيع وان كانت الأسهم مملوكة لوزارة الصناعة والمعادن، ويحق للعراقيين كافة الاشتراك في المزايدة بعد دفع مبلغ التأمينات سواء كانت حزم الأسهم مكونة من (5) آلاف سهم أو من (250) ألف سهم، فمبلغ التأمينات ثابت⁽¹⁾.

وقد أدى بيع أسهم هذه الشركات على شكل حزم وهو أمر ضروري. إذ يصعب بيع كل سهم على حدة عن طريق المزايدة العلنية، إلى أن غالبية الحزم بيعت إلى المستثمرين أو المضاربين الرئيسيين في سوق بغداد للأوراق المالية، ومن ثم حرمان بقية المستثمرين من ذوي الدخل المحدود من الاشتراك في المزايدة بسبب السعر المرتفع للحزمة الواحدة والتي تتضمن (5000) سهم كحد أدنى، ولعل ذلك ما دفع وزارة المالية إلى أن تجعل الحد الأدنى للحزمة الواحدة (500) سهم بدلا من (5000) سهم⁽²⁾.

ونعتقد أن بيع أسهم الشركات العامة أو المعامل وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة لا يستقيم مع الأحكام الأخرى الواردة في التشريع العراقي بخصوص عمليات التحول إلى القطاع الخاص. كما أن تطبيق هذا القانون على عمليات التحول إلى القطاع الخاص التي تتم عن طريق بيع الأسهم يرتب بعض النتائج السلبية التي يمكن تلافيها فيما لو تم البيع بوسيلة أخرى غير المزايدة العلنية. ويمكن أن نعزز رأينا بالأدلة الآتية:

(¹) حدد مبلغ التأمينات بـ (25) ألف دينار، في الإعلانات التي نشرتها الوزارة لبيع أسهم الشركات الأربعة المشار إليها في أعلاه وانظر ملفات هذه الشركات في سوق بغداد للأوراق المالية.

(²) كتاب وزارة المالية ذو الرقم (1457) في 1994/4/25 والموجه إلى سوق بغداد للأوراق المالية، وانظر: ملف شركة أسمنت المنشي في سوق بغداد للأوراق المالية.

1. إن المنشآت السياحية والمعامل التي جرى تحويلها إلى القطاع الخاص وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة لم تكن تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة قبل تحويلها، ومن ثم لم يكن رأسمالها مقسما إلى أسهم لكي يتصور بيعها بقيمتها السوقية في سوق بغداد للأوراق المالية عن طريق المزايدة العلنية. فعملية تحويل هذه المنشآت أو المعامل تستلزم في حقيقة الأمر تأسيس شركة جديدة وإصدار أسهم جديدة تكون قيمتها الاسمية محددة بنص القانون وهي دينار واحد، فلا يجوز إصدار السهم بقيمة اسمية أعلى أو أدنى. وهذا يعني أن هذه الأسهم ليست لها قيمة سوقية لأن الشركة ما زالت في المرحلة التأسيسية ومن ثم لا يمكن أن تباع هذه الأسهم بقيمة أعلى من القيمة الاسمية المشار إليها.
2. إن بيع الأسهم في المزاد العلني لا يمكن ان يتحقق إلا عن طريق بيعها على شكل حزم، إذ يصعب بيع كل سهم على حدة عن طريق المزايدة العلنية، ومما لا شك فيه أن البيع وفقا لهذا الأسلوب يؤدي إلى حرمان المستثمرين من ذوي الدخل المحدود من تملك الأسهم عن طريق الاشتراك في المزايدة العلنية لشرائها.

ولكل ذلك نقترح على المشرع العراقي إلا يجيز بيع أسهم الشركات العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص عن طريق المزايدة العلنية - إلا إذا تمت إعادة هيكلة هذه الشركات أو المشروعات العامة قبل تحويلها إلى القطاع الخاص وذلك من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة تمتلك الوزارة المعنية أسهمها بالكامل، وعلى أن تكون هذه الأسهم قابلة للتداول، فتكون لها قيمة سوقية يمكن الاستناد إليها عند بيع الأسهم بالمزاد العلني أو بغيره من الطرق غير أننا وحتى في هذا الفرض الأخير لا نفضل اتباع هذا الأسلوب للبيع وذلك بسبب العيوب التي أشرنا إليها والتي قد ترافق عملية بيع الأسهم بالمزاد العلني.

المبحث الثالث التحول إلى القطاع الخاص عن طريق البيع للعاملين

أن بيع الأسهم للعاملين (EBOs)⁽¹⁾ قد يتم بصيغ مختلفة غير أن جميع هذه الصيغ تنضوي تحت ما يسمى (بالتحول الداخلي) (Internal Privatization) والذي يقصد به (جميع الأساليب التي ينتج عنها تملك العاملين للشركة العامة التي يعملون فيها أو جزءا منها)⁽²⁾.

ويعتد هذا الأسلوب الفني للتحول إلى القطاع الخاص من الأساليب التي لها أهمية خاصة، لما يترتب عليه من مزايا من حيث أنه يؤدي إلى زيادة المساهمة الشعبية في الإنتاج وتوسيع قاعدة الملكية، كما أنه يشجع العاملين في الشركات العامة التي يجري تحويلها وفقا لهذا الأسلوب على تحسين الإنتاج وتقليل الكلفة وزيادة كفاءة الوحدة الاقتصادية التي يعملون فيها، فضلا عن أنه يؤدي إلى تقليل المعارضة العمالية لبرامج التحول إلى القطاع الخاص وسواء كانت هذه المعارضة مباشرة أم من خلال نقابات العمال بسبب ما قد ينجم عن عملية التحول من آثار تتمثل بالاستغناء عن بعض العمال وزيادة نسبة البطالة⁽³⁾.

وبالرغم من ذلك فإن تطبيق هذا الأسلوب في التحول إلى القطاع الخاص ليس بالأمر اليسير، إذ قد تواجه تطبيقه صعوبات فنية وأخرى مالية، وفيما يتعلق بالصعوبات الفنية فتتمثل بعدم خيرة العاملين في أمور الإدارة بالنسبة إلى بعض الشركات، التي قد تحتاج في إدارتها إلى توافر خبرات خاصة.

⁽¹⁾ Employee by-out.

⁽²⁾ UNCTAD., Op. Cit., P. 92.

⁽³⁾ د. منير إبراهيم هندي، خصخصة المشروعات العامة، المرجع السابق، ص 71 وما بعدها.

أما عن الصعوبات المالية فتتمثل بأن العاملين في الشركة هم في الأغلب من ذوي الدخل المحدود ولا يمتلكون القدرة المالية اللازمة لشراء الشركة⁽¹⁾.

ومن أجل ذلك تولى العديد من التشريعات عناية خاصة بهذا الأسلوب سواء من حيث الطرق المتبعة في عملية البيع للعاملين أم من حيث المزايا التي تقررها للعاملين لتحفيزهم على الشراء، لذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وكما يأتي:

المطلب الأول: أساليب البيع للعاملين

المطلب الثاني: المزايا المقررة للعاملين عند شراء الأسهم

المطلب الأول

أساليب البيع للعاملين

أن بيع أسهم أو موجودات الشركة العامة للعاملين قد يكون كلياً أو جزئياً كما انه قد يكون مباشر أو غير مباشر عندما تتولى جهة معينة شراء الأسهم لمصلحة العاملين، ثم تقوم بعد ذلك بإعادة بيعها لهم وستتناول دراسة الأحكام القانونية الخاصة بالبيع المباشر وغير المباشر للعاملين في المقصدين الآتيين:

المقصود الأول: البيع المباشر للعاملين

تتلخص إجراءات هذا الأسلوب بقيام العاملين بشراء الأسهم مباشرة ودون تدخل أية جهة أخرى في عملية الشراء.

وقد أولى المشرع الفرنسي عناية خاصة بهذا الأسلوب إذ تضمنت المادة (11) المعدلة من قانون التحول الفرنسي الصادر في 1986/8/6 إجراءات البيع للعاملين

(¹) أولف فإن درهوفن ومسعود كرشناس وجورجي شيماساكي، التخصيص وقضايا العمل والعمال في سياق الإصلاح الاقتصادي، بحث مقدم إلى مؤتمر الآثار الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي في الدول العربية، صندوق النقد العربي - الصندوق العربي للإعفاء الاقتصادي والاجتماعي، أبو ظبي، كانون الثاني، 1991، تحرير طاهر كنعان، ص 3-6-307.

عند تنازل الدول عن حصتها في رأسمال الشركة العامة لتحويلها إلى شركة خاصة فأوجب عرض الأسهم المملوكة للدولة على الفئات التالية:

1. العاملين في الشركة
2. العاملين في الشركات التابعة للشركة العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص وهي التي يكون غالبية رأسمالها مملوكة للشركة العامة.
3. العاملين السابقين الذين أمضوا في الشركة أو أحد فروعها خمس سنوات عمل على الأقل.
4. وكلاء هذه الشركة الذين لهم حق القصر.

ووفقا لهذه المادة يجب تلبية جميع أوامر الشراء المقدمة من قبل الفئات المذكورة على أن لا تتجاوز ما مقداره (10%) من الأسهم المطروحة للبيع، وعلى أن يكون لكل منهم حق الحصول على عدد من الأسهم لا يتجاوز خمسة أمثال الحد الأعلى من الأجر السنوي المقرر لهؤلاء العاملين والذي على أساسه تدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العاملين⁽¹⁾. وفي حالة زيادة أوامر الشراء عن حدود العشرة بالمائة يتم تخفيضها ضمن الحد المذكور بقرار يصدره وزير الاقتصاد، وفقا لأسس تحدد بالقرار ذاته، أما إذا كانت طلبات الشراء المقدمة من قبل الفئات المذكورة اقل من (10%) فيجوز لوزير الاقتصاد أن يعرض الأسهم المتبقية على هذه الفئات خلال ستة أشهر، وبذات الشروط من حيث تقسيط قيمة الأسهم أو تأجيل الوفاء بها، ومن حيث سعر الأسهم على أن يتم حساب سعر التخفيض على أساس السعر السائد في البورصة يوم التنازل. وفي حالة بقاء أسهم لم تشتَر من قبل العاملين بعد تطبيق الأحكام المتقدمة فيجب بيعها في سوق الأوراق المالية⁽²⁾.

⁽¹⁾ Alice pezard, Op. Cit., P. 5.

⁽²⁾ فعلى سبيل المثال أجاز قرار وزير الاقتصاد الفرنسي الصادر في 1986/11/21 تقسيط قيمة اسهم شركة Saint-Gobain المخصصة للعاملين، بحيث يدفعون (30%) ويقسط الباقي على 24 شهرا، انظر: Chrstian Baillon , op. Cit., p. 217.

أما عن موقف المشرع المصري فعلى الرغم من أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري لم يتضمن أحكاماً خاصة لبيع أسهم الشركة للعاملين فإنه لا يوجد في هذا القانون ما يحول دون ذلك، إذ يمكن للشركة القابضة أن تبيع عدداً من أسهمها للعاملين مباشرة فيصبحون مساهمين في الشركة ويتمتعون بكافة الحقوق ويتحملون كافة الالتزامات المترتبة على هذه الصفة⁽¹⁾.

أما المشرع المغربي فقد أجازت المادة السابعة من قانون تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل إلى القطاع الخاص أن يقترح تخصيص نسبة معينة من أسهم الشركة أو موجوداتها لكي تباع للعاملين. وقد فصل المرسوم المغربي رقم (290577) الصادر في 1990/10/16⁽²⁾ في إجراءات البيع للعاملين فأجاز للوزير المختص وبعد استطلاع رأي لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أن يقرر تخصيص نصيب لعمال الشركة أو المنشأة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص بشرط أن يكونوا قد أمضوا مدة لا تقل عن سنة في عملهم بالشركة، وعلى أن لا تتعدى النسبة المخصصة للعاملين (20%) من الأسهم المباعة في حدود (10%) من رأسمال الشركة، أما إذا تعلق الأمر ببيع منشأة لا تتخذ شكل شركة فلا يجوز أن تتعدى النسبة المخصصة للعاملين (10%) من قيمتها⁽³⁾.

وفضلاً عن ذلك للوزير المختص أن يقرر أنه لا يجوز لأي عامل أن يشتري عدداً من الأسهم أو الحصص يتعدى نسبة مئوية معينة من النصيب المخصص للعاملين⁽⁴⁾.

(1) د. حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق، ص 163.

(2) انظر نص هذا المرسوم في الموسوعة المغربية للتشريع والقضاء، المرجع السابق، ص، مؤسسات تشريع - ن- 81.

(3) المادة الأولى من المرسوم المغربي المشار إليه.

(4) المادة (3) من المرسوم المغربي المشار إليه.

ولعل من المناسب أن نذكر أن هناك أسلوباً معروفاً في القوانين الانكلوسكسونية يسمى باختيار الأسهم (Stock option). والذي يخول العمال شراء نسبة معينة من أسهم الشركة بشروط تفضيلية، قد يكون من خلال إصدار الشركة العامة لوثيقة باسم كل عامل فيها تخوله الحق في شراء نسبة من

ويتضح مما تقدم، أن هناك تقارباً كبيراً بين موقف المشرع الفرنسي والمشرع المغربي، من حيث تخصيص نسبة معينة من أسهم الشركة العامة المراد تحويلها للعاملين ووضع الضوابط التي من شأنها أن تكفل توزيع هذه الأسهم على العاملين بشكل عادل.

ومع ذلك نلاحظ أن المشرع المغربي قد أجازَ للوزير المختص أن يخصص نسبة معينة من أسهم الشركة العامة أو من موجودات المنشأة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص للعاملين، في حين قصر المشرع الفرنسي ذلك على حالة بيع الأسهم وفقاً لإجراءات سوق الأوراق المالية عن طريق العرض العام للأسهم، ولا يمكن وفقاً للتشريع الفرنسي تخصيص أية نسبة من أسهم الشركة العامة للعاملين إذ تم بيع الأسهم بأية وسيلة أخرى غير العرض العام أو إذا انصب البيع على موجودات الشركة وليس على أسهمها.

ونعتقد أن النص على حق مساهمة العاملين في شراء نسبة معينة من موجودات المشروع العام قد يصعب تحقيقه من الناحية العملية لأن بيع الأصول يكون عادة لشخص واحد، ذلك لأن الأصل في ملكية الأصول أن تكون ملكية مفرزة وليس ملكية شائعة، إذ قد يصعب بيع المشروع العام لشخص واحد ويفرض عليه في الوقت ذاته أن يشترك مع العاملين في ملكية هذا المشروع على الشيوع، لذلك يفضل أن يشتري العمال موجودات المشروع العام والذي لا يقسم رأسماله إلى أسهم بالكامل، ويتم ذلك عن طريق تمويل عملية الشراء بقروض يحصل عليها العاملون، وهذه القروض تكون مضمونة بأصول المشروع نفسه⁽¹⁾.

وفيما يتعلق بقانون الشركات العامة العراقي فقد نصت المادة (37/رابعاً) من هذا القانون على أنه "لمجلس الوزراء عند تحول الشركة إلى شركة مساهمة أن يحدد

اسهم الشركة في تاريخ لاحق وبسعر محدد بحيث يكون للعمال الحق في ممارسة هذا الحق في الشراء أو عدم ممارسته. وانظر: د.

منير إبراهيم هندي، المرجع السابق، خصخصة المشروعات العامة ص 68-69.

(¹) ويطلق هذا الأسلوب (Leverged buy-out) وانظر: p. 92، Unctad, op. Cit.,

نسبة معينة من راس المال الاسمي للشركة تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين".

فالفارق الجوهرى بين موقف المشرع العراقى وموقف التشريعات المقارنة التى أشرنا إليها بخصوص تملك العاملين لأسهم الشركة العامة يتمثل بأن العاملين وفقا للتشريع العراقى يملكون نسبة معينة من رأسمال الشركة الإسمى عن طريق الاكتتاب فى حين انهم يملكونها وفقا للتشريعات المقارنة عن طريق الشراء، ذلك أن عملية التحول تتم وفقا للتشريع العراقى من خلال تأسيس شركة مساهمة جديدة.

ويمكن أن نورد على نص المادة 37/رابعاً من قانون الشركات العامة العراقى الملاحظات الآتية:

1. لم يحدد النص المذكور نسبة معينة (كحد أعلى) من رأسمال الشركة العامة يخص للاكتتاب العاملين فيها، وهذا يعنى ان لمجلس الوزراء أن يحدد هذه النسبة ودون التقيد باى حد أعلى، ومع ذلك لا يمكن تفسير عبارة (نسبة معينة من راس المال) الواردة فى النص المتقدم، بما يسمح بتخصيص رأسمال الشركة الاسمي بالكامل لاكتتابات العاملين فيها.
2. لم يخول هذا النص منتسبي الشركة السابقين الحق فى الاكتتاب بأسهم الشركة العامة المحولة. أي أن المشرع العراقى قصر حق الاكتتاب بأسهم الشركة العامة المحولة على العاملين الموجودين فى الشركة وقت التحول وبصرف النظر عن المدة التى أمضوها فى هذه الشركة.
3. لم يبين هذا النص الحكم الواجب الاتباع فى حالة إقبال العاملين على عملية الاكتتاب بما يؤدي الى زيادة طلبات الاكتتاب المقدمة من قبلهم عن النسبة المحددة من قبل مجلس الوزراء.
4. أن هذا النص لم يبين كيفية التصرف بالأسهم المتبقية فى حالة عدم إقبال العاملين على الاكتتاب بالأسهم المخصصة لهم من قبل مجلس الوزراء.
5. لم يحدد هذا النص المدة التى يجب خلالها على العاملين فى الشركة الاكتتاب بالأسهم المخصصة لهم.

وإزاء كل ذلك نرى انه عند تجاوز طلبات الاكتتاب المقدمة من قبل العاملين النسب المحددة من قبل مجلس الوزراء يجب توزيع الأسهم الفائضة بين المكتتبين من العاملين في الشركة بنسبة مساهمة كل مكتتب، ويجري التوزيع إلى اقرب سهم صحيح وذلك بالقياس على حالة الإكتتابات الفائضة التي قد تظهر بعد إعلان غلق الاكتتاب التأسيسي للشركة والذي نصت عليه المادة (44/ثانيا) من قانون الشركات العراقي. كما ونرى أن للعمال الحق في الاكتتاب بالأسهم المخصصة للعاملين، بعد غلق الاكتتاب فإن هذه الأسهم ستبقى مملوكة بحسب الأصل لنسبة من الأسهم المخصصة للعاملين، والذي يمكنه بعد ذلك بيعها في سوق بغداد للأوراق المالية.

المقصد الثاني: تملك العاملين للأسهم بشكل غير مباشر

مضت الإشارة إلى ان العاملين في الشركة قد يقومون بشراء أسهمها مباشرة عن طريق تخصيص نسبة معينة من الأسهم التي تباع بشروط تفضيلية، فضلا عن ذلك قد تتولى جهة أخرى شراء الأسهم لحساب العاملين في الشركة، وتقوم بعد ذلك ببيعها لهم، وهذه الجهات التي تتولى شراء الأسهم لمصلحة العاملين قد تكون الشركة المصدرة لهذه الأسهم ذاتها وقد تكون هذه الجهة اتحاد العمال الذي يؤسسه العاملون في الشركة لغرض شراء لأسهمها، وفيما يأتي تفصيل هذه الأساليب:

أولا. شراء الشركة لأسهمها بقصد توزيعها على العاملين

وفقا لهذه الطريقة تتولى الشركة المصدرة للأسهم شراء نسبة معينة من أسهمها، بقصد إعادة بيعها ثانية للعاملين فيها خلال مدة محددة وبنفس الشروط التفضيلية التي كان يمكن أن تباع وفقها، فيما لو بيعت هذه الأسهم للعاملين مباشرة⁽¹⁾.

وقد قرر المشرع الفرنسي هذا الحكم صراحة فلقد أجازت المادة (11) المعدلة من قانون التحول إلى القطاع الخاص الفرنسي الصادر في 1986/8/6 أن يتم بيع الأسهم للشركة العامة التي أصدرتها على أن تتولى بيعها ثانية إلى العاملين في الشركة

(¹) Jean -Paul valuet , op. Cit., p. 17.

ووكلاء هذه الشركة على النحو السالف الذكر، وتتم عملية البيع لهذه الفئات خلال سنة من تاريخ شراء الشركة للأسهم وليس للشركة أن تشتري أكثر من (10%) من الأسهم المطروحة للبيع، على أساس أن هذه النسبة تمثل الحد الأعلى للأسهم التي يمكن تخصيصها للعاملين والتي يمكن لوزير الاقتصاد تخفيضها عن هذا الحد.

ويجب أن تكون عملية إعادة البيع لهذه الفئات ضمن الشروط نفسها من حيث مقدار التخفيض في أسعار الأسهم والأجل الممنوح للوفاء بقيمتها، ويتم احتساب التخفيض على أساس السعر السائد في البورصة يوم إعادة التنازل عن الأسهم. وقد نصت هذه المادة على أنه لا تحتسب نسبة الـ (10%) من الأسهم التي تتولى الشركة شرائها بقصد إعادة بيعها للعاملين مرة ثانية ضمن نسبة الـ (10%) التي تنص عليها المادة (213-3) من قانون الشركات التجارية الفرنسي كحد أعلى لتملك الشركة لأسهمها ووفقاً لهذه المادة أيضاً تعد حقوق التصويت الخاصة بهذه الأسهم معلقة خلال فترة تملك الشركة لأسهمها⁽¹⁾.

أما عن موقف المشرع المصري فقد سبقت الإشارة إلى أن المشرع المصري لم ينظم عملية بيع الأسهم للعاملين ضمن تشريع مستقل، غير أن جانباً من الفقه المصري⁽²⁾ يرى جواز شراء الشركة التابعة لعدد من أسهمها بقصد توزيعها على العاملين فيها، وذلك بتطبيق القواعد التي نص عليها قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، على أساس أن نصوص هذا القانون تعد واجبة التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. وذلك وفقاً للمادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون الأخير.

وقد نصت المادة (48) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 على أنه "يجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم من الأرباح".

⁽¹⁾ المادة (11) من قانون التحويل إلى القطاع الخاص الفرنسي الصادر في 1986/8/6.

⁽²⁾ د. حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق، ص 165.

ووفقا للنص المتقدم يكون للشركة التابعة أن تقوم بشراء أسهمها لتوزيعها على العاملين إذ يمكنها شراء هذه الأسهم من البورصة أو من الشركة القابضة بوصفها المالكة لهذه الأسهم ووفقا للمادة (1/151) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري يجب على الشركة التابعة أن تقوم ببيع الأسهم للعاملين خلال سنة من تاريخ الشراء، وتعلق حقوق التصويت الخاصة بهذه الأسهم وكذلك أرباحها خلال هذه المدة. كذلك يحدد مجلس الإدارة وفقا للمادة (2/150) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري الشروط اللازم توافرها في العاملين لتلقي هذا الحق من ناحية الأقدمية والكفاءة، كما ويقرر مجلس الإدارة الحد الأدنى للمدة التي لا يجوز خلالها التصرف بهذه الأسهم والمدة التي يتاح فيها العاملين اختيار الشراء، على أن لا تقل عن ثلاثين يوما وطريقة تحديد الثمن على أساس متوسط سعر التعامل في البورصة خلال الخمسة عشر يوما السابقة على اليوم الذي يقرر فيه العامل شراء نصيبه من الأسهم أو سعر شراء الشركة للأسهم أيهما اقل ولا يجوز أن يشتري العامل من هذه الأسهم ما يجاوز (1%) من أسهم الشركة ⁽¹⁾ ويمكن للعاملين أن يسددوا قيم هذه الأسهم بطريقتين الأولى أن تتولى الشركة تحصيل قيمة الأسهم من العاملين بطريق الخصم من مرتباتهم بأقساط شهرية متساوية، أما الثانية فهي أن يطلب العاملون سداد قيمة هذه الأسهم من الأرباح المقررة لهم، وللعامل أن يختار أيا من هاتين الطريقتين للوفاء ⁽²⁾.

ويرى جانب من الفقه في مصر ⁽³⁾ أنه بالرغم من أنه ليس لهذا الأسلوب أهمية تذكر في الواقع العملي في مصر، بسبب انخفاض أجور العاملين ومن ثم لا مكان في دخلهم للدخار فإنه يعد أفضل الأساليب لأنه يوسع من المساهمة العمالية من جهة ويحقق التحول إلى القطاع الخاص من جهة أخرى.

⁽¹⁾ المادة (151) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، وانظر:

د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ط2، 1989، ص493.

⁽²⁾ المادة (152) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم (59) لسنة 1981، وانظر:

د. أميرة صدقي، النظام القانوني لشراء الأسهم من جانب الشركة المصدر لها، القاهرة، 1993، ص233.

⁽³⁾ د. احمد محمد محرز، المرجع السابق، ص174.

وأخيرا لم يعالج المشرع العراقي والمغربي أحكام هذا الأسلوب للتحويل إلى القطاع الخاص وبقدر تعلق الأمر بالقانون العراقي، فمن الواضح لنا انه لا يمكن تطبيقه على تحول الشركات العامة وفقا لقانون الشركات العامة العراقي، ذلك أن رأسمال الشركة العامة لا يقسم إلى أسهم حتى يمكن تصور شراء هذه الشركة لأسهمها ومن ثم توزيعها على العاملين فيها، كما أن قانون الشركات العراقي يخلو من أي حكم يسمح بتطبيق هذا الأسلوب لتحويل الشركات المختلطة إلى شركات خاصة.

ثانيا. شراء اتحادات العاملين للأسهم

وفقا لهذا الأسلوب يتم تأسيس اتحاد للعاملين في الشركة يتولى شراء أسهم هذه الشركة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص فيكون الاتحاد بوصفه شخصا معنويا هو المالك لهذه الأسهم لمصلحة العاملين في الشركة⁽¹⁾. ولم يتطرق كل من المشرع الفرنسي والمغربي لهذا الأسلوب للتحويل في حين أولاه المشرع المصري عناية خاصة وذلك في قانون سوق رأس المال المصري رقم (95) لسنة 1992. فقد نصت المادة (74) من هذا القانون على انه "يجوز للعاملين في أي شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى (اتحاد العاملين المساهمين) يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة بموافقة جماعة المؤسسين او جمعيتها العامة غير العادية، حسب الأحوال دون إخلال بحق الاتحاد في شراء الأسهم المقيدة أو المتداولة في بورصة الأوراق المالية"⁽²⁾.

وقد فصلت المادة (184) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري في الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يكون للعاملين فيها الحق في إنشاء اتحاد لهم وهي:

1. أن تكون شركة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983. وهذه الشركات تقسم إلى نوعين الأول شركات يؤسسها شخص عام بمفرده أو مع أشخاص عامة أخرى وهذا النوع من الشركات لا يجوز فيه للأشخاص المعنوية العامة أو شركات أو بنوك القطاع العام أن تتصرف في أسهم هذه الشركات المملوكة لها، إلا فيما بينها وذلك وفقا للمادة (27) من القانون

(¹) د. منير إبراهيم هندي، التجربة المصرية في الخصخصة، المرجع السابق، ص 169.

(²) وقد أحالت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور لبيان الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يكون للعاملين فيها الحق في إنشاء الاتحاد، وأنواع الأسهم التي يمكن لأعضاء الاتحاد تملكها وإجراءات تفويضها وأحكام وشروط تداولها والتنازل عنها وحقوق العاملين فيها أثناء مدة خدمتهم أو عند انتهاء الخدمة والشروط الواجب توافرها في الاتحاد واختصاصه والجهة المختصة بإدارته ووسائل هذه الإدارة.

المذكور، أما النوع الثاني فيشمل تلك الشركات التي يشترك في تأسيسها أو المساهمة فيها شركات خاصة أو أفراد مع شخص عام واحد أو أكثر يمتلك فيها نسبة لا تقل عن (51%) من راس المال ووفقاً للمادة (28) من هذا القانون يجوز للشركات الخاصة وللأفراد التصرف بالأسهم المملوكة لهم في شركات القطاع العام⁽¹⁾.

وهذا يعني عدم جواز تأسيس اتحاد العاملين المساهمين في النوع الأول من هذه الشركات إذ لا يمكن تداول أسهمها إلا فيما بين الأشخاص المعنوية العامة، في حين أن ذلك جائز في النوع الثاني، طالما أنه من الممكن التصرف بالأسهم المملوكة للقطاع الخاص في هذه الشركات⁽²⁾.

2. أن تكون شركة من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 - قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري ولا يجوز تأسيس اتحاد العاملين المساهمين في الشركات القابضة.

3. أن تكون شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم، من الشركات الخاضعة لقانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، والتي تتوافر فيها الشروط التالية:

أ. ألا يقل رأسمالها عن مليون جنيه مصري.

ب. ألا يقل عدد العاملين الدائمين بالشركة عن خمسين عاملاً.

أما عن شروط تملك الاتحاد لأسهم الشركة الاسمية لمصلحة أعضائه فهي:

1. موافقة جماعة المؤسسين عند تأسيس الشركة بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.
2. موافقة الجمعية العامة غير العادية، بعد تأسيس الشركة عن طريق زيادة راس المال وتخصيص الزيادة كلها أو بعضها للاتحاد بالقيمة والشروط التي يتم الاتفاق عليها.

(¹) د. علي البارودي، القانون التجاري - القطاع العام وفقاً للقانون 97 لسنة 1983 - المنشأة التجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1986، ص 58 وما بعدها.

(²) د. حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق، ص 116.

3. ويجوز كذلك للاتحاد شراء أسهم الشركة سواء كانت مقيدة أم غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ويجب ألا يقل ما يملكه الاتحاد عن (5%) من قيمة أسهم الشركة الاسمية، ويجوز النزول عن هذا الحد بقرار من مجلس إدارة الهيئة (هيئة سوق المال) في الحالات التي يقدرها ⁽¹⁾.

ويتم تقييم الأسهم التي يمتلكها الاتحاد وفقاً لقيمتها السوقية، إذا كانت الأسهم لشركة من شركات القطاع العام التي يساهم فيها الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة، أما إذا كانت الأسهم لشركة من شركات قطاع الأعمال العام، فيكون تقييم أسهمها وفقاً للأحكام الخاصة بذلك والواردة بقانون شركات قطاع الأعمال العام ⁽²⁾، أما الأسهم التي يمتلكها الاتحاد بموافقة جماعة المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية للشركة الخاضعة لقانون شركات المصري رقم 159 لسنة 1981، فيتم تقييمها وفقاً للشروط التي يتفق عليها ⁽³⁾.

المطلب الثاني

المزايا المقررة للعاملين عند شراء الأسهم

تحرص العديد من التشريعات ومنها التشريع العراقي على أن يشترك العاملون في الشركات العامة التي يراد تحويلها إلى القطاع الخاص وذلك لتخصيص نسبة معينة من أسهم هذه الشركات للعاملين فيها. وبالرغم من ذلك تواجه هذا الأسلوب في التحول عقبات قد تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، ومن أبرز هذه العقبات انخفاض مدخرات العاملين الأمر الذي قد ينجم عنه عدم إقبالهم على شراء الأسهم المخصصة لهم.

⁽¹⁾ المادة (191) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال المصري رقم 95 لسنة 1992.

⁽²⁾ انظر ما تقدم، ص 58 من هذه الأطروحة.

⁽³⁾ المادة (192) من اللائحة التنفيذية لقانون راس المال المصري.

لذلك حرصت هذه التشريعات على تقرير مزايا للعاملين لتحفيزهم على شراء الأسهم وتتمثل هذه المزايا بتخصيص نسبة معينة من أسهم الشركة العامة للعاملين فيها ليتملكوها وفقاً للإجراءات المحددة قانوناً كالشراء أو الاكتتاب، فضلاً عن النص على بيع الأسهم للعاملين بالتقسيط أو توزيع أسهم مجانية عليهم وفقاً لنسب وضوابط محددة قانوناً.

وبما أننا بحثنا في مسألة تخصيص نسبة معينة من أسهم الشركة للعاملين فيها لذا سيقترن هذا المطلب على البحث في المزايا الأخرى المقررة للعاملين وكل في مقصد مستقل وكما يأتي:

المقصد الأول: تملك العاملین للأسهم بسعر مخفض أو مجاناً

لقد حرصت العديد من التشريعات على أن يملك العاملون في الشركة العامة نسبة معينة من أسهم الشركة العامة المراد تحويلها بأسعار مخفضة أو مجاناً⁽¹⁾.

ومن هذه التشريعات التشريع الفرنسي، فلقد قررت المادة (11) المعدلة من قانون التحول إلى القطاع الخاص الفرنسي الصادر في 1986/8/6 إمكانية بيع الأسهم للعاملين وفقاً للمفهوم السالف الذكر - بسعر مخفض على أن لا يتجاوز مبلغ التخفيض (20%) من قيمة الأسهم بالقياس على أوطأ سعر لهذه الأسهم عند بيع الأسهم للجمهور في العملية نفسها. وفي هذه الحالة لا يجوز للعاملين الذين استفادوا من هذا التخفيض أن يتنازلوا عن أسهمهم إلا بعد مضي سنتين أو دفع قيمة أسهمهم بالكامل في حالة البيع بالتقسيط. وإذا ما بيعت الأسهم للشركة المصدرة لها لكي تتولى إعادة بيعها مرة ثانية للعاملين خلال سنة فإنه ينبغي على الشركة أن تبيع الأسهم للعاملين بنفس السعر

(1) فعلى سبيل المثال، نص على هذا الحكم كل من المشرع التونسي والبرازيلي والسلوفيني والسريلاكي والفنزولي، كما وتضمنته أيضاً التشريعات في المملكة المتحدة، انظر: Unctad, op. cit., p. 94.

المخفض والمحدد ابتداء على أن يراعى في احتساب مبلغ التخفيض أن يحتسب على أساس سعر الأسهم يوم التنازل عنها للعاملين⁽¹⁾.

وفضلا عما تقدم أجاز المشرع الفرنسي منح الأشخاص المشار إليهم في المادة (11) من قانون التحويل الفرنسي أسهما مجانية تمثل نسبة من الأسهم المباعة من الدولة لا تتجاوز قيمتها نصف الحد الأقصى للاشتراك الشهري للضمان الاجتماعي الخاص بالعامل ولهذا الغرض تحتسب أسعار الأسهم على أساس السعر المحدد للبيع من قبل الدولة ولا يجوز للعاملين أن يتنازلوا عن هذه الأسهم خلال مدة سنة اعتبارا من تاريخ صيرورة هذه الأسهم قابلة للتداول⁽²⁾.

وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط في العاملين وفقا للتشريع الفرنسي ان يكونوا من الجنسية الفرنسية أو جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي حتى يكون لهم الحق في الحصول على أسهم مجانية. أما العاملون من الجنسيات الأخرى فلا يستفيدون من هذه الأسهم المجانية⁽³⁾.

وفيما يخص موقف المشرع المغربي فقد أجاز منح العاملين تخفيضا أقصاه (15%) من ثمن البيع لتمكينهم من شراء النسبة المخصصة لهم ولا يجوز للعاملين التصرف بالأسهم التي يشترونها بسعر مخفض خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ البيع وفي حالة التخلي عن ملكيتها للغير قبل انقضاء هذا الأجل يلتزم العامل بدفع مبلغ التخفيض المقرر له⁽⁴⁾.

أما عن موقف المشرع المصري فبالرغم من أنه لم يقرر منح مثل هذه المزايا للعاملين عند شرائهم لأسهم شركات القطاع العام غير أن للشركة القابضة بوصفها المالكة لأسهم الشركات التابعة ان تباع أسهم هذه الشركة الأخيرة للعاملين بسعر مخفض يقل عن السعر الذي تباع به هذه الأسهم للجمهور.

(¹) Jean -paul valuet , op. cit., p.17.

(²) المادة (12) المعدلة من قانون التحويل إلى القطاع الخاص الفرنسي الصادر في 1986/8/6.

(³) المادة (13) من قانون التحويل إلى القطاع الخاص الفرنسي المشار إليه وانظر:

Alice Pezard , op. cit., p. 6.

(⁴) المادة الثانية والمادة الرابعة من المرسوم المغربي رقم (290577) الصادر في 1990/10/16.

اما المشرع العراقي فيبدو لنا انه لا يمكن وفقا لأحكام قانون الشركات العراقي منح تخفيض للعاملين في الشركة العامة عند الاكتتاب بأسهمها بقصد تحويلها إلى القطاع الخاص ذلك ان المادة (30) من قانون الشركات العراقي حددت القيمة الاسمية للسهم بدينار واحد، فلا يجوز إصداره بقيمة اسمية أعلى أو أدنى عند الاكتتاب بأسهم الشركة في المرحلة التأسيسية.

المقصد الثاني: تقسيط قيمة الأسهم المباعة للعاملين

أجازت المادة (11) من قانون التحول إلى القطاع الخاص الفرنسي لوزير الاقتصاد أن يقرر تقسيط ثمن الأسهم المباعة للعاملين وللوزير أن يحدد مواعيد دفع الأقساط على أن لا يتجاوز الأجل المحدد للوفاء بكامل الثمن ثلاث سنوات من تاريخ البيع ولا يمكن للعاملين التصرف بهذه الأسهم إلا بعد وفاء قيمتها بالكامل⁽¹⁾. ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الفرنسي قد أجاز بيع الأسهم بالتقسيط للجمهور أيضا فضلا عن العاملين في الشركة ومع ذلك يلاحظ البعض انه لم تتم أية عملية تحول في فرنسا من خلال بيع الأسهم بالتقسيط للجمهور وأن البيع بالتقسيط قد اقتصر على العاملين فقط⁽²⁾. وعلى العكس من التشريع الفرنسي نلاحظ أن كلا من التشريعات العراقية والمصرية والمغربية تخلو من الإشارة إلى هذا الحكم.

وفيما يتعلق بالقانون العراقي فيجوز تقسيط قيمة الأسهم التي يكتتب بها منتسبو الشركة العامة عند تحويلها إلى القطاع الخاص على ان يشمل ذلك بقية المكتتبين من الجمهور أيضا وذلك استنادا إلى نص المادة (48) من قانون الشركات العراقي والتي تجيز تسديد ما لا يقل عن (25%) من قيمة الأسهم عند التأسيس وتقسيط المتبقي من قيمة الأسهم المكتتب بها على أن تسدد خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، غير أن هذه المادة لا تجيز أن يشمل التقسيط بعض المكتتبين دون

(¹) P.Pocht , Relexion Sur Le regim Juridique des Privatisation , Rev.Trim- Droit Com., 41,Juill.-Sept,1988, p. 402

(²) Alice pezard , op. cit., p.7

البعض الآخر، إذ أن تقسيط قيمة الأسهم وفقاً لهذه المادة يكون على أساس إلزام جميع المكتتبين بدفع نسبة معينة من قيمة الأسهم مماثلة للنسبة التي دفعها المؤسسون من قيمة الأسهم. وخلاصة القول، إن قانون الشركات العامة العراقي خول مجلس الوزراء تخصيص نسبة معينة من رأسمال الشركة العامة الاسمي ليكتتب فيه منتسبي الشركة، ولم ينص على قواعد خاصة بهذا الاكتتاب، ومن ثم فهو يخضع لقواعد الاكتتاب الواردة في قانون الشركات الأمر الذي من شأنه أن يثير العديد من التساؤلات حول المدة التي يجب خلالها أن يكتتب منتسبو الشركة بالأسهم المخصصة لهم، وقد سبقت الإشارة إلى أنه وإزاء ذلك يكون لمنسبي الشركة العامة الحق في الاكتتاب بالأسهم المخصصة لهم طوال مدة الاكتتاب، وعند وجود اكتتابات فائضة فتوزع على المكتتبين من منتسبي الشركة وكل حسب مساهمته وإلى أقرب سهم صحيح، وإذا بقيت أسهم غير مكتتب بها من الأسهم المخصصة لمنتسبي الشركة فيجوز للوزارة بيعها في سوق الأوراق المالية بعد انتهاء عملية الاكتتاب.

ومع ذلك فإن أسلوب اكتتاب العاملين بأسهم الشركات العامة من شأنه أن يحول دون تطبيق الأساليب غير المباشرة لتملك العاملين لأسهم الشركات العامة والتي تستلزم أن يكون رأسمال الشركة العامة مقسماً إلى أسهم لكي تتولى جهة معينة شراء الأسهم لمصلحة العاملين في الشركة كتأسيس اتحاد للعمال في الشركة لكي يتولى القيام بهذه المهمة أو قيام الشركة العامة نفسها بشراء أسهمها لمصلحة العاملين، ثم بيعها لهم مرة ثانية.

كما أن تطبيق الأحكام الخاصة بالاكتتاب قد يحول دون تقرير بعض المزايا الخاصة للعاملين لتحفيزهم على شراء الأسهم، إذ لا يمكن وفقاً لأسلوب الاكتتاب تخفيض قيمة الأسهم المخصصة للعاملين لأن قيمة السهم الاسمية عند الاكتتاب محددة وفقاً لقانون الشركات العراقي بدينار واحد فلا يجوز إصداره بقيمة اسمية أعلى أو أدنى كذلك لا يمكن تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها من قبل العاملين إلا إذا شمل هذا التقسيط جميع المكتتبين وإزاء كل ذلك نقترح على المشرع العراقي أن يأخذ بأسلوب بيع الأسهم بدلاً من أسلوب الاكتتاب بها عند تحويل الشركات العامة وأن يخصص

نسبة من هذه الأسهم لتباع للعاملين في الشركة ويمكن في هذه الحالة الاستفادة من التشريعات المقارنة في هذا المجال، كان تقوم الشركة العامة بشراء الأسهم المخصصة للعاملين في الشركة ثم تتولى إعادة بيعها لهم واستيفاء ثمنها من الأرباح المخصصة لهم. أو تأسيس اتحاد للعاملين في الشركة يتولى شراء أسهمها لمصلحة العاملين، فضلا عن أن أسلوب بيع أسهم الشركات العامة للعاملين يتيح منهم مزايا خاصة عند شراهم لأسهم الشركة، إذ يمكن بيع هذه الأسهم للعاملين بسعر مخفض يقل عن السعر الذي تباع به للجمهور، كما ويمكن تقسيط قيمة الأسهم المخصصة للعاملين دون ان يشمل ذلك بقية الأسهم التي تباع للجمهور.

المبحث الرابع التحول إلى القطاع الخاص عن طريق دمج الشركات أو زيادة رأسمالها

قد لا ترغب الدولة في بيع أسهم الشركات العامة أو أصولها بالرغم من اتجاه نيتها لتحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص.

ويحدث ذلك في الغالب عندما تكون الشركة العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص تمارس نشاطا اقتصاديا مؤثرا في الاقتصاد الوطني أو عند تعرض الشركة العامة لخسائر كبيرة قد تعجز الدولة عن إطفائها من المال العام فتلجأ إلى القطاع الخاص لتحقيق هذه الغاية، كما وقد يحدث ذلك أيضا في حالة عجز الأشخاص من القطاع الخاص عن شراء أسهم الشركة العامة أو أصولها أو عند عدم رغبتهم في ذلك لسبب أو لآخر، ففي مثل هذه الأحوال قد تلجأ الدولة من أجل تحويل شركاتها العامة إلى القطاع الخاص إلى دمج هذه الشركات بشركات خاصة أو إلى زيادة رأسمالها بأموال مملوكة للقطاع، إذ أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تخفيض نسبة مساهمة الدولة في رأسمال الشركة العامة جراء تملك القطاع الخاص لنسبة من رأسمال هذه الشركة أو زيادة نسبة مساهمته فيه ⁽¹⁾.

وسنبحث في هذه الأساليب في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: التحول إلى القطاع الخاص عن طريق الدمج.

المطلب الثاني: التحول إلى القطاع الخاص عن طريق زيادة رأس المال.

(¹) د. محمود الصبح، المرجع السابق، ص 39.

المطلب الأول التحول إلى القطاع الخاص عن طريق الدمج

يعرف الدمج بأنه عقد بين شركتين أو أكثر قائمة قانونا وتمارس نشاطا متماثلا أو متكاملا بمقتضاه تنضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى أو تمتزج شركتان على الأقل لتكوين شركة جديدة فتتقضي جميع الشركات المندمجة وتنتقل كافة حقوقها والتزاماتها وكذلك أعضائها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة⁽¹⁾. وعلى ذلك يمكن أن يتحقق الدمج عن طريق الضم بأن تنضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى أو عن طريق المزج بأن تمتزج شركتان أو أكثر لتكوين شركة واحدة جديدة⁽²⁾. ويمكن أن تحول الشركة العامة إلى شركة خاصة عن طريق انضمام الشركة العامة إلى شركة أخرى خاصة أو مختلطة أو بالعكس كما ويمكن أن تتحقق عملية التحول أيضا من خلال المزج بين الشركات العامة والشركات الخاصة أو المختلطة بحيث تكون الشركة الناجمة عن المزج شركة خاصة أو مختلطة بحسب النسب التي يمتلكها القطاع الاشتراكي في رأسمالها. كما ويمكن ضم أو مزج شركة مختلطة مع شركة خاصة بحيث تكون الشركة الناجمة عن الدمج شركة خاصة.

⁽¹⁾ انظر: رسالتنا، دمج الشركات في القانون العراقي - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون - جامعة الموصل، 1996، ص9.

⁽²⁾ المواد (148) من قانون الشركات العراقي و (130) من قانون الشركات المصري و (371) من قانون الشركات التجارية الفرنسي. واستنادا إلى نصوص هذه المواد لا يعد قيام القطاع الاشتراكي بتقديم بعض الأصول المملوكة له (كالمعامل) كحصة عينية في شركة خاصة دمجا إذ أن الدمج يتطلب وجود شركتين قائمتين قانونا على الأقل. وقد أجازت المادة (29/ثانيا) من قانون الشركات العراقي تقديم الحصص العينية عند تأسيس الشركات المساهمة والمحدودة وبينت إجراءات تقويمها غير أنها لم تجز تقديم مثل هذه الحصص عند زيادة رأسمال الشركات المساهمة أو المحدودة لذلك فإن الأمر في مثل هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا تأسيسا لشركة مختلطة يمتلك فيها القطاع الاشتراكي ما لا يقل عن (25%) من رأس المال.

ويتحقق التحول في هذه الحالات جراء ما يرتبه الدمج من اثر يتمثل بتخفيض نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي في رأسمال الشركة العامة أو المختلطة الداخلة في عملية الدمج ويقابل ذلك أن يصبح القطاع الخاص مساهما في هذه الشركات أو تزداد نسبة مساهمة في رأسمالها وبحسب ما إذا كان للقطاع الخاص نسبة من رأس مال هذه الشركات قبل الدمج أو أنه اكتسب ذلك جراء الدمج وتكون نسبة مساهمة القطاع الخاص بمقدار الأصول الصافية للشركة الخاصة التي دخلت في عملية الدمج.

وقد قضي بأنه "يتحقق الدمج عندما تتحد عدة شركات لتكوين شركة واحدة وذلك عن طريق تأسيس شركة واحدة جديدة أو عن طريق الانضمام إلى شركة أخرى قائمة، وإن ما يميز الدمج هو انقضاء الشركات المندمجة وانتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، وهذا يعني أن الشركة المندمجة تساهم برأسمال الشركة الدامجة بمقدار الأصول الصافية للشركة المندمجة⁽¹⁾.

ويترتب على ذلك أن تلتزم الشركة الدامجة أو الناجمة عن الدمج بتوزيع أسهم عينة على أعضاء الشركات المندمجة وبمقدار الأصول الصافية لهذه الشركات فما يصدر عن الشركة الدامجة أو الجديدة من أسهم لأعضاء الشركات المندمجة إنما هو أسهم عينية لأنها تقابل حصصا عينية (موجودات الشركة المندمجة)⁽²⁾.

وهذا يعني انه لو كانت الشركة الدامجة هي الشركة العامة فإنها تلتزم بإصدار أسهم لأعضاء الشركة الخاصة المندمجة أما لو كانت الشركة الدامجة هي الشركة الخاصة فإنها تلتزم بإصدار أسهم جديدة للجهة الممثلة للقطاع الاشتراكي التي تملك رأسمال هذه الشركة العامة، أما لو كان الدمج بالمزج فإن الشركة الجديدة تصدر أسهما بمقدار الأصول الصافية للشركات العامة والخاصة الداخلة في عملية الدمج وتوزع هذه الاسم على أعضاء الشركة الخاصة والجهة الممثلة للقطاع الاشتراكي كلا بمقدار الأصول الصافية لشركته الداخلة إلى الدمج وعلى هذا الأساس قد تكون الشركة

(¹) Versile , 24 jun , 1993 , Bun Joly -1993, not LE conny

(²) د. علي البارودي، و د. محمد فريد العريني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص 605.

الدامجة أو الجديدة شركة خاصة أو مختلطة بحسب ما يملكه القطاع الاشتراكي في رأسمالها بعد عملية الدمج.

وفضلا عما تقدم فقد تقتزن عملية الدمج وفقا للتشريع الفرنسي بعملية الانقسام وفي وقت واحد (Fusion-scission) ويمكن أن يتحقق ذلك بطريقتين، الأولى هي الدمج بالانقسام والضم وبمقتضاها تنقضي- الشخصية المعنوية للشركة المنقسمة وتنقل ذمتها المالية إلى عدة شركات قائمة ويحصل مساهمو الشركة المنقسمة على أسهم جديدة في الشركات التي تلقت (الحصة) الناجمة عن الانقسام. أما الطريقة الثانية فهي حالة الدمج بالانقسام والمزج وهي عملية تستلزم انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المنقسمة وانتقال ذمتها المالية إلى شركات أخرى لتندمج معها وتكون شركة جديدة هي الشركات الناجمة عن هذه العملية⁽¹⁾.

ومن الواضح أن عملية الدمج المقترنة بالانقسام يمكن أن تؤدي إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع العام في الشركة العامة على نحو يكون فيه القطاع الخاص مالكا لأغلبية رأس المال ذلك أن هذه العملية تؤدي إلى توزيع مساهمة القطاع العام في الشركة العامة على عدة شركات.

وعلى هذا الأساس نصت المادة (1) المعدلة من قانون التحويل إلى القطاع الخاص الفرنسي- الصادر في 1986/8/6 على الدمج بوصفه من أساليب التحويل إلى القطاع الخاص⁽²⁾.

وتخضع عمليات الدمج في القانون الفرنسي لأحكام القواعد العامة لدمج الشركات الواردة في قانون الشركات التجارية الفرنسي لسنة 1966 المعدل⁽³⁾.

(¹) B-Caillaudet R.Darand , Fusion , Scission et Apport Partiel , Paris , 1985 , p. 16.

(²) كذلك يشير الفصل (24) من قانون الخصخصة التونسي الصادر في 1989/2/1 إلى اعتبار (اندماج أو ضم أو فصل المنشآت) من أساليب التحويل إلى القطاع الخاص نقلا د. محمد ميدون، المرجع السابق، ص109.

(³) عدلت المواد المتعلقة بالدمج الواردة في قانون الشركات التجارية الفرنسي بالقانون رقم (88-17) الصادر في 1988/1/5، كما عدلت المواد المتعلقة بالدمج والواردة في المرسوم الفرنسي رقم (67-236) الصادر في 1967/3/23 بالمرسوم الفرنسي رقم (88-418) الصادر في 1988/4/22.

فضلا عما تقدم، أجازت المادة (36) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري بقرار من مجلس الوزراء تقسيم ودمج الشركات القابضة بناء على عرض الوزير المختص وكذلك تقسيم ودمج الشركة التابعة لها، بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة بحسب الأحوال. كما وأشارت هذه المادة إلى سريان المواد (130-135) من قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 على دمج شركات قطاع الأعمال العام.

وتأسيسا على ما تقدم يمكننا القول، أن دمج الشركات وفقا للتشريع المصري يخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية⁽¹⁾. مع ملاحظة أن تقدير صافي أصول الشركات الداخلة في عمليات الدمج يتم في هذه الحالة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري وهي اللجنة المختصة بتقدير الحصص العينية.

أما فيما يتعلق بموقف المشرع العراقي فينبغي التمييز بشأنه بين فرضين الأول منهما يتعلق بدمج شركة عامة بأخرى خاصة أو مختلطة، أما الثاني فيتعلق بدمج الشركة المختلطة بأخرى خاصة. وعن الفرض الأول، فنلاحظ أن قانون الشركات العامة العراقي نظم عملية دمج شركة عامة بشركة عامة أخرى أو دمج شركتين عامتين أو أكثر لتكوين شركة عامة

(¹) كذلك نصت المادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المصري على انه (يسري في شأن إدماج الشركات القابضة والشركات التابعة لها أحكام المواد من 289 إلى 298 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة).

ولمزيد من التفصيل عن أحكام الدمج في القانون المصري، انظر: د. حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1987.

جديدة⁽¹⁾. وبين شروط وإجراءات وآثار الدمج في هذه الحالة في المواد (31-34) من قانون الشركات العامة العراقي غير انه لم يشير إلى إمكانية دمج شركة عامة بأخرى خاصة أو مختلطة، لذا يبقى التساؤل حول مدى إمكانية تحقق الدمج في هذا الفرض قائماً.

ويبدو لنا انه لا يوجد ما يمنع من تحقق الدمج في الفرض المتقدم على ان تراعى في عملية الدمج الشروط والإجراءات التي يتضمنها كلا من قانون الشركات وقانون الشركات العامة ولعل ما يدعم ما نذهب إليه هو أن قرار دمج الشركات العامة يجب أن يصدر وفقاً للمادة (31) من قانون الشركات العامة من قبل مجلس الوزراء وهي الجهة ذاتها التي استلزمت المادة (35) من قانون الشركات العامة موافقتها على تحول الشركة العامة فضلاً عن أن هناك تقارباً كبيراً فيما بين أحكام الدمج التي تضمنها قانون الشركات العامة وأحكام الدمج الواردة في قانون الشركات، فالدمج وفقاً لكل من القانونين المذكورين يجب أن يتم بالضم أو المزج وان يكون بين شركات تمارس نشاطاً متماثلاً أو متكاملًا أي أن يكون الدمج أفقياً أو رأسياً، كما أن الدمج يعد من أسباب انقضاء الشركات العامة وكذلك الخاصة والمختلطة بحيث تنتقل حقوق والتزامات الشركة أو الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة⁽²⁾.

وعلى الرغم من ذلك ينبغي التمييز في هذا الفرض بين الدمج الذي يتم عن طريق المزج والدمج الذي يتم عن طريق الضم.

ففي حالة دمج شركة عامة بأخرى خاصة أو مختلطة عن طريق المزج تنقضي الشركة العامة بموجب قرار الدمج الصادر من مجلس الوزراء، كما وتنقضي الشركة الخاصة أو المختلطة بموجب القرار الصادر عن هيئتها العامة. ويتم تأسيس الشركة الجديدة من خلال عقد اجتماع مشترك للهيئات العامة للشركات الداخلة في الدمج لوضع عقد الشركة الجديدة⁽³⁾، يحضره أعضاء الهيئة العامة للشركة الخاصة أو

⁽¹⁾ المادة (31/أولاً) من قانون الشركات العامة العراقي.

⁽²⁾ انظر: المواد (148 و 149 / أولاً و 152) من قانون الشركات العراقي والمادة (31) من قانون الشركات العامة العراقي.

⁽³⁾ انظر المادة (150/سادساً) من قانون الشركات العراقي.

المختلطة وممثل عن الوزارة التي تعود لها الشركة ذلك انه ليس للشركة العامة هيئة عامة. أما في حالة دمج شركة عامة بشركة خاصة أو مختلطة بالضم فينبغي أن يميز بشأنها بين حالة انضمام شركة عامة إلى أخرى خاصة أو مختلطة وحالة انضمام شركة خاصة أو مختلطة إلى أخرى عامة. إذ يمكن أن يتحقق الدمج بالضم في الحالة الأولى دون الثانية ذلك انه في الحالة الأولى، تنقضي- الشركة العامة (المنضمة) وتلتزم الشركة الخاصة أو المختلطة بتعديل عقدها من خلال عقد اجتماع مشترك وعلى النحو الذي أشرنا إليه في حالة الدمج بالمزج⁽¹⁾، فلا تثار أية صعوبة عندئذ.

أما في الحالة الثانية وهي حالة انضمام الشركة الخاصة أو المختلطة إلى أخرى عامة فلا يمكن تصور تحقق الدمج فيها، ذلك أن الدمج في هذه الحالة يقتضي انقضاء الشركة الخاصة أو المختلطة وتعديل عقد الشركة العامة فقط ودون أن يؤدي ذلك إلى انقضائها وتأسيس شركة جديدة. ومن ثم ستبقى الشركة العامة خاضعة لقانون الشركات العامة لأنها لم تنقض ولم تتأسس شركة جديدة وعليه لا يمكن أن يتحقق الدمج في هذه الحالة طالما أن قانون الشركات العامة لا يسمح للأشخاص من القطاع الخاص بتملك نسبة من رأسمال الشركة العامة.

وتأسيسا على ما تقدم يمكننا القول، أن الدمج بين الشركات العامة من جهة والخاصة والمختلطة من جهة أخرى يمكن أن يتحقق في جميع الحالات التي تنقضي فيها الشركة العامة لمصلحة شركة خاصة أو مختلطة وهي حالة الدمج بالمزج، وحالة انضمام شركة عامة إلى شركة خاصة أو مختلطة، ففي هذه الحالات ستكون الشركة الناجمة عن الدمج خاصة أو مختلطة بحسب النسبة التي يملكها القطاع الاشتراكي في

(1) ونرى أن عقد اجتماع مشترك لأعضاء الهيئة العامة للشركة الضامة والشركة المنضمة لتعديل عقد الشركة الضامة قبل نفاذ الدمج وفقا للمادة 150 / سادسا من قانون الشركات حكم قد جانبه الصواب، إذ كيف يمكن لأعضاء الهيئة العامة للشركة المنضمة الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة للشركة الضامة لتعديل عقدها وهم ليسوا بأعضاء فيها أصلا طالما أن الدمج لم ينفذ بعد.

رأسمالها فإذا كانت هذه النسبة أكثر من (25%) فستكون الشركة مختلطة أما إذا كانت أقل فستكون هذه الشركة خاصة⁽¹⁾.

وعلى أي حال ندعو المشرع العراقي إلى تنظيم عملية الدمج التي تتم بين الشركات العامة والخاصة بنصوص قانونية واضحة لا سيما وأن المشرع العراقي قد نظم عملية تحول الشركات العامة وبالتالي لا وجه للتمييز بين الحالتين طالما أن العمليتان تحققان الغاية ذاتها وهي "تحول الشركة العامة إلى شركة خاصة أو مختلطة" بل أن الدمج يتميز عن التحول في أنه فضلا عن تحقيقه للغاية المذكورة، فإنه يحقق أيضا ميزة التكامل الأفقي أو الرأسي بين شركات القطاع الخاص والشركات العامة.

ولا شك في أن من شأن إعادة هيكلة الشركة العامة وتحويلها إلى شركة مساهمة تملك الدولة أسهمها بالكامل أن تيسر إجراءات دمج الشركات العامة بشركات خاصة أو مختلطة، إذ يمكن في هذه الحالة إخضاع عملية الدمج للقواعد الواردة في قانون الشركات، كما هو عليه الحال في التشريع الفرنسي والمصري.

أما عن الفرض الثاني وهو الذي يتعلق بمدى إمكانية تحول الشركات المختلطة إلى شركات خاصة عن طريق الدمج. فنلاحظ ابتداءً أن قانون الشركات العراقي رقم (36) لسنة 1983 الملغي، كان ينص صراحة على عدم جواز فقدان الشركة المختلطة لشخصيتها المعنوية (لصالح شركة خاصة)⁽²⁾، وقد فسر هذا الشرط آنذاك على أساس أن شركات القطاع المختلط هي جزء من القطاع الاشتراكي، وأنها تؤدي ذات الدور الذي تؤديه وحدات القطاع الاشتراكي، ومن ثم لا يجوز أن تفتقد هذه الشركة شخصيتها المعنوية لصالح شركة خاصة وقد ذهب جانباً من الفقه آنذاك إلى أن

(¹) وخلافاً لذلك يرى جانب من الفقه في العراق أنه لا يمكن أن يتحقق الدمج بين الشركات العامة من جهة والشركات الخاصة أو المختلطة من جهة أخرى، لأن ذلك يؤدي إلى أن تكون الشركة الدامجة أو الناجمة من الدمج شركة مختلطة. د. لطيف جبر

كوماني و د. علي الرفيعي، المرجع السابق، ص 428-429.

(²) المادة (141/أولاً) من قانون الشركات العراقي رقم (36) لسنة 1983 الملغي.

الشركات المختلطة لا تحتاج لهذه الحماية، إذ يصعب تحقق مثل هذا الفرض في الواقع العملي⁽¹⁾. أما قانون الشركات النافذ فقد ألغى هذا الشرط ولم يعد هناك ما يمنع من تحقق الدمج في هذا الفرض، ذلك إننا وإن كنا نتفق مع الرأي السابق الذي يرى بأن الشركات المختلطة هي جزء من القطاع الاشتراكي، فإننا نرى وفي الوقت ذاته جواز أن تفقد الشركة المختلطة شخصيتها المعنوية لصالح شركة خاصة جراء الدمج، طالما أن عملية الدمج لا يمكن أن تتحقق إلا بموافقة الجهة القطاعية المختصة، والتي يمكنها أن ترفض الموافقة على إجراء الدمج، فيما إذا تبين لها أنه يترتب آثارا اقتصادية مضادة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية.

ولعل من المناسب أن نذكر أخيرا أن عملية تحول الشركة "Transformation de form" التي ينظمها قانون الشركات العراقي في المواد (153-157) والتي تعني تغيير الشكل القانوني للشركة يمكن أن تكون من أساليب تحويل الشركات المختلطة إلى شركات خاصة وفقا لقانون الشركات العراقي النافذ. فمن المعروف أن الشركة المختلطة قد تكون شركة مساهمة أو محدودة⁽²⁾، وبما أنه لا يجوز وفقا للقانون العراقي أن تتحول الشركة من نوع أعلى إلى نوع أدنى، يكون من المتصور أن تتحول الشركة المحدودة المختلطة إلى شركة مساهمة خاصة، ذلك أن التحول إلى شركة مساهمة لا يكون إلا بدخول أعضاء جدد وإصدار أسهم جديدة تطرح إلى الاكتتاب العام، تطبق بشأنه أحكام الاكتتاب الأصلية الواردة في قانون الشركات⁽³⁾.

فإذا لم يكتب القطاع الاشتراكي - المساهم في الشركة المحدودة بالأسهم الجديدة التي تطرح إلى الاكتتاب العام بمناسبة عملية التحول وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة مساهمته في رأسمال الشركة المساهمة الناجمة عن التحول عن (25%) فإن

(1) أستاذنا كامل عبد الحسين البلداوي، الشركات التجارية في القانون العراقي، مطابع التعليم العالي، الموصل، 1990، ص 232.

(2) المادة (7/ثانيا) من قانون الشركات العراقي.

(3) المادة (154/ثانيا) من قانون الشركات العراقي.

الشركة المحدودة المختلطة ستتحول إلى شركة مساهمة خاصة جراء هذه العملية لا سيما وأنه لا يوجد في قانون الشركات العراقي النافذ ما يحول دون ذلك بعد إلغاء الشرط الذي كان يتضمنه قانون الشركات الملغي والذي يمنع التحول، إذ كان من شأنه أن يحول الشركة المختلطة إلى خاصة⁽¹⁾.

المطلب الثاني

التحول إلى القطاع الخاص عن طريق زيادة رأس المال

يقصد بزيادة رأسمال الشركة تعديل عقد الشركة بزيادة رأسمالها وفقاً للوسائل والإجراءات المحددة قانوناً، وذلك إما بإصدار أسهم جديدة أو بزيادة القيمة الاسمية للأسهم⁽²⁾.

ويمكن أن تتحقق زيادة رأس المال بعدة أساليب، وهي:

1. زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام.
2. زيادة رأس المال عن طريق ضم الاحتياطي لرأس المال، ومقدار هذا الاحتياطي تصدر الشركة أسهما جديدة توزع على المساهمين فيها، أو تزيد من القيمة الاسمية لأسهمهم.
3. تحويل الديون التي على الشركة إلى أسهم.
4. تحويل حصص التأسيس إلى أسهم.

وقد نصت المادة (55) من قانون الشركات العراقي، على إمكانية زيادة رأسمال الشركة المساهمة عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، وضم الاحتياطي إلى

(¹) المادة (145/أولاً) من قانون الشركات العراقي رقم (6) لسنة 1983 الملغي.

(²) أستاذنا كامل عبد الحسين البلداوي ومهند إبراهيم الجبوري، زيادة رأسمال الشركة المساهمة في التشريع العراقي، مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون-جامعة الموصل، العدد العاشر، آذار، 2001، ص52.

رأس المال وإصدار أسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي، وتحويل أموال من الفائض المتراكم إلى أسهم توزع على المساهمين^(١).

وزيادة رأس المال، يمكن أن تكون وسيلة لتحويل الشركة العامة إلى شركة خاصة أو مختلطة، كما ويمكن أن تكون وسيلة لتحويل الشركات المختلطة إلى شركات خاصة. ويتم ذلك عندما تؤدي هذه الزيادة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الشركة. دون أن يقابلها زيادة في نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي في رأسمال الشركة، أو عندما يصبح القطاع الخاص مساهما في شركة كانت مملوكة للقطاع الاشتراكي بالكامل قبل الزيادة. ويتحقق ذلك عندما تكون الأموال المستخدمة في الزيادة مملوكة للقطاع الخاص، أو يساهم في تقديمها القطاع الاشتراكي أيضا ولكن بنسبة اقل من تلك التي قدمها القطاع الخاص.

وعلى هذا الأساس، لا يمكن أن تؤدي زيادة رأسمال الشركة إلى تحويلها إلى القطاع الخاص، إلا إذا تمت هذه الزيادة بأموال "خارجية" غير مملوكة للشركة بالأساس، أي عن طريق زيادة رأس المال بطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، أو من خلال تحويل الديون التي وإصدار أسهم جديدة توزع على المساهمين، أو زيادة قيمة أسهمهم بمقدار هذا الاحتياطي فلا يمكن أن تكون وسيلة للتحويل إلى القطاع الخاص، ذلك أن زيادة رأس المال في هذه الحالة تقتضي زيادة نسبة مساهمة جميع المساهمين في الشركة وكل حسب ما يملكه من أسهم وسواء كانوا من القطاع الخاص أم القطاع الاشتراكي.

ووفقا لهذا المفهوم، نظم المشرع الفرنسي عملية التحويل إلى القطاع الخاص عن طريق زيادة رأسمال الشركة العامة بطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، مع تخلي القطاع العام عن حق الأفضلية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة أو ببيع هذا الحق، كما أجاز المشرع الفرنسي زيادة رأسمال الشركة العامة المراد تحويلها، عن طريق قيام

(١) ويبدو لنا، أن الفائض المتراكم ما هو إلا صورة من صور الاحتياطي الاختياري للشركة، ذلك أن أموال الشركة إما أن تكون جزءا من رأسمالها الفعلي المستثمر ضمن نشاطها، أو أن تكون جزءا من الاحتياطي، ومن ثم لا يمكن وصف أي جزء منها بأنها "أموال فائضة".

الأشخاص من القطاع الخاص بتقديم الأصول "actifs" كحصة عينية في الشركة المراد تحويلها⁽¹⁾. وهذا يعني أنه يمكن وفقا للتشريع الفرنسي تحويل الشركة العامة، وهي الشركة التي يمتلك فيها القطاع العام أكثر من (51%) من رأسمالها بطرح أسهم جديدة لاكتتاب العام، وتخلي القطاع العام عن حقه في الاكتتاب بأسهم الزيادة بالأفضلية، أو ببيعه لهذا الحق للقطاع الخاص، فإذا ما انخفضت نسبة مساهمة القطاع العام عن (51%) من رأسمال الشركة جراء هذه الزيادة، تفقد الشركة العامة وصف الشركة العامة وتصبح شركة خاصة. ومما تجدر ملاحظته أن بيع القطاع العام لحقه في الاكتتاب بالأسهم الجديدة بالأفضلية، يجب أن يتم خلال المدة المحددة لممارسة هذا الحق وهي (10) أيام كحد أدنى⁽²⁾.

ونعتقد أن هذه الأحكام التي قررها المشرع الفرنسي، تمنح الشركة العامة مرونة كبيرة عند زيادة رأسمالها، فقد يكون من مصلحة الشركة أن تقوم بزيادة رأسمالها من خلال تقديم حصص عينية، تعزز من قدرة الشركة الفنية والاقتصادية، كما أن هذه الأحكام تتيح للقطاع العام أن يحصل على ربح مادي عند تحويل الشركة إلى القطاع الخاص عن طريق زيادة رأس المال وبيع حق الأفضلية، ودون بيع بالأسهم المملوكة للقطاع العام.

أما موقف المشرع المصري، فينبغي أن يلاحظ ابتداء أن رأسمال الشركة العامة وفقا للتشريع المصري يمكن أن يقسم إلى رأسمال مصدر وآخر مخصص به⁽³⁾.

(¹) المادة (1) المعدلة من قانون التحويل الفرنسي الصادر في 1986/8/6. وأنظر:

Meichel Durapty ,L' Actuatitd En Droit Economique – Les Relations entre Le Secteur public et Le secteur priv: La Privatisation Du Secteur public en france , P. 74.

(²) المادتان (183) و (188) من قانون الشركات التجارية الفرنسية لسنة 1966، وأنظر:

Francis Lefebver, Memento pratiaue socitetes commerciales Le febreve, Paris, 1995, P. 621.

(³) المادة (47) من قانون شركات قطاع الأعمال المصري. ويقصد برأسمال الشركة المصدر: رأس المال الذي يحدده المؤسسون للشركة المساهمة عند تأسيسها، والذي يجب أن يكون مكتتباً به بالكامل، أما رأس المال المرخص به، فهو الذي يرد في نظام الشركة أو عقدها، والذي يجاوز رأس المال المصدر، أنظر: د. فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999، ص284. كذلك د. عبد الحكيم فودة، شركات

ووفقا للمادة (25/أولا) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، تختص الجمعية العامة غير العادية للشركة في النظر بموضوع زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر في حالة عدم وجود رأسمال مرخص به. وهذا يعني أنه في حالة وجود رأسمال مرخص به، فإن زيادة رأسمال الشركة المصدر ضمن حدود رأسمال الشركة المرخص به يكون من اختصاص مجلس الإدارة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (133) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981، باعتبار أن هذا القانون واجب التطبيق على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون شركات قطاع الأعمال العام.

هذا، ويمكن زيادة رأسمال شركة قطاع الأعمال العام وفقا للتشريع المصري عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو ضم الاحتياطي إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة توزع على المساهمين بما يتناسب وعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم، كما ويمكن زيادة رأسمال الشركة عن طريق تقديم حصص عينية⁽¹⁾ أو عن طريق تحويل الديون التي على الشركة إلى أسهم وفقا لقانون الشركات المصري لسنة 1981. ويتبين لنا من خلال ما تقدم، أنه من الجائز وفقا للتشريع المصري، أن تتحول الشركة التابعة إلى شركة خاصة، من خلال زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة تطرح للاكتتاب العام، متى ما أدت هذه الزيادة إلى انخفاض نسبة مساهمة الشركة القابضة عن (51%) من رأس مال الشركة التابعة، على أن تتنازل الشركة القابضة - بمقابل أو دون مقابل - عن حق الأفضلية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة، وذلك وفقا لأحكام المادة (96) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة 1981. وإذا ما أرادت الشركة القابضة بيع حق الأفضلية المقرر لها، فيجب أن يتم ذلك خلال المدة المحددة لممارسة هذا الحق، وهذه المدة هي (30) يوما كحد أدنى، ويجوز

الأموال والعقود التجارية، في ضوء قانون الشركات الجديد رقم 3 لسنة 1998، دار الفكر الجامعي - الإسكندرية، 2000، ص32.
(¹) أنظر: المواد (19، 32) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، والمادة (51) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

للجمعية العامة عند اتخاذ قرار الزيادة أن تحدد مدة أطول من ذلك، كما ويجوز وفقا للمادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري، وبقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على طلب مجلس الإدارة، لأسباب جدية يديها ويقرها مراقب الحسابات، بتقرير منه، يمكن طرح أسهم زيادة رأس المال كلها أو بعضها للاكتتاب العام المباشر دون أعمال حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى⁽¹⁾.

وتجدر الإشارة إلى أن تحويل الشركة التابعة، وفقا للقانون المصري، إلى شركة خاصة، يمكن أن يتحقق أيضا عن طريق زيادة رأسمال هذه الشركة بتحويل ديونها المقدمة من قبل القطاع الخاص إلى أسهم، متى ما أدت هذه الزيادة إلى انخفاض نسبة مساهمة الشركة القابضة عن (51%) من رأسمال الشركات التابعة، وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981، على أساس أن هذا القانون يطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص في قانون شركات قطاع الأعمال المصري.

وعلى هذا الأساس، يمكن للشركة التابعة أن تقوم بإصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم⁽²⁾ وذلك وفقا لأحكام المادة (165) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة 1981، ويجب أن تصدر هذه السندات بقيمة اسمية مساوية لقيمة الأسهم التي يمكن أن يحصل عليها حملة السندات إذا اختاروا تحويلها إلى أسهم. ولا تتم عملية التحويل إلا بإرادة حملة السندات وبالشروط المحددة في نظام إصدارها، ويجب على حامل السند أن يبيدي رغبته في التحويل في المواعيد التي ينص عليها قرار الإصدار والمعلن عنه في نشرة الاكتتاب، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لاستهلاك السندات، ويجب أن يراعى في اتخاذ

(¹) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 1996، ص 325.

(²) وتعرف هذه السندات بأنها "عبارة صكوك ذات قيمة اسمية واحدة، قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، تصدرها الشركات المساهمة، تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي أسلفوها للشركة، على أن يكون لأصحابها الحق بتحويلها إلى أسهم". وأنظر: الياس نصيف، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجارية، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات، بيروت - باريس، ط 1، 1982، ص 383.

القرار المتعلق بإصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الإجراءات التي ينص عليها القانون عند زيادة رأس المال كضرورة صدور القرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة، أو صدوره من مجلس الإدارة إذا كانت الزيادة في حدود رأس المال المرخص به⁽¹⁾.

أما عن موقف المشرع العراقي، فمن غير المتصور وفقا لأحكام قانون الشركات العامة، تحويل الشركات العامة إلى شركات خاصة أو مختلطة عن طريق زيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، إذ أن رأسمال الشركة العامة لا يقسم أساسا إلى أسهم فضلا عن أنه لا يجوز للقطاع الخاص أن يمتلك جزءا من رأسمال الشركة العامة.

ونعتقد أن من شأن هذه الأحكام، أن تحول دون استخدام هذا الأسلوب في التحول ومن ثم فقدان المزايا التي يمكن أن يحققها، فهو يعد وسيلة ملائمة إلى حد كبير للشركات العامة التي تكون بحاجة إلى تمويل إضافي لدعم قدراتها الاقتصادية في الوقت الذي قد لا ترغب فيه الوزارة المعنية أو لا تستطيع فيه دعم الشركة من رأس المال العام، كما أنه يعد مناسباً للشركات العامة التي تمارس نشاطا اقتصاديا مهما للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الامتناع عن بيع الشركة وتفضيل الاشتراك مع القطاع الخاص في ملكية رأسمالها. ولكل ذلك، نقترح على المشرع العراقي أن يأخذ بهذا الأسلوب للتحويل، وعلى النحو الذي أشرنا إليه بالنسبة للقوانين المقارنة.

أما عن الشركة المختلطة، فيثار التساؤل عن مدى إمكانية تحويلها إلى شركات خاصة من خلال زيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام، فعلى الرغم من أن المادة (64/ثانيا) من قانون الشركات العراقي تمنع المساهم من القطاع الاشتراكي من نقل ملكية أسهمه في الشركة المختلطة إلى شخص من غير هذا القطاع، إذا أدى ذلك

(1) وبخصوص هذه الأحكام الواردة في قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981، أنظر: د. حسني المصري، القانون التجاري، - الكتاب الثاني - شركات القطاع الخاص، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1986، ص250.

إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عن (25%) من رأس المال، فإنه لا يوجد ما يمنع تحول الشركة المختلطة إلى شركة خاصة عن طريق زيادة رأس المال بطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام وذلك إذ أدت هذه الزيادة إلى تخفيض نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي في رأسمال الشركة عن (25%)⁽¹⁾ غير أن هذه العملية لا يمكن ان تتحقق إلا بموافقة القطاع الاشتراكي المساهم في الشركة المساهمة المختلطة، ذلك ان زيادة رأسمال الشركة المساهمة وفقا لقانون الشركات النافذ، تخضع لرقابة الجهة القطاعية المختصة. فوفقا للمادة (54/ثالثا) من قانون الشركات العراقي، تقدم الشركة المساهمة إلى المسجل قرارا من الهيئة العامة بزيادة رأسمالها معززا بدراسة اقتصادية بمسوغات الزيادة وأوجه استخدامها وأية بيانات ضرورية أخرى، ويتولى المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة لبيان رأيها بالموافقة أو الرفض على زيادة رأس المال، ومدى انسجامها مع نشاط الشركة ووضعها المالي، وعلى تلك الجهة الإجابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها كتاب المسجل.

هذا، وقد أعطى المشرع العراقي لكل مساهم في الشركة المساهمة حق الأفضلية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تطرحها الشركة بمناسبة زيادة رأسمالها، اكتتابا يتناسب مع عدد أسهمه في الشركة، على ان تتم ممارسة هذا الحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة المساهمين للاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال⁽²⁾.

ويجب في هذه الحالة على القطاع الاشتراكي أن لا يباشر هذا الحق على نحو يؤدي إلى انخفاض نسبة مساهمته عن (25%) من رأسمال الشركة المساهمة المختلطة. كما ويمكن للقطاع الاشتراكي أن يبيع حق الأفضلية المقرر له، وأن لم ينص قانون الشركات على ذلك صراحة، ذلك أن هذا الحق هو حق شخصي له قيمة مالية، ومن ثم ينطبق على هذا الحق وصف المال، باعتبار أن المال هو كل حق له قيمة مالية⁽³⁾. غير أن بيع

(¹) أستاذنا كامل عبد الحسين البلداوي ومهند إبراهيم الجبوري، المرجع السابق، ص 52.

(²) المادة (56/ثالثا)، من قانون الشركات العراقي.

(³) د. باسم محمد صالح و د. عدنان أحمد ولي، المرجع السابق، ص 201.

القطاع الاشتراكي لهذا الحق، يجب أن يتم حسب تقديرنا - خلال المدة المحددة لممارسته وهي (15) يوما، ذلك أن هذا الحق يسقط بانتهاء هذه المدة.

وعلى أي حال، يجب طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الشركة بموافقة الجهة القطاعية المختصة على الزيادة، ويبقى الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن (30) يوما ولا تزيد على (60) يوما، قابلة للتمديد مدة مماثلة، على أن يتم تسديد قيمة الأسهم المكتتب بها عند غلق الاكتتاب، وفيما عدا ذلك وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة رأس المال تطبق أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة، وتحقق الزيادة في رأس المال بقدر الأسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها عند غلق الاكتتاب - أسهم زيادة رأس المال - وفيما يتعلق بالشركة المحدودة المختلطة، فتوزع الأسهم الجديدة على الشركاء فيها، ويجب تسديد قيمة الأسهم خلال ثلاثين يوما من صدور قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال، وتحقق الزيادة بقدر الأسهم المسددة قيمتها عند انتهاء المدة⁽¹⁾. وهذا يعني أنه لا يمكن الاستفادة من هذا الأسلوب لتحويل الشركة المحدودة المختلطة إلى شركة محدودة خاصة، طالما أن القطاع الاشتراكي المساهم في هذه الشركة سيحصل على عدد من أسهم الزيادة يتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها أساسا.

بقي أن نشير إلى أن المشرع العراقي لم يجز تقديم الحصص العينية عند زيادة رأسمال الشركة المساهمة والمحدودة، في حين أنه أجاز تقديم مثل هذه الحصص عند تأسيس الشركة⁽²⁾، فقد نصت المادة (55) من قانون الشركات العراقي على أنه "للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة تغطية زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أولا. إصدار أسهم جديدة تسدد أقيامها نقدا..."

ويبدو لنا، أن المشرع العراقي لم يكن موافقا في تقرير هذا الحكم، ذلك أنه لم يعد هناك ما يبرر عدم إجازة تقديم الحصص العينية عند زيادة رأسمال الشركة

⁽¹⁾ المادة (56/ثالثا)، من قانون الشركات العراقي، وأنظر: د. باسم محمد صالح و د. عدنان أحمد ولي، المرجع السابق، ص 206.

⁽²⁾ المادة (29) من قانون الشركات العراقي.

المساهمة أو المحدودة، ما دام تقديمها جائزا عند تأسيس الشركة. لذلك ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة (55) السالفة الذكر من قانون الشركات العراقي بما يسمح بتقديم الحصص العينية عند زيادة رأسمال الشركة المساهمة والمحدودة، لما لهذا الحكم من أثر في تدعيم القدرة الفنية للشركة فضلا عن تدعيم قدرتها الاقتصادية، الأمر الذي يجعل من زيادة رأس المال أسلوبا فعالا في تحويل الشركة المساهمة المختلطة إلى شركة مساهمة خاصة، من خلال تقديم بعض الأصول المملوكة للقطاع الخاص (كالمعامل) مثلا، حصصا عينية في الشركة المساهمة المختلطة.

الفصل الثالث
آثار التحول إلى
القطاع الخاص

الفصل الثالث

آثار التحويل إلى القطاع الخاص

تختلف الآثار القانونية للتحويل إلى القطاع الخاص في التشريع العراقي باختلاف الأسلوب المتبع في عملية التحويل، فإذا كانت الآثار المترتبة على التحويل إلى القطاع الخاص عن طريق بيع الأصول، لا تختلف عن آثار عقد البيع المقررة في القواعد العامة، من حيث التزام المشتري بدفع الثمن والتزام البائع بتسليم المبيع وغير ذلك، فإن تحول الشركات العامة ودمجها بشركات أخرى خاصة أو مختلطة يترتب آثاراً قانونية مهمة، إذ انه يؤدي إلى انقضاء الشركة العامة انقضاء مبسراً لا تعقبه عملية تصفية، وانتقال كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الناجمة عن التحويل، أو إلى الشركة الدامجة أو الناجمة عن الدمج، وهذه الآثار تقترب من تلك التي تترتب على إعادة هيكلة الشركات أو المنشآت العامة، وفقاً للتشريعات المقارنة، إذ تؤدي هذه العملية إلى انقضاء الشركة أو المنشأة العامة بدون تصفية، وانتقال كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركة المساهمة التي تمتلك الدولة أسهمها بالكامل والناجمة عن هذه العملية، بحيث يمكن للدولة بعد ذلك تحويل هذه الشركة المساهمة إلى القطاع الخاص بالطريقة التي تراها مناسبة. فضلاً عما تقدم، نلاحظ أن التشريعات المقارنة تقرر إخضاع الشركات الناجمة عن التحويل لنوع من الرقابة اللاحقة على عملية التحويل إلى القطاع الخاص، وذلك من أجل ضمان استمرار المشروعات العامة بعد تحويلها إلى القطاع الخاص، وتحقيق الأهداف المنشودة من وراء عملية التحويل والحيلولة دون سيطرة الأجانب على الشركات الناجمة عن التحويل.

وتأسيساً على ما تقدم، ارتأينا تقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أثر التحويل إلى القطاع الخاص في الشركة العامة.

المبحث الثاني: خلافة الشركات الناجمة عن التحويل للشركة العامة.

المبحث الثالث: الرقابة اللاحقة على عمليات التحويل إلى القطاع الخاص.

المبحث الأول أثر التحويل إلى القطاع الخاص في الشركة العامة

يقتضي التحويل إلى القطاع الخاص - وفقاً للتشريعات المقارنة، إعادة هيكلة الشركات أو المشروعات العامة، بتحويلها إلى شركات مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل، وهذه العملية تستلزم حلول الشركة المساهمة محل الشركة العامة التي تنقضي جراء إعادة هيكلتها في كافة الحقوق والالتزامات، ثم يصار بعد ذلك إلى تحويل الشركة المساهمة إلى القطاع الخاص، وفقاً للأسلوب الذي تراه الدولة مناسباً، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير النظام القانوني الذي كانت تخضع له الشركات العامة بعد أن يتم تحويلها إلى القطاع الخاص، وخلافاً للتشريعات المقارنة، يتم تحويل الشركات العامة إلى القطاع الخاص، وفقاً للتشريع العراقي، بشكل مباشر دون اللجوء إلى إعادة هيكلة الشركات العامة، حيث يتم تحويل الشركات العامة إلى شركات خاصة أو مختلطة مباشرة، مما يؤدي إلى انقضاء الشركة العامة وتأسيس شركة جديدة هي الشركة الناجمة عن التحويل. وهذا يعني أن انقضاء الشركة العامة وتغيير النظام القانوني الذي تخضع له الشركة العامة يتم في وقت واحد وفقاً لأحكام القانون العراقي، في حين أنه يتم على مرحلتين في القوانين المقارنة، حيث تنقضي الشخصية المعنوية للشركة العامة في المرحلة الأولى دون أن يؤدي ذلك إلى خروج الشركة الناجمة عن عملية إعادة الهيكلة من نطاق شركات القطاع العام، إذ لا يتم ذلك إلا في المرحلة الثانية عند تحويل الشركة العامة إلى القطاع الخاص.

وبسبب هذا الاختلاف، ارتأينا تقسيم هذا المبحث على ثلاثة مطالب، خصص الأول منها للبحث في انقضاء الشخصية المعنوية للشركة العامة جراء عملية التحويل، أما المطلب الثاني، فلقد خصص للبحث في تغيير النظام القانوني الذي تخضع له الشركة العامة، أما المطلب الثالث فتناولنا فيه إجراءات تأسيس الشركة الناجمة عن

التحول في القانون العراقي، وذلك لخصوصية القانون العراقي في تنظيم هذا الموضوع.
المطلب الأول
انقضاء الشخصية المعنوية للشركة العامة

سبقت الإشارة إلى أن كلا من المشرع الفرنسي والمصري والأردني قد نظم عملية إعادة هيكلة المنشآت أو الشركات العامة⁽¹⁾ بتحويلها إلى شركات مساهمة تملك الدولة رأسمالها بالكامل، وذلك تمهيدا لتحويلها إلى القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بموقف المشرع الفرنسي فلقد اصدر المشرع الفرنسي العديد من القوانين التي تتضمن إجراءات إعادة هيكلة بعض المنشآت العامة الصناعية والتجارية (Epic)⁽²⁾، ويلاحظ جانب من الفقه الفرنسي⁽³⁾، انه وبالرغم من ان هذه العمليات عبارة عن تغير في الشكل القانوني للمنشآت العامة عن طريق تحويلها إلى شركات (مساهمة وطنية)، فإن هذه العمليات تؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية للمنشآت العامة بوصفها شخصا معنويا عاما، ونشوء شخصية معنوية جديدة، هي شخصية الشركة الناجمة عن (إعادة الهيكلة) بوصفها شخصية معنوية خاصة.

أما عن موقف المشرع المصري، فقد نصت المادة الثانية من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على انه ((تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون الحاجة إلى أي إجراء آخر)).

⁽¹⁾ نظم كل من المشرع الفرنسي والأردني عملية إعادة هيكلة المنشآت العامة، أما المشرع المصري فقد نظم عملية إعادة هيكلة الشركات العامة والهيئات العامة التي تشرف عليها.

⁽²⁾ Jean - Philippe Colson , Op. Cit, P254-255.

⁽³⁾ المرجع نفسه، ص 187.

وقد اختلف الفقه المصري بشأن تحديد المقصود (بالحلول) الذي أشار إليه النص المتقدم. فقد ذهب الرأي الأول⁽¹⁾ إلى أن المقصود بهذا الحل هو ((تغير في الشكل القانوني) أي انه مجرد تغير في التسمية، تصبح بموجبه هيئات القطاع العام شركات قابضة، دون أن يؤثر ذلك في الشخصية المعنوية للهيئة العامة، فتستمر الشركة القابضة محتفظة بذات الشخصية المعنوية لهيئة القطاع العام.

ويذهب الرأي الثاني⁽²⁾ إلى أن المقصود بهذا الحل، هو عدم ضرورة مراعاة إجراءات التأسيس المنصوص عليها قانونا في هذه الحالة، وان تثبت للشركة القابضة والشركة التابعة الشخصية المعنوية من تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام، دون تعليق ذلك على القيد في السجل التجاري خلافا للشركات التي تؤسس ابتداء، فمنطق هذا الرأي إذن هو انقضاء الشخصية المعنوية لهيئات القطاع العام والشركات العامة التابعة لها وثبوت شخصية معنوية جديدة للشركات القابضة والشركات التابعة لها ابتداء من تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام.

ويذهب رأي ثالث⁽³⁾ وهو ما نرجحه إلى التمييز بين حالتين، الأولى، هي حالة حلول الشركة القابضة محل هيئات القطاع العام، ففي هذه الحالة لا يعد هذا الحل مجرد تغير في المسميات، بل هو تغير جوهري، يستلزم انقضاء الشخصية المعنوية لهيئة القطاع العام، وذلك لاختلاف النظام القانوني الذي يخضع له أشخاص القانون العام ((هيئات القطاع العام)) عن النظام القانوني الذي يخضع له أشخاص القانون الخاص ((الشركات القابضة)) فهذا الاختلاف يدحض فكرة استمرار الشخصية المعنوية للهيئة العامة بعد تحويلها إلى شركة قابضة، وقد أكدت محكمة النقض المصرية ذلك في أحد قراراتها، والذي فسرت فيه المقصود بالحلول الذي أشارت إليه المادة الثانية من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها إذ جاء فيه انه ((يدل

(1) رضا السيد عبد الحميد، المرجع السابق، ص 42.

(2) د. محمود سالم، المرجع السابق، ص 30.

(3) د. حسام الدين عبد الغني الصغير، بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام للعاملين، المرجع السابق، ص 41.

على ان هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون رقم 203 لسنة 1991⁽¹⁾)).

أما الحالة الثانية فهي حالة حلول الشركات التابعة محل شركات القطاع العام، ولا يترتب على هذا الحلول انقضاء الشخصية المعنوية لشركة القطاع العام واكتساب الشركة التابعة لشخصية جديدة، فهذا الحلول يختلف عن حلول الشركة القابضة محل هيئة القطاع العام، لان شركة القطاع العام تظل محتفظة بشكلها القانوني كشركة مساهمة تخضع فيما لم يرد بشأنه نص في قانونها لقانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، خلافا لهيئات القطاع العام التي تتحول إلى شركة قابضة تعد من أشخاص القانون الخاص بعد ان كانت من أشخاص القانون العام.

أما بخصوص المشرع الأردني والذي أجاز تحويل ((المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة مساهمة عامة، فقد فسر هذا التحول على أساس انه انقضاء للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة، وإنشاء لشركة مساهمة عامة تتمتع بشخصية معنوية جديدة⁽²⁾.

وأيا كان الأثر المترتب على إعادة الهيكلة، فانه لا يؤدي وفقا للتشريعات المقارنة التي أشرنا إليها إلا إلى انقضاء الشخصية المعنوية دون أن يؤدي ذلك إلى تصفية الشركة أو المنشأة العامة التي انقضت شخصيتها المعنوية جراء إعادة هيكلتها، وانما تنقل موجودات الشركة أو المنشأة العامة إلى الشركة المساهمة الناجمة عن عملية إعادة الهيكلة وعلى النحو الذي سنفصله في الموضع المناسب.

أما بخصوص موقف المشرع العراقي، فقد نصت المادة (37/ثالثا) من قانون الشركات العامة على انه ((تكتسب الشركة المساهمة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ آخر نشر لقرار التحول ((. ومما لا شك فيه ان اكتساب الشركة المساهمة

(¹) الطعن رقم (5445) لسنة 961 ق. جلسة 1992/6/25، حسن الفكاهاني، الموسوعة الذهبية للقواعد العامة التي قررتها محكمة النقض المصرية، الإصدار المدني، الملحق (11)، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص 383.

(²) المادة الثانية من قانون الشركات الأردني لسنة 1997، وانظر: صهيبي موسى، المرجع السابق، ص 46.

الناجمة عن التحول لشخصية معنوية جديدة يعني بالضرورة انقضاء الشخصية المعنوية للشركة العامة، ومع ذلك يثار التساؤل عن الوقت الذي تنقضي فيه الشخصية المعنوية للشركة العامة جراء التحويل؟ وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه في العراق⁽¹⁾ إلى أن الشخصية المعنوية للشركة العامة تنقضي- باتخاذ قرار التحول من قبل مجلس الوزراء، وأن الشركة المساهمة الناجمة عن التحول تكتسب الشخصية المعنوية بنشر هذا القرار.

ولا نتفق مع الرأي المتقدم، في القول بأن الشركة العامة تفقد شخصيتها المعنوية باتخاذ قرار التحول، ونعتقد أنها لا تفقد شخصيتها المعنوية إلا بنشر هذا القرار، أي أن انقضاء الشخصية المعنوية للشركة العامة واكتساب الشركة الناجمة عن التحول للشخصية المعنوية يتم في وقت واحد، والذي يبدأ من تاريخ آخر نشر- لقرار التحول، ذلك أن القول بانقضاء الشخصية المعنوية للشركة العامة باتخاذ قرار التحول، وعدم اكتساب الشركة الناجمة عن التحول للشخصية المعنوية إلا بعد نشر- هذا القرار، قد يلحق ضرراً بنشاط الشركة وبالأغيار.

فالمشرع العراقي لم يحدد وقتاً معيناً يجب خلاله استكمال إجراءات تحول الشركة العامة بعد إصدار قرار التحول والتي تتمثل بقيام الوزارة بإعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء إلى المسجل، ونشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل⁽²⁾. وهذه الإجراءات قد تستغرق مدة طويلة، لذلك فإن القول بانقضاء الشركة العامة باتخاذ قرار التحول يعني أن الشركة ستفقد أهليتها بمجرد اتخاذ قرار التحول، وإنها ستتوقف عن مباشرة نشاطها خلال المدة ما بين اتخاذ قرار التحول ونشر هذا القرار، الأمر الذي قد يلحق ضرراً بها، لا سيما إذا ما استغرقت إجراءات التحول وقتاً طويلاً، كما أن القول بانقضاء الشركة العامة باتخاذ قرار التحول وقبل نشره، قد يلحق ضرراً بالغير، خاصة إذا كان حسن النية لا يعلم بانقضاء الشركة العامة لعدم نشر قرار التحول في الجريدة الرسمية أو

(1) د. إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص 4 هامش (1).

(2) المادة (37/أولاً وثانياً) من قانون الشركات العامة العراقي.

النشرة الخاصة التي يصدرها المسجل فيتعامل مع الشركة العامة التي تكون قد انقضت باتخاذ قرار التحول، ومن ثم تكون جميع تصرفاتها باطلة، بسبب انقضائها وفقدانها لأهليتها جراء هذا الانقضاء. وعلى هذا الأساس نرى ان الشركة العامة لا تفقد شخصيتها المعنوية جراء التحول إلا من تاريخ اكتساب الشركة الناجمة عن التحول لشخصيتها المعنوية، وهو تاريخ آخر نشر لقرار التحول. ومما تجدر الإشارة إليه، هو ان انقضاء الشركة العامة جراء تحولها هو انقضاء من نوع خاص فهو انقضاء مبترس لا تعقبه عملية تصفية، ويمكننا التدليل على ذلك من خلال عرضنا لحالات انقضاء الشركة العامة وحالات تصفيتهما الواردة في قانون الشركات العامة العراقي، فقد تضمن هذا القانون ثلاثة أسباب تؤدي إلى انقضاء الشركة العامة، وهي:

1. انقضاء الشركات العامة جراء الدمج، وفقاً للمادة (33) من قانون الشركات العامة العراقي.
2. انقضاء الشركة العامة جراء تحويلها على النحو الذي أشرنا إليه فيما تقدم.
3. انقضاء الشركات العامة، بسبب خسارتها (50%) من رأسمالها الاسمي وصدور قرار من مجلس الوزراء بتصفيتها، بناء على دراسة اقتصادية تعدها الوزارة المعنية وفقاً للمادة (14) من قانون الشركات العامة.

أما بخصوص حالات التصفية فلقد نصت المادة (39/أولاً) من قانون الشركات العامة على انه ((عند تحقق الأسباب الواردة في المادة (14) من هذا القانون تقوم الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة)) وهذا يعني انه لا يتم تصفية الشركة العامة إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة خسارة الشركة لـ(50%) من رأسمالها، وصدور قرار من مجلس الوزراء بتصفيتها بناء على ذلك. أما بخصوص قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1995 فإنه لم ينص صراحة على أن تحويل الشركة العامة يؤدي إلى انقضائها ودون المرور بمرحلة التصفية، ومع ذلك فإن ما تضمنه هذا القرار من إجراءات تقييم موجودات الشركة العامة، والاكتتاب برأسمال الشركة الناجمة عن التحول، والذي يساوي القيمة المقدرة لموجودات الشركة

العامة يشير إلى أن عملية التحويل تؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة العامة وانتقال موجوداتها إلى الشركة الناجمة عن التحويل. غير أن ما ينبغي ملاحظته بخصوص هذا القرار انه أجاز تحويل المنشآت والمعامل التي لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة⁽¹⁾، ومن ثم لا محل لتطبيق الأحكام الخاصة بانقضاء الشخصية المعنوية في هذه الحالة⁽²⁾، فتحويل المعامل المملوكة للدولة إلى شركات خاصة أو مختلطة ما هو إلا تأسيس لشركة جديدة يتكون رأسمالها من حصة عينة واحدة، وهي موجودات المعمل، يتم تقديرها وفقاً لإجراءات خاصة⁽³⁾.

ومما تجدر الإشارة إليه ان تحويل الشركة العامة إلى شركة خاصة أو مختلطة عن طريق اندماجها بشركة خاصة أو مختلطة يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية لجميع الشركات الداخلة في عملية الاندماج في حالة الاندماج بالمزج، أو إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة في حالة الاندماج بالضم⁽⁴⁾. وعلى أية حال، إذا انقضت الشركة العامة على النحو المشار إليه، فإن ذلك يستتبع فقدان الشركة العامة لأهليتها وانتهاء صلاحيتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتفقد الشركة العامة أهلية التقاضي مدعية أو مدعى عليها وتزول صفة

(¹) المادة (2/ثانياً) من هذا القرار، كذلك لم يتضمن قرار مجلس قيادة الثورة رقم 140 لسنة 1993 الملغي، نصاً يقرر انقضاء الشخصية المعنوية للمشاريع التي تتحول إلى شركة عامة بموجب هذا القرار، ذلك أن هذه المشاريع هي معامل تابعة لوزارة الصناعة والمعادن ولا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، المادة (1) من هذا القرار.

(²) وقد جاء بقرار لمحكمة النقض المصرية أنه ((المصنع في صحيح الوصف أداة إنتاج تدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشركة التي تملكه فلا يتمتع بشخصية اعتبارية ولا تكون له من الحقوق والالتزامات ما يتخلف عنه أو يخلف عنه)). الطعن رقم (623) سنة 46 ق جلسة 1978/12/6 س 29، د. احمد حسيني، قضاء النقض التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983، ص 241.

(³) بخصوص إجراءات التقدير انظر ما تقدم، ص .

(⁴) مهند إبراهيم الجبوري، المرجع السابق، ص 108.

ممثليها في تمثيلها على الرغم من استمرار المشروع الاقتصادي الذي كانت تديره الشركة العامة، وانتقال هذا المشروع إلى الشركة الناجمة عن التحول.

المطلب الثاني تغير النظام القانوني الذي تخضع له الشركة العامة

وفقا للتشريعات المقارنة التي تنظم عملية التحول إلى القطاع الخاص على مرحلتين، يتم في الأولى إعادة هيكلة الشركات أو المشروعات العامة بتحويلها إلى شركات مساهمة تملك الدولة رأسمالها بالكامل، ويتم في المرحلة الثانية تحويل هذه الشركات إلى القطاع الخاص وفقا للإجراءات المحددة قانونا، بمعنى إعادة هيكلة الشركات أو المشروعات العامة لا تؤدي إلى فقدان الشركة لوصف العمومية، إذ أنها تخرج من نطاق القطاع العام وتدخل ضمن إطار القطاع الخاص بعد بيع أسهمها للقطاع الخاص أو دمجها بشركات خاصة أو زيادة رأسمالها بأموال مملوكة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى تغير النظام القانوني الذي تخضع له الشركة العامة أو بعض أوجه هذا النظام.

وفيما يتعلق بموقف المشرع الفرنسي، فالملاحظ أن الشركات المساهمة التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل تخضع لقانون الشركات التجارية الفرنسي لسنة 1966، غير أن سيطرة القطاع العام على هذه الشركات يجعل لهذه الشركات بعض السمات الخاصة التي تميزها عن شركات القطاع الخاص التي تخضع لقانون الشركات التجارية الفرنسي، كما أنها تؤدي إلى خضوع هذه الشركات لبعض القوانين الخاصة، والتي تتعلق بشكل خاص بإدارة هذه الشركات، ومن أهم هذه القوانين قانون تحرير القطاع العام الفرنسي رقم 675 - 83 في 1983/7/26⁽¹⁾.

وعلى هذا الأساس أوجب المشرع الفرنسي- على مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال شهرين من تاريخ تحول الشركة، وذلك بقصد تعيين المدراء من قبل الهيئة العامة للشركة، ووضع نظام للشركة ينسجم مع قانون الشركات التجارية الفرنسي، ما لم يكن هذا القرار قد صدر قبل تحويل الشركة إلى

(¹) Y-Guyon , Leregime juridique des societes privatisées en France et en Italie , Petites affiches , 15 dec , 1997 , P. 5.

القطاع الخاص، ففي هذه الحالة الأخيرة تجتمع الهيئة العامة للشركة قبل عملية التحويل لتعديل نظام الشركة، ويكون قرار الهيئة العامة الخاص بالتعديل معلقا على شرط واقف، ألا وهو تحويل الشركة إلى القطاع الخاص، وفي هذه الحالة، لا بد من عقد اجتماع ثان للهيئة العامة للشركة بعد تحويلها للقطاع الخاص، بغية تعيين المدراء وتحديد صلاحياتهم المالية عند الضرورة⁽¹⁾.

وأبرز المسائل التي يمكن أن ينصب عليها تعديل نظام الشركة هو النص على إمكانية إصدار الأسهم الممتازة التي تخول حاملها صوتا مضاعفا وفقا للمادة 175 من قانون الشركات التجارية الفرنسي- أو تحويل الشركة حق إصدار أسهم للحامل وفقا للمادة (1-263) من قانون الشركات التجارية الفرنسي- وكذلك حق الشركة في شراء أسهمها في حدود (10%) من رأس المال⁽²⁾.

أما بخصوص تعديل نظام الشركة المساهمة (العامة) بقصد تشكيل مجلس الإدارة في الشركة بعد تحويلها إلى القطاع الخاص، فيلاحظ ان الهيئة العامة غير العادية للشركة تتولى تعديل نظام الشركة قبل عملية التحويل، من اجل السماح بإضافة ثلاثة أعضاء إلى مجلس إدارة الشركة الناجمة عن التحويل، اثنين يمثلان العاملين في الشركة وعضو واحد يمثل بقية المساهمين، إذا كان مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يتجاوز (15) عضوا، أو ان يضاف إلى المجلس أربعة أعضاء ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في الشركة وعضو واحد يمثل المساهمين، وذلك عندما يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر فأكثر⁽³⁾.

ويشير جانب من الفقه الفرنسي⁽⁴⁾، إلى انه من الممكن تعديل نظام الشركة بعد ذلك بقصد حرمان العمال من حق التمثيل في مجلس الإدارة على النحو المشار إليه.

⁽¹⁾ الفقرة الثانية من المادة (69) من القانون الفرنسي المرقم 416 - 87 في 1987/6/17، وانظر:

Jean - Paul valuet , Op. Cit. , P.101.

⁽²⁾ المرجع نفسه، نفس الصفحة.

⁽³⁾ المادة (1/8) من قانون التحويل الفرنسي لسنة 1986.

⁽⁴⁾ Jean - Philippe Colson , Op. Cit, P. 153.

ومهما يكن من أمر، فإن عدد الأعضاء الذين يضافون إلى مجلس إدارة الشركة الناجمة عن التحول، يختلف بحسب عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة قبل تحويلها إلى القطاع الخاص، وقد بينت المادة (89) من قانون الشركات التجارية الفرنسي كيفية تشكيل مجلس إدارة الشركة المساهمة إذ نصت على أنه ((تدار الشركة المساهمة من قبل مجلس الإدارة والذي يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل واثنى عشر عضواً على الأكثر، ويمكن أن يصل عدد الأعضاء إلى خمسة عشر عضواً إذا كانت أسهم الشركة لها سعر رسمي في البورصة، ومع ذلك يجوز في حالة الاندماج أن يزيد عدد الأعضاء الاثنى عشر أو الخمسة عشر، إلى عدد يساوي العدد الكلي لجميع أعضاء مجالس إدارة الشركات الداخلة في الاندماج...))⁽¹⁾.

ومما تجدر الإشارة إليه أن لوزير الاقتصاد وفقاً للتشريع الفرنسي الحق في تعيين ممثل أو ممثلين في مجلس إدارة الشركة الناجمة عن التحول، دون أن يكون لهذا الممثل أو الممثلين الحق في التصويت على قرارات مجلس الإدارة، وذلك بموجب الصلاحيات التي يخولها السهم الخاص لوزير الاقتصاد وعلى النحو الذي سنفصله في حينه.

أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري، فوفقاً للمادة (16) من قانون شركات قطاع الأعمال العام، تخرج الشركة التابعة من نطاق هذا القانون إذا انخفضت مساهمة الشركة القابضة، والأشخاص المعنوية العامة وبنوك القطاع العام في رأسمال الشركة عن (51%).

ويثار التساؤل في هذه الحالة عن مصير هذه الشركة التابعة، وفيما إذا كانت ستصبح إحدى شركات قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 أو إحدى شركات قانون الاستثمار رقم 203 لسنة 1989 ؟

(¹) ويتشكل مجلس إدارة الشركة المساهمة (العامة) قبل تحويلها إلى القطاع الخاص وفقاً للمادة (5) من قانون تحرير القطاع العام الفرنسي لسنة 1983 من ثلاث فئات من الأعضاء ممثلي الدولة، وممثلين عن العمال وأشخاص آخرين من ذوي الكفاءة والاختصاص ومن وقت نفاذ التحول ولحين عقد أول اجتماع للهيئة العامة للشركة بعد تحويلها يتولى إدارة الشركة رئيس مجلس الأشخاص من ذوي الكفاءة.

وللإجابة على هذا التساؤل، يلاحظ جانب من الفقه المصري⁽¹⁾، أن قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية لم يعالجا هذه المسألة، مما يشير إلى أن المشرع المصري قد ترك للمساهمين حرية اختيار النظام القانوني الذي تخضع له الشركة بعد خروجها من نطاق تطبيق قانون شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم يكون للجمعية العامة غير العادية أن تقرر الدخول في نطاق قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 على أن تستوفي المستلزمات وأن تتخذ الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون، أو أن تدخل في نطاق قانون الاستثمار للأمر الذي يوجب موافقة هيئة الاستثمار على ذلك بعد استيفاء جميع متطلبات هذا القانون. وعند عدم مراعاة هذه الإجراءات قد تفاجئ مصلحة الشركات وهيئة سوق رأس المال أو هيئة الاستثمار بشركات مساهمة كانت أصلا من شركات القطاع العام وأصبحت نتيجة بيع أسهمها للقطاع الخاص من شركات القانون رقم 159 لسنة 1981 أو من شركات القانون رقم 230 لسنة 1989، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، الأمر الذي ياباه المنطق القانوني السليم⁽²⁾.

وبالرغم مما تقدم يبقى التساؤل قائما عن ماهية الإجراءات التي يجب أن تتبعها الشركة التابعة لكي تتحول إلى شركات خاصة خاضعة لقانون الشركات أو قانون الاستثمار المصري، إذ أن قواعد التأسيس الواردة في هذه القوانين لا تصلح على إطلاقها للتطبيق على حالة تحويل الشركات التابعة إلى القطاع الخاص فقواعد التأسيس الواردة في هذه القوانين، وضعت للتطبيق على الشركات عند بداية تكوينها ولا تسري على حالة التحول إلى القطاع الخاص لأن الشركة التابعة لا تفقد شخصيتها المعنوية، بموجب هذا التحويل وإنما تظل محتفظة بشخصيتها بعد التحول⁽³⁾.

(1) د. محمود سالم، المرجع السابق، ص 55-56.

(2) د. محمود سالم، المرجع السابق، ص 56.

(3) د. حسام الدين عبد الغني الصغير، بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام للعاملين، المرجع السابق، ص 136.

وإزاء ذلك يرى جانب من الفقه المصري ضرورة تدخل المشرع المصري لتقرير الحلول المناسبة بشأن تحويل الشركة التابعة إلى شركات خاصة دون مراعاة لإجراءات التأسيس⁽¹⁾.

ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون الشركات العامة المصري رقم 97 لسنة 1983 كان يعد الشركة من قبيل الشركات العامة التي تخضع لأحكامه حتى وإن كان ما يملكه القطاع العام من رأس مالها يقل عن (51%)، فقد كانت هذه الشركات تعد من شركات القطاع العام لأسباب سياسية أو اجتماعية أو تاريخية وذلك وفقاً للمادة (3) من هذا القانون.

وهذه الشركات لم تدخل ضمن نطاق قانون شركات قطاع الأعمال العام، لأن المادة (16) من القانون المذكور تستلزم أن لا يقل ما يملكه القطاع العام عن (51%) من رأس مال الشركة التابعة، وهذا يعني أن هذه الشركات تفقد وصف الشركات العامة بمجرد تطبيق قانون شركات قطاع الأعمال العام، وتصبح من الشركات الخاصة⁽²⁾.

والحقيقة أن الآثار القانونية الناجمة عن تحويل الشركة المساهمة العامة إلى القطاع الخاص وفقاً للتشريعات المقارنة تشبه إلى حد كبير الآثار الناجمة عن تحويل الشركات المختلطة إلى شركات خاصة وفقاً للتشريع العراقي، إذا ما تمت عملية التحول عن طريق زيادة رأسمال الشركة المختلطة بأموال مقدمة من قبل القطاع الخاص⁽³⁾، فعملية تحول الشركة المختلطة على هذا النحو لا تستلزم انقضاء هذه الشركة وتأسيس شركة جديدة بل أن جل ما يترتب عليه من آثار هو فقدان هذه الشركة لوصفها كشركة مختلطة وما يستتبعه ذلك من آثار قانونية لعل أبرزها هو ضرورة إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الشركة المختلطة بعد تحويلها إلى شركة

(1) المرجع نفسه، نفس الصفحة.

(2) د. محمود سالم، المرجع السابق، ص 57.

(3) أما إذا تمت عملية تحول الشركة المختلطة إلى شركة خاصة عن طريق الدمج أو تحويل الشركة المحدودة المختلطة (تغير شكلها القانوني) إلى شركة مساهمة خاصة فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء الشركة المختلطة وتأسيس شركة جديدة.

خاصة ذلك أن تشكيل مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة يختلف عما هو مقرر بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة⁽¹⁾، إذ يترتب على هذا التحول، فقدان الأعضاء الثلاثة الممثلين للقطاع الاشتراكي لعضويتهم في المجلس.

وفي هذه الحالة نكون أمام فرضين الأول تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة محل الأعضاء الثلاثة الممثلين للقطاع الاشتراكي والذين انتهت عضويتهم في المجلس جراء التحول، إذ يحل الأعضاء الاحتياط الممثلون للقطاع الخاص والذين عينتهم الهيئة العامة محل الأعضاء الذين فقدوا عضويتهم جراء التحول. أما الفرض الثاني فيتمثل بالاكتفاء بالأعضاء الستة المتبقين وعدم تعيين أي عضو جديد في مجلس الإدارة لأن قانون الشركات حدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن (5) أعضاء ولا يزيد على (9). ولا يكون تعويض الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بأعضاء جدد لازماً، إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة إذا ما كانت الشركة المختلطة من شركات المصارف أو شركات الاستثمار المالي التي لا يجيز القانون تمثيل العاملين في مجلس إدارتها⁽²⁾،

(¹) تنص المادة (103) من قانون الشركات العراقي على انه ((أولاً. يتكون مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المختلطة من (9) أعضاء أصليين يتم اختيارهم كما يأتي: 1- ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الاشتراكي يعينون بقرار من الوزير المختص للقطاع الذي تنتمي إليه الشركة أو من دخوله. 2- أربعة أعضاء يمثلون المساهمين من غير القطاع الاشتراكي تنتخبهم الهيئة العامة للشركة. 3- عضوان يمثلان العاملين في الشركة يتم اختيارهما من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال من بين العاملين فيها. ثانياً. يكون لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة المختلطة (9) أعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للأعضاء الأصليين. وتنص المادة (104) من قانون الشركات العراقي على أنه ((أولاً. يتكون مجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة من أعضاء أصليين لا يقل عددهم عن خمسة، ولا يزيد على تسعة، يتم اختيارهم كما يأتي: 1- أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة تنتخبهم الهيئة العامة للشركة. 2- عضوان يمثلان العاملين في الشركة يتم اختيارهم من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال من بين العاملين فيها. ثانياً. يكون لمجلس الإدارة في الشركة المساهمة الخاصة أعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للأعضاء الأصليين. (²) المادة (105) من قانون الشركات العراقي.

إذا يؤدي انتهاء عضوية الأعضاء الممثلين للقطاع الاشتراكي في هذه الحالة إلى بقاء أربعة أعضاء فقط في مجلس إدارتها، الأمر الذي يوجب تعيين عضو واحد جديد على الأقل من الأعضاء الاحتياط، حتى يبلغ عدد أعضاء المجلس الحد الأدنى، أي خمسة أعضاء.

كذلك يؤدي تحويل الشركة المختلطة إلى شركة خاصة إلى ترتيب آثار قانونية أخرى إذا ينبغي للشركة المساهمة الخاصة الناجمة عن التحويل أن تعدل عقدها لتغير اسمها وحذف كلمة المختلطة من اسم الشركة⁽¹⁾، كما ويترتب على هذا التحويل إمكانية زيادة نسبة مساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي من غير القطاع الاشتراكي عن الحد الأعلى المقرر لنسبة مساهمته في الشركة المساهمة المختلطة وهي (10%) من رأس المال أو أقل من ذلك بحسب التحديد الذي تقره الجهة القطاعية المختصة، على أن لا تتجاوز نسبة مساهمة هذا الشخص في الشركة الناجمة عن التحويل عن (20%) من رأسمالها⁽²⁾، ويترتب أيضا على هذه التحويل عدم خضوع الشركة الناجمة عن التحويل لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفقا للمادة (133) من قانون الشركات العراقي، كذلك لا تخضع الشركة الناجمة عن التحويل لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 والذي كان تخضع له الشركة المختلطة قبل عملية التحويل.

المطلب الثالث تأسيس الشركة الناجمة عن التحويل

يستلزم تأسيس الشركة بوجه عام، توافر الشروط الموضوعية العامة للعقد، وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب والشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة والمتمثلة بتعدد الشركاء ومساهمة كل شريك في رأس المال والمساهمة في الأرباح والخسائر

(¹) تنص المادة (13/أولاً) من قانون الشركات العراقي على أن اسم الشركة يجب أن يكون مستمداً من نشاطها ويذكر فيه نوعها، مع إضافة كلمة مختلطة إن كانت مختلطة.

(²) المادة (32/أولاً) من قانون الشركات العراقي.

ونية الاشتراك فضلا عن الشروط الشكلية⁽¹⁾. وإذا كان توافر هذه الأركان غير متصور في ظل التشريعات المقارنة التي تقضي بإعادة هيكلة الشركات أو المشروعات العامة بتحويلها إلى شركات مساهمة تملك الدولة رأسمالها بالكامل، إذ أن قواعد تأسيس الشركات لا تنطبق على هذه العملية، على النحو الذي أشرنا إليه فإن تأسيس الشركة الناجمة عن التحول وفقا للقانون العراقي يخضع لأحكام خاصة تختلف في بعض جوانبها عن تلك التي تنظم إجراءات تأسيس الشركات بشكل عام، فالشركات الناجمة عن التحول تتأسس بموجب قرار التحول الصادر من مجلس الوزراء، من قبل الوزارة المعنية خلافا للشركات الأخرى التي تؤسس بموجب عقد بين عدد من الشركاء ومن ثم لا يتصور توافر الأركان الموضوعية العامة أو الخاصة لعقد الشركة عند تأسيس الشركة الناجمة عن التحول فهي شركة يؤسسها شخص واحد (الوزارة المعنية)، ويملك رأسمالها بالكامل الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأن هذه الشركة ما هي في حقيقة الأمر إلا شركة الشخص الواحد⁽²⁾. ومهما يكن من أمر، فإن البحث في تأسيس الشركة الناجمة عن التحول في ضوء أحكام التشريع العراقي، يقتضي منا أولا تحديد الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة الناجمة عن التحول، ومن ثم بيان مستلزمات وإجراءات تأسيس هذه الشركة وسنخصص لكل من هذه المواضع مقصدا مستقلا وذلك على النحو الآتي:

المقصد الأول: تحديد الشكل القانوني للشركة الناجمة عن التحول

يجب أن تتخذ الشركة الناجمة عن التحول شكل الشركة المساهمة وذلك وفقا للتحديد الذي جاءت به المادة (35) من قانون الشركات العامة العراقي والتي تنص على انه (يجوز تحول الشركة العامة إلى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء"، كما وحدد قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1995 شكل الشركة الناجمة عن التحول بالشركة المساهمة⁽³⁾. ونعتقد أن تحديد شكل الشركة الناجمة عن

(1) د. مرتضى ناصر نصر الله، الشركات التجارية، مطبعة الارشاد، بغداد، 1966، ص 9. كذلك د. احمد إبراهيم البسام، الشركات التجارية في القانون العراقي، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الثانية، 1961، ص 10.

(2) د. صهيب موسى جفال المومني، المرجع السابق، ص 14.

(3) ووفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (273) لسنة 1989 الملغي، يجب أن تتخذ الشركة الناجمة عن التحول شكل الشركة المساهمة حصراً " الفقرة أولاً من هذا القرار"، كذلك الحال بالنسبة لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (140) لسنة 1993 الملغي والذي حدد شكل الشركة الناجمة عن التحول بالشركة المساهمة وأطلق عليها تعبير الشركة المساهمة العامة الفقرة (1) من هذا القرار.

التحول بالشركة المساهمة من شأنه أن يحقق العديد من المزايا فالخصائص التي تتمتع بها هذه الشركة من حيث قدرتها على القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبيرة وتقسيم رأسمالها إلى أسهم والمسؤولية المحددة للمساهمين فيها⁽¹⁾. تجعل منها النموذج الأمثل للشركات الناجمة عن التحول، ذلك أن الشركات العامة تتولى في الغالب مشروعات اقتصادية كبيرة يصعب تحويلها إلى القطاع الخاص ما لم تتخذ هذه المشاريع شكل الشركة المساهمة بعد تحولها، كما أن الانخفاض النسبي لقيمة الأسهم يشكل حافزا لصغار المستثمرين، ليستثمروا أموالهم في الشركة الناجمة عن التحول.

وفضلا عما تقدم، يعد اتخاذ الشركة الناجمة عن التحول شكل الشركة المساهمة من الضمانات المهمة التي تكفل استمرار المشروع الإقتصادي الذي كانت تتولاه الشركة العامة قبل عملية التحول، إذ أن الشركة المساهمة تحمل بذاتها مقومات الاستمرار في الاستغلال الإقتصادي لهذا المشروع، إذ يصعب تصفيتها وانتهاء أعمال مشروعها بالقياس على حالة التحول التي تتم عن طريق بيع الأصول وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة.

وبالرغم مما تقدم يبقى التساؤل قائما حول طبيعة الشركة المساهمة الناجمة عن التحول وفيما إذا كانت خاصة أو مختلطة؟

وللإجابة عن هذا التساؤل نلاحظ أن قانون الشركات العامة العراقي لم ينص صراحة على ذلك، غير ان المادة (38) منه نصت على انه (تحدد مساهمة القطاع الاشتراكي في الشركة الجديدة وفق الأحكام القانونية النافذة). فدلالة هذا النص "هي جواز اتخاذ الشركة الناجمة عن التحول شكل الشركة المساهمة الخاصة أو المختلطة،

(1) د. محمد مختار احمد بري، قانون المعاملات التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987، ص 353-254.

وكل ما في الأمر هو ضرورة مراعاة النسبة التي يجب أن يملكها القطاع الاشتراكي في الشركة الناجمة عن التحويل إذا ما أريد لها أن تكون شركة مساهمة مختلطة، وهذه النسبة هي 25% كحد أدنى، وتستثنى من هذه النسبة شركات التأمين وإعادة التأمين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي وأية جهة استثمارية أخرى يقرر مجلس الوزراء استثناء مساهمتها في رأس مال الشركة من التقيد بهذه النسبة⁽¹⁾. أما بخصوص قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1995، فينص صراحة على إمكانية اتخاذ الشركة الناجمة عن التحويل شكل الشركة المساهمة الخاصة أو المختلطة⁽²⁾.

ويرى البعض⁽³⁾، أن احتفاظ الدولة بجزء من رأسمال الشركة الناجمة عن التحويل، يعد مصدرا لثقة المستثمرين بالدولة، من حيث أنها سوف لن تقرر سياسات جديدة بعد عملية التحويل يكون من شأنها إلحاق الضرر بمالكي أسهم الشركة الناجمة عن التحويل، مما يعني توفير سبل النجاح لبرامج التحويل إلى القطاع الخاص. ومع ذلك ينبغي للدولة، وفقا لهذا الرأي أن لا تشترك في إدارة الشركة المختلطة الناجمة عن التحويل⁽⁴⁾.

ونتفق مع الرأي السابق في أن اتخاذ الشركة الناجمة عن التحويل شكل الشركة المختلطة، يحقق العديد من المزايا ومنها ما أشار إليه هذا الرأي فضلا عن ميزة

(¹) د. لطيف جبر كومانى و د. علي كاظم الرفيعي، المرجع السابق، ص 333-334. في حين نص قرار مجلس قيادة الثورة رقم (40) لسنة 1993 (الملغي) صراحة، على احتفاظ الوزارة من خلال المنشأة العامة التي كانت يرتبط بها المعمل بنسبة (25%) من الأسهم، (الفقرة 1/أ) من هذا القرار.

(²) فقد نصت الفقرة (ثانيا 2) من هذا القرار والمتعلقة بتحديد نطاق سريانه على انه "المنشآت والشركات والمعامل التي يتقرر تحويلها إلى شركات مساهمة مختلطة أو خاصة، كذلك هو الحال بالنسبة لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (273) لسنة 1989 الملغي الفقرة (أولاً) منه.

(³) د. منير إبراهيم هندي، خصخصة المشروعات العامة، المرجع السابق، ص 46.

(⁴) ويبدو أن المشرع العراقي قد اخذ بهذا الرأي، حين قرر تحويل بعض المنشآت السياحية بموجب الأمر الصادر من السيد رئيس الجمهورية المبلغ بكتاب ديوان الرئاسة رقم (42999) في 1989/11/27، إلى شركات مختلطة على أن لا يشترك القطاع الاشتراكي في إدارتها.

أخرى مهمة تتمثل بأن الشركة المختلطة تكون خاضعة لرقابة وتوجيه القطاع الاشتراكي بما يضمن استمرار المشروع بعد تحويله إلى القطاع الخاص من ثم فأنا لا نتفق مع الرأي المتقدم، فيما يذهب إليه من القول بعدم اشتراك القطاع الاشتراكي في إدارة الشركة المختلطة الناجمة عن التحول، لذلك نقترح على المشرع العراقي أن ينص صراحة على أن تكون الشركة الناجمة عن التحول شركة مساهمة مختلطة.

المقصد الثاني: مستلزمات تأسيس الشركة الناجمة عن التحول

تبين لنا من خلال ما تقدم أن الشركة المساهمة الناجمة عن التحول يمكن أن تكون شركة مختلطة، كما ويمكن أن تكون شركة خاصة ومستلزمات تأسيس الشركة الناجمة عن التحول، تختلف عن تلك المستلزمات المقررة لبقية الشركات التي تؤسس ابتداءً وفقاً لأحكام قانون الشركات. إذ أن مستلزمات تأسيس الشركة الناجمة عن التحول تتمثل بموافقة مجلس الوزراء على عملية التحول بناءً على دراسة تعدها الوزارة المعنية تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية للتحول وأسلوب تقويم قيمة أسهم رأس المال وطريقة بيعها⁽¹⁾. كما وتتمثل هذه المستلزمات بقيام الوزارة المعنية بوصفها مؤسسا للشركة الناجمة عن التحول، بإعداد عقد لهذه الشركة. وعلى هذا الأساس تنص المادة (37 / أ) من قانون الشركات العامة العراقي على أنه "بعد موافقة مجلس الوزراء على التحول تقوم الوزارة بإعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء إلى المسجل". بيد أن الشركة الناجمة عن التحول، قد تكون -كما مر بنا- شركة مساهمة مختلطة أو خاصة، وفي هذه الحالة الأخيرة، إما أن يملك القطاع الاشتراكي أقل من (25%) من رأسمال الشركة أو أن لا يكون مساهماً فيها مطلقاً، ومع ذلك تضع الوزارة المعنية عقداً جديداً للشركة الناجمة عن التحول، وينتقد جانب من الفقه في العراق⁽²⁾. هذا

⁽¹⁾ المادة (36) شركات عامة عراقي.

⁽²⁾ د. لطيف جبر كومان، د. علي الرفيعي، المرجع السابق، ص 433.

الحكم ويرى فيه مصادرة على المطلوب، حيث تظل وصاية الوزارة على الشركة رغم تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة.

ونرى أن قيام الوزارة المعنية بتأسيس الشركة الناجمة عن التحول، أمر لا غنى عنه، حتى وإن لم تساهم الوزارة في رأسمال هذه الشركة فمن غير المتصور أن يتولى أشخاص من القطاع الخاص تأسيس الشركة الناجمة عن التحول، ذلك أن تأسيس هذه الشركة يخضع لإجراءات خاصة، فهي بالأساس شركة عامة يتم تحويلها وفقا لهذه الإجراءات إلى شركة مساهمة خاصة أو مختلطة، وحيث أن رأسمال الشركة العامة يكون مملوكا للوزارة المعنية بالكامل، فإنه يكون من غير المتصور أن يتولى شخص آخر غير الوزارة المعنية القيام بإجراءات التحول. ووفقا للمفهوم الواسع للمؤسس تعد هذه الوزارة هي المؤسس للشركة الناجمة عن التحول، وإن لم تساهم فيها، فوفقا لهذا المفهوم يعد مؤسسا للشركة، كل من وقع عقدها أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك اشتراكا فعلياً في تأسيس الشركة⁽¹⁾.

- وطبقا للمادة (13) من قانون الشركات العراقي، يجب أن يحتوي عقد الشركة على البيانات الآتية:
1. اسم الشركة المستمد من نشاطها، ويذكر فيه نوعها مع إضافة كلمة مختلطة، إن كانت مختلطة ويجوز إضافة أية تسمية مقبولة.
 2. هدف الشركة المؤكد لدورها في إثناء جانب من جوانب الاقتصاد الوطني وفق خطط التنمية.
 3. نشاط الشركة المستمد من هدفها، على أن يكون ضمن أحد القطاعات الإقتصادية أو أي من القطاعات الأخرى ذات العلاقة بنشاطها.
 4. المركز الرئيس للشركة على أن يكون في العراق.
 5. رأسمال الشركة وتقسيمه إلى أسهم.

(¹) انظر في مفهوم المؤسس، د. باسم محمد صالح و د. عدنان احمد ولي، المرجع السابق، ص175-176.

6. عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة، إذا كانت الشركة الناجمة عن التحول شركة مساهمة خاصة.

7. الوزارة التي تولت تأسيس الشركة وعدد الأسهم التي تملكها.

أما عن بقية مستلزمات تأسيس الشركة المساهمة والتي ينص عليها قانون الشركات العراقي فلا حاجة إلى توافرها لتأسيس الشركة الناجمة عن التحول، إذ لا يتصور قيام الوزارة بوصفها مؤسسا لهذه الشركة بالاكتتاب بالنسب التي حددها القانون للاكتتاب بها من قبل المؤسسين⁽¹⁾، وجل ما يشترط في هذه الحالة هو ان تحتفظ الوزارة بنسبة (25%) أو أكثر من رأسمال الشركة الناجمة عن التحول إذا ما كانت شركة مساهمة مختلطة، ذلك أن رأسمال الشركة الناجمة عن التحول يتكون أساسا من القيمة المقدرة لموجودات المشروع الذي كانت تديره الشركة العامة قبل التحول، وهل مملوك بالأساس للوزارة المعنية. فضلا عن ذلك، لا يتصور تشكيل لجنة المؤسسين وفقا للمادة (16/ثالثا) من قانون الشركات العراقي، لكي تتولى مهام التأسيس، إذ أن مؤسس الشركة الناجمة عن التحول هو الوزارة المعنية حصرا. وتأسيسا على ما تقدم يمكننا القول ان مستلزمات تأسيس الشركة الناجمة عن التحول تتمثل بقيام الوزارة بإعداد عقد لهذه الشركة فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على عملية التحول.

(1) تقضي المادة (39 / أولاً) من قانون الشركات العراقي بان يكتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (55%) بضمنها الحد الأدنى المقرر للقطاع الاشتراكي البالغ (25%)، كما وتقرر الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بان يكتب المؤسسون في الشركة المساهمة الخاصة بنسبة لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (51%) من رأسمالها الاسمي.

المقصد الثالث: إجراءات تأسيس الشركة الناجمة عن التحول

فصل قانون الشركات العراقي إجراءات تأسيس الشركة المساهمة وتبدأ هذه الإجراءات بقيام المؤسسين بتقديم طلب إلى مسجل الشركات، يرفق به عقد الشركة ووثيقة اكتتاب مؤسسي- الشركة موقعه منهم، كما ويرفق بهذا الطلب أيضا شهادة المصرف الذي يتولى إجراء عملية الاكتتاب بإيداع النسبة القانونية من راس المال، ويتولى المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة، ومفاتحة أية جهة أخرى أوجب قانون أو نظام أو تعليمات استحصال موافقتها على تأسيس الشركة، وفي حالة الموافقة يدعو المسجل مؤسسي- الشركة لتوثيق عقد الشركة أمامه أو أمام من يخوله من موظفي دائرته، ولدفع رسوم التأسيس، ويتولى المسجل نشر- قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة بالشركات وفي صحيفة يومية لمرة واحدة على الأقل، وتصدر شهادة تأسيس الشركة المساهمة بعد اكتتاب الجمهور بأسهمها وخلال خمسة عشر- يوما من تاريخ تقديم مؤسسيها المعلومات المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الشركات⁽¹⁾.

والعلة من تنظيم إجراءات التأسيس على النحو المتقدم، هي توثيق عقد الشركة وفرض رقابة سابقة على تأسيس الشركة، لحماية المكتتبين، والتأكد من مدى انسجام نشاط الشركة وأهدافها الاقتصادية مع خطط التنمية وللتأكد من مدى كفاية رأسمال الشركة للقيام بمشروعها الإقتصادي⁽²⁾.

ونعتقد أن تأسيس الشركة الناجمة عن التحول يكون في منأى عن الخضوع لمثل هذه الرقابة السابقة على التأسيس، ذلك ان التحقق من قدرة الشركة على تحقيق أهدافها الاقتصادية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاط الشركة يخضع بالأساس

(¹) نظم قانون الشركات العراقي، إجراءات التأسيس في المواد (17-25) ولمزيد من التفصيل، انظر: د. باسم محمد صالح و د. عدنان احمد ولي، المرجع السابق، ص126.

(²) تنص المادة (28/أولاً) من قانون الشركات العراقي على انه " لا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة عن (500.000) خمسمائة ألف دينار وعلى المسجل بناء على توصية الجهة القطاعية المختصة الطلب إلى المؤسسين أو الشركة زيادة رأسمالها بما يكفي لتحقيق نشاطها وفق متطلبات التطور الاقتصادي.

لموافقة مجلس الوزراء عند أجازته لعملية التحول، ومن ثم يكون من البديهي أن تقتصر إجراءات تأسيس الشركة الناجمة عن التحول على توثيق عقد الشركة لدى مسجل الشركات، ودون أن يكون للمسجل أو للجهة القطاعية المختصة أية سلطة في الموافقة أو الرفض بخصوص تأسيس الشركة الناجمة عن التحول: ومع ذلك نلاحظ، أن قانون الشركات العامة لم ينص صراحة على توثيق عقد الشركة الناجمة عن التحول لدى مسجل الشركات، غير أنه يمكن أن يستشف ذلك ضمناً من نص المادة (37 / ثانياً) من قانون الشركات العامة، إذ تنص على أنه "تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل، فنشر قرار التحول في النشرة الخاصة للشركات التي يصدرها المسجل يدل على أن المسجل يتولى توثيق عقد الشركة الناجمة عن التحول ثم نشره بعد ذلك في النشرة الخاصة بالشركات التي يصدرها. وتكتسب الشركة الناجمة عن التحول الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ آخر نشر لقرار التحول⁽¹⁾ وذلك خلافاً لما هو مقرر بشأن اكتساب الشركات لشخصيتها المعنوية، إذ أن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية وفقاً للمادة (22) من قانون الشركات العراقي من تاريخ صدور شهادة تأسيسها. ومما تجدر الإشارة إليه أن تأسيس الشركة الناجمة عن التحول على النحو المتقدم لا يعفيها من الالتزام بالتسجيل في السجل التجاري خلال (30) يوماً من تاريخ إنشائها على أن تقدم طلباً للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الآتية:

1. اسم الشركة.
2. تاريخ إنشائها.
3. نوع النشاط التجاري الذي تمارسه.
4. أسماء مؤسسيها ومديرها المفوض.
5. مركز إدارتها الرئيسي.

(¹) المادة (37/ ثالثاً) من قانون الشركات العامة العراقي.

وعلى الشركة تأشير أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال (30) يوماً من تاريخ التصرف القانوني أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم هذا التأشير⁽¹⁾.

(¹) المادتان (34، 35) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.

المبحث الثاني خلافة الشركة الناجمة عن التحويل للشركة العامة

تنقضي الشركة العامة جراء التحويل انقضاء مبسرا لا تعقبه عملية تصفية، ذلك أن الغاية من عملية التحويل هي دعم وتطوير المشاريع الإقتصادية التي تديرها الشركات العامة عن طريق تحويلها إلى القطاع الخاص، لكي تتولى إدارتها شركات مساهمة خاصة أو مختلطة.

لذلك لا بد من أن تنسجم الآثار القانونية المترتبة على عملية التحويل إلى القطاع الخاص، مع الأهداف الإقتصادية التي يراد تحقيقها من خلال هذه العملية، بحيث لا تؤدي عملية التحويل إلى إلحاق آثار سلبية بالمشاريع الإقتصادية التي كانت تديرها الشركات العامة قبل عملية التحويل، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إقرار المشرع لمبدأ انتقال المشروع الإقتصادي للشركة العامة الناجمة عن التحويل، فضلا عن انتقال ما يرتبط بهذا المشروع من حقوق والتزامات وعقود إلى الشركة الناجمة عن التحويل، وبما يكفل استمرار هذا المشروع وتطويره بعد عملية التحويل.

وعلى هذا الأساس لا بد أولا من بيان المقصود بالمشروع الإقتصادي ومدى اعتداد المشرع به، ثم بيان الأساس القانوني لخلافة الشركة الناجمة عن التحويل للشركة العامة، وأخيرا بيان الأحكام الخاصة بهذه الخلافة فيما يتعلق بالعقود التي سبق وان أبرمتها الشركة العامة قبل عملية التحويل. وسنخصص لكل من هذه المواضيع مطلباً مستقلاً وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: المقصود بالمشروع الإقتصادي ومدى اعتداد المشرع به.

المطلب الثاني: الأساس القانوني لخلافة الشركة الناجمة عن التحويل للشركة العامة.

المطلب الثالث: انتقال عقود الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحويل.

المطلب الأول المقصود بالمشروع الإقتصادي ومدى اعتداد المشرع به

يعرف المشروع الإقتصادي بأنه "الوحدة الإقتصادية للإنتاج التي تقوم على مجموعة من العناصر المادية والبشرية التي تتفاعل معا من اجل تحقيق غرض معين يسعى مالِك المشرع إلى تحقيقه⁽¹⁾. فالمشروع الإقتصادي بهذا الوصف يعد تنظيما يستمر لمدة من الزمن، ويقوم بعدة عمليات تهدف إلى تحقيق غرض واحد، وهو إنتاج سلعة أو خدمة، ويتسم بالاستقلال الإداري دون الاستقلال القانوني⁽²⁾. إذ لا يتمتع المشروع الاقتصادي بالشخصية القانونية. وتشمل العناصر المادية للمشروع الأموال المادية والمعنوية كال بضائع وحقوق الملكية الصناعية كالعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها، أما العناصر البشرية فتتمثل بمديري المشروع ومستخدميه⁽³⁾. ومن ثم يعد التنظيم والاحتراف من أهم خصائص المشروع الإقتصادي⁽⁴⁾. وينبغي عدم الخلط بين المشروع الإقتصادي والمحل التجاري فبالرغم من قيام كل منهما على مجموعة من العناصر التي تشكل في مجموعها وحدة واحدة، وعدم تمتعها بالشخصية القانونية فانهما يختلفان من حيث العناصر المكونة لكل منهما، إذ يتألف المحل التجاري من مجموعة من العناصر المادية كال بضائع والعناصر المعنوية

(¹) د. علي حسن يونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، ص55.
(²) د. عبد الوهاب مطر الداهري، تقييم المشاريع ودراسة الجدوى الاقتصادية، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1990، ص32.
(³) د. علي حسن يونس، المرجع السابق، ص56.
(⁴) د. باسم محمد صالح، القانون التجاري -القسم الأول، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، ط2، 1992، ص36.

كالاسم التجاري والسمعة التجارية واتصال بالزبائن وغير ذلك⁽¹⁾، أما المشروع الإقتصادي فيشمل العناصر المشار إليها فضلا عن العقارات التي يشغلها والحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاطه، كما ويشمل مديري المشروع ومستخدميه⁽²⁾.

ومع ذلك ينبغي عدم إغفال حقيقة، ان المحل التجاري يعد الوجه القانوني للمشروع وهو الذي يقرر له الحق في التعامل مع فئات خاصة من الزبائن⁽³⁾.

كما وينبغي عدم إغفال اوجه الارتباط بين الشركة والمشروع الإقتصادي، إذ أن الشركة تقوم بالضرورة على استغلال مشروع اقتصادي. وقد اقر المشرع العراقي بهذا الارتباط بين الشركة والمشروع الإقتصادي. فالشركة كما تعرفها المادة (4/أولا) من قانون الشركات العراقي هي "عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في (مشروع اقتصادي) بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة". كذلك تضمن قانون الشركات العراقي العديد من الأحكام التي تبين اعتداد المشرع العراقي بفكرة المشروع الإقتصادي كوحدة اقتصادية منتجة، كما وتبين مدى حرصه على دعم استمرار هذه المشاريع وتطويرها، والحيلولة دون توقف النشاط الإقتصادي لهذه المشاريع، فالمادة (10/أولا) من قانون الشركات العراقي تلزم أن يأخذ كل مشروع اقتصادي من غير مشروعات القطاع الاشتراكي، والمسجل في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو المقاولات، ويبلغ رأسماله عشرة ملايين دينار فاكثر شكل شركة مساهمة أو محدودة أو تضامنية أو مشروع فردي خلال مدة تسعين يوما من تاريخ بلوغ رأسماله ذلك الحد.

كما وتنص المادة (161) من قانون الشركات العراقي على انه "إذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على التصفية، وكان المشروع الذي تديره الشركة الموصى بتصفيتهما واجب الاستمرار لأهميته الإقتصادية ضمن خطة التنمية والقرارات

(¹) قرار محكمة النقض المصرية رقم 495 سنة 46 ق جلسة 1975/11/19 س26، د. احمد حسني، المرجع السابق، ص344.

(²) د. حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، مطبعة حسان، القاهرة، الطبعة الأولى، 1986، ص135.

(³) د. حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص135.

التخطيطية، وجب عليها أن تحدد الإجراءات اللازمة لضمان استمرار المشروع سواء بتحويله إلى جهة أخرى أو دمج مشروع آخر أو أي إجراء مناسب آخر".

وبقدر تعلق الأمر بموضوعنا نلاحظ أن المشرع العراقي قد اعتد بفكرة المشروع الإقتصادي عندما قرر أن انقضاء الشركة العامة جراء تحولها تعقبه عملية تصفية وهذا يعني بقاء المشروع الإقتصادي للشركة العامة بالرغم من انقضاءها وانتقاله إلى الشركة الناجمة عن التحول بما يضمن دعمه واستمراره كوحدة اقتصادية منتجة، وقضت المادة (29/أولا) من قانون الشركات العامة على حالة واحدة فقط، يمكن عند تحققها إخضاع الشركة العامة للتصفية، وهي حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بتصفية الشركة إذا ما بلغت نسبة خسائرها (50%) من رأسمالها وعلى النحو الذي فصلناه فيما تقدم.

وانتقال المشروع الإقتصادي من الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول هو الذي يفسر- لنا كيفية انقضاء الشركة العامة جراء التحول بدون تصفية، كما ويفسر لنا انتقال حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول، ذلك أن المشروع الإقتصادي يشتمل على عناصر مادية تتمثل بالعقارات التي يشغلها المشروع والحقوق والتزامات وكذلك العقود المرتبطة بنشاطه، وحقوق الملكية الصناعية كالعلامات التجارية وغيرها، كما ويشتمل المشروع الإقتصادي على العناصر البشرية المتمثلة بالمدرء والعاملين في هذا المشروع. ومع ذلك لا يتصور انتقال العناصر البشرية للمشروع الإقتصادي من الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول، طالما ان العاملين في الشركات العامة يعدون من الموظفين ويخضعون للنظام القانوني الذي ينظم قواعد العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي⁽¹⁾. في حين أن العاملين في الشركات الناجمة عن

(¹) يخضع الموظفون لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991.

التحول يخضعون لقواعد قانون العمل⁽¹⁾. وهذا يعني أن انتقال المشروع الإقتصادي من الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول، يقتصر على العناصر المادية للمشروع دون العناصر البشرية له. الأمر الذي قد يشكل عقبة كبيرة أمام عملية تحول الشركات العامة، لأن نقل المشروع من الشركات العامة إلى الشركات الخاصة أو المختلطة، دون العاملين فيه قد يؤثر سلباً في نشاط المشروع، لا سيما إذا كان العمل في المشروع يقتضي توافر خبرات أو مهارات فنية خاصة، لا تتوافر في غير العاملين السابقين في هذا المشروع، كما أن هذا الأمر يستلزم من الدولة إيجاد فرص عمل بديلة لمنتسبي الشركة العامة بعد تحويلها إلى القطاع الخاص.

ومن أجل تفادي هذه العقبات يحبذ تطبيق قواعد العمل في القطاع الخاص على منتسبي الشركات العامة الأمر الذي يسمح بانتقالهم تبعاً للمشروع إلى الشركة الناجمة عن التحول⁽²⁾. ومما تجدر الإشارة إليه، أن فكرة استمرار المشروع الإقتصادي للشركة بالرغم من انقضاءها هي التي أدت إلى جعل عملية دمج الشركات من الأساليب المتبعة في عملية التحول إلى القطاع الخاص. إذ أن عملية الدمج تقتضي انقضاء الشخصية المعنوية للشركات المندمجة، ودون أن يعقب هذا الانقضاء عملية تصفية، إذ تنتقل المشاريع التي كانت تديرها الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة، أو إلى الشركة الناجمة عن الدمج، بحسب ما إذا كان الدمج قد تم بطريق الضم أو بطريق المزج. والسبب في ذلك يكمن في أن الغاية من دمج الشركات بشكل عام هي تحقيق التركيز الإقتصادي فيما يتعلق بالمشاريع التي تديرها الشركات الداخلة في عملية الدمج⁽³⁾.

(¹) يخضع العاملون في الشركات المساهمة الخاصة أو المختلطة لقانون العمل العراقي رقم (71) لسنة 1987.

(²) ولعل من المناسب أن نذكر في هذا المجال، أن الحكومة المصرية قد أنشأت الصندوق الاجتماعي للتنمية بقصد معالجة المشكلات الناجمة عن العمالة الزائدة جراء عمليات التحول إلى القطاع الخاص، وقد وضع هذا الصندوق برنامجاً يسمى برنامج (التنقلية) لمعالجة هذه المشكلات ويتضمن هذا البرنامج ستة أساليب لعلاج هذه المشكلة وهي التقاعد، والتقاعد المبكر، والتدريب وإعادة التدريب، وتعويضات البطالة، وإيجاد فرص بديلة، وإنشاء مشروعات خاصة صغيرة. د. أحمد ماهر، المرجع السابق، ص 302 وما بعدها.

(³) لمزيد من التفصيل، انظر د. حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص 127 وما بعدها.

وعلى هذا الأساس تقرر العديد من التشريعات ومنها التشريع الفرنسي- والمصري والعراقي⁽¹⁾ بمبدأ انتقال كافة حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة.

المطلب الثاني

الأساس القانوني لخلافة الشركة الناجمة عن التحول للشركة العامة

لا تثير مسألة انتقال حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول وفقاً للتشريعات المقارنة أية صعوبة، فقد قررت هذه التشريعات انتقال حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة المساهمة التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، وذلك عند إعادة هيكلة الشركات أو المشروعات العامة، قبل تحويلها إلى القطاع الخاص.

فلقد قرر كل من المشرع الفرنسي والمصري والأردني هذا الحكم صراحة، فوفقاً للتشريع الفرنسي، تنتقل حقوق والتزامات المشروعات العامة عند إعادة هيكلتها إلى الشركة المساهمة الناجمة عن هذه العملية، ومن الأمثلة على ذلك، ما نص عليه القانون الفرنسي الصادر في 1996/7/26، والقاضي بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات الفرنسية France Telecom إلى شركة مساهمة تملك الدولة أسهمها بالكامل، إذا انتقلت الذمة المالية للمنشأة العامة المذكور بحقوقها والتزاماتها الشركة المساهمة الناجمة عن التحول على نحو تعد فيه هذه الأخيرة خلفاً عاماً للمنشأة العامة⁽²⁾.

⁽¹⁾ انظر: الفقرة الأولى من المادة (371) من قانون الشركات التجارية الفرنسي، والمادة (132) من قانون الشركات المصري، والمادة (152) من قانون الشركات العراقي.

⁽²⁾ ومن الأمثلة على ذلك أيضاً، تحويل المنشأة العامة للتبوغ والكبريت الفرنسية، إلى شركة مساهمة تسمى شركة SETTA، بموجب القوانين الصادرة في 1980/7/2 و 1984/7/23 وكذلك تحويل منشأة رينو Renault إلى شركة مساهمة بالقانون الصادر في 1990/7/4 وانظر: Jean-philippe , op. Cit , p. 287.

كذلك نص المشرع المصري في المادة الثانية من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على انه "وتنتقل إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بحسب الأحوال، كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار، كما وتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسؤولية كاملة عنها"، وقد أكد جانب من الفقه المصري⁽¹⁾ على أن هذا الانتقال يستلزم أن تكون الشركات القابضة خلفا عاما للهيئات العامة المنقضية بصور قانون شركات قطاع الأعمال العام في حين أن حلول الشركة التابعة محل الشركات العامة المنقضية، لا يستلزم تطبيق أحكام الخلافة العامة بشأنه، لأن التحول في هذه الحالة لا يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة العامة فشخصية الشركة التابعة ليست شخصية مبتدئة بل هي استمرار لشخصية شركة القطاع العام.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية على تطبيق أحكام الخلافة العامة، على حالة انتقال حقوق والتزامات الهيئات العامة إلى الشركات القابضة فقد جاء في قرار لها "ان النص في المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر وتنتقل إلى الشركات القابضة.. كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق.. كما تتحمل جميع التزاماتها" يدل على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها"⁽²⁾.

أما المشرع الأردني فقد نص صراحة على تطبيق أحكام الخلافة العامة في هذه الحالة فقد نصت المادة (8و) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 على انه ".

(¹) د. حسام الدين عبد الغني الصغير، بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام للعاملين، المرجع السابق، ص 41.

(²) الطعن رقم 5445 لسنة 61 ق-جلسة 1992/6/25، حسن الفكهاني، المرجع السابق، ص 383.

تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفا عاما للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات".

وإذا كانت خلافة الشركة الناجمة عن التحول للشركة العامة خلافة عامة تبدو واضحة استناداً إلى النصوص الصريحة التي أقرتها التشريعات المقارنة على النحو السالف الذكر، فإن الأمر ليس بهذا القدر من الوضوح في التشريع العراقي، إذ نلاحظ سكوت قانون الشركات العامة العراقي وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1995 عن معالجة هذا الموضوع صراحة. إذ لم يشر-ع العراقي فيهما إلى انتقال حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول. غير أنه ومما لاشك فيه أن عملية تحول الشركات العامة يستلزم انتقال كافة حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول⁽¹⁾ طبقاً لما سبق وان ذكرناه بشأن استمرار المشروع الإقتصادي للشركة العامة رغم انقضاءها وانتقاله إلى الشركة الناجمة عن التحول، بما يضمن تحقيق أهداف عملية التحول إلى القطاع الخاص.

فضلاً عما تنص عليه الفقرة (ثالثاً/2/أ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم(100) لسنة 1995 من انه "يتم تقدير قيمة موجوداتها وفق الأسعار السائدة مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوقها والتزاماتها وتعتبر القيمة المقدرة رأسمال للشركة المساهمة الذي يقسم إلى أسهم قيمة السهم دينار واحد".

ونعتقد أن هذا النص، يشير إلى أن حقوق والتزامات المنشآت والشركات التي يتم تحويلها إلى شركات مساهمة خاصة أو مختلطة وفقاً لأحكام هذا القرار، تنتقل إلى الشركات الناجمة عن التحول، إذ أن مراعاة هذه الحقوق والالتزامات في عملية التقدير لغرض التوصل إلى مقدار رأسمال الشركة الناجمة عن التحول، يدل على أن هذه الحقوق والالتزامات تنتقل إلى الشركة الناجمة عن التحول، وإلا فلا داعي لمراعاتها في عملية التقدير طالما أنها لن تنتقل إلى الشركة الناجمة عن التحول ولن تؤثر في رأسمالها.

(¹) من هذا الرأي، د. لطيف جبر كومانى و د. علي كاظم الرفيعي، المرجع السابق، ص433.

وبالرغم مما تقدم، يبقى التساؤل في ظل التشريع العراقي قائما حول الطبيعة القانونية لانتقال حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول ؟

وللإجابة عن هذا التساؤل يمكننا الاستعانة بما أورده الفقهاء من آراء بشأن انتقال حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناجمة عن الدمج في حالة اندماج الشركات، وذلك استنادا إلى أن كلا من اندماج الشركات وتحول الشركات العامة يعدان سببا لانقضاء الشركات دون تصفيتها، فضلا عن أن دمج الشركات العامة بأخرى خاصة أو مختلطة، يعد بالأساس من أساليب تحويل الشركات العامة إلى القطاع الخاص.

وعلى هذا الأساس ذهب جانب من الفقه⁽¹⁾ إلى القول بأن خلافة الشركات تستند إلى فكرة الحوالة، والأخذ بمنطق هذا الرأي يؤدي إلى اعتبار انتقال حقوق والتزامات الشركات العامة إلى الشركات الناجمة عن التحول مستندا إلى فكرة حوالة الحق وحوالة الدين.

وتعرف حوالة الحق بأنها عقد بمقتضاه ينقل شخص هو الدائن في الالتزام ويسمى المحيل حقه إلى شخص آخر هو الدائن الجديد بهذا الالتزام ويسمى المحال له، قبل شخص ثالث هو المدين في هذا الالتزام ويسمى المحال عليه⁽²⁾.

بمعنى أن الشركة العامة ستكون في هذه الحالة بمثابة المحيل والشركة الناجمة عن التحول تكون بمثابة المحال له، ويكون الغير-مدين الشركة العامة هو المحال عليه.

(¹) د. علي العريف، شرح القانون التجاري المصري، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1995، ص 273، كذلك د. فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام، عالم الكتب، القاهرة، 1973، ص 152، د. علي حسين يونس، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1963، ص 150.

(²) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص 442.

ولا تعد حوالة الحق نافذة في حق المحال عليه، إلا إذا قبلها أو أعلنت له، ولا تنفذ في حق الغير بقبول المحال عليه إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ⁽¹⁾.

أما حوالة الدين، فيقصد بها نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (المادة 1/339) مدني عراقي، أي أن الشركة العامة تتفق مع الشركة الناجمة عن التحول، لكي تتحمل هذه الأخيرة ديون الشركة العامة فتحل محلها في هذا الدين نفسه بجميع مقوماته.

ونعتقد انه لا يمكن الأخذ بفكرة الحوالة لتسويغ انتقال حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عند التحول وسواء كانت حوالة حق أم حوالة دين إذ أن الحوالة ما هي إلا عقد يستلزم وجود طرفين على الأقل وقت الحوالة وهما المحيل والمحال عليه في حوالة الدين، والمحيل والمحال له في حوالة الحق وهذا ما لا يمكن تصوره بالنسبة إلى حوالة الحق، إذ أن تحول الشركات العامة يقتضي أن لا تنشئ الشركة الناجمة عن التحول إلا بعد انقضاء الشركة العامة، ومن ثم لا يتصور الاتفاق بين الشركة العامة والشركة الناجمة عن التحول على حوالة الحق وإن كان من المتصور انعقاد حوالة الدين باتفاق الدائن والمحال عليه، أي دائن الشركة العامة والشركة الناجمة عن التحول⁽²⁾.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار انتقال ديون الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول من قبيل حوالة الدين لأن ذلك يتعارض مع نص المادة (340) من القانون المدني العراقي، والتي تشترط موافقة الدائن على الحوالة، ليس من أجل نفاذ الحوالة بحقه فحسب، كما هو عليه الحال في القانون المصري، بل لكي ترتب الحوالة آثارها بين طرفيها، بحيث إذا لم يقرها الدائن بطل الاتفاق واعتبر كأن لم يكن حتى فيما بين

(¹) المادة (363) من القانون المدني العراقي.

(²) فوفقاً للمادة (341) من القانون المدني العراقي، يصبح عقد حوالة الدين بين الدائن والمحال عليه ويلتزم المحال عليه بالأداء، ولكن ليس له الرجوع على المدين الأصلي، إلا إذا أقر هذا الأخير الحوالة.

طرفيه⁽¹⁾ بمعنى ان تحول الشركة العامة لا يرتب أي أثر حتى بالنسبة إلى الشركة العامة نفسها، ما لم يقره دائنوها، إذ ان الأمر لا يقتصر- على مجرد نفاذ الحوالة بحق دائني الشركة العامة، بل انه يتعلق بانعقادها، لذلك لا يمكن الأخذ بهذا الرأي وفقاً للتشريع العراقي.

وعلى هذا الأساس نعتقد أن انتقال حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول إنما يستند إلى فكرة الخلافة العامة على النحو الذي قرره التشريعات المقارنة بحيث تعد الشركة الناجمة عن التحول خلفاً عاماً للشركة العامة التي تنقضي جراء التحول.

والخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها⁽²⁾، والقاعدة العامة في التشريع العراقي هي انصراف أثر العقد إلى الخلف العام، مع ضرورة مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث وطبيعة العقد أو التعامل ونص القانون⁽³⁾. وحيث أن الشركة الناجمة عن التحول تعد بمثابة خلف عام للشركة العامة، فهذا يعني أن نطاق مسؤولية الشركة الناجمة عن التحول عن ديون الشركة العامة، يتحدد بالقواعد التي تحدد مسؤولية الخلف العام عن ديون سلفه، وهذا ما ينسجم مع أحكام الخلافة العامة في القانون الفرنسي، الذي تعد فيه شخصية الخلف امتداداً لشخصية السلف، فيكتسب جميع حقوقه ويلتزم بجميع التزاماته وان تجاوزت مقدار الحقوق التي تلقاها من سلفه⁽⁴⁾، ويصعب تصور مثل هذه النتيجة عند تطبيق أحكام

⁽¹⁾ المادة (340) من القانون المدني العراقي، وانظر: د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني - الجزء الثاني- أحكام الالتزام، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1980، ص 225.

⁽²⁾ د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني - أصول الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1970، ص 153.

⁽³⁾ وقد نصت المادة (1/142) من القانون المدني العراقي على ذلك إذ جاء فيها ((ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام)).

⁽⁴⁾ د. عبد المجيد الحكيم، المرجع السابق، ص 319.

الخلافة العامة في التشريعات المتأثرة بالشرعية الإسلامية، كالتشريع العراقي والمصري، فوفقاً لهذه التشريعات لا تعد شخصية الخلف امتداداً لشخصية السلف، إذ يتلقى الخلف العام جميع حقوق سلفه دون أن يلتزم بالتزاماته، غير أنه لا يتلقى هذه الحقوق إلا بعد سداد الديون، حيث أن المادة المشار إليها تقرر انصراف آثار العقود إلى الخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. غير أن هذا لا يعني أن الشركة الناجمة عن التحول لا تكون مسؤولة عن ديون الشركة العامة إلا بمقدار ما تلقت من حقوق تلك الشركة، كما أن هذا لا يعني أيضاً حلول آجال جميع الديون الخاصة بالشركة العامة بمجرد تحولها، كما تقتضي بذلك قواعد الخلافة العامة المتعلقة بالميراث، ذلك إن خلافة الشركات تختلف عن الخلافة العامة المقررة في القواعد العامة، إذ أنها تقتضي انتقال الحقوق والالتزامات كافة من الشركة السلف إلى الشركة الخلف، ودون أن يراعى في هذا الانتقال القواعد الخاصة بالميراث المتعلقة بوفاة الشخص الطبيعي.

وقد قرر كل من المشرع المصري والأردني ذلك صراحة على النحو الذي أشرنا إليه فيما تقدم. ومن ثم تعد هذه النصوص الخاصة بخلافة الشركات قيدياً على أحكام الخلافة العامة، باعتبار أن الخاص يقيد العام^(١). ووفقاً للقانون العراقي، فنرى أنه لا مانع من التسليم بأن خلافة الشركة الناجمة عن التحول للشركة العامة تختلف عن أحكام الخلافة العامة المقررة في القانون المدني، رغم عدم تصريح المشرع العراقي بذلك، حيث أنه لا محل لتطبيق القواعد المتعلقة بالميراث في حالة خلافة الشركات، لأن هذه القواعد تتعلق بالأساس بوفاة الشخص الطبيعي، ومن ثم يكون من الممكن أن تنتقل كافة حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول، بحيث تعد هذه الأخيرة خلفاً عاماً للشركة العامة ودون أن يراعى في أحكام هذه الخلافة القواعد المتعلقة بالميراث.

(١) وقد سبقت الإشارة إلى أن كلاً من المشرع الفرنسي والعراقي والمصري يقرون بانتقال كافة التزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة بنصوص صريحة.

ولكل ما تقدم، ندعو المشرع العراقي إلى النص صراحة على انتقال كافة حقوق والتزامات الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول، فهذا الانتقال يعد ضرورة لا غنى عنها في عملية التحول، وبخلافه لا يمكن أن تتحقق الأهداف المتوخاة من عملية التحول، بوصفه أداة لتحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص، من أجل دعمها وتطويرها.

بقي أن نذكر، أن اعتبار الشركة الناجمة عن التحول خلفاً عاماً للشركة العامة، لا يتعارض مع قيام الشركة العامة بسداد جميع ديونها قبل عملية التحول، إذ تتلقى في هذه الحالة الشركة الناجمة عن التحول أصول الشركة العامة الصافية، دون الالتزامات التي تم الوفاء بها قبل عملية التحول. بيد أنه من غير المتصور أن تحتفظ الشركة العامة ببعض أصولها للوفاء ببعض خصومها، وأن تنتقل بقية الأصول والخصوم إلى الشركة الناجمة عن التحول، إذ إن هذا التصور يقتضي احتفاظ الشركة العامة بشخصيتها المعنوية بعد التحول وبالقدر اللازم لسداد هذه الديون، وهو ما يتعارض مع ما قرره المشرع العراقي صراحة، من أن التحول يؤدي إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة العامة على النحو الذي أشرنا إليه فيما تقدم.

المطلب الثالث

انتقال عقود الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول

تلجأ الشركة العامة عند ممارستها لنشاطها إلى إبرام بعض العقود وفقاً لمتطلبات هذا النشاط، والأصل أن تنتقل جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبها العقود المبرمة من قبل الشركة العامة قبل عملية التحول إلى الشركة الناجمة عن التحول، ومن هذه العقود، عقد الإيجار، وعقد الترخيص التجاري، وعقد التأمين وعقد التوريد وغيرها من العقود الأخرى. غير أن انتقال الآثار المترتبة على عقود الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول، قد يثير بعض المشكلات القانونية المتعلقة بعملية التحول إلى القطاع الخاص، ويظهر ذلك بشكل كبير عند انتقال الحقوق والالتزامات

المرتبة على عقد الإيجار وعقد الترخيص التجاري، التي سبق وأن أبرمتها الشركة العامة، إلى الشركة الناجمة عن التحول.

لذلك، ستقصر دراستنا في هذا المطلب على هذين العقدين وسنخصص كل منها مقصدا مستقلا وكما يأتي:

المقصد الأول: أثر التحول إلى القطاع الخاص في عقد الإيجار.

المقصد الثاني: أثر التحول إلى القطاع الخاص في عقد الترخيص التجاري.

المقصد الأول: أثر التحول إلى القطاع الخاص في عقد الإيجار

تعرف المادة (722) من القانون المدني العراقي عقد الإيجار بأنه ((تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور)).

ولما كانت عملية التحول إلى القطاع الخاص تؤدي إلى انقضاء الشركة العامة، وانتقال حقوقها والتزاماتها إلى الشركة المساهمة الخاصة أو المختلطة الناجمة عن التحول. فأن التساؤل يثار عما إذا كانت الحقوق والالتزامات التي تنتقل من الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول، تتضمن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار التي سبق وأن أبرمتها الشركة العامة قبل تحويلها، وعما إذا كانت هذه العملية تعد من قبيل تنازل⁽¹⁾ الشركة العامة عن عقد الإيجار لمصلحة الشركة الناجمة عن التحول ؟

وللإجابة عن هذا التساؤل، نلاحظ ان المشرع المصري قد حسم هذا الموضوع صراحة في المادة الثانية من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، التي قررت حلول الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام وحلول الشركات التابعة محل

(1) التنازل عن الإيجار يختلف عن الإيجار من الباطن، على أساس انه في حالة التنازل عن الإيجار لا يوجد إلا عقد إيجار واحد، وهو العقد الأصلي بين المؤجر والمستأجر، أما في الإيجار من الباطن فيوجد عقد إيجار أصلي ما بين المؤجر والمستأجر، ثم عقد إيجار من الباطن ما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. انظر أستاذنا د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية - البيع - الإيجار - المقاول، مطابع التعليم العالي، الموصل، 1989، ص 287.

الشركات العامة التي كانت تشرف عليها هذه الهيئات فقد ورد في هذه المادة انه ((وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال، كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار (...)).

فوفقاً لهذا النص، لم يعد هناك أدنى شك في أن تحويل الهيئات العامة والشركات التابعة لها إلى شركات قابضة وأخرى تابعة لها يستلزم انتقال الحقوق والالتزامات المترتبة على عقود الإيجار من الهيئات العامة والشركات التابعة لها إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة بحسب الأحوال.

وإذا كان الأمر بهذا القدر من الوضوح في القانون المصري، فإنه ليس كذلك في قوانين أخرى كالقانون الأردني والقانون العراقي.

وعلى هذا الأساس يذهب رأي في القانون الأردني⁽¹⁾ إلى انه يمكن قياس حالة تحول المؤسسات أو الهيئات العامة إلى شركات مساهمة على حالة الاندماج، فيما يتعلق بتحديد آثار الخلافة العامة فيما بين الشركات.

لذلك يستعين أصحاب هذا الرأي بقرار لمحكمة التمييز الأردنية بتعلق بحالة اندماج الشركة المستأجرة للعقار بشركة أخرى، وقد جاء في هذا القرار أنه ((يترتب على اندماج الشركة المستأجرة للعقار بشركة أخرى زوال شخصيتها الاعتبارية، وتعتبر الشركة الدامجة شخصية مختلفة عن شخصية الشركة المندمجة، ويعتبر استمرار أشغالها للمأجور دون موافقة المالك الخطية موجبا للإخلاء عملاً بالمادة (3/5) من قانون المالكين والمستأجرين باعتبارها من الغير وليس طرفاً في عقد الإيجار، ولا يغير من ذلك أن جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة تؤوّل إلى الشركة الدامجة بحدود عقد الاندماج باعتبارها خلفاً قانونياً لها عملاً بالمادة (268) من قانون الشركات الأردني، إذ أن ذلك ينصرف إلى الأمور المالية، وليس في قانون الشركات رقم 89/1 ما يعالج حالة العقارات المستأجرة، فيكون الحكم بإخلاء المأجور يتفق مع أحكام القانون))⁽²⁾.

(¹) صهيبي موسى جفال المومني، المرجع السابق، ص 50.

(²) قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 94/944، المرجع نفسه، ص 50.

وبالرغم من انتقاد أصحاب هذا الرأي لهذا القرار القضائي من حيث الأسباب التي بني عليها في عدم اعتباره حق الإيجار من الحقوق المالية، فإنه يتفق معه في النتيجة من حيث اعتبار انقضاء الهيئة أو المنشأة العامة وانتقال كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركة المساهمة الناجمة عن التحول بالقياس على حالة الاندماج التي يشير إليها قرار محكمة التمييز الأردنية المشار إليه سبباً لتخلية العقار المأجور، على أساس نص المادة (8) من قانون الشركات الأردني المتعلقة بالخلافة العامة، هو نص عام تقيده المادة (5/3) من قانون المالكين والمستأجرين الأردني، بوصفه قانوناً خاصاً يطبق على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد اعتبرت محكمة التمييز الأردنية في قرارها المرقم 1995/998 يد الشركة الناجمة عن الاندماج، بحكم اليد الغاصبة للعقار باعتبار أن شخصية الشركة المندمجة والتي كانت تشغل العقار قد انتهت بتمام عملية الاندماج وانتهى تبعاً لذلك عقد الإيجار⁽¹⁾.

وبقدر تعلق الأمر بالتشريع العراقي نرى ان لا يمكن اعتبار انقضاء الشركة العامة جراً التحول، وانتقال عقود الإيجار التي سبق وان أبرمتها إلى الشركة الناجمة عن التحول بمثابة تنازل عن عقد الإيجار، ذلك أن الشركة الناجمة عن التحول تعد خلفاً عاماً للشركة العامة، وتتلقى كافة حقوقها والتزاماتها، ومن ضمنها الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، فمن المعروف أن عقد الإيجار ينتقل من السلف إلى الخلف العام وان موت المستأجر لا يؤدي إلى انتهاء عقد الإيجار⁽²⁾.

والحقيقة، لا تثير هذه المسألة في الوقت الحاضر مشكلة في التشريعات العراقية. ذلك انه حتى لو صح تكييف انتقال الآثار المترتبة على عقود الإيجار التي أبرمتها الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول على أساس أنها تعد بمثابة تنازل من الشركة العامة عن عقد الإيجار لمصلحة الشركة الناجمة عن التحول، فإن هذا التكييف لا يعد سبباً لتخلية المأجور أو لانتهاء عقد الإيجار. إذ ان عقود الإيجار

(¹) نقلاً عن صهيبي موسى جفال المومني، المرجع السابق، ص 50.

(²) وقد نصت المادة (1/78) من القانون المدني العراقي، على انه ((لا ينتهي الإيجار بموت المستأجر)).

التي ترميها الشركة العامة أصبحت تخضع لأحكام القانون المدني، بعد ان كانت تخضع لأحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 والذي تمنع الفقرة الأولى منه المادة الحادية عشر منه التنازل عن الإيجار، فقد عُدل هذا القانون الأخير بموجب القانون رقم (56) لسنة 2000 المعدل بقانون إيجار العقار⁽¹⁾، بحيث أصبح نطاق سريانه قاصراً على العقارات المؤجرة لأغراض السكنى للعراقيين والواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات.

لذلك لم تعد عقود الإيجار التي ترميها الشركة العامة خاضعة لقانون إيجار العقار، لان الغرض من الإيجار في هذه الحالة هو ليس السكنى بالطبع، وانما لممارسة النشاط الإقتصادي للشركة العامة، وبالتالي تخضع عقود الإيجار التي ترميها الشركة العامة للقانون المدني. والقاعدة العامة في القانون المدني هي انه يجوز للمستأجر ان يتنازل لغيره عن الإيجار ويثبت هذا الحق للمستأجر من عقد الإيجار ذاته ودون الحاجة إلى اتفاق خاص يقضي بمنحه إياه، ويصح ان يرد تصرف المستأجر على كل المأجور أو على جزء منه⁽²⁾، وقد نصت المادة (775) من القانون المدني العراقي على ذلك بقولها ((1. للمستأجر ان يؤجر المأجور كله أو بعضه بعد قبضه أو قبله في العقار وفي المنقول، وله كذلك ان يتنازل لغير المؤجر عن الإجارة. كل هذا ما لم يقضي الاتفاق أو العرف بغيره. 2. فإذا اشترط أن إيجار المستأجر أو تنازله عن الإيجار لا يكون إلا بموافقة المؤجر، فلا يجوز لهذا ان يمتنع عن الموافقة إلا بسبب مشروع)). وعلى هذا الأساس نعتقد أن عقود الإيجار التي ترميها الشركة العامة تنتقل إلى الشركة الناجمة عن التحول بوصفها خلفاً عاماً لها وانه حتى لو عد هذه الانتقال بمثابة تنازل عن الإيجار، فان ذلك لا يتعارض مع أحكام القانون المدني العراقي. وهذا

(¹) الوقائع العراقية، العدد (3848) في 16/10/2000، ولعل من المناسب أن نذكر في هذا المجال، أن هذا القانون قد ألغى ضمناً القانون رقم 25 لسنة 1996 المنشور في الوقائع العراقية العدد (3647) في 9/12/1996 والذي كان ينص على عدم سريان قانون إيجار العقار على العقارات المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية.

(²) أستاذنا د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص 289.

الحكم ينطبق أيضا على حالة التحويل إلى القطاع الخاص، الذي يتم عن طريق اندماج شركة عامة بأخرى خاصة أو مختلطة على أساس أن الشركة الناجمة عن الدمج أو الشركة الدامجة تعد خلفا عاما للشركات التي انقضت جراء الاندماج.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص عن طريق بيعها كأصول، أي دون تحويلها إلى شركات خاصة أو مختلطة وكانت هذه المشروعات العامة مقامة على أراضي مستأجرة فإن بيعها يقتضي أن تتنازل الجهة المالكة لهذا المشروع العام عن عقد الإيجار لمصلحة المشتري وفقا لأحكام التنازل الواردة في القانون المدني العراقي.

ونلاحظ في هذا المجال، إن المادة (12) من قانون إيجار العقار قررت حلول مشتري المصنع محل مستأجر العقار الذي أنشئ فيه هذا المصنع دون أن تعتبر ذلك تنازلا عن الإيجار أو إيجارا من الباطن⁽¹⁾. فقد جاء فيها أنه ((إذا كان المأجور عقارا أنشئ فيه المصنع وباع المستأجر المصنع حل المشتري محل المستأجر في عقد الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون)). غير أن هذا النص يعد ملغيا صراحة.

هذا عن انتقال عقود الإيجار التي أبرمتها الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحويل، بوصفها مستأجرة أما إذا كانت الشركة العامة هي المؤجر، فإن الأمر في هذه الحالة لا يعدو أن يكون، إلا تطبيقا من تطبيقات انتقال ملكية المأجور الذي عالجته المادة (786) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها انه ((1. إذا انتقلت ملكية المأجور إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا في حقه إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية. 2. ولكن لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار حتى لو كان هذا العقد غير نافذ في حقه)).

يتضح من هذا النص، أن عقد الإيجار ينتقل في هذه الحالة من الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحويل، إذا كان له تاريخ ثابت سابق على عملية التحويل، ما لم يرتض المستأجر بفسخ الإيجار عند تحويل الشركة العامة، وفي هذه الحالة تخلف الشركة الناجمة عن التحويل الشركة العامة في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن

(¹) أستاذنا د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص 298-299.

عقد الإيجار. وكذلك الحكم إذا لم يكن الإيجار نافذاً في حق الشركة الناجمة عن التحول لعدم ثبوت تاريخه، غير أنها تمسكت به رغم ذلك⁽¹⁾، غير أن هذا الفرض الأخير لا يمكن تصوره بالنسبة لعقود الإيجار التي تبرمها الشركة العامة، إذ أن هذه العقود تكون دائماً ثابتة التاريخ، لأنها عقود رسمية يتم إبرامها وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 فعقد الإيجار يكون رسمياً إذا قام بتنظيمه أو تصديقه موظف عام مختص مراعيًا في تحريره الأوضاع المقررة قانوناً⁽²⁾، وهو يعد كذلك طالما أنه قد أبرم وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، الذي ينص على مجموعة من هذه الإجراءات الواجبة الاتباع عند إبرام عقود الإيجار، وهذه الإجراءات يقوم بها الموظفون المختصون قانوناً.

المقصد الثاني: أثر التحول إلى القطاع الخاص في عقد الترخيص التجاري

يعرف عقد الترخيص التجاري "Franchising" بأنه "العقد الذي بمقتضاه يمنح أحد طرفيه والذي يطلق عليه مانح الترخيص، الطرف الآخر والذي يطلق عليه المرخص له، حق استخدام حق من حقوق الملكية الصناعية (الاسم التجاري - الرسوم والنماذج الصناعية - براءة الاختراع - علامة تجارية) أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الترخيص"⁽³⁾.

(¹) بهذا المعنى، انظر أستاذنا د. جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص 301.

(²) عرفت الفقرة الأولى من المادة (21) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 السندات الرسمية بقولها ((السندات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه أو ما أدلى به ذوو الشأن في حضوره)). ولمزيد من التفصيل، انظر: أستاذنا د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات العراقي، جامعة الموصل، ط2، 1997، ص 103.

(³) د. فايز نعيم رضوان، عقد الترخيص التجاري، مطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1990، ص 22.

- ويقسم عقد الترخيص وفقاً لطبيعة الأعمال التي يمارسها مانح الترخيص إلى ثلاثة أنواع، هي:⁽¹⁾
1. عقد الترخيص التجاري للخدمات، وهو عقد يخول بمقتضاه مانح الترخيص المرخص له، بتقديم الخدمات التي يقدمها الطرف الأول، ومثالها عقد الترخيص في مجال الخدمات الفندقية، ويلتزم مانح الترخيص في هذه الحالة بتقديم المساعدات الفنية التي تمكن المرخص له من تقديم الخدمات.
 2. عقد الترخيص التجاري للإنتاج، وهو ذلك العقد الذي يخول بمقتضاه، المرخص له، الحق بإنتاج السلع التي يقوم بإنتاجها مانح الترخيص، وذلك وفقاً للتعليمات والرقابة الفنية من جانب هذا الآخر، على أن يتم تسويق المنتجات، باستخدام نفس العلامة التجارية التي توضع على السلع الأصلية، ومن أمثلة هذه العقود، عقود الترخيص في مجال إنتاج المشروبات مثل (Coca-cola).
 3. عقد الترخيص التجاري للتوزيع، وهو العقد الذي يكون محله بيع المرخص له للسلع التي ينتجها المرخص، وهو أوسع أنواع عقود الترخيص التجاري انتشاراً وأياً كان نوع عقد الترخيص، فإن أطرافه هم المرخص والمرخص له، وهذا الأخير قد يكون شخصاً واحداً أو عدة أشخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً معنوية⁽²⁾.

وعقد الترخيص يعد من العقود المهمة في ميدان التعامل التجاري، فهو من عقود نقل التكنولوجيا Know-how، التي استخدمتها الشركات في الدول الصناعية بوصفها وسيلة للسيطرة على الأسواق العالمية لتسويق منتجاتها وخدماتها، كما

(¹) المرجع نفسه، ص 24 وما بعدها.

(²) Kenneth W. Clarkson , Roger Leroy Miller , Bonnie B.Laire , West's Business Law , West publishing company , St. Paul U.S.A. , 1980 , P.731.

واستفادت منه أيضا الدول النامية في تلبية حاجتها للتكنولوجيا الحديثة من أجل استخدامها في تنمية اقتصادها⁽¹⁾.

وعلى هذا الأساس، ينبغي أن نبين أثر تحول الشركات العامة في عقود الترخيص التي سبق وأن أبرمتها هذه الشركات، وفيما إذا كانت الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد تنتقل إلى الشركة الناجمة عن التحول بوصفها الخلف العام للشركة العامة، وبهذا الصدد، يجب أن نميز بين فرضين الأول، يتعلق بكون الشركة العامة هي المرخص في عقد الترخيص، أما الفرض الثاني، فيتعلق بكون الشركة العامة هي المرخص له في هذا العقد.

وفيما يخص الفرض الأول، فمن المعروف أن الالتزام الرئيسي الذي يقع على عاتق الشركة العامة في هذا الفرض، بوصفها الجهة المانحة للترخيص، هو تمكين المرخص له من الانتفاع بعقد الترخيص من خلال تمكينه من استعمال حقوق الملكية الصناعية، أو عن طريق توريد المواد الأولية والحاجات اللازمة لتصنيع المنتجات، أو الالتزام بنقل المعرفة الفنية للمرخص له في مجال التصنيع والتسويق⁽²⁾، وفي هذا الفرض تنتقل الآثار المترتبة على عقد الترخيص من الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول بوصفها خلفا عاما لها، فتحل هذه الشركة الأخيرة محل الشركة العامة في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الترخيص التجاري.

ومع ذلك، يبدو لنا، أنه من الصعب تصور تحقق مثل هذا الفرض من الناحية العملية في العراق، ذلك أن الشركات العامة في العراق، لم يسبق لها - على قدر اطلاعنا - أن منحت أي ترخيص ولأية جهة كانت وسواء كان محل عقد الترخيص هو الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، بيد أنه إذا كان يصعب تصور تحقق مثل هذا الفرض في الواقع العملي في العراق، فإن ذلك يمكن تصوره في بعض الدول الصناعية، كفرنسا مثلا، لذلك نجد أن المشرع الفرنسي قد أشار إلى حالة تحول

(¹) د. محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا - دراسة تطبيقية، مطبعة عبيد للكتاب والأعمال التجارية، القاهرة، 1988، ص 17-18.

(²) د. حسام الدين عبدالغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، دار الكتب القومية، القاهرة، 1993، ص 125.

الشركات العامة إلى القطاع الخاص، والتي سبق لها أن منحت ترخيصا للغير، فقرر معاملة المرخص له على نحو مماثل للعاملين في الشركة العامة، من حيث وجوب عرض نسبة معينة من أسهم الشركة عليهم لشرائها بالأولوية، فضلا عن إمكانية شرائهم للأسهم بسعر مخفض، وكذلك منحهم عددا معينا من الأسهم مجانا، وفقا لما أشرنا إليه فيما تقدم، غير أن المشرع الفرنسي اشترط، لكي يحصل هؤلاء على هذه المعاملة التفضيلية، أن يكون لهم حق القصر⁽¹⁾، ويكون للمرخص له حق القصر، إذا تضمن عقد الترخيص المبرم مع الشركات العامة، شرطا يسمى "بشرط القصر" والذي يقصد به التزام أحد طرفي عقد الترخيص بالتعامل مع الطرف الآخر فقط، كما وقد يكون شرط القصر تبادليا، يضمن لكل من الطرفين عدم التعامل مع الغير فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات محل عقد الترخيص، وهذا يسمى بعقد الترخيص الإستثنائي⁽²⁾.

أما عقد الترخيص غير الاستثنائي، فهو لا يمنع المرخص من منح ترخيصات أخرى لأي عدد من الأشخاص ضمن النطاق المكاني الذي يحدده عقد الترخيص، ويسمح للمرخص له بالتزود بمنتجات أخرى من موردين آخرين - غير مانح الترخيص، أو أن يستعمل علامة تجارية أخرى غير علامة مانح الترخيص، وبحسب محل عقد الترخيص⁽³⁾، أي أن المرخص له في هذا النوع من عقود الترخيص، لا يتمتع بحق القصر، ومن ثم لا يكون له الحق في التمتع بالشروط التفضيلية عند شرائه أسهم الشركة العامة مانحة الترخيص.

أما عن الفرض الثاني، والذي تكون فيه الشركة العامة الطرف الثاني في عقد الترخيص، أي المرخص له، فيصعب تصور انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الترخيص من الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول، ذلك أن شخصية

⁽¹⁾ المادة (11) من قانون التحول إلى القطاع الخاص الفرنسي الصادر في 1986/8/6.

⁽²⁾ د. فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص 107.

⁽³⁾ هالة مقداد احمد الجليلي، العلامة التجارية - دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 1997، ص 103.

المرخص له تكون محل اعتبار في عقد الترخيص⁽¹⁾، ومن ثم فإن حقوق والتزامات المرخص له في عقد الترخيص لا تنتقل إلى خلفه العام كقاعدة عامة، فطبيعة عقد الترخيص التجاري وما يفرضه من التزامات على عاتق المرخص له، هي التي تجعل من شخصية المرخص له محل اعتبار في العقد، إذ يلتزم المرخص له في عقد الترخيص بالمحافظة على سرية المعرفة الفنية التي يطلع عليها بمقتضى عقد الترخيص، ويكون حق استغلال هذه المعرفة الفنية قاصراً على المرخص له فقط، بحيث يحظر على المرخص له التصرف في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الترخيص بدون موافقة المرخص الذي يكون من حقه فقط حرية اختيار المرخص لهم⁽²⁾. وتأسيساً على ما تقدم، يعد انقضاء الشركة العامة المرخص لها، بموجب عقد الترخيص جراًء عملية التحول، سبباً لانتهاء هذا العقد، لما يؤدي إليه هذا الانقضاء من انهيار للاعتبار الشخصي- في عقد الترخيص التجاري⁽³⁾، ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك، إذ قد يجيز المرخص للمرخص له أن يتنازل بمقابل أو دون مقابل عن الحقوق المترتبة على عقد الترخيص.

(¹) د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1996، ص 340 وكذلك، زينة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص 36.

(²) د. فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص 165-166.

(³) وقد أشارت إلى هذا الاعتبار الشخصي لعقد الترخيص التجاري المادة (1/5) من قانون الالتزامات الخاصة بعقد الترخيص التجاري الأوروبي، والذي اقره الاتحاد الفرنسي- للترخيص التجاري في 1980/2/29، فقد جاء فيها أنه "لما منح الترخيص بعد الاختبار والتحري، ألا يوافق على منح الترخيص إلا لطالبيه الذين اتضح بعد فحص طلباتهم، أنهم يتمتعون بالصفات الشخصية والكفاءات والوسائل الضرورية التي يرجح معها فرصة نجاح عقد الترخيص التجاري، ومن حق مانح الترخيص في حالات الضرورة أن يطالب من مقدم طلب الترخيص استكمال المعلومات المهنية الخاصة والضرورية للوقوف على مدى إمكانية نجاح العقد"، نقلاً عن د. فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص 86.

وفضلا عما تقدم، يجب ان يلاحظ ان عقد الترخيص التجاري ينتهي أيضا عند تحويل المشروعات العامة التي لا تتخذ شكل الشركة إلى القطاع الخاص، أي عن طريق بيعها كأصول، إذا كان هذا المشروع مرخصا له بموجب عقد ترخيص سابق على عملية التحويل، لما يؤدي إليه ذلك البيع من انهيار للاعتبار الشخصي في عقد الترخيص.

وعلى هذا الأساس، مثلت عقود الترخيص عقبة حقيقية أمام عملية التحويل إلى القطاع الخاص التي جرت في مصر، فقد رفضت شركة شيراتون العالمية بيع فندق شيراتون القاهرة، كما اعترضت الشركات الأجنبية (مانحة الترخيص) على بيع شركة النصر لتعبئة الزجاجات (كوكا كولا) المصرية، وأسهم الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبي كولا)، وحققت هذه الشركات أهدافها، إذ تم بيع أسهم الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (بيبي كولا) لشركة بيبي كولا الأجنبية بمشاركة شركة مصرية، وكذلك أسهم شركة النصر- لتعبئة الزجاجات (كوكا كولا) فقد اشترتها شركة بيبي كولا الأجنبية بمشاركة شركة مصرية أيضا⁽¹⁾.

(¹) د. منير إبراهيم هندي، التجربة المصرية في الخصخصة، المرجع السابق، ص 197-198.

المبحث الثالث الرقابة اللاحقة على عمليات التحول إلى القطاع الخاص

تبين لنا فيما تقدم، أن التشريعات المقارنة تضع ضوابط صارمة على إجراءات التحول إلى القطاع الخاص، عن طريق تعيين جهة مختصة تتولى الإشراف على عمليات التحول، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكذلك عن طريق تحديد إجراءات تقويم الشركات العامة المراد تحويلها ضمن الالتزام بمبدأ الشفافية، وذلك من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنشودة من وراء عملية التحول إلى القطاع الخاص.

وبالرغم مما تقدم، فإن تحقيق هذه الأهداف، يستلزم فرض رقابة لاحقة على عمليات التحول، إذ يخشى عند تحويل الشركات العامة من سيطرة فئة معينة على إدارة الشركة، ومن ثم التأثير في نشاط الشركة وسياساتها الاقتصادية بشكل لا ينسجم مع أهداف عملية التحول، كما قد تكون الشركات العامة الخاضعة لعمليات التحول، ذات أهمية اقتصادية خاصة، ومرتبطة باقتصاد الدولة، أو مرتبطة بالحاجات العامة للأفراد لاحتكارها نشاطا بعينه⁽¹⁾.

وعليه، لا بد من أن تجد الدولة من الوسائل القانونية ما يكفل لها الرقابة على نشاط الشركات الناجمة عن التحول، ويحولها التدخل في نشاط هذه الشركات من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التحول وحماية المصلحة العامة.

وعلى هذا الأساس، ظهرت في التشريعات المقارنة فكرة إيجاد سهم ذي طبيعة قانونية خاصة يخول الدولة العديد من الحقوق التي تكفل لها الرقابة على نشاط الشركة الناجمة عن التحول، ومن أجل تحقيق الغاية ذاتها، قد يتم اللجوء عند بيع أسهم الشركات العامة إلى إدراج شرط يمنع المساهم من التصرف بأسهمه خلال فترة محددة، أو أن لا يتصرف بهذه الأسهم إلا لمساهم آخر توافق عليه الدولة ويتم الاتفاق على هذه الشروط عادة من خلال تشكيل مجموعة تسمى مجموعة المساهمين الثابتة.

وعلى هذا الأساس ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

(¹) صهيب موسى جفال المومني، المرجع السابق، ص 74-75.

المطلب الأول: حق الدولة في إنشاء السهم الخاص.
المطلب الثاني: تشكيل مجموعة المساهمين الثابتة.

المطلب الأول حق الدولة في إنشاء السهم الخاص

إن البحث في الأحكام القانونية الخاصة بحق الدولة في إنشاء السهم الخاص، يستلزم منا أن نبحث في الحقوق التي يخولها السهم الخاص أولاً، ثم بيان الطبيعة القانونية للسهم الخاص، ثانياً وكل في مقصد مستقل، وكما يأتي:

المقصد الأول: الحقوق التي يخولها السهم الخاص

أجازت العديد من التشريعات للدولة، عند تحويل الشركات العامة، أن تحتفظ بسهم ذي طبيعة خاصة يسمى بالسهم الخاص Action specifque⁽¹⁾، ويخول هذا السهم الدولة حقوقاً استثنائية، تمكنها من ممارسة العديد من الصلاحيات، لعل أهمها هو الحق في نقض "Veto" أي قرار يمكن أن يصدر من الهيئة العامة للشركة الناجمة عن التحويل إذا كان لا يتفق مع المصلحة العامة، وتستخدم الدولة هذا الحق بشكل خاص، لمنع السيطرة الأجنبية على الشركات الناجمة عن التحويل عن طريق تملك الأجانب لعدد كبير من أسهم هذه الشركة⁽²⁾.

ومن أجل ذلك أجاز المشرع الفرنسي، تحويل سهم عادي يملكه الدولة إلى سهم خاص، بموجب مرسوم يصدر من مجلس الدولة، يكون سابقاً على عقد جلسة لجنة المشاركات والتحويلات والمختصة باتخاذ قرار التحويل إلى جانب وزير الاقتصاد،

(¹) وقد عرف هذا السهم لأول مرة في المملكة المتحدة باسم "السهم الذهبي" "Golden Share" ثم تبعتها بعد ذلك العديد من التشريعات كالتشريع الفرنسي والبرتغالي والنيوزلندي، انظر:

Unctad , Op.Cit , P.116.

(²) صهيب موسى جفال المومني، المرجع السابق، ص 75.

ويحدد هذا المرسوم الحقوق التي يمكن أن يخولها هذا السهم، والتي قد تكون جميع أو بعض الحقوق الآتية:⁽¹⁾

1. موافقة وزير الاقتصاد المسبقة، على أي تصرف يقوم به شخص مفردة أو بالاتفاق مع أشخاص آخرين، يؤدي إلى التنازل عن نسبة من رأسمال الشركة، تتجاوز النسبة المئوية المحددة بالمرسوم المشار إليه وتحتسب هذه النسبة على أساس رأسمال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
2. تعيين ممثل واحد أو اثنين للدولة في مجلس إدارة الشركة أو مجلس الرقابة فيها، بحسب الأحوال، دون أن يكون لهذا الممثل الحق في التصويت على القرارات.
3. حق الوزير في إلغاء أي تنازل عن موجودات الشركة أو عن فروعها، إذا كان من شأن هذا التنازل إلحاق ضرر بالمصلحة العامة⁽²⁾.

أما عن كيفية مباشرة الحقوق التي يخولها هذا السهم الخاص، فيلاحظ أن المرسوم الفرنسي- رقم 1296-93 الصادر في 1993/12/13، قد أوجب عرض أي

(¹) المادة العاشرة المعدلة من قانون التحويل الفرنسي الصادر في 1986/8/6، وانظر:

Jean-Philippe colson , Op.Cit , P.145.

(²) ويلاحظ أن هذه الحقوق التي يخولها السهم الخاص، قد نص عليها القانون التونسي- رقم (102)، والصادر في آب/ 1994، والذي أجاز تحويل سهم عادي إلى سهم "امتياز" يتم إنشاؤه بموجب أمر رئاسي، وينص عليه في النظام الأساسي للشركة ويمكن تحويله في أي وقت إلى سهم عادي بمقتضى أمر رئاسي أيضاً، وتتمثل الصلاحيات التي يخولها هذا السهم بما يأتي:

1. تعيين ممثل أو ممثلين للدولة في مجلس الإدارة والجلسات العامة للشركة دون التمتع بحق التصويت.
2. المصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلف بمساهمات الدولة على تجاوز كل شخص مفردة أو بالتحالف مع أشخاص آخرين حدود نسب المساهمة المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالسوق المالية، وعدم مراعاة هذا الحكم يستتبع منع المشتري من ممارسة حق التصويت وبيع أسهمه جبراً.
3. حق الاعتراض على القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو انفصالها أو التصفية الإدارية لها، وانظر: د. محمد ميدون، المرجع السابق، ص120.

مشروع للتنازل عن جزء من موجودات الشركة على وزير الاقتصاد، على أن يتضمن هذا العرض جميع العناصر الضرورية لملف العملية كجنسية الأشخاص المتنازل لهم والتمن وغير ذلك، ويعد الوزير موافقا على عملية التنازل إذا انقضت ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الملف دون أن يعلن عن معارضته لعملية التنازل في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، ويمكن لوزير الاقتصاد أن يقلص هذه المدة إلى خمسة عشر يوما، كما ويمكنه أن يتنازل عن حقه في معارضة عملية التنازل قبل انقضاء الأجل المشار إليه، وتعد أية عملية للتنازل عن موجودات الشركة لاغية، ولا أثر لها، إذا لم تراعى فيها الأحكام المتقدمة، أما في حالة التنازل عن الأسهم، فإن معارضة وزير الاقتصاد عن طريق استعماله لحق الاعتراض الذي يخوله إياه السهم الخاص، يستتبع منع حملة الأسهم والذين تملكوا أسهما تزيد على النسبة المحددة بالمرسوم من ممارسة حقهم في التصويت الناجم عن ملكيتهم لهذه الأسهم، ويلتزمون بالتنازل عن الأسهم التي تزيد عن النسبة المحددة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة والهيئة العامة للمساهمين بذلك، وإذا انقضت هذه المدة دون أن يتنازل هؤلاء المساهمون عن أسهمهم، فإن هذه الأسهم تخضع للبيع الجبري من قبل الدولة⁽¹⁾.

وقد فصل المرسوم الفرنسي رقم 86-1141 الصادر في 1986/10/25 المعدل⁽²⁾ في إجراءات هذا البيع الجبري، فوفقا لهذا المرسوم يتولى وزير الاقتصاد إخطار رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي يخطر بدوره مجلس السوق المالية، بأن الأسهم في الشركة الناجمة عن التحول، قد تم الحصول عليها على نحو مخالف للقانون سواء تم الحصول على هذه الأسهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كانت وسيلة الحصول عليها⁽³⁾. وعند انتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة لبيع الأسهم، يتولى مجلس السوق المالية، إخطار رئيس مجلس إدارة الشركة بوضعية الأسهم المعترض على ملكيتها من قبل

(¹) Y.GUYON , Op. Cit., P.8.

(²) عدل هذا المرسوم بالمرسوم الفرنسي رقم 93-1297 الصادر في 1993/12/13.

(³) المادة الأولى من المرسوم الفرنسي المشار إليه.

وزير الاقتصاد، وفيما إذا كان قد تم التنازل عنها أم لا، وفي هذه الحالة لا يحق لحامل الأسهم التنازل عنها بأي شكل من الأشكال إلا ضمن الشروط التي نص عليها هذا المرسوم⁽¹⁾، ويجب وفقا للمادة (3) من هذا المرسوم الإعلان عن بيع الأسهم في الصحف قبل خمسة عشر يوما من تاريخ البيع، كما وينشر الإعلان في نشرة الإعلانات الرسمية الإخبارية، إذا كانت أسهم الشركة محل البيع لها سعر رسمي في سوق الأوراق المالية. ويتم بيع الأسهم في سوق الأوراق المالية المسجلة فيها أسهم الشركة ويمكن ان يتم البيع في عدة جلسات لسوق الأوراق المالية، إذا كان من شان بيعها دفعة واحدة ان يؤثر سلبا في سعر البيع. أما إذا لم يكن لأسهم الشركة سعر رسمي مسجل في سوق الأوراق المالية، فإنها تباع بوساطة المزايدة العلنية بوساطة الشركة أو سوق الأوراق المالية⁽²⁾.

أما بخصوص إلغاء السهم الخاص، فلقد كان المشرع الفرنسي ينص على أن يتحول السهم الخاص إلى سهم عادي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إنشائه ودون الحاجة إلى إجراء آخر، وقد عدل المشرع الفرنسي هذا الحكم بموجب المادة (7) من القانون رقم 93-923 الصادر في 1993/7/19، فقد ألغيت هذه المادة هذا الانقضاء التلقائي للسهم الخاص، ونصت على إمكانية تحويله إلى سهم عادي، وفي أي وقت كان بموجب مرسوم صادر من ذات الجهة التي أنشأته⁽³⁾.

ونستنتج مما تقدم أن المشرع الفرنسي قد وضع قواعد محددة وتفصيلية من شأنها أن تضمن ممارسة الدولة للحقوق الاستثنائية التي يقررها السهم الخاص، وبالتالي ضمان تحقيق نوع من الرقابة اللاحقة على نشاط الشركات الناجمة عند التحول من أجل استمرار هذه الشركة في اتباع نهج اقتصادي معين يتفق مع أهداف عملية التحول إلى القطاع الخاص ولا يلحق ضررا بالمصلحة العامة.

(¹) المادة الثانية من المرسوم الفرنسي المشار إليه.

(²) Jean-Philippe colson , Op.Cit , P.45.

(³) Alic Pezard , Op.Cit , P.3.

ونعتقد انه إذا كان احتفاظ الدولة بسهم خاص في ظل القانون الفرنسي، يؤدي إلى تحقيق الفائدة المرجوة منه، وهي الرقابة على نشاط الشركات الناجمة عن التحول، فإن الأخذ بفكرة السهم الخاص في التشريع العراقي لن تحقق مثل هذه الفائدة⁽¹⁾، ذلك أن القواعد الواردة في قانون الشركات العراقي تحقق ذات المزايا، التي يمكن أن تتحقق عن طريق إنشاء سهم خاص في التشريع الفرنسي- ودون الحاجة إلى الأخذ بفكرة السهم الخاص، أي أن القواعد الواردة في قانون الشركات العراقي، تقرر نوعاً من الرقابة على نشاط الشركة الناجمة عن التحول وشانها في ذلك - بالطبع - شأن بقية الشركات التي تؤسس ابتداءً من قبل القطاع الخاص أو المختلط، وهذه الرقابة تغني المشرع العراقي عن الأخذ بفكرة السهم الخاص.

فإذا كانت الغاية من إنشاء السهم الخاص في التشريع الفرنسي وبقية التشريعات المقارنة التي تقرر إنشاء مثل هذا السهم، هي الحيلولة دون سيطرة فئة قليلة من الأشخاص، ولاسيما الأجانب منهم على الشركة الناجمة عن التحول، فإن القواعد الواردة في التشريع العراقي تمنع بالأساس الأجانب من تملك الأسهم في الشركات العراقية، وسواء كانت هذه الشركات قد أسست ابتداءً من قبل القطاع الخاص أو المختلط، أم إنها قد أسست جراء تحويل الشركات العامة إلى القطاع الخاص، فقرار مجلس قيادة الثورة رقم (23) لسنة 1994 - أوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي أو استثمار أمواله في الشركات داخل العراق، وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار من أي وجه كان، كما ولا يخفى أيضاً من سيطرة أي شخص سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، ممن يحق لهم تملك الأسهم في الشركات العراقية، على أسهم الشركة الناجمة عن التحول، فوفقاً للمادة (32) من قانون الشركات العراقي، لا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي من غير القطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة الخاصة على (20%) من رأسمالها.

(¹) خلافاً لذلك، يرى البعض ضرورة تبني المشرع العراقي لفكرة السهم الخاص، لأنه يؤمن للدولة استمرار المشاريع العامة بعد تحويلها إلى القطاع الخاص، فوزي حسين سلمان الجبوري، المرجع السابق، ص 115.

وللجهة القطاعية المختصة، وفقا لهذه المادة - أن تحدد الحد الأعلى لمساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي من غير القطاع الاشتراكي في الشركة المختلطة على أن لا تتجاوز (10%) من رأس المال. فضلا عن ذلك، لا يخشى في التشريع العراقي من عدم استمرار الشركة الناجمة عن التحول في استغلال المشروع الاقتصادي الذي تلقته من الشركة العامة، ويتحقق ذلك من خلال الرقابة التي قررها المشرع العراقي للجهة القطاعية المختصة على نشاط الشركات عموما، ومنها بالطبع الشركات الناجمة عن التحول، إذ لا يمكن وفقا لقانون الشركات العراقي للهيئة العامة لشركة الناجمة عن التحول أن تقرر تصفيتها، إلا إذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على التصفية، بل انه حتى لو وافقت الجهة القطاعية على التصفية، وكان المشروع الذي تديره الشركة الموصى بتصفيتتها واجب الاستمرار لأهميته الاقتصادية ضمن خطة التنمية والقرارات التخطيطية، فإنه يجب على هذه الجهة القطاعية أن تحدد الإجراءات اللازمة لضمان استمرار المشروع سواء بتحويله إلى جهة أخرى أو دمج مشروع آخر أو أي إجراء مناسب آخر⁽¹⁾. كما لا يخشى من خروج الشركة الناجمة عن التحول عن النهج الاقتصادي المطلوب في ممارسة نشاطها، عن طريق اندماجها بشركة أخرى بعد عملية التحول، ذلك أن عمليات الاندماج تخضع وفقا لقانون الشركات العراقي لرقابة الجهة القطاعية المختصة⁽²⁾. فضلا عما تقدم، فقد قرر المشرع العراقي وسيلة فعالة للرقابة على نشاط الشركات المساهمة المختلطة، وهو الشكل الذي تتخذه - غالبا - الشركات الناجمة عن التحول، وذلك عند تقريره للأحكام الخاصة بمجلس الإدارة في هذه الشركات، إذ لا يعد النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة متحققا، إلا إذا حضره أغلبية عدد أعضائه على أن يكون من ضمنهم اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي⁽³⁾، كما ويشترط لنفاذ قرارات مجلس الإدارة، أن يكون اثنان من ممثلي القطاع

(¹) المادة (161) من قانون الشركات العراقي.

(²) المادة (150/رابعاً) من قانون الشركات العراقي.

(³) المادة (113) من قانون الشركات العراقي.

الاشتراكي قد صوتوا إلى جانبها في الأقل⁽¹⁾.

ويقينا أن هذه الأحكام من شأنها أن تخول القطاع الاشتراكي سلطة واسعة في إدارة ورقابة الشركات الناجمة عن التحول، بل أن هذه الأحكام تتميز عن تلك التي جاء بها المشرع الفرنسي. لدى تقريره للأحكام التي تجيز لوزير الاقتصاد، حق تعيين ممثل أو ممثلين عنه في مجلس إدارة الشركة الناجمة عن التحول، فليس لهذا الممثل وفقا للتشريع الفرنسي، الحق في المشاركة بالتصويت عند اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة، الأمر الذي دفع جانبا من الفقه الفرنسي للتساؤل عن مدى جدوى تعيين هذا الممثل في مجلس إدارة الشركة الناجمة عن التحول⁽²⁾، لذلك لا نرى أية ضرورة تدعو المشرع العراقي إلى تبني فكرة السهم الخاص على النحو الذي اقترحه المشرع الفرنسي.

المقصد الثاني: الطبيعة القانونية للسهم الخاص

اتضح لنا مما تقدم، أن العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الفرنسي، تجيز للدولة أن تحول سهما عاديا إلى سهم خاص، يخولها بعض الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة الرقابة على نشاط الشركة الناجمة عن التحول.

ويثار التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذا السهم الخاص، ومدى انسجامها مع القواعد الواردة في قوانين الشركات، من حيث خصائص السهم، والمركز القانوني لحامل السهم، أي حقوق والتزامات المساهم، فالسهم هو حصة المساهم في شركة الأموال، ويقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص، كما ويقصد به أيضا، الصك الذي تصدره الشركة ويمثل حق المساهم فيها⁽³⁾.

(¹) المادة (114/ثانياً) من قانون الشركات العراقي.

(²) Jean-Paul valuet , Op.Cit , P.21.

(³) د. محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ص 167.

وتكون الأسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة، وقابلة للتداول⁽¹⁾ ويشترك السهم الخاص مع الأسهم العادية من حيث تساوي القيمة وعدم إمكانية تجزئته، ذلك أن المقصود يتساوى قيمة الأسهم، هو تساويها في القيمة الاسمية عند الإصدار.

وبما أن السهم الخاص، هو بالأساس سهم عادي، يتم تحويله وفقا للإجراءات المحددة قانونا إلى سهم خاص، فإنه يخضع لهذه القاعدة، أي أنه يتساوى مع الأسهم العادية من حيث قيمته الاسمية، كما أن السهم يكون غير قابل للتجزئة، بيد أنه إذا كانت العلة من وراء عدم جواز تجزئة الأسهم العادية، أي اشتراك أكثر من شخص في ملكية السهم، على نحو يملك فيه كل منهم أجزاء من السهم، هو ما يثيره ذلك من مشاكل عند التصويت في الهيئة العامة أو عند بيع الأسهم أو توزيع الأرباح على المساهمين⁽²⁾، فإن العلة من عدم قابلية السهم الخاص للتجزئة ليس ذلك فحسب، بل أنه يتمثل بعدم جواز اشتراك أي شخص في ملكية هذا السهم مع الدولة، لأن هذا السهم قد أنشئ أساسا لكي تملكه الدولة حصرا، بوصفه وسيلة للرقابة على الشركات الناجمة عن التحول، وعلى هذا الأساس لا يمكن التنازل عن السهم الخاص وبأي شكل من الأشكال، بمعنى أن السهم الخاص وخلافا للأسهم العادية لا يكون قابلا للتداول، وهذا ما ينفي عن السهم الخاص سمة أساسية من سمات الأسهم، إذ أن قابلية الأسهم للتداول إذا لم تكن هي المعيار المميز للأسهم، فإنها واحدة من الخصائص الجوهرية التي تميزه في شركات الأموال، وإذا كان من الممكن أن ترد قيود قانونية أو اتفاقية على حرية تداول الأسهم العادية، فإن هذه القيود لا يمكن أن تصل إلى حد المنع المطلق، لأن ذلك يخالف جوهر السهم في الشركات⁽³⁾.

وفضلا عن ذلك، فإن القاعدة هي أن يتمتع المساهمون بحقوق متساوية ويخضعون لنفس الالتزامات مع مراعاة أحكام القانون، وهذه الحقوق والالتزامات قد

(1) أستاذنا كامل عبدالحسين البلداوي، المرجع السابق، ص 144.

(2) د. محمد كامل أمين ملش، الشركات تأسيسها وإدارتها، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، 1957 ص 142.

(3) د. يعقوب يوسف صرخوة، الأسهم وتداولها في الشركات المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص 216-217.

تكون ذات صفة مالية أو صفة غير مالية (إدارية)⁽¹⁾، وما نلاحظه في هذا المجال، ان السهم الخاص يختلف عن الأسهم العادية من حيث الحقوق والالتزامات المرتبطة به، فإذا كان السهم الخاص لا يختلف عن الأسهم العادية من حيث الحقوق المالية المرتبطة به، فإنه ودون أدنى شك يختلف عنها في الحقوق الإدارية، ذلك انه يخول حامله "الدولة" حقوقاً لا تخولها الأسهم العادية لحاملها، إذ انه يجيز للدولة أن تعين ممثلين عنها في مجلس إدارة الشركة الناجمة عن التحول، كما يجيز لها نقض أي قرار صادر من الهيئة العامة للشركة، وأياً كانت الأغلبية التي صدر بها هذا القرار وهذا يعني أن حامل السهم الخاص لا يخضع للالتزام الرئيسي- الذي يخضع له كافة المساهمين والمتمثل بخضوع أقلية المساهمين لقرارات الأغلبية في اجتماعات الهيئة العامة للشركة⁽²⁾، وهذه السمات التي يتسم بها السهم الخاص هي التي تميزه عن الأسهم الممتازة، فالأسهم الممتازة هي الأسهم التي تخول أصحابها أولوية أو أفضلية، يختص بمقتضاها حملة هذه الأسهم دون غيرهم ببعض المزايا، والتي قد تكون ذات طابع مالي، كمنح حملة هذه الأسهم حق أولوية في الأرباح، بحيث يختص هؤلاء بنسبة معينة من الأرباح لا تقل عن (5%) مثلاً، ويوزع ما يبقى من الأرباح بعد ذلك على أصحاب الأسهم العادية أو يوزع بين الأسهم بنوعيتها، وكذلك منح أصحاب الأسهم الممتازة أولوية في الحصول على قيمة أسهمهم الاسمية عند تصفية الشركة، كما قد تكون هذه المزايا ذات طابع إداري، كإعطاء صاحب السهم الممتاز أصواتاً أكثر في الهيئة العامة⁽³⁾، وقد أجاز كل من المشرع الفرنسي والمصري والمغربي، للشركة

(¹) د. باسم محمد صالح ود. عدنان احمد ولي، المرجع السابق، ص216.

(²) ولمزيد من التفصيل في خضوع أقلية المساهمين لقرارات الأغلبية في الهيئة العامة للشركة، انظر: د. عبدالفضيل محمد احمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الأول، السنة الأولى، 1986.

(³) د. صلاح الدين الناهي، الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي، ج2، ط2، بدون تاريخ نشر، ص194.

إصدار أسهم ممتازة⁽¹⁾، في حين لم يأخذ المشرع العراقي بهذا النوع من الأسهم، لما قد يترتب عليه من إخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين⁽²⁾.

وعلى أي حال، فإن الأسهم الممتازة لا ترقى فيما تمنحه من حقوق إلى مرتبة السهم الخاص، إذ أن الحقوق التي تخولها الأسهم الممتازة لحامليها، لا يمكن وبأي شكل من الأشكال أن تصل إلى حد الحق في نقض قرارات الهيئة العامة للشركة أو تعيين أعضاء في مجلس الإدارة، فضلا عن أن التشريعات التي أجازت للشركة إصدار أسهم ممتازة ذات أصوات متعددة، حصرت ذلك في حالات استثنائية محددة⁽³⁾، لذلك فإن هذا النوع من الأسهم الممتازة يعد استثناء، ومن ثم لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسير أحكامها، كما أن الأسهم الممتازة تكون قابلة للتداول، كقاعدة عامة، غير أن نقل ملكية الأسهم التي تخول أصحابها أصواتا متعددة يترتب عليه، فقد الحق في الصوتين، إلا إذا كان انتقال ملكية السهم عن طريق الإرث أو قسمة الأموال المشتركة بين الزوجين، أو هبة بين الأحياء تحقق لأحد الزوجين أو لأحد الأقارب ممن يكون لهم الحق بالميراث⁽⁴⁾.

وتأسيسا على ما تقدم، نعتقد أن وصف السهم لا ينطبق على ما يعرف بالسهم الخاص، إذ أن هذا الأخير يختلف عن الأسهم العادية من حيث الخصائص الجوهرية والحقوق والالتزامات المرتبطة به، فما يعرف بالسهم الخاص ما هو في حقيقة الأمر، إلا نظاما قانونيا للرقابة على الشركات الناجمة عن التحول، وهو مقرر بقواعد قانونية

⁽¹⁾ المواد (175 و176) شركات فرنسي، و (2/35) شركات مصري و (257، 258، 259، 261).

⁽²⁾ أستاذنا كامل عبدالحسين، المرجع السابق، ص148.

⁽³⁾ من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة (492) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966، والتي لم تجز للشركة إصدار أسهم ممتازة تخول أصحابها أصواتاً متعددة إلا في ثلاث حالات، الأولى وهي حالة الشركات التي يكون موضوع نشاطها التزام المرافق العامة، إذا كانت هذه الشركات تعمل خارج فرنسا، والثانية، تتعلق بكون الشركة من شركات الاقتصاد المختلط، أما الثالثة فهي حالة الشركات التي تساهم في نشاط إنتاجي وتعمل في بلاد ما وراء البحار، وذلك وفقاً للقانون الصادر في 1956/9/13، نقلاً عن يعقوب يوسف صرخوة، المرجع السابق، ص117.

⁽⁴⁾ المادة (1/176) من قانون الشركات التجارية الفرنسي.

آمرة لا سبيل لمخالفتها، كما انه يتعلق بالنظام العام لارتباطه بفكرة المصلحة العامة، ومن ثم لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسير القواعد القانونية التي تنظمه.

المطلب الثاني تشكيل مجموعة المساهمين الثابتة

تنتهج كل شركة نهجا اقتصاديا خاصا في ممارسة نشاطها، بحسب الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها، وغالبا ما تختص الشركات العامة بممارسة نشاط اقتصادي يرتبط بالمصلحة العامة، ويؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وبغية المحافظة على النهج الاقتصادي للشركات العامة بعد تحويلها إلى القطاع الخاص، قد تعمد الدولة بعد تحويل الشركة العامة إلى القطاع الخاص، إلى الاتفاق مع بعض المساهمين في الشركة الناجمة عن التحويل لتشكيل "مجموعة المساهمين الثابتة" G.A.S⁽¹⁾، وهذا الاتفاق ما هو في حقيقة الأمر إلا اتفاقا بين الدولة وبعض المساهمين في الشركة الناجمة عن التحويل، على أن لا يتصرف أي من هؤلاء المساهمين بأسهمه خلال فترة معينة، وعلى ان يخضع التصرف بهذه الأسهم بعد انقضاء الفترة المحددة لموافقة الجهة المختصة في الدولة، على نحو يكون فيه لهذه الأخيرة حق تعيين المشتري، وهو ما يعرف بشرط الأفضلية أو "الشفعة" Clausos de primption⁽²⁾ ومقتضى هذا الاتفاق يلتزم أعضاء هذه المجموعة بتوجيه الشركة نحو تطبيق سياسة اقتصادية

(¹) Groupe d'actionnaires stables.

(²) ويختلف الفقه في مدى جواز تسمية هذا الحق بحق الشفعة، إذ يرى البعض جواز ذلك، د. فوزي عطوي، القانون التجاري،

دار العلوم العربية، بيروت، ط1، 1986، ص 261.

كما يستخدم المشروع المغربي هذا المصطلح صراحة في المادة (257) من قانون الشركات المساهمة المغربي في حين يفضل البعض

الآخر تسمية هذا الشرط بحق الأفضلية أو الاسترداد، لان الشفعة لا تكون إلا في العقار، د. عباس مرزوك، المرجع السابق،

ص 87.

معينة، وهي بشكل عام تتفق مع السياسة الاقتصادية التي كانت تنتهجها الشركة العامة قبل تحويلها إلى القطاع الخاص⁽¹⁾.

وتشكل مجموعة المساهمين الثابتة، تقتضي ان يتفق المساهمون على تنظيم أنفسهم من اجل القيام بعمل جماعي في مواجهة الأجهزة الإدارية في الشركة الناجمة عن التحول، وذلك بقصد الدفاع عن مصالحهم المشتركة، التي يتفقون عليها ابتداء الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا إذا كونوا مجموعة لها وزنها على نحو تمارس فيه دورا حقيقيا في إدارة الشركة، وبشكل خاص في مواجهة الأغلبية في اجتماعات الهيئة العامة، ومن المتصور أيضا ان تشكل هذه المجموعة أغلبية تمكنهم من توجيه نشاط الشركة وفقا للاتفاق المعقود بينهم، وهذا الاتفاق يعد شكلا من أشكال الرقابة على الشركات الناجمة عن التحول، من خلال تجميع الأسهم المتناثرة، وقيام حملة هذه الأسهم بعمل جماعي منظم يحل محل العمل الفردي المشتت⁽²⁾، وإذا كانت القاعدة هي أن تتشكل مجموعة المساهمين من أعضاء اشتروا أسهم الشركة العامة عند تحويلها إلى القطاع الخاص، فإنه لا مانع من أن تتكون هذه المجموعة من مساهمين موجودين أصلا في الشركة العامة قبل تحويلها إلى القطاع الخاص⁽³⁾، وهذا الفرض الأخير لا يتصور تحقيقه إلا بالنسبة للتشريعات التي تجيز للأشخاص من القطاع الخاص، تملك أسهم في الشركة العامة.

ومن الواضح ان عقد مثل هذا الاتفاق بين الدولة والمساهمين، يفترض فيه تحقيق المصالح المشتركة لجميع أعضاء مجموعة المساهمين، وهذه المصالح قد لا تكون متفقة تماما، فإذا كانت مصلحة الدولة تقتضي- إخضاع الشركة الناجمة عن التحول لسلطة أو رقابة أعضاء هذه المجموعة، لتوجيه نشاط الشركة توجيهها يتفق مع المصلحة العامة، فإن مصلحة بقية أعضاء هذه المجموعة تختلف عن ذلك، إذ قلما ينصب اهتمام المساهمين من القطاع الخاص على المحافظة على المصلحة العامة،

(¹) Jean - Paul valuet , Op. Cit. , P.12.
Lysiane cartelelier , Op. Cit. , P.162.

(²) بهذا المعنى، د. يعقوب يوسف صرخوه، المرجع السابق، ص 445.

(³) Jean - Paul valuet , Op. Cit. , P.12.

وغالبا ما يكون هدفهم من تشكيل هذه المجموعة هو تحقيق مصالحهم الخاصة، لذلك يصعب على الدولة تشكيل مثل هذه المجموعة، وفرض الشروط التي تضمن المحافظة على المصلحة العامة، إلا من خلال تقديم بعض المزايا الخاصة لأعضاء هذه المجموعة عند الاتفاق على تشكيل هذه المجموعة، الأمر الذي دفع جانبا من الفقه في فرنسا إلى القول بصعوبة تشكيل مجموعة المساهمين الثابتة، إذا ما تمت عملية التحويل عن طريق بيع أسهم الشركة العامة بالعرض العام، لأن هذا الأسلوب يقتضي بيع الأسهم للجمهور بشروط واحدة، في حين أن بيع الأسهم بالتراضي خارج سوق الأوراق المالية، يمكن الدولة من التفاوض والاتفاق مع مجموعة من المساهمين لتشكيل هذه المجموعة، كما ويمكنها ذلك من تقديم بعض المزايا لأعضاء هذه المجموعة⁽¹⁾.

وعلى هذا الأساس، جرى العمل في فرنسا على بيع أسهم الشركات العامة بالتراضي وخارج سوق الأوراق المالية، لعدد محدد من المساهمين، يشكلون مجموعة المساهمين الثابتة، وبالرغم من أن قانون التحويل إلى القطاع الخاص الفرنسي، لم يتضمن أحكاما تنظم صراحة تشكيل مثل هذه المجموعة، فإنه من الممكن تشكيل هذه المجموعة، ضمن الإطار العام للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون التحويل الفرنسي الصادر في 1986/8/6، التي تحدد أساليب التحويل وكذلك ضمن إطار المرسوم الفرنسي رقم (1041) الصادر في 1993/9/3، والذي يجيز بيع أسهم الشركات العامة خارج سوق الأوراق المالية بالتراضي، ويجري بيع الأسهم لأعضاء هذه المجموعة بقرار يصدر من وزير الاقتصاد، بعد موافقة لجنة المشاركات والتحويلات على شروط البيع، وتنظم العلاقة فيما بين المساهمين الأعضاء في هذه المجموعة بموجب "دفتر الشروط" والذي يستخدم عند بيع الأسهم لأعضاء هذه المجموعة، ومن ضمن الشروط التي يتضمنها هذا الدفتر، شرطا يلزم أعضاء هذه المجموعة بعدم التصرف بأسهمهم Claus d'inalienabilite خلال مدة محددة سنة أو سنتين مثلا، فلا يجوز لهم خلال هذه المدة أن يتصرفوا بنسبة معينة من أسهمهم

(¹) Alic Pezard , Op. Cit. ,P. 4.
Jean – Paul valuet , Op. Cit. , P.

(80%) مثلاً، وبعد انقضاء المدة المحددة، يلتزم أعضاء هذه المجموعة أيضاً، بأن لا يتصرفوا بهذه الأسهم، إلا لمصلحة أشخاص يعينهم وزير الاقتصاد "شرط الأفضلية"⁽¹⁾.

ويتم الاتفاق على هذه الشروط عن طريق اتفاق الدولة بوصفها أحد المساهمين في الشركة مع كل مشترك للأسهم على حدة، فلا يمكن الاتفاق مع المجموعة كشخص واحد، لأن كل مساهم في المجموعة يمتلك أسهمه على وجه الاستقلال وينصب الاتفاق بين أعضاء هذه المجموعة بشكل عام، على التصويت إلى جانب أو ضد بعض القرارات التي يمكن أن تصدر من الهيئة العامة للشركة الناجمة عن التحول من أجل وضع سياسة معينة موضع التنفيذ ووفقاً للمادة (1/355) من قانون الشركات التجارية الفرنسي- الصادر في 1966/7/24 لا يعد إنشاء مجموعة المساهمين الثابتة، منشأً لشخص معنوي مستقل عن أعضاء المجموعة، فالمادة المشار إليها لا تهدف من وراء تشكيل مجموعة المساهمين الثابتة، إنشاء شركة تتولى الرقابة على شركة أخرى، وبمعنى آخر لا يكون لمجموعة المساهمين شخصية معنوية مستقلة⁽²⁾.

ومهما يكن من أمر، فإن أعمال شرط الأفضلية، يستلزم تعيين الأسس التي يتحدد بموجبها ثمن الأسهم المراد شراؤها وفقاً لحق الأفضلية، كما يجب تحديد المدة التي يمكن خلالها شراء الأسهم المراد بيعها بموجب حق الأفضلية، على النحو الذي تتحقق فيه مصلحة المساهم في أن يتصرف بأسهمه ومصلحة صاحب هذا الحق في الشراء بموجب هذا الشرط. وبما أن المشرع الفرنسي- لم ينص على أحكام خاصة بهذا الشأن في التشريعات الخاصة بالتحول إلى القطاع الخاص، فإنها تخضع للقواعد الواردة في قانون الشركات التجارية الفرنسي⁽³⁾.

وفيما يتعلق بتحديد ثمن الأسهم المراد شراؤها أعمالاً لحق الأفضلية، ميز المشرع الفرنسي، بين نوعين من الأسهم، وهي أسهم الشركات المقيدة في البورصة،

(¹) Y. D. Jehane, Op. Cit., P. 27-28.

(²) Jean - Paul valuet , Op. Cit. , P.12.

-D. Carreau et R. Treuhhold , Privatisation , droit: boursier et pratiques des marches, Rev. societates , 1994, P.10.

(³) Jean - Paul valuet , Op. Cit. , P.12.

وأسهام الشركات غير المقيدة في البورصة، وبخصوص النوع الأول يتم تحديد ثمن الأسهم عند تنفيذ شرط الأفضلية، على أساس سعر هذه الأسهم في سوق الأوراق المالية، يوم الإعلان عن الرغبة بشراء هذه الأسهم بموجب حق الأفضلية، وفي حالة عدم وجود تسعيرة في هذا اليوم، يتحدد الثمن على أساس آخر سعر للأسهم في البورصة قبل ذلك⁽¹⁾، أما النوع الثاني من الأسهم، وهي أسهم الشركات غير المقيدة في البورصة، فيتحدد ثمنها باتفاق ذوي الشأن، وبخلاف ذلك يتم تحديد الثمن وفقاً لما نصت عليه المادة (5/1868) من القانون المدني الفرنسي، غير أن هذه المادة ألغيت بالقانون المدني الفرنسي- الجديد الصادر في 1978/6/3، وحلت محلها المادة (1843) من القانون المدني الفرنسي- الجديد والتي تنص على أنه " في جميع الحالات المنصوص عليها بشأن التنازل عن حقوق أحد الشركاء قبل الشركة، أو بشأن إعادة شراء هذه الحقوق لحساب الشركة، تحدد قيمة هذه الحقوق في حالة النزاع، عن طريق خبير يعين باتفاق الأطراف فإذا لم يوجد اتفاق عين الخبير بقرار من رئيس المحكمة⁽²⁾ .

أما بخصوص المدة التي يجب خلالها مباشرة حق الأفضلية، فقد ميز المشرع الفرنسي- بشأنها، بين أسهم الشركات المسجلة في البورصة، وتلك التي لم تقيد فيها، إذ جعل هذه المدة (30) يوماً من تاريخ الإعلان عن الرغبة في شراء الأسهم بموجب حق الأفضلية بالنسبة لأسهم الشركات المسجلة في البورصة، أما أسهم الشركات غير المسجلة في البورصة، فإن المدة التي يجب خلالها شراء الأسهم إعمالاً لحق الأفضلية هي ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن الرغبة بشرائها⁽³⁾ . فإذا انقضت المدة المشار إليها، دون أن يعلن وزير الاقتصاد بوصفه صاحب حق الأفضلية، عن رغبته في تنفيذ شرط الأفضلية، فإن الوزير يعد موافقاً على التنازل عن هذه الأسهم للغير⁽⁴⁾ .

(¹) المادة (276) شركات تجارية فرنسي.

(²) نقلاً عن، فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في الشركة المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1991، ص 106.

(³) المادتان (2/275 و 2/276) من قانون الشركات التجارية الفرنسي.

(⁴) المادتان (3/275 و 4/276) من قانون الشركات التجارية الفرنسي.

ولعل من المناسب أن نذكر في هذا المجال، أن المستفيد من شرط الأفضلية، الذي يحدده وزير الاقتصاد، قد يكون أحد المساهمين في الشركة أو من الغير، كما وقد يكون شخصا واحداً أو عدة أشخاص، على أنه ينبغي أن يراعى عند شراء الأسهم بموجب شرط الأفضلية، أن ينصب الشراء على كل الأسهم المراد التنازل عنها، وبغير ذلك يكون المساهم مخيراً بين قبول تنفيذ شرط الأفضلية جزئياً، أو أن يتنازل عن كل أسهمه إلى المتنازل إليه الذي يختاره، كما أن المساهم الذي يرغب في بيع أسهمه غير ملزم بالخضوع لشرط الأفضلية، إذ يمكن لهذا المساهم أن يسحب عرضه بالتنازل عن أسهمه وأن يعلن بأنه يفضل الاحتفاظ بها⁽¹⁾.

فضلاً عن ذلك، يمكن طبقاً للتشريع المغربي أن يتم تشكيل مجموعة المساهمين الثابتة، إذ يلاحظ أن قانون الشركات المساهمة المغربي لسنة 1996 قد جاء بأحكام مشابهة لتلك التي نص عليها المشرع الفرنسي⁽²⁾، فقد نصت المادة (257) من هذا القانون على أنه " يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار بشأن شروط تفويت حقوق الشركة، وأن تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إلا بعد مدة معينة، أو إجراءه تلقائياً أن اقتضى الحال، بصورة تفصيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الأغيار أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي".

فوفقاً لهذا النص، يمكن للوزير المختص بعمليات التحويل إلى القطاع الخاص، أن يبرم اتفاقاً مع مجموعة من المساهمين في الشركة الناجمة عن التحويل، لتشكيل مجموعة المساهمين الثابتة، بحيث يلتزم أعضاء هذه المجموعة بعدم التنازل عن

(¹) وبهذا المعنى، انظر: حكم محكمة باريس الصادر في 1976/10/26، والذي صادقت عليه محكمة النقض الفرنسية في 1977/4/3، نقلاً عن، يعقوب يوسف صرخوة، المرجع السابق، ص 431.

(²) كذلك يمكن تطبيق الأحكام التي جاء بها المشرع الفرنسي بخصوص شرط الأفضلية طبقاً للمادة (414) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري: د. حسني المصري، مدى حرية الانضمام إلى الشركة والانسحاب منها، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985، ص 96.

أسهمهم خلال فترة محددة، وأن لا يتنازلوا عن أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة إلا لمصلحة أشخاص يعينهم الوزير المختص بعمليات التحول إلى القطاع الخاص، ومع ذلك يختلف موقف المشرع المغربي عن موقف المشرع الفرنسي، من حيث تحديد ثمن الأسهم المراد شراؤها أعمالا لشرط الأفضلية، إذ أن هذا السعر يتحدد طبقا لنص قانون الشركات المساهمة المغربي المشار إليه، بالسعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الأغيار أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، كذلك يجب ان يتضمن النظام الأساسي للشركة المدة التي يجب خلالها مباشرة حق الأفضلية في شراء الأسهم المراد بيعها، بموجب حق الأفضلية، أما عن موقف المشرع العراقي، فيلاحظ أن قانون الشركات العراقي يخلو من الإشارة إلى أية أحكام من شأنها أن تجيز أو تمنع تشكيل مجموعة المساهمين الثابتة، ولما كانت مجموعة المساهمين الثابتة ما هي إلا اتفاق بين مجموعة من المساهمين على عدم التصرف بأسهمهم خلال فترة محددة، وعلى أن لا يتصرفوا بهذه الأسهم بعد انقضاء هذه الفترة إلا لمصلحة أشخاص يعينهم الوزير المختص، وكل ذلك - بالطبع - من اجل تحقيق قدر معين من السيطرة على إدارة الشركة الناجمة عن التحول، فان القول بمدى جواز تشكيل مجموعة المساهمين الثابتة من عدمه يستند بالأساس إلى إمكانية وضع الشروط التي تكفل تشكيل هذه المجموعة، وهي شرط المنع من التصرف، وشرط الأفضلية.

وفيما يتعلق بالشرط الذي يمنع المساهم من التصرف بأسهمه، فالملاحظ ان المشرع العراقي لم ينظم أحكامه سواء في قانون الشركات أم القانون المدني، لذلك فقد انقسم الفقه في العراق إلى رأيين، يذهب الأول منهما إلى أن شرط المنع من التصرف يعد استثناء خطيرا لا يثبت إلا بنص صريح، ولا يجوز التوسع فيه، في الحالات التي يقرر فيها المشرع هذا المنع⁽¹⁾، في حين يذهب الرأي الثاني إلى القول بان سكوت المشرع العراقي عن معالجة أحكام شرط المنع من التصرف يفسر على أساس انه

(1) شاكر ناصر حيدر، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، بغداد، 1971، ص 138-139. كذلك : د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، بغداد، 1960، ص 102.

ترك ذلك لأحكام القواعد العامة، ومن ثم يعد هذا الشرط صحيحاً طالما أنه غير ممنوع قانوناً ولا مخالف للنظام العام والآداب، وهذا يعني أنه يجب لكي يعد هذا الشرط صحيحاً أن يكون مؤقتاً وأن تكون هناك مصلحة تدعو إليه، سواء كانت هذه المصلحة هي مصلحة المشتري أم مصلحة المتصرف إليه أم مصلحة الغير⁽¹⁾.

وبالرغم من وجهة هذا الرأي الأخير، انقسم شراح قانون الشركات العراقي في مدى قبوله إلى رأيين أيضاً، وقد ذهب الرأي الأول⁽²⁾ إلى عدم جواز وضع أية شروط تمنع المساهم من التصرف بأسهمه باعتبار أن هذه الشروط هي استثناء، وأن الاستثناء لا يجوز افتراضه أو التوسع في أحكامه، ويستند هذا الرأي فيما يذهب إليه على أساس ضرورة إدراج الشروط الاتفاقية التي تحد من حرية المساهم في التصرف بأسهمه أن وجدت، في النظام الأساسي للشركة، وأن المشرع العراقي لم يجيز أن يكون للشركة نظام أساسي⁽³⁾، أما الرأي الثاني، فيذهب إلى أن الواقع العملي يشير إلى أن بعض الشركات تنظم حياتها الداخلية بتعليمات تشبه إلى حد كبير النظام، ودون أن يتسنى لمديرية تسجيل الشركات فرصة رقابتها، فوفقاً لهذا الرأي يمكن استحداث الشروط الاتفاقية التي تحد من حرية المساهم في التصرف بأسهمه بقرار يصدر من الهيئة العامة للشركة، بوصفها الجهة التشريعية في الشركة، والتي يكون لها أن تقرر كل ما يعود على الشركة بالمصلحة، ولها أن تقرر حل الشركة وتصفيته وتعديلها. على أن لا تؤدي هذه القيود إلى زيادة التزامات المساهمين، وأن لا تتعسف الشركة في فرضها⁽⁴⁾، ويبدو لنا، أن هذا الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب، إذ ليس في قانون الشركات العراقي، ما يمنع من تقييد حرية المساهم في التصرف بأسهمه، طالما أن شرط المنع من التصرف لن يؤدي إلى إبقاء المساهم حبيس أسهمه، وأنه مقرر

(1) د. غني حسون طه ومحمد طه البشير، الحقوق العينية، بغداد، 1982، ص 91.

(2) فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص 107.

(3) د. عدنان أحمد ولي، أحكام تأسيس الشركات في القانون العراقي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد 1-2، 1985، ص 222.

(4) د. عباس مرزوك فليح العبيدي، التصرف بالأسهم والحصص في الشركات بيعاً وهبة، المرجع السابق، ص 82.

لفترة محددة لمصلحة تدعو إلى ذلك، لذا نرى انه من الممكن للوزارة المعنية بعد تحويل الشركة العامة إلى القطاع الخاص، ان تبرم اتفاقا مع مجموعة من المساهمين، تلزمهم فيه بعدم التصرف بأسهمهم خلال فترة محددة، وعلى أن يعارضوا أي قرار يمكن أن يصدر من الهيئة العامة للشركة الناجمة عن التحول، إذا كان من شأنه حل الشركة أو اندماجها بشركة أخرى، أو أي قرار آخر يمكن أن يؤثر في استمرار الشركة، ما لم توافق الوزارة المعنية على هذا القرار، كما ونرى جواز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطا يمنع بمقتضاه المساهمون من بيع أسهمهم بعد انقضاء المدة التي يحضر عليهم خلالها التصرف بأسهمهم، إلا لمصلحة أشخاص تتولى الوزارة المعنية تعيينهم، عندما يرغب أحد المساهمين في بيع أسهمه، على أن يراعى في هذا الاتفاق، أن يتضمن تحديد الأسس التي يتحدد بموجبها سعر الأسهم عندما يراد شراؤها بموجب شرط الأفضلية، والمدة التي يجب خلال مباشرة هذا الحق بشراء الأسهم.

وعلى أية حال، فقد جرى العمل في العراق، على إدراج بعض القيود التي تحد من حرية المساهم في التصرف بأسهمه، فقد منع المساهمون من بيع أسهمهم في الشركات الناجمة عن تحويل، معمل طابوق القادسية ومعمل نسيج الديوانية ومعمل نسيج الناصرية ومعمل أسمنت المثنى إلى شركات مساهمة عامة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (140) لسنة 1993 الملغي، إذ تضمنت الإعلانات الخاصة ببيع أسهم هذه الشركات قيودا يمنع مشتري الأسهم من بيعها مرة ثانية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشراء⁽¹⁾، غير ان وزارة الصناعة والمعادن أجازت بعد ذلك لهؤلاء المساهمين بيع أسهمهم في هذه الشركات دون التقييد بفترة زمنية محددة⁽²⁾، والغاية من هذا القيد - حسب تقديرنا- هي تمكين وزارة الصناعة والمعادن من بيع أسهم هذه الشركات، ذلك ان عملية البيع تستغرق فترة طويلة نسبيا، لان البيع لا يكون إلا في يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع في سوق بغداد للأوراق المالية، عن طريق

(¹) انظر الملفات الخاصة بهذه الشركات في سوق بغداد للأوراق المالية.

(²) كتاب وزارة الصناعة والمعادن / الدائرة الاقتصادية والإنتاجية، الموجه إلى سوق بغداد للأوراق المالية، ذي الرقم (12983) في 1994/3/31.

المزاد العلني⁽¹⁾، ومما لاشك فيه انه إذا ما أُجيز للمساهم بيع أسهمه خلال الفترة التي تستغرقها عملية بيع الأسهم من قبل وزارة الصناعة والمعادن، فإن ذلك سيؤثر سلباً في عدد الأسهم المباعة وأسعارها، وبالتالي يكون من البديهي وضع شرط يمنع المساهم من بيع أسهمه في الشركة الناجمة عن التحول، خلال الفترة التي تستغرقها عملية بيع كافة أسهم الشركة الناجمة عن التحول أو معظمها على اقل تقدير⁽²⁾. وتجدر الإشارة إلى ان الواقع يشير إلى ان وزارة المالية قد تطلب من مسجل الشركات أن يقاتحها لغرض اخذ موافقتها، عند تصرف المساهمين بأسهمهم في الشركات السياحية المختلطة، التي تأسست جراء تحويل بعض المنشآت السياحية إلى القطاع الخاص، بناء على الأمر الصادر من السيد رئيس الجمهورية في 1988/1/27 ويعلل البعض⁽³⁾ موقف وزارة المالية، على أساس انه يستند إلى ان المساهم في هذه الشركات مدينا بجزء من قيمة أسهمه للوزارة المذكورة، والتي قامت ببيع أسهمها في هذه الشركات عن طريق المزاد العلني وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، ومن خلال مكتب تداول الأسهم في المصرف الصناعي، إذ أن الوزارة استوفت (50%) فقط من قيمة الأسهم المباعة، وتم تقسيط المتبقي على قسطين متساويين، مدة كل قسط عام واحد، وقد تم وضع شارة عدم التصرف بهذه الأسهم في سجلات الشركات المصدرة لها، ويستند طلب الجهة القطاعية المختصة - وفقاً لهذا الرأي - إلى معيار المصلحة العامة والحفاظ على أموال الدولة من الضياع، وهذا القيد

(1) ملف شركة طابق القادسية في سوق بغداد للأوراق المالية.

(2) ويشير البعض إلى انه مع بداية العمل في سوق بغداد للأوراق المالية أشار تعميم صادر من اللجنة الوزارية إلى منع المشتري من التصرف بأسهمه للغير إلا بعد مضي ثلاثة اشهر - على تاريخ شرائه لها، وذلك بهدف منع المضاربة وتنظيم تداول الأسهم، إلا انه بعدما استقرت أعمال سوق بغداد الغي التعميم المذكور واصبح المشتري حراً في بيع أسهمه في أي وقت يشاء بعد شرائها.

د. عباس مرزوك فليح العبيدي، التصرف بالأسهم والحصص بيعاً وهبة، المرجع السابق، ص 136.

(3) د. عباس مرزوك فليح العبيدي، التصرف بالأسهم والحصص بيعاً وهبة، المرجع السابق، ص 99.

على تداول الأسهم لا يستند إلى نظام الشركة أو قانون الشركات، أي انه لا يعد من القيود النظامية رغم اتفاقه مع هذه الأخيرة في النتيجة من حيث انه يؤدي إلى تقييد حرية المساهم في التصرف بأسهمه. ونتفق مع الرأي المتقدم، في أن دواعي المصلحة العامة، قد تستلزم في بعض الأحيان، فرض بعض القيود على حرية تداول الأسهم، غير أننا نؤكد على ضرورة انسجام هذه القيود مع أحكام القانون، إذ لا يجوز فرض أية قيود تحد من حرية المساهم في التصرف في أسهمه من قبل الجهة القطاعية المختصة، إلا إذا كانت هذه القيود، متفقا عليها مع المساهمين في الشركة، أو أنها مقررّة بقواعد قانونية صريحة، وان لا تؤدي إلى حرمان المساهم من التصرف في أسهمه بشكل مطلق، لما في ذلك من تعارض مع طبيعة الأسهم من حيث إنها قابلة للتداول.

وتأسيسا على ما تقدم، نقترح على المشرع العراقي أن ينظم القيود الاتفاقية التي تحد من حرية تداول الأسهم، بنصوص قانونية واضحة، من شأنها أن تمنع أي خلاف قد يثار حول مدى مشروعية مثل هذه القيود من عدمها.

الخاتمة

نبرز في خاتمة هذا الكتاب أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها وكما يأتي:

أولاً. النتائج

1. منع المشرع العراقي الأجنبي من التملك والاستثمار في الشركات داخل العراق وبأي وجه كان وإذا كان من شأن هذا الحكم أن يمنع السيطرة الأجنبية على الشركات العراقية فإنه قد يفوت على هذه الشركات فرصة التطور عن طريق بيع اسهم الشركات العامة لشريك استراتيجي وهو أجنبي في الغالب، ويمتلك المعرفة الفنية والتكنولوجية.
2. إن الأموال التي يصح تحويلها إلى القطاع الخاص هي أموال الدول الخاصة ولا سيما تلك التي تتخذ شكل وحدات اقتصادية (مشروعات عامة)، ولا يصح تحويل أموال الدولة العامة إلى القطاع الخاص.
3. لا يجوز وفقاً للدستور العراقي لسنة 1970، أن يكون الهدف من التحويل إلى القطاع الخاص، التحويل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، كما ولا يجوز تحويل وسائل الإنتاج الأساسية والثروات الطبيعية إلى القطاع الخاص، إذ يجب تستثمر الدولة هذه الثروات استثماراً مباشراً، لذلك نلاحظ أن عمليات التحويل إلى القطاع الخاص التي جرت في العراق لم تتناول وسائل الإنتاج الأساسية والثروات الطبيعية، وإنما شملت بعض المعامل الصغيرة نسبياً، وبعض المنشآت السياحية.
4. لم ينظم المشرع العراقي عملية إعادة هيكلة المشروعات العامة، بحيث يسهل تحويلها إلى شركات خاصة أو مختلطة من خلال تنظيمه لهذه المشروعات العامة في قانون الشركات العامة، وذلك بالرغم من أن هذا القانون قد قضى بتحويل جميع الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع الاشتراكي الممولة ذاتياً والتي تمارس نشاطاً اقتصادياً إلى شركات عامة. إذ أن هذه الشركات لا تخضع للنظام القانوني الذي

- تخضع له الشركات الخاصة، في حين أن عملية إعادة الهيكلة تقتضي تحويل المشروعات العامة إلى شركات مساهمة تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
5. تخضع عمليات التحويل إلى القطاع الخاص في العراق لقانون الشركات العامة ذي الرقم (22) لسنة 1997، وقانون بيع وإيجار أموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 وقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (100) لسنة 1995، ويترتب على ذلك النتائج الآتية:
- I. إن قرار التحويل قد يصدره وزير الصناعة والمعادن أو وزير النقل والمواصلات وبحسب الجهة التي يتبعها المشروع العام، كما أن تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة، يستلزم موافقة مجلس الوزراء على عملية التحويل، في حين أن التحويل إلى القطاع الخاص الذي يتم عن طريق بيع الأصول كالمعامل والفنادق على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة لا يقتضي موافقة مجلس الوزراء على عملية البيع.
- II. إن عدم وجود جهة خاصة تتولى الإشراف على عمليات التحويل إلى القطاع الخاص في العراق، يعد من ضمن الأسباب التي أدت إلى الاختيار غير الدقيق لبعض المشروعات العامة التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى نزع ملكية هذه المشروعات وإعادتها إلى القطاع الاشتراكي مجدداً.
6. خول المشرع العراقي الوزارة المعنية، صلاحية تحديد قواعد تقييم اسهم الشركة العامة عند تحويلها إلى شركات مساهمة، وهذا يعني أن الوزارة المعنية، غير ملزمة باتباع القواعد والإجراءات الخاصة بالتقييم الوارد في قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
7. ثمة تعارض بين المادة (36) من قانون الشركات العامة والمادة (37) منه، فالمادة (36) تجيز للوزارة المعنية بيع اسهم الشركة العامة عند تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة أو مختلطة، بأية وسيلة تراها مناسبة في حين أن المادة (37) تستلزم إجراء اكتتاب عام باسهم الشركة الناجمة عن التحويل على أساس أن هذه المادة

تنص على انقضاء الشخصية المعنوية للشركة العامة جراء التحول وتأسيس شركة جديدة.

8. لا يجوز عند تحويل الشركة العامة تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها من قبل الجمهور، ذلك أن قيمة الأسهم التي تحتفظ بها الوزارة تعد مدفوعة بالكامل والمادة (48 / أولا) من قانون الشركات العراقي لا يجيز تقسيط قيمة الأسهم المكتتبه بها من قبل الجمهور إلا إذا شمل هذا التقسيط بقية المؤسسين أي الوزارة المعنية.

9. إن بيع اسهم الشركات العامة أو المعامل المملوكة للقطاع الاشتراكي بالمزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986، لا ينسجم مع الأحكام الأخرى الواردة في التشريع العراقي والخاصة بالتحويل الى القطاع الخاص، والتي تقتضي ان تتم عملية التحويل من خلال تأسيس شركة جديدة وطرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمتها الاسمية المحددة بنص القانون وهي (دينار واحد)، كما أن بيع الأسهم بالمزايدة العلنية يجب أن يتم عن طريق بيعها على شكل (حزم) تتضمن الواحدة منها، عددا محددا من الأسهم (خمسة آلاف سهم) مثلا مما يؤدي إلى حرمان ذوي الدخل المحدود من استثمار أموالهم في اسهم هذه الشركات.

10. إن تخصيص نسبة معينة من اسهم الشركة العامة المحولة لمنتسبي الشركة للاكتتاب بها كمساهمين من شأنه أن يحول دون تطبيق الأساليب غير المباشرة لتملك العاملين لأسهم الشركات العامة، والتي تستلزم أن يكون رأسمال الشركة العامة مقسما إلى اسهم لكي تتولى جهة معينة شراء الأسهم لمصلحة منتسبي الشركة كتأسيس اتحاد للعمال في الشركة لكي يتولى القيام بهذه المهمة، أو قيام الشركة العامة نفسها بشراء أسهمها لمصلحة العاملين فيها، لكي تتولى بيعها لهم مرة ثانية، فضلا عن أن اتباع أسلوب الاكتتاب العام يحول دون إمكانية منح مزايا خاصة لمنتسبي الشركة العامة عند تحويلها إلى شركة مساهمة كتخفيض قيمة الأسهم المخصصة للمنتسبين أو تقسيطها.

11. إن الاندماج بين الشركات العامة من جهة والخاصة أو المختلطة من جهة أخرى، يمكن أن يتحقق وفقا للتشريع العراقي في جميع الحالات التي تنقضي- فيها الشركة العامة لمصلحة شركة خاصة أو مختلطة، وهي حالة الاندماج بالمزج، وحالة الاندماج بالضم التي تتم عن طريق انضمام شركة عامة إلى شركة خاصة أو مختلطة.

ففي هذه الحالات ستكون الشركة الناجمة عن الاندماج شركة خاصة أو مختلطة، وبحسب النسبة التي يملكها القطاع الاشتراكي في رأسمال الشركة الناجمة عن الاندماج.

12. لا يمكن طبقاً لأحكام قانون الشركات العامة العراقي، تحويل الشركة العامة إلى شركة مساهمة خاصة أو مختلطة عن طريق زيادة رأسمالها بطرح اسهم للاكتتاب العام، ذلك أن رأسمال الشركة العامة لا يقسم إلى اسهم أساساً فضلاً عن أنه لا يجوز للقطاع الخاص أن يمتلك جزءاً من رأسمال الشركة العامة.

13. لا يمكن تحويل الشركات المختلطة إلى شركات خاصة عن طريق بيع أسهمها للقطاع الخاص، بيد أن عملية التحويل تكون متصورة عن طريق اندماج الشركات المختلطة بالشركات الخاصة، وكذلك عن طريق زيادة رأسمال الشركة المختلطة بأموال يقدمها القطاع الخاص.

14. يترتب على تحول الشركة العامة وفقاً للتشريع العراقي أن تنقضي الشخصية المعنوية للشركة العامة وينتقل مشروعها الاقتصادي إلى الشركة الناجمة عن التحويل، غير أن الشركة العامة لا تفقد شخصيتها المعنوية إلا من تاريخ اكتساب الشركة الناجمة عن التحويل لشخصيتها المعنوية وذلك ابتداءً من تاريخ آخر نشر لقرار التحويل.

15. يمكن أن تتخذ الشركة الناجمة عن التحويل شكل الشركة المساهمة الخاصة أو المختلطة وتتولى الوزارة المعنية تأسيس هذه الشركة طبقاً لإجراءات خاصة، إذ تقتصر مستلزمات تأسيس الشركة الناجمة عن التحويل على قيام الوزارة بإعداد عقد جديد لهذه الشركة، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على عملية التحويل.

16. تنتقل حقوق والتزامات الشركة العامة كافة إلى الشركة الناجمة عن التحويل بوصفها خلفاً عاماً لها، مع ملاحظة أن هذه الخلافة تختلف عن الخلافة العامة المقررة في القواعد العامة، إذ أنها تقتضي انتقال كافة الالتزامات من الشركة السلف إلى شركة الخلف، ودون أن يراعى في هذا الانتقال القواعد الخاصة بالميراث، والتي تتعلق بوفاء الشخص الطبيعي.

17. تنتقل عقود الإيجار التي تبرمها الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول بوصفها خلفا عاما لها، وحتى لو عد هذا الانتقال بمثابة تنازل عن الإيجار، فإن ذلك لا يتعارض مع أحكام القانون المدني العراقي الذي يجيز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار للغير بمقابل أو دون مقابل.
18. يعد انقضاء الشركة العامة (المرخص لها) بموجب عقد الترخيص جراء عملية التحول سببا لانتهاء هذا العقد لما يؤدي إليه هذا الانقضاء من انهيار للاعتبار الشخصي. في عقد الترخيص التجاري، ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك، إذ قد يجيز المرخص للمرخص له، أن يتنازل بمقابل أو دون مقابل عن الحقوق الناشئة عن عقد الترخيص.
19. إن وصف (السهم) لا ينطبق على ما يعرف بالسهم الخاص، إذ أن هذا الأخير يختلف عن الأسهم العادية من حيث الخصائص الجوهرية والحقوق والالتزامات المرتبطة به، فما يعرف بالسهم الخاص ما هو في حقيقة الأمر إلا نظام قانوني للرقابة على الشركات الناجمة عن التحول، وهو مقرر بقواعد قانونية أمره لا سبيل للاتفاق على مخالفتها، كما انه يتعلق بالنظام العام لارتباطه بفكرة المصلحة العامة، ومن ثم لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسير القواعد القانونية التي تنظمه.
20. لا توجد أية ضرورة تدعو المشرع العراقي إلى تبني فكرة السهم الخاص المعروفة في القوانين المقارنة، ذلك أن القواعد الواردة في قانون الشركات العراقي تقرر نوعا من الرقابة على نشاط الشركات الناجمة عن التحول وشأنها في ذلك شأن بقية الشركات التي يؤسسها ابتداء القطاع الخاص أو المختلط وهذه الرقابة تغني المشرع العراقي عن تبني فكرة السهم الخاص.
21. إن للوزارة المعنية بعد تحويل الشركة العامة أن تبرم اتفاقا مع مجموعة من المساهمين يلتزم بمقتضاه هؤلاء المساهمون بعدم التصرف بأسهمهم خلال مدة محددة، وبمعارضة أي قرار يمكن أن يصدر من الهيئة العامة للشركة الناجمة عن التحول، إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى حل الشركة أو اندماجها بشركة أخرى، أو أي قرار آخر يمكن أن يؤثر في استمرار الشركة، ما لم توافق الوزارة المعنية على هذا

القرار، كما ويمكن أن يتضمن هذا الاتفاق شرطاً يمنع بمقتضاه المساهمون من بيع أسهمهم بعد انقضاء المدة التي يحظر عليهم خلالها التصرف بأسهمهم إلا لمصلحة أشخاص تتولى الوزارة المعنية تعيينهم عندما يرغب أحد المساهمين في بيع أسهمه، على أن يراعى في هذا الاتفاق أن يتضمن تحديد الأسس التي يتحدد بموجبها سعر الأسهم عندما يراد شراؤها بموجب شرط الأفضلية والمدة التي يجب خلالها مباشرة هذا الحق.

ثانياً. التوصيات

1. نقترح على المشرع العراقي، أن ينظم عملية إعادة هيكلة الشركات العامة قبل تحويلها إلى شركات مساهمة بحيث يتم تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة تعمل على وفق الأسس التجارية، وتخضع لقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، وتكون جميع أسهم هذه الشركة مملوكة للوزارة المعنية، على أن يدير هذه الشركة مدير ومجلس إدارة يعينهم الوزير المختص يتولون إدارة الشركة لحين تحويلها إلى القطاع الخاص، وعلى أن تحل هذه الشركة محل الشركة العامة في كافة حقوقها والتزاماتها، ابتداءً من تاريخ اكتساب الشركة المساهمة للشخصية المعنوية، ثم تتولى الوزارة المعنية تحويل هذه الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مختلطة وبالطريقة التي تراها مناسبة.
2. يجب أن تناط مهمة الإشراف على عمليات التحويل إلى القطاع الخاص بوزير معين (كوزير المالية) مثلاً، بحيث يتولى هذا الوزير الإعداد لعمليات التحويل إلى القطاع الخاص، من حيث اختيار المعامل أو الشركات العامة لغرض تحويلها إلى القطاع الخاص، وتحديد شروط البيع وقواعده واتخاذ القرار الخاص بتحديد السعر النهائي للبيع، فضلاً عن سلطته في مطالبة مديري الشركات العامة أو من يقوم مقامهم باطلاعه على الوثائق الضرورية لعملية التحويل، كما ونقترح تشكيل لجنة تتولى مساعدة الوزير المختص في هذه المهام، على أن تضم هذه اللجنة عدداً من الخبراء (سبعة) مثلاً في الأمور الاقتصادية والمالية والقانونية ويتأسس هذه اللجنة الوزير المختص، وتتولى هذه اللجنة الإشراف على عمليات التحويل إلى القطاع الخاص وتقديم

- تقارير دورية عن هذه العمليات للوزير المختص، وتقديم التوصيات بشأن إجراء البيع خارج سوق الأوراق المالية، ومراجعة تقييم اسهم الشركات العامة وغير ذلك من الأمور الفنية الأخرى.
3. يجب أن تتم المصادقة على جميع عمليات التحويل إلى القطاع الخاص، سواء تمت عن طريق بيع الموجودات وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، أو عن طريق تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة، وفقاً لقانون الشركات العامة، من قبل مجلس الوزراء، فلا مسوغ للتمييز بين الحالتين خاصة وأن المقصود بالموجودات التي تباع وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة هي الموجودات ذات القيمة المرتفعة والتي يمكن أن تشكل وحدة اقتصادية مستقلة كالمعامل والفنادق.
4. من الضروري أن تناط مهمة تقييم الشركات العامة عند تحويلها إلى القطاع الخاص باللجنة التي سبق وأن اقترحنا تشكيلها لغرض مساعدة الوزير المختص في الإعداد والتنفيذ لعمليات التحويل إلى القطاع الخاص، بحيث تختص هذه اللجنة بإجراء التقييم سواء تم البيع على شكل أصول أو على شكل اسهم، على أن تتم عملية التقييم أول الأمر من قبل خبراء يتم التعاقد معهم بواسطة هذه اللجنة ثم يصار بعد ذلك إلى مراجعة هذا التقييم من اللجنة نفسها، بحيث يخول أعضاء هذه اللجنة الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لعملية التقييم، ويجب أن يحظر على أعضاء هذه اللجنة أن يملكوا الأسهم أو الأصول التي كانت محلاً للتقييم، كما ويجب أن يشمل هذا الحظر أزواج أعضاء هذه اللجنة وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، كما ويجب أن يحظر على هؤلاء أن يشغلوا منصب المدير المفوض أو عضوية مجلس الإدارة في الشركات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص.
5. نقترح على المشرع العراقي أن ينظم أساليب بيع اسهم الشركات العامة، ويجعل من أسلوب العرض العام الأساس في عملية التحويل مع إمكانية التعاقد عن طريق تقديم العطاءات في الحالات الاستثنائية التي يقدر المشرع أهميتها.
6. يحبذ لو أن المشرع العراقي يجيز للشركات العامة إصدار سندات قرض تخول أصحابها الحق في استبدالها باسهم الشركات العامة، عند تحويلها إلى القطاع الخاص، لما يترتب على ذلك من مزايا تتمثل بالتيسير على الأفراد في وفاء قيمة

- الأسهم التي يشترونها، فضلا عن إمكانية تقدير الطلب على اسهم الشركات العامة، قبل تحويلها إلى القطاع الخاص.
7. من الضروري تنظيم الإجراءات التي تكفل تقسيط قيمة اسهم الشركات العامة عند تحويلها إلى القطاع الخاص وذلك لتمكين الأفراد من ذوي الدخل المحدود من تملك اسهم الشركات العامة عند تحويلها إلى القطاع الخاص، لتوسيع قاعدة الملكية.
8. يجب عند بيع اسهم الشركات العامة، تخصيص نسبة معينة من اسهم هذه الشركات لتباع للمنتسبين العاملين فيها، ويمكن أن يتم البيع في هذه الحالة بشكل مباشر، مع منحهم مزايا خاصة، كالببيع بسعر مخفض أو عن طريق البيع بالتقسيط، دون أن يشمل ذلك، بقية الأسهم التي تباع للجمهور، كما ويمكن أن يتم البيع بشكل غير مباشر، كان تقوم الشركة العامة بشراء الأسهم المخصصة للعاملين في الشركة ثم تتولى إعادة بيعها لهم مرة ثانية، وتستوفي ثمن الأسهم من الأرباح المخصصة لهؤلاء العاملين، أو أن يتأسس اتحاد للعاملين في الشركة يتولى شراء أسهمها لمصلحتهم.
9. ندعو المشرع العراقي، إلى تنظيم عملية الاندماج التي تتم بين الشركات العامة والخاصة، بنصوص قانونية صريحة، ذلك أن هذا الأسلوب للتحويل يتميز بأنه يحقق ميزة التكامل الأفقي أو الرأسي بين الشركات العامة وشركات القطاع الخاص.
10. ندعو المشرع العراقي إلى تنظيم عملية تحويل الشركات العامة عن طريق زيادة رأسمالها بأموال يقدمها القطاع الخاص، ذلك أن هذا الأسلوب يعد ملائماً إلى حد كبير للشركات العامة التي تكون بحاجة إلى تمويل إضافي لدعم قدراتها الاقتصادية في الوقت الذي قد لا ترغب فيه الوزارة المعنية أو لا تستطيع فيه دعم الشركة من رأس المال العام، كما أن هذا الأسلوب يعد مناسباً للشركات العامة التي لها أهمية اقتصادية ترتبط بالاقتصاد الوطني، فتفضل الوزارة أن تحتفظ بجزء كبير من رأسمالها بعد تحويلها إلى القطاع الخاص.
11. نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة (55) من قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997، بما يسمح بتقديم الحصة العينية عند زيادة رأس مال الشركة المساهمة أو المحدودة، لما لهذا الحكم من اثر في تدعيم القدرة الفنية

- والاقتصادية للشركة، الأمر الذي يجعل من زيادة رأس المال أسلوباً فعالاً في تحويل الشركة المساهمة المختلطة إلى شركة مساهمة خاصة عن طريق تقديم بعض الأصول المملوكة للقطاع الخاص (كالمعامل) مثلاً كحصة عينية في الشركة المساهمة المختلطة.
12. يفضل لو أن المشرع العراقي يميز تحويل الشركات المختلطة عن طريق بيع أسهمها، مادام أنه أجاز تحويل الشركات العامة إلى خاصة أو مختلطة، وما دام ذلك يتفق مع سياسة الدولة الاقتصادية ويحقق المصلحة العامة.
13. ندعو المشرع العراقي إلى تطبيق قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 على منتسبي الشركات العامة، الأمر الذي يسمح بانتقالهم تبعاً لمشروع الشركة العامة إلى الشركة الناجمة عن التحول، لأن نقل المشروع الاقتصادي من الشركة العامة إلى الشركة المساهمة الخاصة أو المختلطة دون العاملين فيه قد يؤثر سلباً في نشاط المشروع، لا سيما إذا كان العمل في المشروع يقتضي توافر خبرات معينة، لا تتوافر في غير العاملين في المشروع، كما أن هذا الأمر يوفر على الدولة ما قد تبذله من جهود من أجل إيجاد فرص عمل بديلة لمنتسبي الشركة العامة بعد تحويلها إلى القطاع الخاص.
14. ندعو المشرع العراقي إلى النص صراحة على انتقال حقوق والتزامات الشركة العامة كافة إلى الشركة الناجمة عن التحول فهذا الانتقال يعد ضرورة لا غنى عنها في عملية التحول، وبخلافه لا يمكن أن تتحقق الأهداف المتوخاة من عملية التحول بوصفه أداة لتحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص من أجل دعمها وتطويرها.
15. نقترح على المشرع العراقي أن ينظم القيود الاتفاقية التي تحد من حرية تداول الأسهم، بنصوص قانونية واضحة من شأنها أن تمنع أي خلاف قد يثار حول مدى مشروعية مثل هذه القيود من عدمها.
16. ندعو المشرع العراقي إلى إصدار قانون (خاص) بعمليات التحول إلى القطاع الخاص، يضم جميع الأحكام القانونية الخاصة بهذه العملية من حيث تنظيم عملية إعادة هيكلة المشروعات وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على عملية التحول

وإجراءات تقييم الشركات العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص وأساليب هذا التحويل وآثاره القانونية وذلك على وفق التوصيات التي أشرنا إليها فيما تقدم.

﴿والحمد لله رب العالمين﴾

المراجع

أولاً. المراجع العربية

الكتب:

1. د. احمد إبراهيم البسام، الشركات التجارية في القانون العراقي، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الثانية، 1961.
2. د. احمد حسني، قضاء النقض التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983.
3. د. احمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء السادس، شركات الأموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة، دار نشر المعرفة، الرباط، 1992.
4. د. احمد ماهر، دليل المدير في التخصص، مركز التنمية الإدارية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، بدون تاريخ نشر.
5. د. احمد محمد محرز، النظام القانوني لتحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص، التخصص، القاهرة، 1995.
6. د. أميرة صدقي، النظام القانوني لشراء الأسهم من جانب الشركة المصدر لها، القاهرة، 1993.
7. الياس نصيف، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجارية، منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات، بيروت - باريس، ط1، 1982.
8. د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، ط2، 1992.
9. د. باسم محمد صالح، د. عدنان احمد ولي، القانون التجاري، الشركات التجارية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1989.
10. د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع-الإيجار-المقاوله، مطابع التعليم العالي، الموصل، 1989.

11. د. حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، طظ يا عاشور، دار الشروق، القاهرة، ط1، 1998.
12. د. حسام الدين عبد الغني الصغير، الترخيص باستعمال العلامة التجارية، دار الكتب القومية، القاهرة، 1993.
13. د. حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1987.
14. د. حسام الدين عبد الغني الصغير، بيع اسهم شركات قطاع الأعمال للعاملين في إطار البرنامج الحكومي لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، برنامج الخصخصة، دار الفكر العربي ودار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
15. د. حسن النجفي، سوق الأوراق المالية، البورصة، مكتبة الخلفاء، بغداد، 1992.
16. د. حسن على الذنون، شرح القانون المدني، أصول الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.
17. د. حسني المصري، القانون التجاري، الكتاب الثاني، شركات القطاع الخاص، مطبعة حسان، القاهرة، ط1، 1986.
18. د. حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، مطبعة حسان، القاهرة، الطبعة الأولى، 1986.
19. د. حسني المصري، مدى حرية الانضمام إلى الشركة والانسحاب منها، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985.
20. د. حميد الجميلي، حلقة نقاشية، استشراف مستقبل الاقتصاد العربي في ظل المتغيرات الدولية، بيت الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، تموز، 1997.
21. د. خالد الشاوي، شرح قانون الشركات التجارية العراقي، ط1، بغداد، 1968.
22. د. ربيع صادق دحلان، الاتجاهات المعاصرة في إدارة المشروعات العامة، التحول إلى القطاع الخاص، دار البلاد للطباعة والنشر، جدة، ط1، 1988.
23. د. رضا عبد الحميد السيد، شرح قانون شركات قطاع الأعمال العام، القاهرة، 1993.

24. د. رفيق عبد السلام، الحماية الجنائية للمال العام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1994.
25. د. سعاد الشرفاوي، القانون الإداري وتحرير الاقتصاد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
26. د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، آ مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، ط2، 1989.
27. د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1996.
28. شاكِر ناصر حيدر، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، بغداد، 1971.
29. د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، بغداد، 1960.
30. د. صلاح الدين الناهي، الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي، ج2، ط2، بدون تاريخ نشر.
31. د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات العراقي، جامعة الموصل، الطبعة الثانية، 1997.
32. د. عباس مرزوك فليح العبيدي، الاكتتاب برأسمال الشركة المساهمة، دراسة قانونية وعملية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998.
33. د. عبد الحكيم فودة، شركات الأموال والعقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديد رقم (3) لسنة 1991، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2000.
34. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967.
35. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964.
36. د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الرابعة، 1974.

37. د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1980.
38. د. عبد الوهاب مطر الداهري، تقييم المشاريع ودراسة الجدوى الاقتصادية، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1990.
39. د. عصمت عبد المجيد بكر، أحكام بيع وإيجار أموال الدولة، دراسة في ضوء القانون رقم 32 لسنة 1986، مطبعة الخيرات، بغداد، 2000.
40. د. علي البارودي، القانون التجاري، القطاع العام وفقاً للقانون 97 لسنة 1983-المنشأة التجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1986.
41. د. علي البارودي، د. محمد فريد العريني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987.
42. د. علي العريف، شرح القانون التجاري المصري، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1965.
43. د. علي حسن يونس، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1963.
44. د. علي حسن يونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ نشر.
45. د. علي محمد بدير، د. عصام البرزنجي، د. مهدي السلامي، مبادئ واحكام القانون الإداري، بغداد، 1999.
46. د. غسان القلعاوي، القطاع العام إلى أين ؟ دار المكتبي، دمشق، ط1، 1995.
47. د. غني حسون طه ومحمد طه البشير، الحقوق العينية، بغداد، 1982.
48. د. فايز نعيم رضوان، عقد الترخيص التجاري، مطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1990.
49. د. فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام، عالم الكتب، القاهرة، 1973.
50. د. فوزي عطوى، القانون التجاري، دار العلوم العربية، بيروت، 1986.

51. د. فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة، مكتبة دار الثقافة للنشر- والتوزيع، عمان، 1999.
52. كامل عبد الحسين البلداوي، الشركات التجارية في القانون العراقي، مطابع التعليم العالي، الموصل، 1990.
53. د. لطيف جبر كومان، د. علي كاظم الرفيعي، القانون التجاري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر- بغداد.
54. د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999.
55. ماري شارلي، جون نبليس، إصلاح المشروعات العامة، دروس من التجربة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 1995.
56. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القانون الإداري، مطبوعات جامعة الموصل، 1989.
57. د. محسن احمد الخضير، الخصخصة، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1993.
58. د. محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967- 1968.
59. د. محمد صبري بن اونج، الخصخصة، تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، الأردن، ط1، 2000.
60. د. محمد علي آل ياسين، القانون الإداري، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ نشر.
61. د. محمد كامل أمين ملش، الشركات تأسيسها وإدارتها، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، 1957.
62. د. محمد مختار احمد بريري، قانون المعاملات التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987.
63. د. محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، دراسة تطبيقية، مطبعة عبير للكتاب والأعمال التجارية، القاهرة، 1988.

64. د. محمود سالم، قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، دوره في برنامج الإصلاح الاقتصادي ودور المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام في تصحيح مسيرة شركات قطاع الأعمال العام، مطبعة الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية، القاهرة، 1997.
65. د. محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
66. د. محمود صبح، الخصخصة ماذا ؟ متى ؟ لماذا ؟ كيف ؟، المشكلات والحلول، البيان للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1999.
67. د. مرتضى ناصر نصر الله، الشركات التجارية، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1966.
68. د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 1996.
69. د. منير إبراهيم هندي، أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة، خلاصة الخبرات العالمية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إدارة البحوث والدراسات، القاهرة، 1995.
70. د. موسى اللويزي، التنمية الإدارية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الطبعة الأولى، 2000.
71. د. هاني الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 1997.
72. د. يعقوب يوسف صرخوة، الأسهم وتداولها في الشركات المساهمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.

البحوث والموسوعات

73. د. إبراهيم طه الفياض، الشركات العامة، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والتطور في المجتمع العراقي، المعقود في كلية الحداثة الجامعة، الموصل 24-25 آذار، 2001.
74. د. إبراهيم محمد الحمود، الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة، دراسة تحليلية نقدية مقارنة، مجلة الحقوق، السنة الثانية والعشرون، العدد الثاني، 1998.
75. إدريس بن علي، التجربة المغربية في الخصخصة، بحث مقدم إلى ندوة التحول إلى القطاع الخاص، تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إدارة البحوث والدراسات، القاهرة، 1996.
76. د. آدم مهدي احمد، الخصخصة في البلدان العربية، نماذج الخصخصة، بحث مقدم إلى المؤتمر العشرون لاتحاد المحامون العرب، بيروت 20-24 آذار، 2001.
77. أولف فان درهوفن ومسعود كرشناس وجورجي شيماساكي، التخصيص وقضايا العمل والعمال في سياق الإصلاح الاقتصادي، بحث مقدم إلى مؤتمر الآثار الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي في الدول العربي، صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ابو ظبي، كانون الثاني، 1991.
78. د. احمد النمري، الخصخصة، مالها وما عليها، مجلة المهندس الأردني، العدد (67)، السنة (34) آب، 1999.
79. د. احمد صقر عاشور، سياسة خصخصة المشروعات العامة، وركائزها ومقومات نجاحها، ندوة التحول إلى القطاع الخاص، تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إدارة البحوث والدراسات، القاهرة، 1995.
80. الضو نعيم احمد، الاقتصاد القطري ومنهج الخصخصة، ندوة توجهات وافاق الخصخصة في قطر، الدوحة 7/6 نيسان، 1996، غرفة تجارة وصناعة قطر، ط2، 1997-1998.

81. الموسوعة المغربية في التشريع والقضاء، الدار العربية للموسوعات، المجلد(23)، بدون تاريخ نشر.
82. د. عبدالفضيل محمد احمد، حماية الأقلية من قرارات أغلبية المساهمين في الجمعيات العامة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الأول، السنة الأولى، 1986.
83. د. حسن الفكاهاني، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، الإصدار المدني، ملحق (8)، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، بدون تاريخ نشر.
84. صدقي حسين سليمان، الجانب القانوني للخصخصة، بحث مقدم إلى ندوة توجهات وفاق الخصخصة بدولة قطر، الدوحة، 7/6 نيسان، 1996، غرفة صناعة وتجارة قطر، ط2، 1997-1998.
85. عاطف الدغمي، استراتيجية الخصخصة في البلدان النامية، مجلة المهندس الأردني، العدد (67) السنة (34)، آب، 1999.
86. عبد الحسين وداي العطية، الخصخصة (Privatization) في البلدان النامية: إيجابياتها وسلبياتها، مجلة دراسات، المجلد 45، العدد (1)، كانون الثاني، 1998.
87. د. عبد المنعم السيد علي، تجربة العراق مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة، بحث مقدم إلى ندوة القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية والصندوق العربي للإيماء الاقتصادي والاجتماعي، بيروت 1990.
88. د. عدنان احمد ولي، أحكام تأسيس الشركات في القانون العراقي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد 1-2، 1985.
89. علاء خليفة، التخاصية، نظرة شاملة، مجلة المهندس الأردني، العدد (67)، السنة 34، آب، 1999.
90. د. علي الخطار، عقد امتياز المرافق العامة وتطبيقاته في الأردن، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد السابع، العدد الخامس، 1992.

91. علي حسين علي، التخصص، مفاهيم ومحاذاير، مجلة التجارة والصناعة، أيلول، 1995.
92. فريدة علي أبو الفتح، التخصص في الدول المتقدمة والنامية، دروس مستفادة، مجلة التجارة والصناعة، العدد الثالث والثلاثون، 1997.
93. كامل عبد الحسين البلداوي، مهند إبراهيم الجبوري، زيادة رأسمال الشركة المساهمة في التشريع العراقي، مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون، جامعة المصل، العدد العاشر، آذار، 2001.
94. محمد العليج، حصيلة وافاق عملية الخوصصة في المغرب (1989-1996)، بحث مقدم إلى ندوة الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الخوصصة في البلدان العربية، المعقودة في المركز الوطني للدراسات والتحليل الخاصة بالتخطيط، الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1999.
95. د. محمد أمين عودة، مفاهيم وصور أشكال التحول إلى القطاع الخاص، بحث مقدم إلى ندوة التوجهات المستقبلية للتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، 1995.
96. د. محمد محمود الإمام، محددات الأداء الاقتصادي لكل من القطاعين العام والخاص في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية والصندوق العربي للإيماء الاقتصادي والاجتماعي، بيروت، 1990.
97. د. محمد ميدون، التجربة التونسية في التخصص، ندوة التحول إلى القطاع الخاص، تجارب عربية في تخصصية المشروعات العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إدارة البحوث والدراسات، القاهرة، 1996.
98. د. محمود حسين الراوي، الآثار الاقتصادية للتخصص في ظل العولمة مع إشارة إلى تجربة الأردن، بحث مقدم إلى المؤتمر الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء الأهلية، العولمة وابعادها الاقتصادية، 8-10 آب، 2000، ط1، 2001.

99. د. منير إبراهيم هندي، التجربة المصرية في الخصخصة، بحث مقدم إلى ندوة التحول إلى القطاع الخاص، تجارب عربية في خصخصة المشروعات العامة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 1996.
100. د. ميرغني عبد العال حمور، مؤسسات القطاع العام في مفترق الطريق بين إمكانيات التطوير واحتمالات الخصخصة، دراسة نظرية، بحث مقدم إلى ندوة التوجهات المستقبلية للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي، المنامة - البحرين، 27-28 آذار، 1995.
101. د. ميرغني عبد العال حمور، الخصخصة، المفاهيم والتجارب والدروس، ندوة توجهات وافاق الخصخصة بدولة قطر، الدوحة 7/6 نيسان، 1996، غرفة صناعة وتجارة قطر، ط2، 1997-1998.
102. وارن ريدل، خبرات عالمية في تطبيق برامج الخصخصة، بحث مقدم إلى ندوة التوجهات المستقبلية للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي، غرفة تجارة وصناعة البحرين، 1995.

ج. الرسائل الجامعية

103. زينة غانم عبد الجبار الصفار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000.
104. صهيب موسى جفال المومني، الجوانب القانونية للتخاصية في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 1997.
105. عباس مرزوك فليح العبيدي، التصرف بالأسهم والحصص في الشركة بيعاً أو هبة، دراسة قانونية وعملية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1997.
106. فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في الشركة المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 1991.

107. فوزي حسين سلمان، حق الملكية ازاء اتجاهات الدولة في التأمين والتخصيصية، دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والفرنسي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية صدام للحقوق، 2001.
108. مهند إبراهيم الجبوري، دمج الشركات في القانون العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 1996.
109. هالة مقداد احمد الجليلي، العلامة التجارية، دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 1997.

د. الوثائق

110. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تقويم خصخصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية في دول مختارة أعضاء في الاسكوا، الأمم المتحدة، نيويورك، 1999.
111. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، تقييم برامج الخصخصة في منطقة الاسكوا، الأمم المتحدة، نيويورك، 1999.
112. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوا (1995)، الجزء الثاني، الخصخصة في منطقة الاسكوا، الامم المتحدة، نيويورك، 1997.
113. دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية واعادة الهيكلة وحوافز العاملين والإدارة لسنة 1996، مطبعة الأهرام التجارية، قلوب، مصر، 1996.
114. غرفة تجارة وصناعة البحرين، التخصيص في دولة البحرين الواقع الحالي والافاق المستقبلية، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة التوجهات المستقبلية للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي، المنامة - البحرين، 1995.

هـ. القوانين والقرارات واللوائح

115. قانون الشركات العامة العراقي ذو الرقم (22) لسنة 1997.

116. قانون الشركات العامة العراقي ذو الرقم (21) لسنة 1997.
117. قانون سوق بغداد للأوراق المالية ذو الرقم (24) لسنة 1991.
118. قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي ذو الرقم (32) لسنة 1986.
119. قانون التجارة العراقي ذو الرقم (30) لسنة 1984.
120. قانون إيجار العقار العراقي ذو الرقم (87) لسنة 1979.
121. الدستور العراقي لسنة 1970.
122. القانون المدني العراقي ذو الرقم (40) لسنة 1951.
123. القانون ذو الرقم (56) لسنة 2000 المعدل لقانون إيجار العقار.
124. قانون الشركات العراقي ذو الرقم (36) لسنة 1983 (الملغي).
125. قانون شركات قطاع الأعمال العام المصري ذو الرقم (203) لسنة 1991.
126. قانون سوق راس المال المصري ذو الرقم (95) لسنة 1992.
127. قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة المدني المصري ذو الرقم (159) لسنة 1983.
128. القانون المدني المصري ذو الرقم (31) لسنة 1948.
129. قانون الشركات الأردني ذو الرقم (22) لسنة 1997.
130. قانون شركات المساهمة المغربي ذو الرقم (17/95) لسنة 1996.
131. قانون التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص المغربي ذو الرقم (3989) لسنة 1990.
132. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (373) في 1977/3/28.
133. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (23) في 1994/3/7.
134. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (187) في 1994/12/25.
135. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (151) في 1989/3/11.
136. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (273) في 1989/4/23.
137. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (140) في 1993 /9/13.
138. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (100) في 1995/9/20.
139. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (12) في 1999/2/7.

140. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (67) في 1996/6/8.
141. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (208) في 1994/11/30.
142. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (83) في 1998/6/15.
143. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (836) في 1984/7/31.
144. قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (858) في 1987/7/19.
145. التعليمات المالية الصادرة من وزارة المالية ذو الرقم (5) لسنة 1986.
146. المرسوم المغربي ذو الرقم (290402) الصادر في 1990/10/16.
147. المرسوم المغربي ذو الرقم (290403) الصادر في 1990/10/16.
148. المرسوم المغربي ذو الرقم (290578) الصادر في 1990/10/16.
149. المرسوم المغربي ذو الرقم (290577) الصادر في 1990/10/16.
150. اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام المصري ذو الرقم (203) لسنة 1991.
151. اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال المصري ذو الرقم (95) لسنة 1992.

ثانياً. المراجع باللغة الفرنسية:

1. Alice Pezard , L'experience Francaise en matiere de Privatisation , محاضرة القيت على طلبية الدراسات العليا في كلية القانون - جامعة الموصل، 1999 (غير منشورة)
2. B. caillaudet R. D urand , Fuson-scission et Apport partiel, paris; 1985.
3. Christian baillon , Droit des Entreprises publiques Encyclopdie delmas pour Lavie des affaires, dlems-paris, 1^{er} edition, 1992.
4. Code des societes, Litec, 1999.
5. D. ccarreau et R. Treuhhold, privatsation , droit boursier et pratiques de marches, Rev. societe 5, 1999.
6. Francis Lefebver, memento pratique socitetes commerciales, Edition Francis Le febreve , paris, 1995.
7. Jean-paul voluet , privatisation et socite privatisee, Rep-societes dalloz, Avril , 1999.
8. Jean-philippe colson, droit public Econonique, L. G. D. J., paris , 1997.
9. Lysian cartelier, privatisation et construction Europenne, Etudes de droit des commanates tes Europeennes-Les Entreprises publiques dans

- L'union Europeenne: Entre concurrence et iteret general, Edition A. Pedone, paris, 1995.
10. Meichel durpty, L'a etuatite en droit economique les relations entre le secteur publice et le secteur privi: La Privatisation du secteur public en France, D., Dec. 1988.
11. P. Pochet, Reflexion sur le regime Juridique dies privatisation , Rev. Trim. Droit com, 41(3), Juill-sept, 1988.
12. PENE (P.) , Laprivatisation en france, AJ DA, No5, 20 mai, 1987.
13. Roland Laskine , Les privatisations Enjeux Strategiques et opport unites boursieres, Les Edition d'Organisation, paris, 1993.
14. Y. Guyon, Le regieue juridiq des societes privatisess en France et en italie, petites affiches, 5 dec., 1997.
15. Y. Jehane, pasoyaux durs aux gropes de actionuaires stables , Banque , n 543, dec. 1993.

ثالثاً. المراجع باللغة الإنكليزية

1. Aysit Tansel, Workers Displaced Due to Privatization in Turkey , Working paper-series (9719).
2. Economic and social commission for western Asia (ESCWA), Role of financial markets in privatization in the ESCWA Region, united nation New York, 1997.
3. Economic commission for Europe (ECE), privatization and changing ownership in the steel Industry , united nations , New York and Geneva, 1996.
4. Fu Fengxing, corporation Reform in china, United Nation-department of Economic and Social affairs, Privatization of Public sector activities, United Nations , New York, 1999.
5. Kenneth W. Clarkson, Roger Leroy Miller, Bonnie B., Business Law, West Publishing Co., St. Paul, U.S.A., 1980.
6. Metin R. Ercam, Efficiency of institutions and the privatization process: The Turkish privatization Administration in critical perspective , ESWA, proceedings expert group meeting on the institutional Aspect of privatization in the ESCWA region , Beirut, 1-3 Dec. 1997. United nations -New York, 1999.
7. Oxford Dictionary of law, Fourth Edition, Oxford University Press, Great Britain , 1998.
8. United Nation Conference on trade and development (UINCTAD), comparative Experiences with privatization-policy insights and Lessons Learned, united nation, New York and Geneva, 1995.